

ZAVASCKI

COMENTÁRIOS AO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

XII

771
ao
796

MARINONI

2ª edição

RT

TEORI ZAVASCKI

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

XII

ARTIGOS 771 AO 796

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS
REVISTA DOS
TRIBUNAIS™

2019 - 03 - 16

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

PRIMEIRAS PÁGINAS

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

VOLUME XII – ARTIGOS 771 AO 796

Autor

Teori Zavascki

© desta edição [2018]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono
Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel.: 11 3613-8400 - Fax: 11 3613-8450
CEP 01136-000 - São Paulo

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).



Visite nosso site: www.rt.com.br

Central de Relacionamento RT (atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Fechamento desta edição: [04.07.2018]



ISBN 978-85-5321-186-9

© desta edição [2018]

2019 - 03 - 16

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha Catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Zavascki, Teori

Comentários ao Código de Processo Civil: (arts. 771 ao 796) [livro eletrônico]/ Teori Zavascki. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. -- (Coleção comentários ao Código de Processo Civil; v. XII / direção Luiz Guilherme Marinoni; coordenação Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero)

6 Mb ; e-PUB

2. ed em e-book baseada na 2. ed. impressa rev. e atual.

Bibliografia.

ISBN 978-85-5321-186-9

1. Processo civil - Legislação - Brasil I. Marinoni, Luiz Guilherme. II. Arenhart, Sérgio Cruz. III. Mitidiero, Daniel. IV. Título. V. Título.

18-19286 CDU-347.9(81)(094.46)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil: Código de Processo Civil comentado 347.9(81)(094.46)

2. Código de Processo Civil: Comentários : Comentários : Brasil 347.9(81)(094.46)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

© desta edição [2018]

2019 - 03 - 16

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chrisley Figueiredo

Adaptação de capa: Linotec

Diagramação e Projeto gráfico: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

2019 - 03 - 16

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o Autor

Doutor e Mestre em Direito Processual Civil. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi Presidente da 2.^a Turma do Supremo Tribunal Federal (2014–2015). Foi Ministro do Superior Tribunal de Justiça (2003–2012). Foi Presidente do Tribunal Regional Federal da 4.^a Região (2001–2003). Ex-Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4.^a Região (1989–2003). Professor de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autor de diversos livros e ensaios sobre Direito Processual Civil e Direito Constitucional.

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

TÍTULO I - DA EXECUÇÃO EM GERAL [Art. 771 a 796]

CAPÍTULO I - Disposições Gerais [Art. 771 a 777]

CAPÍTULO II - Das Partes [Art. 778 a 780]

CAPÍTULO III - Da Competência [Art. 781 a 782]

CAPÍTULO IV - Dos Requisitos Nec. p/ Realizar Qqr. Exec. [Art. 783 a 788]

CAPÍTULO V - Da Responsabilidade Patrimonial [Art. 789 a 796]

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Título I. Da execução em geral

1. Atividades jurídicas do Estado: legislativa e jurisdicional

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, diz a Constituição (art. 5.º, II). O princípio da legalidade, assim consagrado, tem dupla significação: (a) a conduta humana é, de regra, livre, mas (b) a lei pode impor limites a essa liberdade, estabelecendo ações ou omissões a serem compulsoriamente observadas. Por isso, se diz que a lei, ou, mais precisamente, a norma jurídica (é esse, sem dúvida, o sentido da palavra lei no texto constitucional citado) é uma norma de conduta, que tem como destinatários pessoas. A norma estatui a conduta de seres humanos nas suas múltiplas relações comunitárias. Ela tem por finalidade dirigir o comportamento dos indivíduos, das entidades coletivas personalizadas, dos seus dirigentes e funcionários e do próprio Estado.

Não se pode imaginar a convivência em sociedade desprovida de normas reguladoras do comportamento. Mais ainda: seriam inócuas, para alcançar a sua finalidade reguladora, normas que representassem simples recomendação, de observância facultativa. Indispensável se evidencia que as normas de conduta sejam também coercitivas, vale dizer, que tenham aptidão para serem impostas mesmo contra a vontade de quem não as queira observar ou de quem já tenha descumprido seu preceito. O ordenamento jurídico, assim entendido o conjunto das normas de conduta coercitivas, é, pois, condição inafastável de qualquer sociedade organizada.

Criar as leis (= normas jurídicas) é a primeira atividade desenvolvida pelo Estado no domínio do direito.

Ultrapassado o processo de sua criação, a norma jurídica existe e, integrada em moldura abstrata no ordenamento jurídico, estará apta a incidir sempre que ocorrer, daí em diante, situação de fato ou a prática de ato a ela amoldada. Formam-se, por efeito dessa incidência, relações jurídicas, direitos subjetivos, deveres jurídicos, pretensões, obrigações. A norma jurídica abstrata, incidindo, concretiza-se, assumindo feição identificável no mundo da realidade. Nasce a norma jurídica individualizada.

O fenômeno da incidência independe do conhecimento ou da vontade do destinatário da norma. O que se situa no plano volitivo é apenas a realização do ato sobre o qual ela incide. Mas, realizado o ato ou, se for o caso, ocorrido o fato, abstratamente descrito no preceito normativo (suporte fático), a incidência é infalível e se dá necessária e automaticamente. “A incidência das regras jurídicas não falha”, escreveu Pontes de Miranda; “o que falha”, acrescentou, “é o atendimento a ela”.¹ Realmente, a norma jurídica concreta, a que dita a conduta a ser observada quando incide preceito normativo abstrato, é, em geral, atendida espontaneamente. Pode-se dizer que as crises de descumprimento são fenômenos de exceção no comportamento humano, de frequência inversamente proporcional ao grau de civilização dos povos. Mas ocorrem. E ocorrem ou (a) porque se questiona o conteúdo da norma abstrata que incidiu, ou (b) porque se nega a existência ou a configuração do ato ou fato que é suporte da incidência, ou, ainda, (c) porque

simplesmente não se quer ou não se pode dar realização à norma concretizada. Nas hipóteses (a) e (b) a crise está relacionada com a identificação da norma jurídica concreta; a hipótese (c) é típica crise de execução.

A norma jurídica, que é coercitiva, o é porque tem, em sua retaguarda, um aparelhamento estatal encarregado de assegurar seu cumprimento. É o Poder Judiciário, cuja função primordial consiste, nas palavras da Constituição, em proceder a apreciação de toda e qualquer lesão ou ameaça a direito que lhe seja submetida (art. 5.º, XXXV). Apreciar, aqui, significa, em primeiro lugar, fazer juízo a respeito da existência da suposta lesão ou ameaça; mas significa também, e sobretudo, promover medidas para evitar que a ameaça se concretize (tutela preventiva) ou para aplicar as sanções (reparatórias, compensatórias ou punitivas) cabíveis nos casos em que a lesão ao direito já se tenha concretizado (tutela sancionatória). Ao Poder Judiciário cabe, portanto, atender as demandas dos cidadãos por proteção de seus direitos, ou seja, por medidas tendentes a fazer com que as normas jurídicas abstratas, transformadas pela incidência sobre determinado ato ou fato, em normas jurídicas concretas, tenham seu comando efetivamente realizado. Esse conjunto de atividades destinadas a tutelar direitos compõe o que se costuma denominar de função jurisdicional do Estado ou, simplesmente, de jurisdição.

Legislar, criando normas, e jurisdicionar, tutelando o ordenamento jurídico, garantindo a sua observância, dando-lhe consistência prática,² constituem, portanto, as duas funções do Estado na área jurídica.³ Trata-se de funções públicas complementares: sem a norma, perderia sua razão de ser a função jurisdicional; e sem a jurisdição, para garantir sua observância, a norma perderia sua força coercitiva e estaria, conseqüentemente, inabilitada às funções sociais a que se destina. A função jurisdicional, como se percebe, é a guardiã indispensável do princípio constitucional da legalidade. Como disse Calamandrei, “o Estado defende com a jurisdição sua autoridade de legislador”.⁴

2. Conceito de jurisdição

O conceito de jurisdição acima formulado – como atividade estatal destinada a tutelar direitos, identificando e fazendo atuar a norma jurídica abstrata que, pela incidência, se concretizou – corresponde ao que foi desenvolvido por Liebman, cuja doutrina teve influência marcante na formulação do Código de Processo Civil de 1973 e ainda hoje guarda grande prestígio. Dizia Liebman, sintetizando doutrina tradicional,⁵ que jurisdição é “a atividade dos órgãos do Estado, destinada a formular e atuar praticamente a regra jurídica concreta que, segundo o direito vigente, disciplina determinada situação jurídica”.⁶

Convém assinalar que tal conceito, embora adequado ao processo civil quando visto exclusivamente em suas estruturas codificadas, é certamente insuficiente para definir os limites cada vez mais amplos que, modernamente, e de modo especial no Brasil, assumiu a função jurisdicional. Mesmo que a ele agregássemos as ideias de Carnelutti, que via a jurisdição e o processo sob o enfoque da lide e da sua “justa composição”,⁷ finalidade de ambos, ainda assim não se chegaria a uma definição satisfatória. É que, tanto em um quanto em outro ângulo de visão, parte-se do pressuposto básico de que a função jurisdicional somente atua quando há conflito de interesses (“a jurisdição existe por causa de um conflito e para solucioná-lo” disse Galeno Lacerda), o que significa que ela supõe dissídio a respeito da incidência, ou não, da norma jurídica (“A jurisdição não é mais, nos nossos dias, do que instrumento para que se respeite a incidência”, escreveu Pontes de Miranda⁸), o que já não corresponde à realidade do nosso sistema.

Atualmente, a função jurisdicional é exercida não apenas quando há lides individualizadas, estabelecidas entre pessoas identificadas ou identificáveis, em que se faz necessária a formulação da norma concretizada para, deste modo, promover a justa composição do litígio; ela pode ser invocada também para buscar proteção a direitos e interesses transindividuais, difusos e coletivos, de titularidade indeterminada, o que já representa significativo alargamento do âmbito da tutela jurisdicional, se comparado com o dos limites delineados no Código. Mas, mais que isso, a função jurisdicional tem, hoje, também a finalidade de dar proteção ao próprio ordenamento jurídico, independentemente da consideração de um específico fenômeno de incidência e de surgimento de

norma jurídica concreta. É o que se dá nas ações destinadas ao controle concentrado da constitucionalidade das leis e demais atos normativos (ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão), notavelmente expandidas em nosso sistema a partir da Constituição de 1988. Trata-se de atuação objetivando dar efetividade à ordem jurídica abstratamente considerada, em processo em que não há lide e nem, conseqüentemente, partes, no sentido com que tal terminologia é adotada pelo Código. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, nessas ações o que se tem é “processo objetivo por ser processo de controle de normas em abstrato, em que não há prestação de jurisdição em conflitos de interesses que pressupõem necessariamente partes antagônicas, mas em que há, sim, a prática, por fundamentos jurídicos, do ato político de fiscalização dos Poderes constituídos decorrente da aferição da observância, ou não, da Constituição pelos atos normativos deles emanados”.⁹ Esta peculiar forma de processo, inteiramente desprendida de uma específica situação conflituosa e, por isso mesmo, não amoldada às estruturas desenhadas no regime geral do Código, deu margem, inclusive, a que se duvidasse de sua natureza jurisdicional. Há quem pense, com efeito, que a decisão proferida nos processos de controle concentrado de constitucionalidade é “apenas formalmente jurisdicional”, sendo, “materialmente, de natureza legislativa”.¹⁰

O que fica evidenciado, do exposto, é que a ideia de jurisdição que serviu para modelar em grandes linhas o Código de Processo Civil, embora correta, é insuficiente para abarcar os atuais horizontes da função jurisdicional. Jurisdição, em nosso sistema constitucional, é, na verdade, a função do Estado destinada a garantir a legitimidade e a efetividade do conjunto da ordem jurídica, e não apenas da norma jurídica incidente em casos concretos.

3. Discriminação das atividades jurisdicionais: cognição e execução

Com a ressalva do exposto no item anterior, mas presente a circunstância de que, aqui, se faz a exegese do texto codificado, podemos identificar, na jurisdição, duas classes bem distintas de atividades: a de “formular a regra jurídica concreta” e a de “fazer atuar a regra jurídica concreta”. Com efeito, já se disse que o descumprimento das normas jurídicas ocorre ou (a) porque se questiona o conteúdo da norma abstrata que incidiu, ou (b) porque se nega a existência ou a configuração do ato ou fato que é suporte da incidência, ou, ainda, (c) porque simplesmente não se quer ou não se pode dar realização à norma concretizada. Nas hipóteses (a) e (b) há uma crise relacionada com a identificação da norma jurídica concreta, que é debelada com uma decisão judicial identificando o conteúdo da norma que incidiu ou declarando que ela não incidiu; na hipótese (c) há uma crise de execução da norma individualizada e já identificada, crise que, para ser resolvida, exige do Estado providências no sentido de promover, por meios forçados, a execução que não ocorreu espontaneamente.

Compõe, portanto, a atividade jurisdicional aquela destinada a formular juízo a respeito da incidência ou não de norma abstrata, e que consiste, essencialmente, em: (a) coletar e examinar provas sobre o ato ou o fato em que possa ter havido incidência; (b) verificar, no ordenamento jurídico, a norma ajustável àquele suporte fático; e (c), finalmente, declarar as consequências jurídicas decorrentes da incidência ou, se for o caso, declarar que não ocorreu a incidência por falta do suporte fático, ou não ocorreu pelo modo ou na extensão ou com as consequências pretendidas, ou, ainda, que em relação ao fato ou ato não incidiu o preceito normativo alvitado na demanda. A essa atividade, que se desenvolve com a colaboração dos interessados no conflito, em regime contraditório, e que tem como resultado uma sentença identificadora do conteúdo da norma jurídica concreta, denomina-se cognição.¹¹

Por outro lado, há a atividade jurisdicional destinada, especificamente, a promover o cumprimento forçado da norma jurídica concreta cujo conteúdo já se encontra identificado ou por sentença (título executivo judicial) ou por outro ato jurídico (título executivo extrajudicial). Essa atividade jurisdicional, a da execução, tem como ponto de partida, destarte, a certeza do direito à prestação,¹² já reconhecida por ato do Estado-juiz (sentença) ou presumida por ato do Estado-legislador (preceito normativo). Busca-se, aqui, tutela para uma pretensão insatisfeita e não (ou não mais) para uma pretensão contestada.¹³

A distinção entre cognição e execução situa-se, essencialmente, na finalidade de cada uma delas: na cognição o objetivo é “descobrir e formular a regra jurídica concreta que deve regular o caso”; na execução é de “efetivar o conteúdo daquela regra”; ¹⁴ na cognição, busca-se ver declarado “o que deve ser”; na execução, busca-se “conseguir que seja o que deve ser”; ¹⁵ a cognição está direcionada à “declaração de certeza de um mandato individualizado”; a execução “trata de fazer com que o mandato individualizado, declarado certo pela decisão, seja executado praticamente”. ¹⁶ Desse modo, “na cognição, a atividade do juiz é prevalentemente de caráter lógico: ele deve estudar o caso, investigar os fatos, escolher, interpretar e aplicar as normas adequadas, fazendo um trabalho intelectual, que se assemelha, sob certos pontos de vista, ao de um historiador, quando reconstrói e avalia os fatos do passado. O resultado de todas essas atividades é de caráter ideal, porque consiste na enunciação de uma regra jurídica que, reunindo certas condições, torna-se imutável (coisa julgada). Na execução, ao contrário, a atividade do órgão é prevalentemente prática e material, visando produzir na situação de fato as modificações aludidas acima”. ¹⁷

A atividade jurisdicional executiva consiste, assim, em efetivar, coativamente, no plano dos fatos, o resultado previsto no ordenamento jurídico, exigível em razão do fenômeno da incidência, que deveria ter sido alcançado, mas não foi, pelo atendimento espontâneo por parte do sujeito obrigado.

4. Execução forçada e atuação da sanção jurídica

Costuma-se dizer, repetindo os clássicos, que a atividade executiva realiza, concretamente, a “vontade sancionatória” prevista abstratamente na norma jurídica. ¹⁸ A afirmação deve ser devidamente compreendida: se é certo que a execução forçada é meio para aplicar a sanção, também é certo que nem toda a sanção jurídica depende de execução forçada para atuar efetivamente. Com efeito, a norma jurídica contém, em sua estrutura, dois distintos enunciados: o da prestação e o da sanção. O primeiro dispõe sobre a conduta (= prestação, dever jurídico) do sujeito passivo em face do ativo, a ser observada ante determinado fato; o segundo estabelece a sanção (= consequência jurídica), a ser aplicada pelo Estado, em face do não atendimento da prestação, ou seja, do não cumprimento do primeiro enunciado. Os dois enunciados, ensina a teoria egológica do direito, estão enlaçados entre si, formando um único juízo hipotético-disjuntivo, que pode ser esquematizado da seguinte maneira: dado um fato temporal, deve ocorrer a prestação do sujeito passivo em favor do sujeito ativo; ou, não ocorrendo a prestação, deve ocorrer a sanção por parte do Estado. ¹⁹ Ao primeiro enunciado denomina-se endonorma (ou norma primária); ao segundo, perinorma (ou norma secundária, ou, ainda, norma sancionatória²⁰).

Isso significa dizer que toda a norma, além de prever a hipótese do seu atendimento espontâneo por seus destinatários (endonorma), contempla também a hipótese de seu descumprimento, para o que estabelece, desde logo, a correspondente sanção (perinorma). Por isso mesmo, como escreveu, Norberto Bobbio, a sanção nada mais é do que “a resposta à violação”, e nisso está um ponto de relevo para distinguir-se um sistema científico de um sistema normativo: “num sistema científico, quando os fatos desmentem uma lei, gera-se a modificação da lei; em um sistema normativo, quando a ação não se adequa à norma, nos orientamos a modificar a ação e a salvar a norma. No primeiro caso, a contradição se resolve modificando a lei, e, por conseguinte, redimensionando o sistema; no segundo caso, modificando a ação desconforme e, por conseguinte, tratando de fazer com que a ação não se leve a cabo, ou, pelo menos, tratando de neutralizar suas consequências”. E conclui: “A ação que se desenvolve para anular a conduta desconforme, ou, pelo menos, para anular suas consequências danosas, é, precisamente, o que se denomina ‘sanção’”. ²¹

A sanção jurídica, assim considerada como “a reação do direito à inobservância ou à violação das suas normas”, ²² não só está prevista no próprio enunciado normativo, como também constitui um dos seus elementos essenciais, o da perinorma, cujo destinatário é o órgão estatal encarregado de prestar jurisdição. A endonorma anuncia a pretensão de direito material; a perinorma, a pretensão à tutela jurisdicional. “O que se chama de sanção”, diz Bobbio, “outra coisa não é senão o comportamento que o juiz deve ter em uma determinada circunstância”. ²³ Atribuir ao lesado a

faculdade de exigir a prestação jurisdicional é, portanto, qualidade inerente à própria norma jurídica. É justamente essa atributividade ou, como preferem alguns, esse autorizamento,²⁴ a mais marcante diferença entre a norma jurídica e as outras normas de conduta: “a essência específica da norma jurídica é o autorizamento, porque o que compete a ela é autorizar ou não o uso dessa faculdade de reação do lesado. A norma jurídica autoriza que o lesado pela violação exija o seu cumprimento ou a reparação pelo mal causado”.²⁵

Pois bem, as sanções jurídicas previstas na norma, ou, mais especificamente, no enunciado da perinorma, são de variada natureza e comportam diferentes formas de classificação. Há sanções consistentes na reconstituição in natura da situação anterior à lesão; há as que consistem em reparação por equivalente; há as que impõem compensação pecuniária, e assim por diante. Mas há também sanções jurídicas que consistem, simplesmente, em negar a validade ou a eficácia do ato praticado em desacordo com a endonorma. Do ponto de vista de seu conteúdo, as sanções podem ser classificadas em dois grupos: há sanções de conteúdo exclusivamente jurídico-formal, e que, conseqüentemente, são impostas mediante atuação no plano jurídico, como as de constituir, desconstituir ou modificar uma relação jurídica; e há sanções de conteúdo concreto, que demandam, para sua aplicação, providências para manter ou modificar o estado dos fatos (fazer, desfazer, entregar, pagar).

Quem entende que deve ser tida como de execução qualquer atividade jurisdicional destinada a impor a vontade sancionatória da norma, concluirá que também pertence a esse domínio a imposição das sanções de natureza puramente jurídico-formal, como a de simplesmente anular um ato.²⁶ Todavia, não é esse o entendimento dominante e nem foi esse o que inspirou o sistema do Código de Processo Civil. É que esta espécie de sanção, do primeiro grupo, não demanda subsequente atuação prática dos órgãos jurisdicionais, sendo suficiente para sua realização a modificação do estado jurídico. Na verdade, quando se afirma que a execução forçada é a atuação concreta da vontade sancionatória da norma jurídica, está-se referindo apenas às sanções do segundo grupo, ou seja, apenas àquelas que exigem, para sua concretização, providências práticas, materiais, no sentido de adequar o mundo real ao enunciado endonormativo.²⁷

5. Autonomia da execução forçada

Distintas por natureza, as atividades de cognição e de execução desenvolvem-se, de um modo geral, em relações processuais também distintas. Proclama-se enfaticamente, por isso mesmo, a autonomia do processo de execução²⁸ em face do cognitivo. Traço mais marcante dessa autonomia é a tendência, cada vez mais acentuada em nosso sistema – contrariando antigas lições que recomendavam a prévia cognição antes da tomada de medidas executivas (“a espada do executor não pode mover-se sem que antes o juiz tenha pesado imparcialmente as razões da justiça”, dizia Calamandrei²⁹) –, de admitir postulações diretas de tutela de execução. É o que ocorre nas ações de execução fundadas em título executivo extrajudicial, nas quais a tutela cognitiva se dará quando já desencadeados os atos de execução e desde que haja interesse e iniciativa do executado (que a requisitará, se for o caso, por ação própria, de embargos).

Inobstante, convém anotar que essa autonomia não decorre de uma exigência científica ou da natureza das coisas, nem é absoluta em nosso sistema. Tutela de conhecimento, tutela executiva e tutela cautelar, as três espécies de tutela jurisdicional segundo os padrões clássicos, formam a base sobre a qual o legislador brasileiro de 1973 formulou a estrutura do sistema processual civil: a cada uma delas correspondem processo, ações e procedimentos, com seus princípios e normas próprias e separados em Livros específicos. Todavia, essa segmentação não importa, necessariamente, a separação absoluta das diversas modalidades de tutela jurisdicional – e o Código de 2015 prova semelhante assertiva ao misturar tutelas de conhecimento e de execução em um mesmo processo, seja a título de tutelas provisórias, seja a título de cumprimento de sentença. Assim, o processo de conhecimento, prevalentemente voltado ao exercício da pretensão à tutela para certificar o direito, nem por isso é incompatível com a outorga de tutela de outra espécie e o mesmo vale para o processo de execução.

6. Autonomia da execução e ações executivas lato sensu

A mais clara evidência da relatividade da autonomia do processo de execução em face do de cognição – e vice-versa – está nas chamadas ações executivas lato sensu, que ensejam, desde logo e na mesma relação processual, além da certificação do direito (tutela de cognição), a prática dos atos executivos tendentes a efetivar o direito certificado (tutela de execução). Caso típico é o da ação de para a entrega de coisa (arts. 498 e 538, CPC).

Ao significativo elenco das ações desta natureza já existentes em nosso sistema (por exemplo, a ação de reintegração de posse, a de despejo, a de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, apenas para mencionar as mais comuns), vieram se juntar, a partir da reforma processual de 1994, cujo teor foi reprisado pelo Código de 2015, muitas das ações para cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, previstas nos arts. 497 e 536 do CPC.

Reafirma-se, portanto, que a autonomia do processo de execução não é absoluta, nem decorre de uma imposição de natureza científica. Depende, na verdade, de opção política do legislador, que, atento para a natureza instrumental do processo, deve dotá-lo de formas e procedimentos adequados ao fim a que se destina: a realização segura, célere e efetiva do direito material.

7. Autonomia da execução e antecipação da tutela

Marco significativo, no sentido de romper o dogma da absoluta separação entre processo de cognição e processo de execução, foi a reforma processual de 1994, notadamente ao universalizar o instituto da tutela antecipada (arts. 273 e 461 do CPC, com a redação que lhes deu a Lei 8.952/1994), o que foi também consagrado pelo Código de 2015 (art. 294 e ss.). Conforme tivemos oportunidade de sustentar,³⁰ a antecipação da tutela nada mais representa senão a possibilidade de adiantar atos de execução. Ora, para que isso ocorra, impõe-se ao intérprete e aplicador do direito a necessidade de adequar o sistema tradicional do Código, a fim de viabilizar, na medida do possível, que os atos executivos sejam promovidos no âmbito da própria ação de conhecimento, sem o que a medida antecipatória nem sempre poderá alcançar, adequada e eficazmente, a sua finalidade.

Não há consenso doutrinário sobre o procedimento a ser adotado para fazer cumprir as decisões que antecipam tutela, notadamente quando prolatadas no âmbito de ação condenatória. Há os que entendem que a medida antecipatória deve sujeitar-se a ação autônoma de execução, enquanto outros sustentam que ela deve ser cumprida na própria ação de conhecimento.³¹ Em nosso entender, a questão se resolve à luz de dois princípios: o da finalidade e o da adequação das formas. O primeiro impõe que os atos executivos sejam concretizados pelo modo que melhor atenda a razão de ser da antecipação; e o segundo, que o procedimento deve ser compatível com a natureza e o conteúdo das providências a serem cumpridas. Por imposição do princípio da finalidade, há que se distinguir (a) a antecipação fundada no art. 300 (que se destina a afastar “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”), (b) da antecipação fundada, por exemplo, no art. 311, I (que tem como finalidade antecipar os efeitos da sentença cuja prolação é retardada por atos protelatórios do réu). A execução imediata das providências antecipatórias, mediante ordens ou mandados a serem cumpridos na própria ação de conhecimento, é a que melhor se adequa à hipótese (a), em face da urgência da situação. Não teria sentido algum deferir antecipação de tutela para evitar dano iminente ao direito e, ao mesmo tempo, submeter o cumprimento da medida a outra ação autônoma, com novos prazos, sujeita a embargos suspensivos. Isso seria incompatível com a própria razão de ser da medida antecipatória. Já no que concerne à antecipação da tutela decorrente de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (b), o deferimento independe da existência de risco de dano ao direito. Aqui, o que se busca é a remoção dos obstáculos colocados à prolação da sentença, de modo que tal finalidade é inteiramente alcançada pela simples formação antecipada do título executivo, mesmo que a sua execução ocorra em ação autônoma.

O princípio da adequação das formas impõe que se leve em conta a natureza e o conteúdo das providências antecipadas. Ora, a execução imediata da medida antecipatória, mediante ordens ou

mandados expedidos na própria ação de conhecimento, (a) é bem apropriada para situações em que se antecipa medida executiva de entrega de coisa: descumprida a ordem de entrega, poderá o juiz, por meio de providências sub-rogatórias, mediante atividade do oficial de justiça e com auxílio, se necessário, de força policial, cumprir a providência decorrente da decisão. Tais providências, a rigor, em nada diferem, quanto ao conteúdo, das que seriam desenvolvidas em ação autônoma de execução. Mas (b) o mesmo não ocorre quando o objeto da antecipação é o pagamento de quantia. Nesse caso, o cumprimento depende do concurso da vontade do executado ou, então, de atos de expropriação extremamente burocratizados, insuscetíveis de serem praticados na própria ação cognitiva e nem sempre compatíveis com a situação de urgência presente no caso concreto. Frustrada a ordem judicial dirigida ao demandado, pode-se oferecer ao demandante, no domínio do processo civil, a execução provisória por quantia certa. Outra inadequação formal que poderá surgir ao cumprimento da medida na própria ação cognitiva é a possível iliquidez da obrigação. Imagine-se, por exemplo, antecipação de tutela indenizatória cujo montante não esteja definido. Como se vê, em casos tais, não há como cumprir a medida antecipatória senão pelas formas tradicionais da liquidação e execução.

Em face desse conjunto de situações, pode-se traçar o seguinte critério geral definidor do procedimento para a execução da medida antecipatória: será cumprida imediatamente, na própria ação de conhecimento, quando deferida com fundamento no art. 300; porém, (a) em se tratando de antecipação com base no art. 311, I (abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório) ou, (b) quando concedida com fundamento no art. 300, for incompatível ou frustrada a efetivação da medida antecipatória por simples mandado, na própria ação de conhecimento, caberá ao demandante promover execução provisória por quantia certa, antecedida, se for o caso, por ação de liquidação de sentença.

O que se quer deixar desde logo bem evidenciado é que a antecipação da tutela importa, em inúmeras situações, a necessidade de trazer, para o âmbito da ação de conhecimento, as providências práticas para satisfação – ainda que em caráter provisório – do direito material afirmado pelo demandante. Em outras palavras, representa o surgimento de novas formas de ações executivas lato sensu, comprometendo o dogma da separação entre tutela cognitiva e executiva, a demonstrar, outra vez, o relativismo da autonomia dos respectivos processos.

8. Objeto do Livro II

Com base no que acima ficou exposto é possível identificar, com mais precisão, o objeto do Livro II, do Código: nele se disciplina a prestação da tutela jurisdicional executiva, mas apenas quando essa prestação é outorgada em processo autônomo, o “Processo de Execução”.

Disciplinar processo significa tratar de uma relação jurídica peculiar porque (a) estabelecida, em configuração de triângulo, entre demandante, juiz e demandado, (b) de natureza dinâmica e progressiva, desenvolvida, em etapas sucessivas, pela ocorrência de fatos e pela prática de atos jurídicos encadeados uns aos outros e (c) tudo em conformidade com programas delineados previamente, em formas procedimentais voltadas a alcançar, com a maior eficiência possível, uma específica finalidade, que é a prestação da tutela jurisdicional. “O processo”, portanto, como bem observou, “é a síntese dessa relação jurídica progressiva (relação processual) e da série de fatos que determinam a sua progressão (procedimento)”.³² Assim, o Livro II, que trata do processo destinado a atender a demandas por prestação da tutela executiva (o “Processo de Execução”), disciplina a relação processual e os procedimentos próprios e adequados a alcançar aquela finalidade.

A tutela jurisdicional executiva, consistente na realização das providências práticas necessárias a atuar o preceito sancionatório da norma jurídica, exige, não raro, a prestação de atividades jurisdicionais de outra natureza, cognitiva e, eventualmente, a cautelar. A tutela de cognição, de um modo geral, precede a da execução. Todavia, se isso não ocorreu, ou se ocorreu de modo incompleto (como quando a sentença condenatória foi genérica, sem definição do conteúdo exato da prestação devida), ou, ainda, se fatos novos, supervenientes ao processo de cognição, possam comprometer a higidez da obrigação exigida pelo exequente, todas essas são situações que

demandam atividades tipicamente cognitivas do juiz competente para a execução e estão também disciplinadas no Livro II. Desenvolvem-se, ou em relações processuais autônomas (ações de liquidação de sentença, ações de embargos), ou no próprio âmbito da ação de execução, em incidentes próprios.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, t. I, p. 12.

2

J. Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 125.

3

A terceira atividade estatal (a Administração, realizada, primordialmente, pelo Poder Executivo) tem, em relação à norma, sobretudo a condição de sua destinatária, devendo, nessa condição, dar-lhe o devido cumprimento.

5

É o que se pode constatar, apenas como amostragem, em Chiovenda, que definiu jurisdição como “a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade dos órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva” (Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, 3. ed., trad. de J. Guimarães Menegale, São Paulo: Saraiva, 1969, vol. II, p. 3). Para Calamandrei, o caráter da função jurisdicional é a sua finalidade, que é “fazer observar o direito objetivo em seus preceitos individualizados” (Instituciones..., cit., vol. I, p. 178). Esse é também o conceito geralmente adotado na doutrina brasileira, como se pode ver, por exemplo, em Pontes de Miranda (“Jurisdição é a atividade do Estado para aplicar as leis, como função específica”), Comentários ao código de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1974, t. I, p. 104); em José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, 12. ed., São Paulo: Saraiva, 1987, vol. I, p. 8; em José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 3; em Celso Neves, Estrutura fundamental do processo civil, 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 28; em Cândido Rangel Dinamarco, Execução civil, 6. ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 185.

7

Francesco Carnelutti, Instituciones del proceso civil, trad. de Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, vol. I, p. 43.

8

Pontes de Miranda, op. cit., t. I, p. 105.

9

Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 1, voto do relator Min. Moreira Alves, RTJ 157/382. Nesse sentido, ver a doutrina de Gilmar Ferreira Mendes (Controle de constitucionalidade – aspectos jurídicos e políticos, São Paulo: Saraiva, 1990, p. 249 e Jurisdição constitucional, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 130).

12

Carlo Furno, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo executivo, Florença: Casa Editrice del Dott. Carlo Cya, 1942, n. 7, p. 44.

20

Piero Calamandrei, op. cit., vol. I, p. 136.

23

Norberto Bobbio, op. cit., p. 125.

24

Goffredo Telles Júnior, Direito quântico, São Paulo: Max Limonad, p. 263.

25

Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à ciência do direito, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 341.

28

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, cit., p. 38; Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, vol. II, p. 715; Cândido Dinamarco, Execução civil, cit., p. 131; Araken de Assis, Manual do processo de execução, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1995, p. 96.

29

Piero Calamandrei, Instituciones..., cit., p. 168.

4

Piero Calamandrei, Instituciones de derecho procesal civil, trad. de Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1986, vol. I, p. 175.

6

Enrico Tullio Liebman, Manual de direito processual civil, 2. ed., trad. de Cândido Rangel Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 7.

10

Hugo de Brito Machado, Ação declaratória de constitucionalidade, obra coletiva, coordenadores Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 117. No mesmo sentido: Athos Gusmão Carneiro, Jurisdição – Noções fundamentais, *Ajuris* 20/33.

11

Conforme Pontes de Miranda, “nas ações de cognição – ações declarativas em sentido larguíssimo, de que não usamos – há enunciados sobre incidência (toda aplicação de lei é enunciado sobre incidência) e certa quantidade de raciocínio que o juiz deve fazer. Nas ações executivas, ou há também, pela duplicidade de elementos (cognitivo e executivo), esse raciocínio, como é o caso das ações de títulos executivos extrajudiciais; ou ficou para trás, noutro processo, a cognição, como ocorre com as ações de execução de sentença. O enunciado sobre incidência, nas ações executivas, é mínimo, e não tem raciocínio posterior, que leva a ser preciso confirmá-la” (Comentários..., cit., t. IX, p. 27 e 28).

13

Francesco Carnelutti, op. cit., vol. I, p. 77.

14

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1968, p. 37.

15

Francesco Carnelutti, op. cit., vol. I, p. 61.

16

Piero Calamandrei, op. cit., vol. I, p. 159.

17

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, cit., p. 37.

18

Cândido Dinamarco, op. cit., p. 106; Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, cit., p. 48.

19

Carlos Cossio, La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad, 2. ed., Buenos Aires:

Abelardo-Perrot, 1964, p. 333. Segundo relatou Carlos Cossio, em outro escrito, a tese da disjuntividade do enunciado normativo ganhou a adesão de Hans Kelsen: “o problema da norma jurídica, como juízo hipotético ou disjuntivo, foi por Kelsen examinado. Reconheceu que minha tese de ser a norma um juízo disjuntivo era mais completa do que a tese defendida pela Teoria Pura, de ser a norma um juízo hipotético. Mas, depois, disse-me que em vez de ou, que coloco entre a endonorma e a perinorma, seria melhor colocar e se não” (Carlos Cossio, Teoria egológica e teoria pura do direito, Revista Forense, maio de 1950, p. 47).

21

Norberto Bobbio, Teoría general del Derecho, 2. ed., trad. de Jorge Guerrero R., Santa Fe de Bogota, Colombia: Editorial Temis, 1992, p. 105.

22

J. Baptista Machado, op. cit., p. 133.

26

Entre nós, Celso Neves representa esta corrente de pensamento (Estrutura fundamental do processo civil, cit., p. 33).

27

J. Ramiro Podetti, Tratado de las ejecuciones, 3. ed., Buenos Aires: Ediar, 1997, p. 410.

30

Teori Albino Zavascki, Antecipação da tutela, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 84.

31

Entendem ser caso de ação autônoma: Kazuo Watanabe, Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, apud Reforma do código de processo civil, obra coletiva, coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 37; J. J. Calmon de Passos, Inovações no código de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 32; Sérgio Bermudes, A reforma do código de processo civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 31; Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do código de processo civil, São Paulo: Malheiros, 1995, p. 141; José Carlos Barbosa Moreira, A antecipação da tutela jurisdicional na reforma do código de processo civil, RePro 81/210. Em sentido contrário, entendendo que “não se trata de processo de execução autônomo. É execução sem intervalo, na mesma relação processual”, Luiz Fux, Tutela antecipada e locações, Rio de Janeiro: Destaque, 1995, p. 118. Também em sentido contrário, Luiz Guilherme Marinoni (A antecipação da tutela na reforma do processo civil, 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 87), admitindo, contudo, que “no caso de soma em dinheiro aplicam-se as normas do processo de execução como ‘parâmetro operativo’, porém prescindindo-se da necessidade de citação” e vedado o uso de embargos (p. 91).

Cândido Rangel Dinamarco, op. cit., p. 123.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I. Disposições gerais

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

1. Aplicação subsidiária do processo de conhecimento

Processo de conhecimento e processo de execução têm, entre si, vasto campo de afinidades. Afinal, ambos são “instrumentos de atuação do direito público subjetivo de ação e do poder-dever jurisdicional com vistas à aplicação autoritativa do direito”.¹ Temas como o da jurisdição e da ação, dos figurantes da relação processual (juiz, partes), dos seus procuradores, do Ministério Público, dos auxiliares da justiça, dos atos processuais (forma, tempo, prazos, comunicação, nulidades) e tantos outros, são, em seus aspectos gerais, comuns a qualquer processo e a todos os procedimentos. A opção do legislador de 2015 de estruturar uma Parte Geral e uma Parte Especial contribui para uma melhor compreensão dessa aplicação comum de uma série de institutos. Isso porque a Parte Especial cuida, dentre outros temas, dos sujeitos processuais, dos atos processuais, além de prever uma série de compromissos fundamentais (as “Normas Fundamentais”, do Livro I da Parte Geral) que inevitavelmente aplicam-se a todos os processos judiciais, incluídos aí o processo de execução de título extrajudicial. Diminui, com isso, a desafiadora tarefa hermenêutica de preencher os vazios do processo de execução, das medidas cautelares e dos procedimentos especiais à base da sistemática adotada para a fase de conhecimento, não se comprometendo, assim, os princípios e valores específicos de cada um deles. A opção do legislador de 2015 por uma Parte Especial, portanto, diminui os conflitos de coordenação entre processo de conhecimento e processo de execução. Entretanto, há alguns institutos ligados à própria fase de conhecimento e à fase de cumprimento de sentença do procedimento comum (regidos pelo Livro I da Parte Especial) que poderão ser aplicados subsidiariamente aos processos de execução (regidos pelo Livro II da Parte Especial), seja pela abertura de módulos cognitivos ao longo do processo executivo (aplicação das normas relativas à fase de conhecimento do procedimento comum), seja pela necessidade de adaptação das técnicas executivas (aplicação das normas relativas à fase de cumprimento de sentença).

Essas peculiaridades são particularmente delicadas porque no Livro II da Parte Especial – “Do Processo de Execução” – estão disciplinados, além da ação e dos procedimentos tipicamente executórios (ou seja, os destinados a realizar concretamente a satisfação do direito representado por título executivo), também ações e procedimentos com inegável natureza cognitiva. É o caso das ações de embargos à execução, para as quais o regime do processo de conhecimento é certamente aplicável em sua quase inteireza. Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, da existência, higidez e tipicidade do título executivo, são alguns dos temas afetos a controle judicial inafastável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício, admite-se que a própria parte interessada os traga a lume,

independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de preexecutividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando “evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória”.²

Bem se vê, portanto, que é extenso o domínio do juízo de conhecimento no processo de execução, o que põe em elevado grau de evidência e importância a tarefa de discriminar adequadamente as disposições do Livro I da Parte Especial que lhe são aplicáveis subsidiariamente.

Além disso, cumpre ressaltar que, mesmo não havendo previsão expressa, aplicam-se inegavelmente as disposições do Livro III da Parte Especial (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais”), já que, em certos casos, haverá a possibilidade de impugnação de decisões proferidas ao longo do procedimento executivo.

2. Método para aplicação subsidiária

O indispensável preenchimento das lacunas, mediante a aplicação subsidiária preconizada pelo art. 771 do CPC/2015, deve ser efetuado topicamente, mas sem perder de vista o processo de execução como sistema, isto é, como “uma totalidade ordenada”.³ E não se poderá falar em sistema se as normas que o compõem forem incompatíveis entre si.⁴ É preciso que ao fim e ao cabo se obtenha, para a disciplina do processo de execução, um conjunto de normas (as específicas do Livro II e as da Parte Geral acrescidas das subsidiariamente aplicáveis, do Livro I) formado com harmonia e coerência.

Para que isso seja alcançado, duas medidas devem ser adotadas. A primeira, menos difícil, é a de evitar antinomias: em temas tratados por normas específicas no processo de execução, elimina-se a possibilidade da aplicação subsidiária das disposições antinômicas do processo de conhecimento. A segunda, a de evitar as incompatibilidades: eliminam-se da aplicação subsidiária as normas incompatíveis com a natureza peculiar do processo executivo. Aqui a tarefa é mais difícil, porque a incompatibilidade nem sempre é evidente. Exige-se, para sua identificação, uma acentuada visão do sistema da execução, um domínio acurado dos seus princípios, uma sensibilidade para os valores que inspiram cada um dos seus dispositivos⁵ e, igualmente, das lacunas deixadas pelo legislador. Há situações em que a lacuna legislativa existe porque deve existir. São lacunas eloquentes, necessárias, impostas pela natureza das coisas e como tais devem ser respeitadas.

Casos há em que a aplicação das normas do processo de conhecimento se impõe ao processo de execução pela força de princípios superiores, de natureza constitucional. A imperatividade dessa espécie de comando exige, não raro, um cuidadoso trabalho de adaptação dos institutos invocados subsidiariamente, de modo a adequá-los ao sistema executivo a que vêm servir. Exemplo paradigmático é o da nomeação de curador ao executado, que, citado por edital, não comparece. A questão despertou polêmica em dois aspectos: primeiro, o do cabimento da nomeação, e segundo o da extensão dos poderes do curador, especialmente no relativo ao ajuizamento dos embargos. Os que negavam a aplicação subsidiária do antigo art. 9.º, II, do CPC/1973 (atual art. 72, II, do Código), sustentavam que o instituto da revelia não era compatível com o processo de execução porque: (a) o executado não é citado para contestar, mas para cumprir a obrigação; (b) no processo de execução não há margem para contraditório formal; (c) a defesa do executado se dá por ação autônoma, de embargos; (d) não pode, destarte, haver revelia do executado, mas, sim, do exequente, se deixar de impugnar os embargos contra ele propostos.

A essa linha de argumentação, desenvolvida à base do direito ordinário, opôs-se um superior fundamento: o da preservação do princípio do contraditório, assegurado pela Constituição e assumido como norma fundamental do novo Código (arts. 7.º, 9.º e 10), e que é a razão de ser da nomeação do curador especial. O curador tem a seu cargo a tarefa de defender o réu, tomando-se o conceito de defesa no seu sentido constitucional, ou seja, como direito de ter suas razões consideradas pelo juiz da causa, e não no sentido estritamente processual, de apresentar resposta a uma determinada demanda do autor. Nesse sentido maior, há, sim, defesa no processo de

execução, seja a que se desenvolve pelo acompanhamento e controle dos atos executivos e das questões processuais, seja a que se exerce por via de contra-ataque em ação autônoma de embargos.

Acolhida a tese da nomeação de curador especial ao executado revel, citado por edital, tema hoje pacificado na jurisprudência, ⁶ tem-se aí exemplo de aplicação direta da Parte Geral ao processo de execução (não mais sendo necessária aplicação subsidiária de disciplina do processo de conhecimento ditada por princípio superior, que impõe um trabalho de adequação dos institutos). Ao contrário do que se passa no processo de conhecimento, em que o curador apenas representa a parte na ação em que ocorreu a revelia, no processo de execução ele estará investido também do poder de, em nome dela, propor nova ação (de embargos).

A opção, sempre defendida, é hoje corroborada pela opção do legislador em estruturar uma Parte Geral no Código de Processo, com a consequente desnecessidade de invocar, no exemplo, a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento, que exigiria do intérprete um trabalho de particular significação. Segue, entretanto, a necessidade de o intérprete, na aplicação subsidiária do Livro I (em especial das disposições referentes ao cumprimento de sentença), afastar antinomias, eliminar incompatibilidades e proceder a adequação dos institutos transplantados, a fim de produzir, como resultado final, um conjunto harmônico e coerente de normas, ao qual se possa atribuir a designação científica de sistema do processo de execução, com os seus valores e os seus princípios.

Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo:

I – ordenar o comparecimento das partes;

II – advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça.

III – determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.

1. Poderes do juiz na direção do processo

O Código de Processo Civil atribui ao juiz uma posição de comando da cena processual. Não lhe cabe, é certo, instalar o debate judicial em que atuará. O princípio da iniciativa impõe que o agente estatal fique inerte enquanto não provocado pela ação da parte (*ne procedat iudex ex officio; nemo iudex sine actore*). A propositura da demanda, no entanto, tem como efeito imediato o de impor ao Estado o dever de levar o processo a bom termo, dando à causa solução justa, efetiva e em tempo razoável. A adequada prestação jurisdicional a quem a reclama é função pública cujo exercício não pode ficar dependente da vontade ou da iniciativa dos litigantes e de seus advogados. Deve, ao contrário, ser exercida de ofício pelo juiz (princípio da oficialidade). O art. 2.º sintetiza claramente a situação: “O processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial”.

Não se pode confundir inércia da jurisdição com inércia do juiz. Uma vez proposta a ação, ao juiz caberá presidir o seu desenvolvimento, adotando as providências impulsionadoras necessárias para, no processo de conhecimento, chegar a uma sentença justa, e, no processo de execução, realizar materialmente a prestação reclamada. A figura do juiz passivo, espectador distante, indiferente à controvérsia que lhe foi posta, não mais se adequa às exigências do processo moderno. “O juiz dirigirá o processo”, diz o art. 139 do Código, o que em nada compromete sua independência e imparcialidade. Juiz independente não é sinônimo de juiz passivo; e imparcialidade não é sinônimo de indiferença. No dizer de Barbosa Moreira, “uma coisa, com efeito, é proceder o juiz, movido por interesses ou sentimentos pessoais, de tal modo que se beneficie o litigante cuja vitória se lhe afigura desejável; outra coisa é proceder o juiz, movido pela consciência de sua responsabilidade, de tal modo que o desfecho do pleito corresponda àquilo que é o direito no caso concreto. A primeira atitude obviamente repugna ao

ordenamento jurídico; a segunda só pode ser bem vista por ele (...). Em tal sentido, nem sequer é exato dizer que o juiz deve ser ‘neutro’, porque não é próprio identificar-lhe a imagem de um espectador frio, para quem ‘tanto faz’ que se realize ou não se realize a justiça, quando, bem ao contrário, esse é um cuidado que deve estar presente, do primeiro momento ao último, em seu espírito”.⁷ Aliás, essa a orientação do Código como um todo: um juiz ativo na tutela da igualdade (art. 7.º), na busca pela autocomposição (art. 3.º, §§ 2.º e 3.º) e observância de comportamentos de boa-fé por todos os sujeitos processuais (art. 5.º), e assim por diante.

No comando do processo, incumbe ao juiz, segundo o art. 139: “I – assegurar às partes igualdade de tratamento; II – velar pela duração razoável do processo; III – prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V – promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII – exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII – determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX – determinar o suprimimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X – quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5.º da Lei 7.347/1985, e o art. 82 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva”. Cabe-lhe também, mesmo de ofício, “determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, indeferindo, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (CPC, art. 370).

É nesse contexto que deve ser entendido o art. 772. Também no processo de execução o juiz deve adotar, mesmo de ofício, as providências que julgar indispensáveis para que se outorgue a quem tem direito a tutela jurisdicional reclamada. Assim, além dos poderes previstos nos dispositivos já mencionados, invocáveis subsidiariamente, ao juiz da execução cabe também ordenar o comparecimento das partes (ou de uma delas), bem como advertir ao devedor quanto à prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, como tais definidos no art. 774.

2. O substrato ético no comportamento processual

A ordem para o comparecimento pessoal e a advertência ao devedor da prática de atos contrários à dignidade da justiça, são medidas destinadas a manter o padrão ético do processo.⁸ Com efeito, o dever de submissão à verdade, à lealdade e à boa-fé, imposto à parte e a seus procuradores, e o repúdio à chicana, pela proibição de formular pretensões descabidas, de requerer provas desnecessárias e de resistir injustificadamente ao andamento do processo (CPC/2015, arts. 77 e 80), evidenciam a preocupação do legislador de fazer com que os litigantes e seus representantes (situados em campos opostos quanto aos interesses particulares disputados), mantenham, em face do Estado-juiz (que não pode ser encarado como adversário, mas como indispensável agente público para a solução da controvérsia) um procedimento digno e participativo. Atitudes contrárias são reprimidas por vários modos: condenação no pagamento de prejuízos (art. 81), antecipação da tutela (art. 311, I), imposição de multas (art. 77, § 2.º; art. 774, parágrafo único), dentre outros.

O descumprimento dos deveres éticos constitui, inquestionavelmente, uma das mais representativas causas do emperramento do mecanismo judiciário. Nossos mais experientes processualistas alertam que, pelos desconcertos da justiça civil, “só em pequena porção se pode imputar a responsabilidade à lei processual”,⁹ que “são bem poucos e de secundária relevância, no contexto global, os problemas especificamente procedimentais da execução”¹⁰ e que “a esmagadora maioria dos problemas com que nos defrontamos, em termos de efetividade do processo, têm raízes culturais”.¹¹ Despontam, no particular, (a) o comportamento nem sempre

participativo dos litigantes e, sobretudo, dos seus advogados, estes os que, realmente, atuam no cenário do processo e comandam o procedimento dos seus representados; e (b) “a influência de certa mentalidade que, sob valor de zelo em preservar a imparcialidade do juiz, preconiza uma espécie de ‘distanciamento’ capaz de confundir-se, sem dificuldade, com a mais gélida indiferença pelo curso e pelo resultado do pleito”.¹²

O que se preconiza, nessas circunstâncias, como indispensável à boa prestação da justiça, é que os litigantes e seus defensores observem os padrões éticos recomendados pelo Código, o que supõe um nível superior de consciência e de cultura; e, no que toca ao juiz, que conduza o processo “com mão firme por entre os eventuais escolhos, impedindo ou neutralizando prontamente manobras procrastinatórias”,¹³ lançando mão, sempre que necessário, dos poderes que para tanto lhe atribui o Código, inclusive esses do art. 772.

3. Deveres cooperativos do juiz na execução

O art. 772 prevê a possibilidade de o juiz atuar proativamente com vistas à manutenção do padrão ético do processo. Essa previsão – específica para o processo executivo – encontra fundamento no art. 6.º do Código, que adota o modelo cooperativo de processo¹⁴: o inciso II prevê inequívoca aplicação do dever de prevenção; o inc. III, por sua vez, trata do dever de auxílio. Ao permitir que o juiz determine a terceiros o fornecimento de informações, o Código está conferindo a ele a possibilidade de auxiliar a parte a desincumbir-se de um ônus, corolário da noção de cooperação que norteia o novo processo civil.

Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.

Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade.

1. Efetivação da ordem de entrega de documentos

O art. 773 dispõe que, para fazer cumprir a ordem de entrega de documentos e dados (prevista no inc. III do art. 772), poderá o juiz utilizar-se das “medidas necessárias” ao seu cumprimento. O artigo tem inequívoca relação com o art. 139, IV, que faculta a utilização de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, inclusive em se tratando de demandas que tenham por objeto prestação pecuniária. O cumprimento desse tipo de ordem, por se tratar de entrega de coisa, far-se-á pela aplicação do art. 538, permitindo-se, portanto, a utilização de mandado de busca e apreensão ou, em sendo o caso, de medidas de execução indireta (multa, por exemplo). A previsão do art. 773 segue a orientação do Código de reforçar os poderes do juiz relativamente à exibição de documento ou coisa, contra partes e terceiros, a exemplo do art. 400, parágrafo único, que torna superada a orientação consagrada no enunciado de Súmula 372 do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”).

2. Confidencialidade

O parágrafo único do art. 773 trata da necessidade de assegurar a confidencialidade dos documentos, no caso de serem sigilosos. Na maioria dos casos, o sigilo impõe a decretação do “segredo de justiça” (art. 11, parágrafo único). Se, porém, for possível, sem prejuízo de partes, manter o sigilo tão somente do documento confidencial, essa medida deverá ser adotada, em atendimento ao princípio da publicidade, que somente pode sofrer as restrições estritamente indispensáveis. Haveria a decretação de “segredo de justiça parcial”, restringindo-se o acesso ao documento apenas às partes e aos procuradores. Essa, entretanto, não é a posição do Superior Tribunal de Justiça, que, em alguns julgados, não admitiu o arquivamento em apartado (STJ, 1.ª Seção, REsp 1.349.363/SP, rel. Min. Campbell Marques, DJe 31.05.2013).

Art. 774. Considera-se atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do

executado que:

I – frauda a execução;

II – se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III – dificulta ou embaraça a realização de penhora;

IV – resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V – intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exhibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

1. Atos atentatórios à dignidade da justiça

Assim como já o fizera em relação às situações definidas como litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80), o Código enumera, no art. 774, os atos que considera atentatórios à dignidade da justiça. Nos dois casos utilizou-se quase sempre de conceitos abertos, indeterminados, de conteúdo e extensão em larga medida incertos, aos quais o juiz dará preenchimento caso a caso, topicamente, mediante “atos de valoração”.¹⁵ Essa técnica permite maior autonomia à atuação judicial, habilitando-a a enfrentar as peculiaridades das situações novas, nem sempre possível de serem imaginadas ou descritas previamente pelo legislador. Isso não significa atribuir ao juiz poder para decidir de modo inteiramente discricionário. Cabe-lhe, na verdade, buscar a solução do caso sem desprezar a vinculação teleológica que cada conceito aberto mantém com o conjunto do sistema normativo. Ou seja, deverá determinar o conteúdo do conceito levando sempre em consideração os valores que a ordem jurídica buscou preservar ao estabelecer as medidas repressivas. Registre-se que a redação do art. 774 prevê a possibilidade de imposição da multa tanto para atos comissivos quanto omissivos. Essa modificação permite a reconstrução de novas hipóteses de ato atentatório ligadas à omissão do executado em prestar informações ao juiz ou seus auxiliares, por exemplo.

2. Ato que frauda a execução

No inciso I tem-se como atentatórios à dignidade da justiça os atos do devedor que fraudam a execução. Fraudar a execução não apenas o ato de alienação ou oneração de bens de que trata o art. 792, mas também “outro qualquer expediente que frustrar a execução, como, por exemplo, a ocultação de bens móveis, sem aliená-los”, isto porque o verbo fraudar está empregado “como sinônimo de frustrar, baldar, inutilizar, malograr, tornar sem efeito”.¹⁶

Poderia parecer supérflua a imposição de multa (CPC, art. 774, parágrafo único) para os casos de fraude à execução de que trata o art. 792, uma vez que a lei já considera os atos dessa natureza como ineficazes em face do credor. Há de se considerar, no entanto, que a simples cominação de ineficácia estabelecida no plano jurídico-formal, nem sempre corresponde a uma efetiva viabilidade material de submeter o bem aos efeitos do processo executivo. É o que geralmente ocorre quando se trata de bens móveis: alienados fraudulentamente, repassados a adquirentes incertos, dificilmente poderão ser reconduzidos à origem. Em tais casos, configurado o ato atentatório, a aplicação da multa será a mais eficiente maneira de restaurar, em alguma medida, a autoridade e a dignidade da função jurisdicional.

3. Ato de oposição maliciosa

Opor-se “maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos” é modo genérico de descrever um indeterminado número de comportamentos. Há, na linguagem empregada no

inciso II, a mais significativa representação de conceito aberto a que nos referimos. A lei utilizou terminologia semelhante quando, ao tratar da litigância de má-fé, averbou como tal aquele que “opuser resistência injustificada ao andamento do processo” ou “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, ou, ainda, “provocar incidentes manifestamente infundados” (CPC, art. 80, IV, V e VI). Na essência, o que o legislador quer reprimir são os atos e as omissões do devedor que extrapolam os limites razoáveis do seu direito de se defender. Com efeito, o direito ao contraditório e à ampla defesa, que tem origem constitucional, não é absoluto, nem ilimitado. Seu exercício deve ser compatibilizado com os direitos constitucionais do litigante adversário, nomeadamente o de receber do Estado uma resposta ao seu pedido de tutela jurisdicional em forma efetiva e no menor prazo possível. O emprego, pelo demandado, de malícia, de ardis, de artifícios, para fugir à execução, não constitui certamente ato enquadrável, legitimamente, no âmbito de qualquer das cláusulas constitucionais do devido processo legal.

A oposição maliciosa à execução poderá ocorrer não apenas no âmbito estrito da ação executiva, como também no curso dos embargos. Estes últimos são campo fértil para a chicana, ainda que já não mais tenham, como regra, efeito suspensivo. Daí porque, além de prever a rejeição liminar dos embargos manifestamente protelatórios (art. 918, III), o legislador tipifica tal conduta como atentatória à dignidade da justiça (art. 918, parágrafo único).

Considerando que os atos do inc. II do art. 774 constituem abuso do direito de defesa e têm manifesto propósito protelatório, nada impede que a reprimenda a eles cominável seja acompanhada, também, de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 311, I, do Código, dando-se ao instituto a conformação necessária para adequá-lo às circunstâncias. Tratando sobre o momento em que o juiz poderá deferir provimentos antecipatórios sustentamos, alhures, ainda sob o regime do Código revogado, o seguinte: “Pode ocorrer antecipação de tutela até mesmo quando já instaurada ação de execução de sentença ou de título executivo extrajudicial. É que, havendo embargos, os atos executivos ficam suspensos (CPC/2015, art. 739, § 1.º), não se podendo descartar a configuração, nesse momento, de hipótese concreta de urgência na satisfação do direito em execução, a ponto de não se poder aguardar, pena de ineficácia, o julgamento dos embargos. Não há razão para, em tal situação, preenchidos os requisitos do art. 273, deixar de atender o pedido. O ponto ganha relevância quando a execução se fundar em título extrajudicial: se o legislador permite antecipar a tutela mesmo antes da formação do título executivo, ou seja, no curso do processo de conhecimento, não haveria porque negá-la se o título, ainda que extrajudicial, já existe, fazendo presumir legítima a obrigação nele certificada. Aliás, a ação de embargos, na verdade, nada mais é do que a ação de conhecimento deslocada para a fase de execução, de modo que esse deslocamento não é motivo suficiente nem razoável para inviabilizar a medida antecipatória”.¹⁷

Essas considerações são inteiramente apropriadas para os casos de abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório (previsto no novo código no art. 311, I). Praticado ato dessa natureza – como o são os previstos no inc. II do art. 774 – nada impede que o credor formule pedido de antecipação da tutela. O provimento antecipatório, em tais casos, somente terá sentido prático se a execução estiver suspensa. Realmente, antecipar efeitos da tutela nada mais significa senão antecipar efeitos executivos, ou seja, promover antecipadamente atos de execução.¹⁸ Ora, não há falar-se em antecipação (= realização antes do tempo normal) de um ato processual se já está chegado o momento próprio para a sua prática. Assim, a oposição maliciosa à execução que pode dar ensejo a pedido de antecipação da tutela com base no art. 311, I, é a produzida no curso da ação de embargos, e seu efeito prático será o de permitir o prosseguimento dos atos executivos. Considerando que os embargos não têm, em regra, efeito suspensivo, serão mais raras as hipóteses em que medidas antecipatórias sejam necessárias.

4. Dificuldade ou embaraço à realização da penhora

O inc. III do art. 774 inaugura nova hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça no curso da execução. Podem ser enquadradas como tais as condutas de omitir informações ou de prestá-las com erro proposital, acerca da localização do bem a ser penhorado ou ao encobrimento/ocultação de bens passíveis de penhora.

5. Resistência a ordens judiciais

A resistência injustificada a ordens judiciais enseja ao Estado o uso da força pública para combatê-la (CPC/2015, art. 782, parágrafo § 2.º), empregando-se, quando necessário, atos de arrombamento (CPC, art. 846). Não se descarta, ademais, em semelhantes situações de recalcitrância, a configuração de crime contra a administração da justiça, tipificado nos arts. 329 e 330 do CP. A severidade da reação se impõe porque os atos daquela natureza atentam, não apenas contra o litigante adversário, mas, sobretudo, contra a autoridade e a dignidade da função jurisdicional. É o que anotamos nos comentários ao § 2.º do art. 782.

Porém, a sanção penal não é meio de coação, nem mecanismo destinado a obter o cumprimento da prestação executada. Sua aplicação está sujeita a ação própria, de iniciativa do Ministério Público, que se desenvolve no âmbito da jurisdição criminal, sem comunicação alguma com o da execução civil. Ademais, a resistência ao cumprimento de ordem judicial nem sempre pode ser debelada com o uso da força pública. Justificável, conseqüentemente, a previsão de mais esta medida de repressão ao executado renitente: a de enquadrar seu comportamento como atentatório à dignidade da justiça, sujeitando-o, conseqüentemente, à multa pecuniária.

Registre-se que o art. 77, IV tem previsão assemelhada, ao capitular como atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, § 2.º) o não cumprimento das decisões jurisdicionais com exatidão e a criação de embaraços à sua efetivação. Naqueles casos, a multa cominada (até vinte por cento do valor da causa) será revertida ao Estado e não ao exequente. Dada a diferente natureza da sanção, nada impede, por isso mesmo, sua aplicação cumulativa.

6. Falta de indicação de onde se encontram os bens

É atentatório à dignidade da justiça o ato (na verdade, a omissão) do devedor que “não indica ao juiz onde se encontram os bens sujeitos à execução”. O texto do inc. IV não permite que se confunda essa omissão do devedor com a falta de indicação de bens à penhora. Se o executado, apesar de ter bens penhoráveis, deixa de indicá-los (CPC/2015, art. 829, §2.º – que determina a contrapartida de demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente), a consequência será a preclusão da faculdade de proceder a indicação nesses termos, e não, necessariamente, um ato atentado à dignidade da justiça.

Para que se configure a situação prevista no dispositivo é indispensável a concorrência dos seguintes pressupostos: (a) a não localização dos bens sujeitos à execução; (b) a demonstração de que o devedor sabe onde eles se encontram; e (c) a negativa do devedor em fazer a indicação de onde ou com quem se encontram. Ressalte-se que o juiz pode determinar ao executado a indicação (com base no dever de transparência patrimonial que pode ser reconstruído a partir da previsão do art. 772, III). Quanto aos bens sujeitos à execução, seu rol está alinhado nos arts. 789 e 790 do Código e nele se incluem não apenas os de propriedade e que estejam na posse do devedor, mas igualmente os que se encontram em poder de terceiro e os alienados ou gravados em fraude à execução. O que nem sempre é fácil comprovar é o segundo pressuposto. Em se tratando de execução de obrigação para a entrega de coisa, se o objeto da pretensão (ou, se for o caso, o objeto litigioso do processo) estava, quando da propositura da ação, em poder do réu, é razoável exigir-se que, no momento da execução, ele dê conta ao juiz do local onde agora poderá ser apreendido ou da identidade da pessoa que atualmente o detém. Já quando se trata de execução por quantia certa, a configuração do atentado à dignidade da justiça não é tão simples. Somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens, ou que os possuiu e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições patrimoniais para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição.

A dificuldade de comprovar a existência de bens penhoráveis faz com que seja ineficiente, para não dizer letra morta, a norma do art. 774, V, ficando o juiz desprovido de meios expeditos e eficientes para desincumbir-se da prestação adequada da tutela executiva a que o credor tem

direito. Aqui reside, quase sempre, o ponto crítico do processo de execução, do qual se aproveitam os maus pagadores, pondo em xeque a autoridade e a dignidade da justiça, com as quais pouco se importam. Por isso mesmo, havendo razoáveis indícios de que o executado dispõe de bens penhoráveis (como, por exemplo, se está sujeito a apresentar declaração anual de renda ou de bens) e que os está subtraindo à execução, evidencia-se legítima a providência de requisitar, por via judicial, informações a respeito junto à Receita Federal. O sigilo fiscal não constitui, por si só, embaraço insuperável à providência requisitória, devendo ceder passo quando, não sendo possível a localização de bens pelos meios ordinários, se configurar a inviabilidade do prosseguimento da execução, atividade jurisdicional que interessa não apenas ao exequente mas ao próprio Estado.¹⁹ Sempre foi nesse sentido também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preocupada em salvaguardar os superiores interesses públicos em jogo nesses casos. “Essa requisição”, diz um precedente da Corte Suprema, “se faz no interesse da Justiça, pois a penhora é ato preliminar para a execução do patrimônio do devedor, e o titular desse poder de excutir é o Estado, que o tem como instrumento necessário para desincumbir-se de seu dever de prestar jurisdição. Daí, o preceito contido no art. 774, V, do CPC, o qual considera atentatório à dignidade da justiça o ato do devedor que não indica ao juiz onde se encontram os bens sujeitos à execução”.²⁰ No Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência sobre o tema é, até o momento, vacilante, parecendo prevalecer o entendimento assim sumariado em precedente da Segunda Seção: “somente em hipóteses excepcionais, quando comprovadamente infrutíferos os esforços diretos do exequente, admite-se a requisição pelo juiz de informações (à Receita Federal) sobre a existência e localização de bens do devedor”.²¹ Os amplos poderes conferidos ao juiz na condução e na efetivação dos atos executivos, como transparece no art. 772, III, e no art. 773, permitem inclusive que determine a terceiros a prestação de informações a respeito de possíveis bens do devedor, o que certamente poderá concorrer de modo eficiente a submeter à execução eventual patrimônio oculto.

7. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça

Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito à multa – que reverterá em proveito do credor – “em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução”. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou o montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou do dolo com que agiu o devedor. Sendo o atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas consequências do ato. Aliás, pela mesma razão, não parece ter sido adequada a opção legislativa de destinar ao credor o produto da pena. A rigor, ele deveria reverter aos cofres públicos, pois a vítima do ato apenado foi, primordialmente, a função jurisdicional.

Se do ato decorrer dano, seu ressarcimento ocorrerá independentemente e sem prejuízo da incidência da multa. Igualmente, se o fato tipificar ilícito punível com sanção própria por outro dispositivo do Código, as incidências serão aplicadas cumulativamente.

Ao estabelecer como base de cálculo da multa o “valor atualizado do débito”, o legislador teve em consideração apenas a execução de quantia certa. Nos casos em que a execução tenha por objeto entrega de coisa, ou prestação de fazer, a multa haverá de incidir sobre o seu equivalente em dinheiro. O valor atribuído à causa será parâmetro recomendável para esse efeito,²² eis que ele representa (ou deve representar) o significado econômico da obrigação. Se houver descompasso evidente entre um e outro, caberá ao juiz estimar a base de cálculo da multa utilizando-se de outras fontes disponíveis, caso em que justificará adequadamente as razões para assim proceder.

8. Procedimento para aplicação da multa

Na sua redação original, o art. 601 do CPC/1973 estabelecia o seguinte: “Se, advertido, o devedor preservar na prática de atos definidos no artigo antecedente, o juiz, por decisão, lhe proibirá que daí por diante fale nos autos. Preclusa esta decisão, é defeso ao devedor requerer, reclamar, recorrer, ou praticar no processo quaisquer atos, enquanto não lhe for relevada a pena”. Com a

nova redação, dada pela Lei 8.953, de 13.12.1994, a penalidade de não falar nos autos, de constitucionalidade contestada em face do direito ao contraditório, foi substituída por pena pecuniária.

O atual parágrafo único do art. 774 não subordina a aplicação da multa à prévia advertência do devedor. A sanção poderá ocorrer desde logo, tão pronto configurado o ato atentatório à dignidade da justiça. Aliás, o requisito da prévia advertência era uma das tantas causas de descrédito e do quase absoluto ceticismo que envolvia a antiga apenação,²³ sujeita a três decisões interlocutórias (uma, sobre a advertência, outra, a que aplicava a multa e a terceira, decidindo o pedido para relevá-la) e, portanto, a tríplice oportunidade de agravo. O que o legislador buscou, com a integral modificação do dispositivo, foi acabar com aqueles exageros e, assim, “dar efetividade e eficácia no combate à litigância de má-fé, para tanto adotando critério mais objetivo e mecanismo mais eficiente”,²⁴

Assinale-se, entretanto, que há opiniões doutrinárias defendendo que a prévia advertência constituiria, no regime do código de 1973 reformado, pressuposto necessário da aplicação da multa.²⁵ Fulcram-se no argumento de que não foi revogado o antigo art. 559, II (atual inc. II do art. 772), sendo necessário dar-lhe aplicação. Realmente, a advertência ao devedor, prevista no citado inciso, ainda persiste, mas deve ser vista com outros olhos, para que se mantenha coerente com o novo sistema. A exemplo da providência de que trata o inc. I do art. 772, também a do inc. II deve ser interpretada como providência que fica a critério do juiz, a ser adotada quando realmente puder mostrar-se útil. Ela terá eficácia prática significativa em situações em que o ato atentatório ainda não se consumou irreversivelmente, ou quando ele se mostrar reversível por ato do devedor. Porém, consumado o atentado sem possibilidade de reversão, a advertência seria absolutamente inútil, revelando-se exagerada subserviência a formas exigir do juiz que, mesmo assim, a leve a cabo antes de aplicar a multa.

Seja como for, o princípio do contraditório impõe ao juiz que, antes de aplicar a multa, abra prazo para o devedor se manifestar a respeito. Ora, o despacho que determinar a intimação e fixar o prazo para a ouvida, trará consigo desde logo um juízo de valor, ainda que implícito e preliminar, sobre o questionado ato atentatório, motivo a mais para tornar desnecessária outra medida formal de advertência.

A sanção do parágrafo único do art. 774 independe de provocação da parte.²⁶ Tratando-se de medida para salvaguardar a sua própria função, pode o juiz aplicá-la de ofício, devendo fazê-lo em decisão fundamentada.²⁷

9. Procedimento para a cobrança da multa

A multa reverte em favor do credor, podendo ser exigida “nos próprios autos”. Exigir “na própria execução” (como fazia o Código de 1973) suscita problemas práticos, notadamente em se tratando de execuções de obrigações que não adotem o procedimento para cumprimento de prestação de natureza pecuniária. Em se tratando de execução para entrega de coisa ou de prestação de fazer ou de não fazer, a diversidade de procedimento impede a inclusão cumulativa do valor da multa (CPC/2015, art. 780). Mesmo na execução de quantia certa, o pedido cumulativo não poderá ser acolhido se puder causar tumulto processual, com a repetição de atos já praticados ou de novas aberturas de prazos já preclusos, ou, ainda, se importar modo mais gravoso ao devedor (CPC/2015, art. 805).

10. Procedimento para relevação da pena

O novo Código não mais prevê (como fazia o parágrafo único do art. 601 do CPC/1973) a possibilidade de ser relevada a sanção pela prática de atentado à dignidade da justiça.

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I – serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II – nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

1. O princípio da disponibilidade

Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor. No processo de conhecimento, destinado que é a eliminar incertezas sobre a existência ou não do direito subjetivo, ou de sua ameaça ou violação, o interesse das partes litigantes é concorrente,²⁸ e não só do demandante, eis que a sentença de improcedência faz coisa julgada a favor do demandado. Daí porque a desistência da ação cognitiva depois de decorrido o prazo da resposta supõe o assentimento do réu (§ 4.º do art. 485). O mesmo não ocorre no processo de execução, perante o qual o executado não pode alimentar “qualquer expectativa de solução favorável”, a não ser a de almejar “que o processo se extinga”.²⁹ Assim, no pressuposto de que a desistência da execução a ninguém prejudica e que “é sempre favorável ao réu”,³⁰ até porque tudo volta ao status quo,³¹ assentou-se o princípio de que o exequente tem a disponibilidade da ação de execução, podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume. Doutrina³² e jurisprudência,³³ veem no art. 775 do CPC a consagração legislada do referido princípio.

Não se confunde a desistência da ação com a renúncia do direito de ação ou do crédito. A renúncia tem eficácia no plano do direito material: manifestada e acolhida pela sentença, extingue-se não apenas o processo, mas também o direito de crédito e a pretensão à execução. Já a desistência opera no plano exclusivamente processual, podendo a ação de execução ser repetida. Nesse caso, aplica-se subsidiariamente o art. 486, § 2.º do CPC, ou seja, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios devidos no processo anterior.

A desistência da execução, para ter eficácia, depende de homologação, conforme prevê o parágrafo único do art. 200, aplicável subsidiariamente. Ao juiz caberá, ao examinar o pedido, verificar se é aplicável o princípio da disponibilidade e se o advogado está munido de poderes especiais para desistir (art. 105 do CPC). Se houver embargos, decidirá sobre o seu destino, observado o que dispõe o parágrafo único do art. 775. Mesmo que não haja embargos, a sentença deverá dispor sobre as despesas processuais da ação de execução e, se o executado tiver constituído advogado, sobre os honorários a ele devidos, que deverão ser suportados pelo desistente, como prevê o art. 90 do Código.

O princípio da disponibilidade faculta ao credor desistir da ação de execução ou “de apenas algumas medidas executivas”. Medidas executivas, ou meios executivos, são as que têm por finalidade alcançar o atendimento da pretensão do exequente. A desistência de uma delas, na hipótese aventada, não compromete o prosseguimento da execução. Portanto, logicamente, só é viável quando houver pluralidade de meios executivos à disposição do exequente, sejam de coerção (multa diária, prisão) sejam de sub-rogação (alienação de bens, usufruto, desconto em folha). A eficácia da desistência supõe, também aqui, homologação, que se dará por decisão interlocutória e não por sentença, pois não há extinção do processo. Ao proferi-la, deve o juiz atentar para o disposto no art. 805 do Código, indeferindo o pedido se a medida substitutiva pretendida for mais gravosa para o devedor. Deve igualmente indeferi-lo, se a medida da qual se pretende desistir já estiver irreversivelmente consumada. Assim, é incabível a desistência da penhora de um bem que já foi arrematado.

Se há, na ação executiva, litisconsórcio ativo, ou passivo, ou misto, é viável a desistência por um (ou mais de um) dos litisconsortes, independentemente do consentimento dos demais e dos executados. Será cabível, da mesma forma, a desistência em relação a litisconsorte passivo, sem prejuízo do prosseguimento da execução em relação aos demais.³⁴ No litisconsórcio ativo e no misto, a desistência pode ter, em relação ao executado, eficácia de variado grau, dependendo da

natureza da obrigação ou da pretensão. Poderá ter eficácia integral, excluindo o executado da relação processual, se a desistência for manifestada por todos os litisconsortes ativos, ou se o desistente for o único titular da pretensão deduzida contra o devedor em relação ao qual é apresentada a desistência; poderá ser restrita ao exequente que desistiu se a obrigação for divisível, comportando execução por partes autônomas, caso em que a execução prosseguirá em relação à prestação devida aos credores que não desistiram; e poderá não ter eficácia prática alguma, quando a qualquer dos credores for facultado exigir a integralidade da prestação comum (solidariedade ativa) ou se a prestação for indivisível. A exclusão de um dos litisconsortes da relação processual não extingue o processo, que é um só, mesmo havendo pluralidade de partes. O ato do juiz que a homologa é, portanto, decisão interlocutória, impugnável por agravo. ³⁵

Registre-se que o dispositivo processual acerca da desistência aplica-se tanto à execução de título extrajudicial quanto ao cumprimento de sentença. Tal conclusão se retira, não apenas da aplicação subsidiária recomendada no art. 771, como da própria menção, expressa no parágrafo único, à impugnação, que é meio de defesa típico do cumprimento de sentença.

2. Quem pode dispor da execução

Pode desistir da execução quem a propôs, ou seja, o exequente, mesmo que seja o espólio, os herdeiros ou sucessores, o cessionário ou o sub-rogado.

Do rol dos legitimados ativos enumerados no art. 778, um deles não tem, em regra, a faculdade de desistir: o Ministério Público, cuja atuação é, por natureza, orientada pelo princípio da indisponibilidade, ³⁶ ou seja: configurada hipótese de atuação do órgão ministerial, é seu dever propor a demanda e nela prosseguir até o final, seja no processo de conhecimento, seja no de execução. ³⁷

Não é invocável, aqui, o argumento de que, por não ser vedada expressamente pela lei, a desistência, pelo Ministério Público, estaria permitida. Se o argumento vale para o particular, não se aplica ao parquet que, como órgão do Estado, submete-se à regra do direito público segundo a qual os agentes do Estado somente podem praticar atos para os quais estejam autorizados pela norma. A atuação do Ministério Público em juízo, inclusive no juízo de execução, é vinculada não à vontade pessoal de seus agentes, mas a uma finalidade impessoal e pública, definida em lei. Quem não atua como órgão do Estado está autorizado a fazer tudo o que não seja proibido pela ordem legal, ao passo que o Estado, isto é, o indivíduo que age como órgão do Estado, pode fazer somente aquilo a que estiver autorizado pelo ordenamento jurídico. Do ponto de vista de técnica legislativa, portanto, é supérfluo estatuir quaisquer proibições para um órgão do Estado. É suficiente não autorizá-lo. ³⁸ Não basta, portanto, ausência de proibição de desistir. A desistência, contraposição que é do poder-dever do Ministério Público de intentar a demanda executória, imposto por lei, haveria de estar, também ela, expressamente autorizada.

Impedido de desistir da execução, nem por isso é vedado ao Ministério Público requerer a desistência de algum ato executivo específico quando outro meio se mostrar mais adequado à satisfação do direito executado. A desistência, em tais circunstâncias, é justificada pela conformidade que tem com os princípios que dão suporte às funções institucionais do órgão ministerial e de sua atuação em juízo: a defesa, pela melhor forma possível, do interesse público.

3. Limites ao princípio da disponibilidade

Costuma-se afirmar que, não havendo embargos, o princípio da disponibilidade da execução opera-se de modo integral ³⁹ e absoluto, ⁴⁰ sem qualquer limite temporal. ⁴¹ Não podemos concordar com tão extremado pensamento. Em direito, não há princípios absolutos, e o da disponibilidade da execução não foge à regra. Há os limites impostos pelo dever de fidelidade e de preservação dos próprios valores que dão sustento ao princípio; e há os decorrentes da necessidade de harmonizar valores e princípios com outros de mesma ou superior hierarquia.

A disponibilidade da execução inspira-se no pressuposto axiológico de que a desistência, com consequente retorno de tudo ao status quo, a ninguém prejudica, muito menos ao devedor, que é

até beneficiado. Pois bem, a fidelidade a esse pressuposto é o limite de aplicação do princípio. Verificando-se, concretamente, situação em que não é viável o retorno ao status quo, ou em que tal retorno não é possível sem prejuízo a direito ou interesse do devedor ou de terceiro, a faculdade de desistir importaria comprometimento de sua base de sustentação, de modo que, nesses casos, não pode ser exercida unilateralmente.

Assim, a desistência unilateral da execução não é cabível após a assinatura do auto de arrematação, porque – perfeita, acabada e irretratável (CPC/2015, art. 903) – a alienação do bem penhorado não comporta desfazimento a não ser comprometendo-se os direitos do arrematante. O mesmo se diga em relação à adjudicação, especialmente quando exercida por outro credor que não o desistente. Relativamente a este, irretratável a adjudicação após a assinatura do auto,⁴² dela não poderá desistir sem o consentimento do executado. E, não podendo desistir desse ato executivo, não poderá certamente desistir da ação.

Também não será cabível a desistência unilateral da execução quando a prestação de fazer, por fungível, tiver sido cometida a terceiro (CPC/2015, art. 817), ou quando já estiver sendo cumprida pelo devedor. Nesses casos, a homologação da desistência há de ter em conta a preservação dos direitos do terceiro e, mesmo, do direito do devedor de ultimar o cumprimento de sua obrigação. Na precisa observação de Antonio Janyr Dall’Agnol Júnior, “é de reconhecer-se ao devedor, pelo menos em uma oportunidade, o direito de se opor à desistência: é quando ele se dispõe a satisfazer o direito de crédito do exequente”.⁴³ O princípio da disponibilidade, com efeito, deve ser harmonizado com o que consagra o direito de cumprir a obrigação, instrumentalizado no art. 539 e ss. do CPC, que asseguram ao devedor mecanismos processuais para obrigar o credor a receber a prestação: havendo, por parte do devedor, comportamento que demonstre seu manifesto propósito de satisfazer adequadamente a prestação, não teria sentido algum, sob o aspecto sistemático, admitir a desistência unilateral da execução pelo credor.

No que se refere especificamente à execução por quantia certa contra devedor insolvente, o princípio da disponibilidade limita-se à fase anterior à instalação do concurso universal, ou seja, a desistência unilateral da execução pode ser requerida até a sentença declaratória da insolvência (art. 761 do CPC/1973, mantido no ponto por expressa disposição do art. 1.052 do novo Código). Daí em diante, a ação passa a ser de interesse de todos os credores do insolvente, em cujo benefício é promovida, de modo que eventual desistência dependerá do seu consentimento.

4. Disponibilidade da execução e destino dos embargos

O parágrafo único do art. 775 tem sua raiz histórica na alteração promovida pela Lei 8.953/1994, ao antigo art. 569, tendo por finalidade disciplinar o destino dos embargos nas hipóteses em que o exequente desistir da execução. Ficaram estabelecidas duas regras básicas (mantidas no novo Código): extinta a execução por desistência, (a) serão também extintos os embargos “que versarem apenas questões processuais”, independentemente do consentimento do embargante; e (b) nos demais casos, ou seja, quando os embargos não versarem apenas questões processuais, sua extinção dependerá do consentimento do embargante.

Os embargos constituem ação autônoma do executado contra o exequente, visando opor-se à execução ou a algum ato executivo específico. Doutrinariamente, a partir de Liebman, classificam-se como “embargos de forma” os que “têm como alvo a legalidade de um ato de execução” e como “embargos de mérito” os que “têm por fundamento a afirmação da inexistência do direito à prestação, para cujo cumprimento se preparou a execução”.⁴⁴

A orientação adotada pelo parágrafo único do art. 775 tem por substrato inspirador o interesse de agir: extinto o processo de execução já não subsistirá interesse do embargante em questionar matéria processual com ele relacionada. Não teria sentido nem finalidade, em tais circunstâncias, o prosseguimento dos embargos de forma, cuja extinção, conseqüentemente, é imperativa, uma vez que a função jurisdicional somente se justifica quando útil e necessária. Tendo sido o embargado quem provocou a superveniente perda do interesse de agir, caberá a ele arcar com os ônus correspondentes à extinção dos embargos, a saber, as custas e os honorários advocatícios.

Diferente é a situação dos embargos que impugnam o título executivo ou o direito à prestação executada. A sentença de procedência, em tais casos, tem eficácia transcendente aos lindes da execução extinta por desistência: declarado, no julgamento dos embargos, nulo o título ou inexistente o direito à prestação, a eficácia da coisa julgada material impedirá a futura investida do exequente contra o executado. Aqui, mesmo extinta a ação de execução, não fenece o interesse jurídico que ensejou a ação de embargos. Sua extinção, portanto, não será automática com a extinção do processo executivo. “Dependerá da concordância do embargante”, diz a lei. Observe-se que a concordância a que se refere ao inc. II do parágrafo único diz respeito exclusivamente à extinção da ação de embargos e não à da execução.⁴⁵ Esta, mesmo pendentes embargos de mérito, continua sujeita ao princípio da disponibilidade.

Teoricamente, o embargado também poderia ter interesse no prosseguimento dos embargos de mérito, já que a sentença de improcedência faria coisa julgada a seu favor, impedindo futura renovação da discussão. Mas, ao submeter a extinção desses embargos apenas à concordância do embargante, o Código presumiu o consentimento do embargado: desistindo da execução o embargado estará, também, desistindo do prosseguimento dos embargos de mérito. E, inobstante o silêncio a respeito na letra b do parágrafo, caberá ao embargado, como nos casos da letra a, suportar os ônus processuais de custas e honorários advocatícios.⁴⁶ Aplica-se, aqui, com mão invertida, o art. 90 do Código, como se o próprio exequente fosse o desistente da ação de embargos.

Em outras palavras, extinta a execução por desistência do credor, extinguem-se automaticamente os embargos de forma; e, se houver a concordância do embargante, extinguem-se também os embargos de mérito. Em qualquer caso, suportará o exequente o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não havendo concordância do embargante com a extinção, os embargos de mérito prosseguem como ação autônoma de cognição “destinada (como desde o início, aliás) à obtenção de uma sentença declarando que o crédito existe ou que não existe”.⁴⁷ Daí em diante, o regime da desistência é o do processo de conhecimento, ou seja, se o embargante pretender desistir dos embargos, somente poderá fazê-lo unilateralmente antes da impugnação a que se refere o art. 920. Daí em diante, a desistência dependerá do consentimento do embargado, cabendo ao embargante suportar as despesas e honorários. É o que impõem os arts. 485, § 4.º, e 90, aplicáveis subsidiariamente.

5. Embargos fundados em excesso de execução

A disciplina prevista no parágrafo único do art. 775 não dá solução para todas as situações. Assim, não se pode dizer que os embargos fundados em excesso de execução versam, sempre, questões processuais. Não é matéria processual a que impugna a execução por quantia superior à do título, ou por coisa diversa da nele prevista, ou quando impugna a ação do exequente que ainda não cumpriu a prestação que lhe corresponde ou que não provou a realização da condição para a exigibilidade da prestação (art. 917, § 2.º, I, II, IV e V). Todavia, também nesses casos a desistência da execução importará automática extinção dos embargos, por imposição inafastável do mesmo princípio inspirador do inciso I do parágrafo único: a inutilidade do pronunciamento judicial a respeito do excesso da execução e a consequente ausência de interesse jurídico no prosseguimento do debate a respeito. Extintos os embargos, caberá ao embargado, também nesses casos, o ônus das despesas do processo e dos honorários advocatícios.

6. Embargos de retenção

Os embargos fundados em direito de retenção por benfeitorias, de que trata o art. 917, IV, igualmente não versam questões processuais. São, na verdade, instrumento de defesa do direito de só entregar o bem mediante a indenização das benfeitorias, como prevê a lei civil (art. 1.219, CC). Não há razão, entretanto, para o seu prosseguimento, se o credor desistir da execução: cessadas as medidas executivas que visavam retirar a coisa da posse do executado, fenece o interesse em continuar a ação de oposição à entrega.

7. Desistência da execução quando incidiu multa diária

Pode ocorrer, em execução de obrigação de fazer e de não fazer, que o pedido de desistência se dê após o decurso do prazo para o cumprimento da obrigação. Cabe perguntar se, nesse caso, é devida a multa diária (art. 814) correspondente aos dias de atraso já decorridos. A resposta há de ser negativa: quem desiste da execução, desiste dos correspondentes meios de coação. E se já houve o pagamento ou a execução da multa? Já se disse que o princípio da disponibilidade supõe reposição dos fatos ao estado anterior. Sendo assim, a desistência unilateral da execução implicará a obrigação do exequente de restituir o que recebeu a título de multa. A responsabilidade pela restituição dos fatos ao estado anterior, em casos tais, é de natureza objetiva. Caberá ao juiz, ao homologar a desistência, prover a respeito, como o faz relativamente às custas e aos honorários advocatícios.

8. Destino da medida cautelar e dos embargos de terceiro

Homologado o pedido de desistência e extinto o processo de execução, ficam comprometidas as medidas cautelares (tutela provisória de urgência cautelar) a ele relacionadas, que perderão a eficácia (CPC, art. 309, I). O mesmo pode ocorrer se a desistência for de alguma medida executiva referenciada especificamente com a cautelar, como, por exemplo, se o exequente desistir da penhora de bens objeto de arresto.⁴⁸ Em qualquer hipótese, suportará o exequente os ônus processuais da medida cautelar, respondendo pelos prejuízos causados a quem teve de suportá-la (art. 302). É responsabilidade objetiva.

Situação semelhante ocorrerá com os embargos de terceiro. Se houver desistência de toda a execução ou da medida executiva específica que ensejou a ação de embargos, esta perderá sua razão de ser, devendo ser extinto o respectivo processo pela superveniente perda do interesse de agir. Suportará o exequente, que provocou a extinção do processo, os ônus respectivos. É responsabilidade objetiva, semelhante à do inc. I do parágrafo único do art. 775.

9. Desistência do cumprimento provisório

O princípio da disponibilidade aplica-se também ao cumprimento provisório de sentença. A desistência certamente não comprometerá o julgamento do recurso na ação de conhecimento, nem impedirá a repetição do requerimento ou o requerimento de cumprimento definitivo.

Pode ocorrer que o cumprimento provisório tenha sido requerido na pendência de recurso da decisão que homologou a liquidação de sentença. Considerando a autonomia da fase de liquidação em relação à de cumprimento, e considerando que a desistência não é empecilho ao novo requerimento de cumprimento – provisório ou definitivo – não há porque imaginar-se prejudicado o julgamento do recurso.

10. Desistência da execução e extinção do direito e da pretensão

A desistência da execução a que se refere o parágrafo único do art. 775, é a pura e simples, ou seja, a que não tem qualquer relação com a higidez do direito material. Quando a desistência estiver fundada em renúncia à pretensão ou ao crédito ou em remissão da dívida (como, por exemplo, anistia fiscal) ou em qualquer outro ato ou fato que importe a extinção do próprio direito, a situação é diversa. Haverá mais que simples desistência. Os partidários da teoria civilista da ação – segundo a qual só há direito de ação quando há direito material – diriam que, nesses casos, a desistência seria até uma impropriedade, dado que não se poderia desistir daquilo que já não se tem. Todavia, para quem distingue a relação jurídica processual da relação substancial, é conceitual desistir da ação em razão de superveniente extinção do direito. A extinção do processo, nas aludidas situações, será fundada no inc. III ou no IV, do art. 924. As consequências em relação aos embargos (e à impugnação) não serão, necessariamente, as mesmas que decorrem da pura e simples desistência da ação. Em princípio, extinguir-se-ão não apenas os embargos de forma, mas também os de mérito, por falta de interesse de agir. Pela mesma razão, serão extintos os embargos de terceiro e o requerimento de liquidação de sentença referenciados à execução ou ao cumprimento de sentença, perdendo objeto também as medidas cautelares.

Pode ocorrer que a extinção do direito material do exequente se dê quando já consumado ato

executivo de interesse de terceiro e que não pode ser revertido sem atingir tal interesse. Por exemplo: no interregno entre a arrematação do bem penhorado e antes do pagamento. O direito de terceiro que validamente adquiriu o bem não poderá, nestas circunstâncias, ficar comprometido. A solução é atribuir ao executado o preço arrecadado. E se a validade do ato – no exemplo, a arrematação – estiver sendo questionada em ação paralela pelo executado ou por terceiro? Não havendo desistência por parte do autor, a ação deverá prosseguir, mesmo que seu objeto seja apenas um ato processual da execução.

Em qualquer dos casos aventados – em que a desistência da execução, por superveniente extinção do direito, importar também a extinção da ação paralela –, a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios devidos nos processos extintos tem regime próprio, diverso do previsto no inciso I, do parágrafo único, do art. 775 e do art. 90 do CPC. Não há de se falar, aqui, em responsabilidade objetiva. Tendo a extinção decorrida de fato superveniente, suportará aqueles ônus a parte que possivelmente sucumbiria se a ação prosseguisse normalmente até o seu final. Caberá ao juiz, para esse efeito, formular um “julgamento hipotético”,⁴⁹ a fim de apurar quem “deu causa à instauração do processo de modo objetivamente injurídico”.⁵⁰

Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação, que ensejou execução.

1. Responsabilidade do exequente e direito à reposição do status quo ante

São várias as situações em que a execução – e o cumprimento provisório ou definitivo –, depois de levada a cabo, pode vir a ser reconhecida como ilegítima e indevida. A mais comum, em se tratando de cumprimento provisório, é a reforma ou a anulação, em grau de recurso, da sentença executada. Para esta hipótese há disciplina específica no Código de Processo, que prevê duas consequências, distintas e inconfundíveis: a responsabilidade do exequente pelos danos causados ao executado (art. 520, I) e a reposição das coisas ao estado anterior (art. 520, II).

Relativamente à execução ou ao cumprimento definitivo, sua insubsistência pode decorrer de variadas causas, como por exemplo: (a) do provimento do recurso contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ou desacolheu a impugnação, (b) da procedência de ação declaratória de nulidade do título que deu base à execução e (c) da procedência da ação rescisória da sentença executada ou da que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em qualquer desses casos, o sucesso da demanda intentada pelo devedor pode ter por fundamento, tanto razões de mérito relacionadas especificamente com a existência da obrigação, quanto outras razões, inclusive nitidamente formais ou processuais: a incompetência do juízo, a nulidade da citação, a ilegitimidade de parte, a ausência de pressuposto processual, e assim por diante.

Seja qual for o fundamento da decisão, tenha ela declarado ou não inexistente a obrigação executada, uma consequência é certa, embora sem previsão expressa no Código: a do direito do executado à reposição dos fatos ao estado anterior. Imagine-se a hipótese de execução de título extrajudicial, em que o devedor interpõe embargos sustentando a incompetência absoluta do juízo. Rejeitados estes por sentença, o recurso de apelação não terá efeito suspensivo, de modo que a execução poderá prosseguir. Ora, provido o recurso, não pode haver dúvida que assiste ao executado o direito de ver desfeitos os atos executivos já consumados, pena de ter sido inteiramente inútil o julgamento do Tribunal. Outro exemplo: tendo sido vencedor na ação rescisória em que ficou assentada a ocorrência da prescrição da obrigação objeto da sentença condenatória executada, tem o devedor, inquestionavelmente, o direito à recomposição da situação anterior. O retorno ao status quo ante, que se dará nos próprios autos,⁵¹ constitui, nos exemplos aventados e em todas as demais situações análogas antes referidas, efeito natural e inafastável do provimento sentencial em favor do devedor. É efeito decorrente do princípio constitucional da utilidade da função jurisdicional, que permeia necessariamente o sistema do processo civil, mesmo que dele não conste explicitamente.

Ora, o art. 776 do CPC trata da responsabilidade do credor numa específica situação: a que tem como pressuposto o superveniente reconhecimento judicial de que a obrigação executada era “inexistente, no todo ou em parte”. Não se pode confundir o direito à indenização que daí decorre com o direito à reposição das coisas ao estado anterior, presente este, como se viu, não só quando ficar atestada a inexistência da obrigação, mas em todas as demais situações em que ficar reconhecida, inclusive por razões processuais, a insubsistência dos atos executivos levados a cabo.

2. Natureza dos danos ressarcíveis

Os danos ressarcíveis não se confundem com a reposição dos fatos ao estado anterior. Não se confundem, igualmente, com a obrigação de que trata o art. 940 do CC (art. 1.531 do CC/1916), segundo o qual “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas, ou pedir mais do que foi devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Aqui, com efeito, a imposição tem natureza punitiva, é aplicável mesmo que não haja dano e dela se exime o exequente de boa-fé, segundo prevê a Súmula 159 do STF.

Os danos de que trata o art. 776 são os objetivamente decorrentes da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. Não se limitam ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que têm disciplina própria e são devidos em qualquer execução, e não apenas na que foi frustrada pela superveniente sentença que declarou a inexistência da obrigação. O dispositivo fala em “danos que (o devedor) sofreu”, devendo-se compreendê-los, portanto, em sentido amplo, tais como previstos no art. 402 do CC (art. 1.059 do CC/1916): abrangem, além do que o executado efetivamente perdeu, também o que deixou de lucrar. Não há porque excluir os danos morais efetivamente comprovados,⁵² notadamente em face do que dispõe o art. 5.º, X, da CF/1988. Saliente-se que, hoje, pode-se considerar “absolutamente inaceitável a doutrina, que se chamou de eclética, a afirmar ser indenizável o dano moral apenas na medida de seus reflexos patrimoniais. Se somente as consequências materiais de um ato ilícito devem ser ressarcidas, a toda evidência está se negando o direito à reparação do dano moral”.⁵³ Em suma: são todos os danos, devidamente comprovados, que tenham relação de causalidade com o processo de execução intentado para haver o cumprimento de obrigação declarada, posteriormente, inexistente.

3. Natureza da responsabilidade

Segundo opinião generalizada da doutrina, é de natureza objetiva a responsabilidade prevista no art. 776.⁵⁴ “O fundamento do ressarcimento ao executado dos danos que sofreu pela execução infundada é o mesmo da condenação em custas. É o fato objetivo da derrota, ou do sucumbimento”, escreveu Amílcar de Castro.⁵⁵ “Trata-se de responsabilidade objetiva que decorre do risco ligado ao ônus processual”, observou Mario Aguiar Moura.⁵⁶ Sua natureza é idêntica à da prevista para o ressarcimento dos danos em caso de cumprimento provisório (art. 520, I), também objetiva, segundo doutrina clássica a respeito da hoje inexistente execução provisória.⁵⁷ Dispensa-se, conseqüentemente, investigação sobre dolo ou culpa. Basta, para obter ressarcimento, a prova da existência do dano – patrimonial ou moral – e da sua relação de causa e efeito com a execução.

4. Sentença passada em julgado declarando inexistente a obrigação

A peculiar responsabilidade objetiva do exequente supõe a superveniência de sentença declarando “inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que deu lugar à execução”. Se a ilegitimidade dos atos executivos decorreu de outra causa, o regime das perdas e danos obedecerá (a) o disposto no art. 186 do CC, que corresponde ao art. 159 do CC/1916 (responsabilidade subjetiva), em se tratando de execução definitiva, e (b) o que estabelece o art. 520, I, do CPC/2015 (responsabilidade objetiva), se o cumprimento for provisório.

O reconhecimento da inexistência da obrigação executada pode decorrer não só da sentença ou do acórdão proferido em embargos do executado ou impugnação ao cumprimento de sentença, como também em ação declaratória, proposta antes ou, inexistindo embargos, até mesmo no curso

ou após a execução. Pode, igualmente, decorrer do acórdão que julgar procedente ação rescisória da sentença executada ou da que julgou improcedentes os embargos. Em qualquer caso, é invocável o art. 776 do CPC/2015.⁵⁸

5. Procedimento

O ressarcimento dos danos se dará nos próprios autos em que se realizou a execução ou o cumprimento,⁵⁹ sendo competente, portanto, o mesmo juiz. Mas a ação não é a mesma. É ação própria,⁶⁰ sujeita à iniciativa do executado, que, embora dispensado de provar a culpa do exequente, terá o ônus de demonstrar a ocorrência dos danos, o seu valor e a sua relação de causa e efeito com a execução da obrigação inexistente.⁶¹ Trata-se, aqui, de ação tipicamente cognitiva. Apurados e liquidados os danos, seguir-se-á cumprimento de sentença por quantia certa, movida pelo antigo executado contra o antigo exequente, cujas posições processuais ficam agora, como se percebe, invertidas.

6. Efeitos decorrentes da execução injusta

Do que acima se expôs, podemos concluir que, em nosso sistema, quando ficar reconhecido que a execução foi promovida injusta ou ilegítimamente, os seguintes efeitos ocorrerão: (a) em qualquer caso, o direito do executado à reposição dos fatos ao estado anterior; (b) em qualquer caso, a responsabilidade do exequente pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente as despesas processuais e os honorários advocatícios; (c) em qualquer caso, a responsabilidade do credor-exequente – de natureza subjetiva, em se tratando de execução e cumprimento definitivo, e objetiva, em se tratando de cumprimento provisório – de ressarcir as perdas e danos decorrentes da execução; e, finalmente, (d) no específico caso em que a execução tenha tido por base obrigação inexistente, como tal reconhecida por sentença transitada em julgado, a responsabilidade do credor-exequente – de natureza objetiva – de ressarcir os danos sofridos pelo devedor-executado. Esta última é a hipótese disciplinada no art. 776 do CPC.

Art. 777. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo.

1. Cobrança de multas e indenizações processuais

O Código deixa clara a opção pela desnecessidade de um novo processo judicial para cobrança das inúmeras sanções processuais previstas para assegurar a conduta ética no processo. Havendo possibilidade de cumulação com a execução em curso, a medida é recomendável, inclusive pela sua praticidade. Todavia, não sendo viável a cumulação, mormente por incompatibilidade de procedimento, a execução do valor da multa e das indenizações, bem como sua liquidação, se for o caso (art. 509), tramitará em separado.

2. Compensação

Diferentemente do que ocorria no regime anterior, o Código de 2015 não prevê a possibilidade de compensação. Todavia, embora não mais expressamente prevista, é cabível a compensação quando o devedor da multa ou de indenização for o próprio exequente de obrigação de pagar quantia. Aplicam-se à hipótese as normas próprias do direito civil (Código Civil, art. 368).

NOTAS DE RODAPÉ

1

J. J. Calmon de Passos, Comentários ao código de processo civil, 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, vol. III, p. 7.

2

TRF, 4. a Região, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 47.992, 2. a Turma, Juiz Teori Albino Zavascki, DJ de 27.11.1996, p. 91.446. Na doutrina: Galeno Lacerda, Execução de título extrajudicial e segurança do juízo, *Ajuris* 23/11; Pontes de Miranda, Dez anos de pareceres, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1975, vol. 4, p. 131; Araken de Assis, *Op. cit.*, p. 426; Carlos Renato de Azevedo Ferreira, Exceção de preexecutividade. *Revista dos Tribunais*, 657/243; Pedro dos Santos Barcelos, Possibilidade de admissão de embargos de devedor sem estar seguro o juízo da execução, *Revista dos Tribunais*, 652/227.

5

Juarez Freitas acentua a importância da visão do “sistema como ordem axiológica ou teleológica” apontando como suas “principais vantagens: (a) salienta, no trato de temas como antinomias, a função do sistema como sendo a de traduzir coerência valorativa, impedindo uma abordagem meramente formal; (b) evita a crença exacerbada na completude fechada e auto-suficiente do sistema, permitindo pensar a completude e a coerência como processos abertos; (c) resguarda o papel da interpretação sistemática, pois tal abertura não contradita (antes pelo contrário) a exigência de ordem e de unidade interna; (d) realça o papel decisivo da interpretação bem ponderada, em virtude do manejo concertado de princípios no bojo do sistema jurídico, tomado e concebido em sua dinamicidade” (*A interpretação sistemática do direito*, São Paulo: Malheiros, 1995, p. 39).

7

José Carlos Barbosa Moreira, Sobre a participação do juiz no processo civil, *Participação e processo, coordenação de Ada Pellegrini Grinover; Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe*, São Paulo: Ed. RT, 1988, p. 389.

12

José Carlos Barbosa Moreira, Sobre a participação do juiz no processo civil, *cit.*, p. 389.

14

Sobre os deveres inerentes ao dever de cooperação, ver Miguel Teixeira de Sousa, *Estudos sobre o novo processo civil*, Lisboa: Lex, 1997. Essa sistematização é hoje utilizada pela doutrina brasileira (exceto pela enunciação do dever de auxílio, rejeitado por parcela dos doutrinadores). Sobre o tema, para uma resenha desse desenvolvimento, ver ainda Daniel Mitidiero, *Colaboração no processo civil. Pressupostos sociais, lógicos e ética*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 102-106.

15

Karl Engisch, *Introdução ao pensamento jurídico*, 3. ed., trad. de J. Baptista Machado, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 177.

17

Teori Albino Zavascki, *Antecipação da tutela*, *cit.*, p. 82.

26

Nesse sentido STJ, 4.^a Turma, AgRg no REsp 1192155/MG, rel. Ministro Raul Araújo, DJe 01.09.2014.

31

Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 140.

32

Araken de Assis. Manual..., cit., p. 99.

34

STJ, REsp 6.539, 4.ª Turma, Min. Athos Carneiro, DJ de 09.09.1991, p. 12.206.

38

Teori Albino Zavascki, Ministério público e ação civil pública, Revista de Informação Legislativa 114/156.

39

Araken de Assis. Manual..., cit., p. 99.

45

Carlos Alberto Carmona, O processo de execução depois da reforma, apud Reforma do código de processo civil, obra coletiva, coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 749.

56

Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 66.

3

Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 71.

4

“Diz-se que um ordenamento jurídico constitui um sistema porque não podem coexistir nele normas incompatíveis”, observou Norberto Bobbio (Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 80).

6

A matéria é objeto da Súmula 196 do STJ: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”.

8

Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 481; Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 217.

9

José Carlos Barbosa Moreira, Sobre a participação do juiz no processo civil, cit., p. 385.

10

J. J. Calmon de passos, A crise do processo de execução, Ciência jurídica 37/21.

11

J. J. Calmon de Passos, A crise do processo de execução, cit., p. 23.

13

Idem, p. 383.

16

Amílcar de Castro, Comentários..., cit., p. 108. No mesmo sentido: Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 487; Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 142.

18

Idem, p. 48 e 84.

19

Foi o que sustentamos, como relator, no Agravo de Instrumento 18.814, TRF, 4. a Região, 2. a Turma, DJ de 15.01.1997, p. 1.024.

20

RE 92.377, 2.^a Turma, Min. Moreira Alves, RTJ 110/184. No mesmo sentido: RE 94.608, 2. a Turma, Min. Cordeiro Guerra, RTJ 110/195, em cuja ementa se lê: “É legítima a requisição de informações, pelo magistrado, ao imposto de renda, no interesse da justiça. Nada justifica a proteção ao inadimplente em detrimento da boa-fé dos negócios e do prestígio da justiça”.

21

Embargos de Divergência no Recurso Especial 28.067, Min. Torreão Braz, DJ de 27.03.1995, p. 7.119. Os precedentes da 4. a Turma admitem, em geral, a requisição das informações à Receita Federal (REsp 2.777,

Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 09.10.1990, p. 10.898; REsp 8.806, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 24.02.1992, p. 1.873; REsp 10.896, Min. Athos Carneiro, DJ de 11.05.1995, p. 6.437; REsp 8.794, Min. Bueno de Souza, DJ de 25.10.1993, p. 22.496; REsp 53.179, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 28.08.1995, p. 26.637; REsp 102.292, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 16.12.1996, p. 50.880). Na 3.ª Turma, predomina orientação que considerava incabível tal forma de requisição (REsp 8.805, Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 06.05.1991, p. 5.668; REsp 19.568, Min. Dias Trindade, DJ de 20.04.1992, p. 5.253; REsp 28.067, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 29.03.1993, p. 5.256; REsp 16.356, Min. Cláudio Santos, DJ de 16.11.1992, p. 21.134; REsp 59.812, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 13.11.1995, p. 38.674; REsp 84.581, Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 17.06.1996, p. 21.454).

22

Araken de Assis, Manual..., cit., p. 345.

23

Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 485.

24

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Código de processo civil anotado, cit., p. 425.

25

Cândido Dinamarco, A reforma do código de processo civil, cit., p. 65; Araken de Assis, Reforma do processo executivo, cit., p. 149; J. J. Calmon de Passos, Inovações no código de processo civil, cit., p. 135; Donaldo Armelin, O processo de execução e a reforma do código de processo civil, cit., p. 700. Em sentido contrário, Carlos Alberto Carmona, entendendo que a prévia advertência não é obrigatória, mas conveniente (O processo de execução depois da reforma. Reforma do código de processo civil, coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, cit., p. 753).

27

Clito Fornaciari Júnior, A reforma processual civil (artigo por artigo), cit., p. 161.

28

Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, cit., vol. II, p. 720.

29

Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do código de processo civil, cit., p. 233.

30

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 109.

33

STJ, REsp 767, 4. a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, RSTJ 6/419; REsp 7.370, 4. a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, RSTJ 29/386.

35

Cândido Dinamarco, *Litisconsórcio*, cit., p. 36.

36

Arruda Alvim, *Código de processo civil comentado*, São Paulo: Ed. RT, 1976, vol. III, p. 382.

37

Sobre a impossibilidade de o Ministério Público desistir da ação civil pública: Galeno Lacerda, *Ação civil pública*. Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 19/32; Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Édís Milaré e Nelson Nery Junior, *A ação civil pública e a tutela jurisdicional dos interesses difusos*, São Paulo: Saraiva, 1984, p. 43; José Domingos Da Silva Marinho, *A necessidade de uma constituição concisa*, *Justitia* 135/24; Voltaire de Lima Moraes, *A ação civil pública e a tutela do meio ambiente*, *Ajuris* 37/220; Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1988, vol. I, p. 56; e Hely Lopes Meirelles, *Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data*, 12. ed., São Paulo: Ed. RT, 1989, p. 123.

40

Cândido Dinamarco, *A reforma do código de processo civil*, cit., p. 233.

41

Pontes de Miranda, *Comentários...*, cit., t. IX, p. 109.

42

José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 302.

43

Antônio Janyr Dall'agnol Júnior, *Da desistência no processo de execução*, *Ajuris* 19/86.

44

Enrico Tullio Liebman, *Embargos do executado*, 2. ed., trad. de J. Guimarães Menegale, São Paulo: Saraiva, 1968, p. 150 e 152.

46

Clito Fornaciari Júnior, A reforma processual civil (artigo por artigo), São Paulo: Saraiva, 1996, p. 154.

47

Cândido Dinamarco, A reforma do código de processo civil, cit., p. 235.

48

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 111.

49

Yussef Said Cahali, Honorários advocatícios, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1990, p. 327.

50

STJ, REsp 7.772, 3. a Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 21.09.1992, p. 15.686. No mesmo sentido: REsp 60.331, 5. a Turma, Min. Jesus Costa Lima, DJ de 10.04.1995, p. 9.290; REsp 13.404, 2. a Turma, Min. Pádua Ribeiro, RSTJ 52/103; TRF 4. a Região, AC 94.04.02709, 5. a Turma, Juiz Teori Albino Zavascki, DJ de 14.06.1995, p. 37.691.

51

STF, RE 91.974, 2. a Turma, Min. Cordeiro Guerra, RT 559/241; STF, RE 92.027, 2. a Turma, Min. Leitão de Abreu, RT 552/250; 2. a TACSP, AgPt 22.671, 5. a Turma, RF 254/260.

52

Em sentido contrário, entendendo incabível o ressarcimento de dano moral na hipótese: Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 68; José da Silva Pacheco, Tratado das execuções, cit., vol. I, p. 216.

53

Eduardo Ribeiro de Oliveira, Dano moral, RDR 7/2, jan./abr. 1997.

54

Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 177; Amílcar de Castro, Comentários..., cit., p. 28; Ulderico Pires dos Santos, O processo de execução na doutrina e na jurisprudência, cit., p. 35; Araken de Assis, Manual..., cit., p. 341; Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 66; Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas..., cit., p. 229. No mesmo sentido, na jurisprudência: TRF, 1. a Região, AC 111993, 3. a Turma, Juiz Tourinho Neto, DJ de 14.09.1995, p. 61.308.

55

Amílcar de Castro, Comentários..., cit., p. 28.

57

Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, 3. ed., trad. de J. Guimarães Menegale, São Paulo: Saraiva, 1969, vol. I, p. 270; Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, cit., p. 59.

58

Nesse sentido: Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 148; Araken de Assis. Manual..., cit., p. 342. Em sentido contrário, entendendo que a sentença referida no art. 574 é apenas a que julga embargos à execução: Alcides Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 176; Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 67; Ulderico Pires dos Santos, O processo de execução na doutrina e na jurisprudência, cit., p. 36; J. J. Calmon de Passos, Responsabilidade do exequente no novo código de processo civil, RF 246/171.

59

Nesse sentido: TFR, AC 105944, 4.ª Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 12.06.1986; Araken de Assis, Manual..., cit., p. 343. Em sentido contrário: Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 178.

60

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 150.

61

Mario Aguiar Moura sustenta, em posição isolada na doutrina, que a responsabilidade prevista no art. 574 deve, necessariamente, constar como condenação na sentença que declarar inexistente a obrigação (O processo de execução, cit., p. 69).

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO II. DAS PARTES

Capítulo II. Das partes

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1.º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I – o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II – o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III – o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV – o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1.º independe de consentimento do executado.

1. Partes do processo de execução

Às partes, no processo de execução, bem como aos seus procuradores, aplicam-se, de um modo geral, as disposições sobre capacidade processual, deveres e responsabilidades, previstas para o processo de conhecimento (Parte Geral, Livro III, Título I, Capítulos I a III).

Aqui, como lá, importa fazer as devidas distinções entre (a) o sujeito habilitado a figurar legitimamente no processo (parte legítima) e (b) o que efetivamente está figurando em determinada relação processual (parte processual). Parte processual é aquela que pede ou em face de quem é pedida a tutela jurisdicional. A sua identificação tem como parâmetro único a demanda concretamente posta em juízo. Já a parte legítima é aquela que, segundo a lei processual, deve figurar como promovente ou em face de quem deve ser promovida a ação. A legitimidade ad causam, consequentemente, é aferível mediante contraste entre os figurantes da relação processual efetivamente instaurada e os que, à luz dos preceitos normativos, nela deveriam figurar. Havendo coincidência, a parte processual será também parte legítima. Do contrário, o processo terá parte, mas não terá parte legítima.

A parte, pela simples razão de figurar como tal no processo, ainda que ilegitimamente, estará, desde logo, habilitada a praticar validamente atos processuais, a exercer direitos e faculdades e a submeter-se a deveres e ônus próprios da condição de sujeito ativo ou passivo da relação jurídica processual. Assim, um processo no qual apenas se perquire a respeito da legitimação dos seus sujeitos e que é extinto por falta dessa condição, será um processo válido. Válido, porém inútil¹ para o demandante, pois a devida legitimação é, em nosso sistema, uma das condições da ação, cuja falta impede o juiz de, no processo de conhecimento, julgar a pretensão e, no processo de execução, promover atos executivos.

Os arts. 778 e 779 do Código trazem disciplina sobre quem pode legitimamente figurar como sujeito ativo e passivo no processo de execução.

2. Litisconsórcio, assistência e intervenção de terceiros

Admite-se que a ação de execução seja promovida em litisconsórcio ativo (mais de um exequente) ou passivo (mais de um executado) ou misto (mais de um exequente e mais de um executado), conforme decorrer do conteúdo do correspondente título executivo que a documenta. Tratar-se-á, salvo raríssimas exceções, de litisconsórcio facultativo.² Cita-se como caso de litisconsórcio necessário o estabelecido na execução de obrigação alternativa (CPC, art. 800), quando a escolha da prestação couber a mais de um devedor, hipótese em que haverá necessidade da citação de todos para exercer o direito de escolher. Há, também, o que se forma entre o espólio, quando representado por inventariante dativo, e os herdeiros e sucessores do falecido, nas ações de execução propostas pelo espólio ou contra ele (CPC, art. 75, § 1.º).³ Mas aqui, como observa Cândido Dinamarco, não se está diante de litisconsórcio típico, e sim de “representação do espólio, necessariamente conjunta por todos os herdeiros, sendo parte somente aquele, e estes não”.⁴

A figura do assistente, personagem processual com interesse jurídico em que uma das partes sobrepuje a posição da outra, é conciliável com o processo de execução.⁵ A controvérsia que, no particular, grassa na doutrina, tem origem, ao que parece, não propriamente na incompatibilidade do instituto da assistência em face do processo de execução, mas sim na raridade dos casos em que se configura o interesse jurídico ensejador da intervenção assistencial. São casos de assistência os que decorrem do art. 1.498 do Código Civil: a intervenção do fiador ou do abonador, para promover o andamento do processo, retardado, sem justa causa, pelo credor.⁶

Considerada a natureza da ação de execução, que se caracteriza por buscar solução para crise de cumprimento da obrigação e não para a sua identificação ou de seus figurantes-destinatários, não se mostram com ela compatíveis os institutos da intervenção de terceiros,⁷ como a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Tais institutos são típicos do processo de conhecimento, já que intimamente relacionados com a atividade jurisdicional destinada a obter, por sentença, a solução para as crises de identificação do preceito normativo concretizado.

3. Princípio da iniciativa

O processo de execução não pode ser instaurado de ofício pelo juiz. Como as demais espécies de tutela, também a executiva está sujeita aos princípios norteadores da prestação jurisdicional, entre os quais o que veda a iniciativa oficial e atribui ao interessado o direito e o poder de provocar sua atuação.

Estimulado pela ação da parte, o órgão jurisdicional estará habilitado a desenvolver as atividades executivas, e o fará, então, sob regime de impulso estatal, a exemplo do que ocorre no processo de conhecimento (CPC, art. 2.º). Todavia, não poderá ir além (ultra petita) ou fora (extra petita) dos limites estabelecidos na demanda. Também no processo de execução, com efeito, deverá ser observada a relação de congruência e de adequação entre o pedido formulado e a prestação jurisdicional entregue, o que, afinal de contas, é decorrência natural e lógica do princípio da iniciativa.

4. O credor

Em tema de legitimação, vigora, em nosso sistema, regra geral segundo a qual deve ser reproduzido, no processo, o elenco subjetivo da relação jurídica material afirmada pelo autor. No que se refere especificamente ao demandante, estabelece o Código, no art. 18, que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. É a legitimação ordinária, que se contrapõe à extraordinária, aquela em que alguém fica autorizado por lei a, em nome próprio, demandar em juízo direito de outrem.

Ao indicar como primeiro legitimado a promover a execução forçada “o credor a quem a lei confere título executivo”, o Código, como se vê, dá estrito cumprimento à regra geral de legitimação. Credor, aqui, tem o sentido próprio do direito material: é quem, segundo a norma jurídica concreta posta à execução forçada, figura como titular do direito subjetivo. E tem sentido amplo, referindo-se a direitos obrigacionais e a direitos reais.⁸ É credor tanto o vencedor da ação

de conhecimento (título executivo judicial), quanto o portador do cheque ou o debenturista (título executivo extrajudicial); é credor não apenas o que pode exigir de outrem o pagamento de quantia certa, como também o que, conforme dispuser o título executivo, tem a faculdade de exigir uma prestação de fazer ou de não fazer ou de entregar coisa.

Nem sempre o credor figura expressamente no título executivo. No direito cambiário, o endosso em branco legitima o portador a promover a execução, mesmo que o seu nome não tenha sido apostado no verso da cártula.⁹ O advogado que patrocinou a causa, embora não tenha sido ele, pessoalmente, e sim o seu representado, o vencedor na ação, é credor por título executivo judicial, para fins de execução dos honorários advocatícios incluídos na sentença de procedência. Isto por força de expressa disposição do art. 23, da Lei 8.906/1994.¹⁰

5. O Ministério Público

A legitimação do Ministério Público como autor na execução forçada é de natureza extraordinária: há demanda, em nome próprio, por tutela jurisdicional em favor de terceiro. O regime é, pois, de substituição processual, e não de representação. A diferença básica entre os dois regimes é que o representante atua em nome do seu representado, enquanto o substituto age sempre em nome próprio.¹¹

A autorização para que o Ministério Público possa atuar nessa qualidade há de decorrer de lei, diz o inc. I do § 1.º do art. 778 do CPC/2015, repetindo, no particular, a regra constante do art. 177. No que se refere especificamente ao cumprimento de sentença, o seu requerimento, pelo Ministério Público, ocorre, quase sempre, com base em título executivo judicial formado em ação cognitiva por ele mesmo proposta. Assim, por exemplo, em caso de sentença condenatória nas ações civis públicas destinadas a tutelar direitos ou interesses coletivos e difusos (art. 3.º, da Lei 7.347, de 24.07.1985) ou a probidade administrativa, em situações de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública (Lei 8.429, de 02.06.1992, art. 17). Casos há, porém, em que o cumprimento é requerido pelo Ministério Público, embora a sentença condenatória tenha sido proferida em demanda da qual não foi autor. É o que ocorre na ação popular quando, decorridos sessenta dias da condenação, ninguém requer o cumprimento (art. 16 da Lei 4.717, de 29.06.1965).

De um modo geral, a legitimação extraordinária para pleitear a tutela condenatória estende-se ao cumprimento da sentença.¹² Em se tratando de direitos e interesses difusos e coletivos, para cuja defesa o Ministério Público está habilitado pela própria Constituição Federal (art. 129, III), é natural que assim ocorra. Sendo por natureza transindividuais – isto é, sem titular individual determinado, mas pertencentes a um grupo ou a uma classe de pessoas, coletivamente consideradas – tais direitos não podem ser tutelados senão pela ação de um substituto processual, inclusive no que se refere ao seu cumprimento.

Já em se tratando de tutela de direitos subjetivos individuais a situação é bem diversa: o Ministério Público tem legitimação para promover ação cognitiva, destinada a obter sentença condenatória genérica, mas, não está, a não ser quando se trata de direito individual indisponível, habilitado a requerer o cumprimento em nome ou no interesse particular do titular do direito subjetivo. Esta é a única forma para justificar, constitucionalmente, a atuação ministerial nas demandas em que se busca tutela para tais direitos, como é o caso dos chamados direitos individuais homogêneos. É o que sustentamos em estudos específicos,¹³ por fundamentos que, sinteticamente, passaremos a demonstrar.

O legislador ordinário habilitou o Ministério Público a defender direitos individuais de consumidores (Lei 8.078/1990, art. 91), de investidores no mercado de valores mobiliários (Lei 7.913/1989) e de credores de instituições financeiras em regime de liquidação extrajudicial (Lei 6.024/1974), sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, sejam necessitados ou não. Aparentemente, esta legitimação – para defender em nome próprio direitos tipicamente individuais e disponíveis – não seria compatível com a natureza e a finalidade do Ministério Público, instituição destinada, constitucionalmente, apenas à tutela de interesses sociais ou individuais indisponíveis (art. 127), e à qual se proíbe de atuar em juízo em nome até mesmo de entidades públicas (art. 129, IX), quanto

mais de pessoas privadas.

Nas situações de que tratam as leis referidas, contudo, há comprometimento, mais que de simples direitos individuais, de importantes interesses sociais. Vistas em seu conjunto, as lesões fazem periclitar valores de especial significado para o funcionamento de destacadas instituições sociais. Com efeito, segundo a Constituição, a defesa dos consumidores é princípio fundamental da atividade econômica (art. 170, V), razão pela qual deve ser promovida, inclusive pelo Estado, em forma obrigatória (art. 5.º, XXXII). Não se trata de proteção individual, pessoal, particular, deste ou daquele consumidor lesado, mas da tutela coletiva dos consumidores, considerados em sua dimensão comunitária e impessoal. O mesmo ocorre em relação aos poupadores que investem seus recursos no mercado de valores mobiliários. Conquanto suas posições individuais e particulares possam não ser relevantes para a sociedade, o certo é que, quando consideradas em sua projeção coletiva, passam a ter relevância ampliada, de repercussão maior que a simples soma de posições individuais. O interesse social na tutela desses direitos decorre, não do significado particular de cada um. Está, sim, nas consequências que a lesão deles, globalmente considerada, representa para o adequado funcionamento do sistema financeiro, que é, segundo a própria Constituição, instrumento fundamental para promover o desenvolvimento equilibrado do País e servir os interesses da comunidade (art. 192).

Não há dúvida, portanto, que a defesa de direitos individuais de consumidores e de investidores no mercado financeiro, previstas na legislação antes referida, pode ser compatibilizada com a incumbência do Ministério Público de defender interesses sociais (art. 127 da Constituição). Para que isso ocorra, é indispensável que a defesa seja pautada pelo trato coletivo e impessoal dos direitos subjetivos a serem tutelados. Somente nessa dimensão é que tais direitos – embora por natureza individuais e disponíveis – ganham relevância social.

Pois bem, ao disciplinar os procedimentos para a tutela dos direitos individuais homogêneos antes referidos, o legislador ordinário traçou-lhes uma linha comum e característica: a atuação do Ministério Público objetiva sentença condenatória genérica, englobando o conjunto dos lesados, sem individuar nomes, valores ou situações particulares. Essa individualização se fará, posteriormente, mediante habilitações próprias ou por procedimentos liquidatórios e de cumprimentos específicos, promovidos pelo próprio titular do direito individual. Ou seja, os direitos individuais dos substituídos serão defendidos pelo Ministério Público sempre global, impessoal e coletivamente. Obtido o provimento jurisdicional genérico, encerra-se a legitimação ministerial, sendo que a liquidação da sentença e a execução dos danos individualmente sofridos serão promovidas, não em regime de substituição processual, mas de representação.¹⁴

A sentença genérica assim proferida tem natureza peculiar, distinta da “sentença ilíquida”, a que se refere o art. 491 do CPC. Esta, com efeito, decorre de um pedido genérico no que se refere ao objeto (CPC, art. 324). Aquela, proferida em ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, contém generalidade em grau ainda mais elevado: é indefinida inclusive quanto aos próprios titulares do direito material. Ela não constitui propriamente um título executivo e nem mesmo um título que habilita à liquidação apenas do quantum debeatur. Na verdade, é título para uma especial fase liquidatória, uma fase de cumprimento, em cujo objeto incluem-se não apenas a apuração dos valores devidos, mas também a identificação e a situação particular do titular do direito. Ou seja: aqui já imperam interesses puramente individuais. O interesse social, para o qual se habilitara o Ministério Público, satisfaz-se com a condenação genérica do autor da lesão.

A técnica de autorizar o Ministério Público a promover a ação condenatória tendente a obter sentença genérica, deixando para os próprios interessados, a partir daí, a iniciativa da liquidação e cumprimento individual, constitui, portanto, a maneira de compatibilizar a atuação do parquet em defesa de interesses sociais com as limitações constitucionais que lhe são impostas no que se refere à tutela de direitos individuais disponíveis. Essa técnica deve ser observada nos demais casos em que o Ministério Público pretenda habilitar-se a promover demandas por direitos individuais semelhantes. Sua atuação somente ganhará amparo constitucional na medida em que a defesa das individualidades representadas puder significar também a tutela de interesses sociais, assim entendidos aqueles cuja salvaguarda é importante para a organização e o funcionamento da sociedade e para atender suas necessidades de bem-estar e desenvolvimento. Não se pode

confundir interesses sociais com interesses de entidades públicas, nem com o conjunto de interesses de pessoas ou de grupos. A tutela de direitos individuais somente pode ser considerada de interesse social quando a lesão deles, considerada em seu todo, atingir também valores comunitários especialmente privilegiados no ordenamento jurídico.

Outro espaço possível de atuação do Ministério Público no polo ativo da execução está na efetivação de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) descumpridos. É muito comum que em inquérito civil ou já na pendência de ação judicial o Ministério Público e o investigado formalizem ajuste de conduta por meio de instrumento próprio. Tal documento, mesmo não homologado judicialmente, tem força de ser título executivo extrajudicial (art. 784, IV), passível de ser executado pelo Ministério Público. Havendo homologação, é título executivo judicial (art. 515, II ou III), podendo ser submetido ao regime de cumprimento de sentença.

6. Outras hipóteses de legitimação por substituição processual

Além do Ministério Público, outras entidades estão legitimadas a propor, em regime de substituição processual, ações condenatórias e os correspondentes requerimentos de cumprimento. Assim, na ação popular, habilita-se qualquer cidadão, tanto para a ação cognitiva (Lei 4.717, de 29.06.1965, art. 1.º) quanto para seu cumprimento (art. 16). Em se tratando de direitos e interesses transindividuais (difusos e coletivos), habilitam-se o Ministério Público e pessoas jurídicas de direito público (União, Estados e Municípios), bem assim as autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista ou associações constituídas há pelo menos um ano e cuja finalidade institucional seja a proteção dos direitos e interesses cuja tutela pretenda-se ver alcançada em juízo (Lei 7.347, de 24.07.1985, art. 5.º). É o que ocorre, também, em se tratando de lesões a direitos e interesses de consumidores (Lei 8.078/1990, art. 82), de pessoas portadoras de deficiência (Lei 7.853/1989, art. 3.º), de crianças e adolescentes (Lei 8.069/1990, art. 210) ou por infração à ordem econômica (Lei 8.884/1994, art. 17).

Não é exaustivo, portanto, o rol do art. 778 do Código.

7. O substituto processual na execução

Em todos os casos em que a execução é promovida por substituto processual, será incabível, a não ser com expressa autorização do substituído (o que, em se tratando de interesses difusos e coletivos, é impossível obter), a prática de atos que importem disposição do direito material, como, por exemplo, a transação, a renúncia ou qualquer outra forma de remissão da dívida (CPC, art. 924, III e IV). Quem defende em juízo, em nome próprio, direito de outrem, não substitui o titular na relação de direito material, mas sim e apenas na relação processual.¹⁵ Conforme anotou Pontes de Miranda, “a transação judicial tem conteúdo de direito material e só é processual o efeito de pôr termo ao processo...”,¹⁶ de modo que ela “tem de existir, ser válida e ser eficaz segundo os princípios de direito material, que a rege”.¹⁷ E acrescenta, mais adiante: “A feitura da transação pendente a lide, homologada pelo juiz (...) não a processualiza: a homologação é para reconhecer-lhe a eficácia quanto à relação jurídica processual, que é entre os figurantes da transação e o juiz, e só por decisão dele se pode desfazer, cessando, então, para o Estado, o dever da prestação jurisdicional prometida”.¹⁸ Essas observações valem para todos os demais meios pelos quais se manifestam atos de disposição do direito afirmado em juízo: é o direito material que os rege, não o direito processual. E o substituto processual tem apenas o direito de ação, não estando autorizado a dispor do direito material do seu substituído.

Habilitado a pleitear, judicialmente, a tutela de direito de outrem, investe-se o substituto processual do poder-dever de defesa do direito afirmado, quando contra-atacado pelo executado. O contra-ataque poderá ocorrer na própria execução ou cumprimento (por exemplo, pela via de exceção de preexecutividade do título) ou em impugnação ou ação de embargos, caso em que o substituto processual figurará como impugnado ou embargado.

8. Sucessão no crédito por morte do credor original

Se, por ato entre vivos ou por morte do credor, o crédito for transferido, o novo titular habilita-

se a promover a execução ou cumprimento ou, caso já proposta a execução ou requerido o cumprimento, a dar-lhe seguimento. É a legitimação ativa superveniente, que se distingue da prevista no caput e no inc. I do § 1.º do art. 778 porque naquela, o legitimado ativo (ou, se for o caso, o substituído processual) figura como credor desde o momento da formação do título executivo (legitimação ativa primária) e nessa, a legitimação decorre de causa (ato ou fato) posterior a ela.

Ocorrendo a morte do credor originalmente nominado no título executivo, o crédito, como todos os demais bens do falecido, transfere-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários (CC, art. 1.784; CC/1916, art. 1.572). Opera-se, com o fato, mutação subjetiva na titularidade do patrimônio, sendo que “os herdeiros sub-rogam-se nas relações jurídicas do defunto; não somente no ativo patrimonial, como também no passivo, posto que limitado às forças da herança”.¹⁹

A partilha dos bens, com a individuação do que tocará a cada herdeiro, será procedida mediante inventário judicial (CPC, art. 610) ou extrajudicial, em sendo o caso. No interregno, enquanto não partilhados, os bens e obrigações do falecido constituirão um todo indiviso, denominado espólio, que, embora sem personalidade jurídica, pode, porque assim o autoriza a lei, figurar como parte em demandas judiciais. Representa o espólio, para esse efeito, o seu inventariante (CPC, art. 75, VII). Cabe ao espólio, portanto, promover ou dar seguimento à ação de execução fundada em títulos executivos extrajudiciais – ou requerer ou dar seguimento ao cumprimento de títulos judiciais – integrantes dos bens a serem partilhados.

Quando não houver testamento, nem herdeiros notoriamente conhecidos a herança é considerada jacente (CC, art. 1.819; CC/1916, art. 1.591). Os bens serão arrecadados e entregues à guarda e conservação de um curador nomeado pelo Juiz (CPC, arts. 738 e 739). Passado um ano sem que se habilite qualquer herdeiro, a herança jacente será declarada vacante (CC, art. 1.820; CC/1916, art. 1.593; CPC, art. 743, § 2.º), o mesmo ocorrendo quando todos os chamados a suceder apresentarem renúncia (CC, art. 1.823). Decorridos cinco anos da abertura da sucessão, os bens passarão ao domínio público (CC, art. 1.822; CC/1916, art. 1.594). A herança jacente e a vacante podem, como o espólio, atuar em juízo, sendo aí representadas por seu curador (CPC, art. 75, VI, e art. 739, § 1.º). Assim, embora não haja menção a respeito no art. 778 do CPC, é certo que estão legitimadas a promover a ação de execução ou requerer cumprimento de sentença com base em títulos executivos deixados pelo falecido.

Encerrado o inventário e partilhados os bens, extingue-se o espólio, cabendo ao herdeiro ou sucessor a quem tocar o crédito, promover ou dar seguimento à execução. A prova da sucessão no crédito específico, será o formal de partilha, expedido nos termos do art. 655 do CPC. Aqui, o formal é mero título de legitimação, e não título executivo. A força executiva do formal de partilha guarda as limitações estabelecidas pelo parágrafo único do art. 515, IV do CPC (“exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título universal ou singular”).

9. Legitimação ativa do cônjuge sobrevivente

Ao cônjuge sobrevivente é assegurada a condição de herdeiro, em concorrência com os descendentes do falecido (CC, art. 1.829, I)²⁰. Contudo, não se pode confundir sua situação de herdeiro com a de meeiro. A meação “é um efeito da comunhão, ao passo que o direito hereditário não depende do regime de bens. E a ela já tem o cônjuge direito em vida do outro, na vigência da sociedade conjugal, não lhe advindo, portanto, *sucessionis causa*”.²¹ O meeiro sobrevivente, nessa condição, não é sucessor do falecido. É, isto sim, titular da metade do crédito, como já o era antes da morte. Sendo assim, sua legitimação ativa para intentar ou prosseguir na execução tem base no art. 778, caput, do CPC e não se modifica com a morte do outro cônjuge. Modificação poderá ocorrer se, na partilha, o crédito, em sua totalidade, for destinado a herdeiro,²² hipótese em que a sucessão no crédito terá decorrida, no que se refere à parte do cônjuge supérstite, de ato entre vivos, com natureza de cessão.

10. Legitimação ativa do cessionário

Segundo prevê o Código Civil, o credor pode ceder o seu crédito a terceiro, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor (art. 286; CC/1916, art. 1.065). Se a cessão é de direito estampado em título executivo, judicial ou extrajudicial, habilita-se o cessionário a requerer o cumprimento ou promover a execução, apresentando, para tanto, o respectivo contrato ajustado com o cedente.

Caso a cessão tenha sido ajustada relativamente a título judicial ou depois de proposta a ação executiva, a sucessão na relação processual (do cedente pelo cessionário) não é obrigatória, mas facultativa.²³ Decidindo os interessados por não efetuar-lá, nenhuma alteração subjetiva ocorrerá no processo. Todavia, importante mutação se operará no que tange à natureza da legitimação: o cedente continuará como legitimado ativo na condição de substituto processual do cessionário, com as limitações daí decorrentes.²⁴

A cessão pode ter por objeto direitos hereditários, hipótese em que o cessionário assumirá, em relação a tais direitos, a mesma condição jurídica do herdeiro cedente,²⁵ de modo que, enquanto não ultimada a partilha, a legitimação ativa para a execução é do espólio e não do cessionário. Na partilha, o cessionário será contemplado com o quinhão que lhe couber em decorrência do contrato de cessão. Expedido o respectivo formal, passará a ter legitimidade ativa para propor ou prosseguir a execução dos créditos representados por títulos executivos integrantes da sua quota na partilha.

Conforme anotou Pontes de Miranda, comentando o antigo art. 567, II, do Código revogado (análogo ao atual art. 778, §1.º, III) “o Código emprega a palavra ‘cessionário’ em sentido amplíssimo”, para abarcar não apenas os casos de sucessão decorrente do ato entre vivos de cessão propriamente dita, mas também “por outro meio, como se houve arrematação da massa ou do crédito”.²⁶ Enquadra-se no dispositivo a hipótese de cessão de contrato, que não se confunde com a cessão de crédito. Na cessão de contrato opera-se a transferência, não apenas dos direitos, como também das obrigações do cedente. “A cessão do contrato” escreveu Silvio Rodrigues, “serve para tornar possível a circulação do contrato em sua integralidade, permitindo o ingresso na relação contratual, e em lugar de um dos contratantes originais, de um estranho que lhe assumira todos os direitos e deveres. É assim uma instituição mais completa que a cessão de crédito, porque, enquanto esta apenas permite a circulação do crédito, aquela permite o tráfico de toda a posição derivada do contrato, através de um único negócio jurídico”.²⁷ E observa, mais adiante: “Embora sem texto legal expresso, o instituto da cessão de contrato existe no direito pátrio como ato jurídico inominado, pois advém do princípio da autonomia negocial: desde que lícito o objeto, sendo as partes capazes e não recorrendo à forma vedada em lei, podem as partes convencionar o que bem entendem”.²⁸

11. Cessão quieta e cessão qualitativa

A cessão de crédito tem sido instrumento utilíssimo para atender às novas e sempre mais imprevisíveis necessidades impostas ao comércio jurídico pela vida moderna. A autonomia da vontade, que inspira e domina o sistema de direito privado, permite que se dê ao contrato de cessão contornos e finalidades peculiares, cujos reflexos no campo processual devem ser compreendidos e absorvidos adequadamente.

Assim, considerando que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (CC, art; 290; CC/1916, art. 1.069) e que só tem eficácia perante terceiro quando devidamente registrada no Registro de Títulos e Documentos (Lei 6.015, de 31.12.1973, art. 129, item 9),²⁹ nada impede que entre cedente e cessionário fique estabelecida cláusula excluindo tanto o registro, quanto a notificação. É modalidade de cessão que Pontes de Miranda denominou cessão quieta.³⁰ Nesta hipótese, embora se tenha operado eficazmente a transferência do crédito do cedente para o cessionário, a legitimação ativa para a execução continua sendo do cedente, pois para o devedor, seus sucessores e terceiros, o crédito continua no patrimônio do primitivo titular.

É igualmente possível e corriqueira a cessão de crédito como negócio fiduciário e, portanto, acoplado a outro negócio de natureza obrigacional, para o qual serve de garantia. Vistos os dois

negócios em conjunto, como necessariamente deve ocorrer, fica evidenciado o interesse do cedente no êxito da cobrança do crédito cedido, que, se fracassada, refletirá diretamente no seu próprio patrimônio. Modalidade semelhante é a da cessão com a cláusula de responsabilidade do cedente não apenas pela existência do crédito (CC, art. 295; CC/1916, art. 1.073), mas também pela solvência do devedor (cessão pro solvendo). Ao contrário do que ocorre na cessão pro soluto – em que a liberação do cedente em relação ao cessionário se dá imediatamente, independentemente do que daí em diante ocorrer com o crédito –, na cessão pro solvendo o cedente permanece vinculado até que ocorra, efetivamente, o pagamento por parte do devedor. Nestas, como em muitas outras situações semelhantes, é legítima a cláusula que reserve ao cedente a pretensão e a ação, permitindo que, em nome próprio, ele promova a ação de execução do crédito, cujo pagamento continua sendo de seu mais vivo interesse econômico e jurídico e pelo qual é corresponsável perante o cessionário. É, na denominação de Pontes de Miranda, cessão qualitativa.³¹

Pode parecer que as cessões quietas e as cessões qualitativas importam a criação, por contrato, de novas hipóteses de substituição processual, não previstas em lei e, conseqüentemente, vedadas pelo art. 18 do CPC. A objeção não procede. Na verdade, o que é importante considerar é a legitimidade do negócio jurídico em face do direito material, e esta resulta inquestionável em nosso sistema. É preciso ter presente, que, além do notório interesse próprio do cedente na cobrança dos créditos cedidos pro solvendo ou em garantia, sua vinculação à relação jurídica original, estabelecida com o devedor, não se desfaz inteiramente, nem naquelas como também em nenhuma outra hipótese de cessão. O cedente, em todos os casos, continua responsável pela existência do crédito ao tempo em que foi cedido (CC, art. 295; CC/1916, art. 1.073). Desse modo, refletirá contra ele, cedente, o êxito de eventuais defesas que o devedor opuser ao cessionário relativamente a fatos impeditivos (vício de forma ou de vontade, por exemplo), modificativos (moratória ou pagamento parcial, por exemplo) ou extintivos (pagamento, novação, compensação, por exemplo) do direito cedido.

A cessão do crédito não retira do devedor os direitos potestativos relacionados com a existência da obrigação (direitos de resolução ou de denúncia), que poderão ser invocados perante o cessionário, com eficácia reflexa na esfera jurídica do cedente. Perante o devedor, conseqüentemente, a cessão de crédito opera, simplesmente, o surgimento de mais um figurante (o cessionário) no polo ativo relação jurídica, sem, contudo, eliminar inteiramente do cenário jurídico o primitivo titular. Esta realidade provinda do direito material não é, nem pode ser, desconsiderada pelo processo. A tutela judicial do crédito e a sua cobrança pelo cedente, nas peculiares circunstâncias e hipóteses descritas, não deixa de se qualificar, portanto, como forma de defender também direito próprio, para os fins do art. 18 do Código.

O que se conclui, do exposto, é que, também nas cessões quietas ou qualitativas, a legitimação ativa do cedente, ordinária ou extraordinária, não decorre de contrato, mas da lei, ou, mais precisamente, do sistema de direito material. O fenômeno jurídico é idêntico ao de qualquer contrato de cessão firmado no curso do processo executivo: ele também transforma o cedente, que dá curso à ação, em substituto processual do cessionário, e ninguém se aventura a afirmar que a substituição processual, neste caso, é criada pelo contrato.

12. Legitimação ativa do sub-rogado

Na sub-rogação há transferência, do primitivo para o novo credor, de todos os direitos, ações, privilégios e garantias em relação à dívida, contra o devedor principal e seus fiadores (CC, art. 349). O sub-rogado assume o lugar do credor que foi satisfeito: “satisfaz-se o credor, sem que o devedor se libere. Outrem, em verdade, adimpliu, e não o devedor, que há de adimplir a quem adimpliu”.³²

A sub-rogação opera-se de pleno direito nas hipóteses previstas no art. 346 do Código Civil e em outras situações em que a lei assim determina. O Código de Processo Civil contempla hipótese de sub-rogação sem pagamento: a do exequente, “nos direitos do devedor até a concorrência do seu crédito” quando houve penhora em direito e ação do devedor (art. 857).

São espécies de sub-rogação legal as previstas no direito cambiário. O endossante que paga o

título sub-roga-se no direito do credor em relação aos endossantes anteriores, ao devedor e respectivos avalistas. O avalista que paga sub-roga-se nos direitos emergentes do título, seja em relação ao avalizado, seja em relação aos coobrigados. Se há coavalista simultâneo (não o sucessivo), o que honra o aval pode haver também do outro (ou dos outros) a respectiva cota. ³³

Pode dar-se sub-rogação também por negócio jurídico bilateral, nos casos previstos no art. 347 do Código Civil (CC/1916, art. 986). No inciso I desse artigo, o negócio é entre o terceiro, que efetua o pagamento, e o credor, que o recebe e transfere àquele todos os seus direitos, independentemente do consentimento ou da participação do devedor. Trata-se, na verdade, de cessão de crédito, a cujo regramento ficam os contratantes assujeitados (CC, art. 348; CC/1916, art. 987). No inc. II do art. 347, o negócio jurídico se estabelece entre o terceiro, que empresta a quantia para solver a dívida, e o devedor, operando-se a sub-rogação sem que se faça necessária a concordância do credor.

A sub-rogação convencional somente surtirá efeitos perante terceiros com o registro do respectivo instrumento no Registro de Títulos e Documentos (Lei 6.015/1973, art. 129, 9.º).

O sub-rogado, assumindo o lugar do credor na relação de direito material, habilita-se a promover ou a prosseguir a execução. A sub-rogação não tem, entretanto, qualquer eficácia novativa. Tirante a modificação subjetiva em seu polo ativo, a relação jurídica permanecerá exatamente a mesma para todos os demais efeitos.

13. Outras hipóteses de legitimação ativa

Não é exaustivo o rol dos legitimados previsto no art. 567 do CPC. Também se legitimam a promover a execução, embora sem personalidade jurídica própria, a massa falida, representada pelo síndico (Lei 7.661, de 21.06.1945, art. 63, XVI) e a massa do devedor civil insolvente, representada por seu administrador (Código de 1973, mantido no ponto, art. 766, III).

Por outro lado, o Código, que previu a sucessão do crédito por morte da pessoa natural (art. 778, § 1.º, II), não fez alusão às hipóteses de sucessão decorrente de morte da pessoa jurídica. Segundo dispõe o Código Civil, termina a existência da pessoa jurídica pela sua dissolução (CC, art. 51, CC/1916, art. 21). O eventual patrimônio remanescente, inclusive o representado por títulos executivos, será transferido a terceiro, cabendo a ele promover ou dar seguimento à execução, se for o caso.

No que se refere especificamente às sociedades, sua dissolução pode ser convencional ou por ato de império, segundo as causas previstas no art. 1.033 do Código Civil e, sendo empresária, também por falência (CC, art. 1.044). Nessas situações, dissolvida a sociedade, tem início a sua liquidação, destinada à apuração do ativo e pagamento dos credores e a partilha dos bens remanescentes, nos termos previstos nos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil. No interregno a sociedade ainda mantém a personalidade jurídica, acrescida, em sua denominação, a cláusula em liquidação (CC, art. 1.103, § único), sendo representada por liquidante (CC, art. 1.105). Ultimada esta fase, partilham-se os bens restantes (CC, art. 1.108), extinguindo-se, agora sim, a personalidade jurídica (CC, art. 1.109). Habilita-se o sucessor, daí em diante, a promover, ou a dar seguimento, à execução do título que lhe coube na partilha.

Em se tratando de sociedade anônima, as hipóteses de dissolução encontram-se elencadas no art. 206 da Lei 6.404/1976, sendo, de um modo geral, semelhantes às das demais sociedades comerciais. É expresso o art. 207 da referida Lei no sentido de que “a companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação”. Na fase liquidatória, pagos ou garantidos os credores, partilha-se o eventual ativo remanescente (art. 215, § 1.º), com o que, encerrada a liquidação e extinta a companhia (art. 219, I), há sucessão no crédito, operando-se, em consequência, a correspondente mudança do legitimado ativo na relação processual.

Há hipóteses em que a sociedade anônima se extingue sem passar pelas fases de dissolução e de liquidação. Isso ocorre quando há incorporação (“operação pela qual uma ou mais sociedades são

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” – art. 227 da Lei 6.404/1976), ou fusão (“operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações” – art. 228) ou, ainda, em caso de cisão com versão de todo o seu patrimônio (“A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver a versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão” – art. 229). Nesses casos extingue-se a companhia (art. 219, II), o que importa o fim definitivo da existência da sociedade, com extinção da sua personalidade jurídica, ³⁴ transferindo-se seus direitos e obrigações à sucessora, que fica legitimada a promover ou a dar seguimento às demandas executivas.

O Código Civil de 2002 disciplinou, para serem aplicados ao geral das sociedades, os institutos da incorporação, da fusão e da cisão, seguindo as linhas gerais adotadas pela Lei das Sociedades Anônimas (CC, arts. 1.113 a 1.122).

14. Desnecessidade de concordância

O parágrafo único do art. 778 deixa clara a opção do sistema processual brasileiro relativamente à legitimidade ativa para a execução: o exercício da sucessão em processos executivos ou fases de cumprimento de sentença independe de concordância ou anuência do executado. Trata-se, portanto, de regime diverso daquele relativo à alienação da coisa litigiosa (art. 109, § 1.º).

Art. 779. A execução pode ser movida contra:

I – o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II – o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III – o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV – o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V – o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI – o responsável tributário, assim definido em lei.

1. Parte passiva processual e parte legítima. A distinção entre parte processual e parte legítima, referida nos comentários ao art. 778, é de particular importância quando se trata de legitimação passiva na execução. À parte, com efeito, caberá opor-se à execução por meio de embargos do devedor (Título III, Livro II, da Parte Especial) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1.º), enquanto que os demais porventura atingidos por atos executivos, não sendo partes, defendem-se por embargos de terceiro (Parte Especial, Livro I, Título III, Capítulo VII). Ora, para se estabelecer a distinção entre parte e terceiro, o conceito a ser considerado é o de parte processual e não o de parte passiva legítima. Ou seja: é parte na execução, e como tal deve a ela opor-se pela via de embargos de devedor, aquela que, indicada pelo exequente, é citada e figura como executada na relação processual. Pouco importa, para essa finalidade, indagar-se da legitimidade. Quem, mesmo ilegitimamente, figurar como executado, é parte processual, devendo alegar sua ilegitimidade em impugnação (art. 525, § 1.º, II) ou embargos de devedor (art. 910, § 2.º), e não em embargos de terceiro. Por outro lado, quem não é parte processual, embora por lei devesse ter sido, utilizar-se-á de embargos de terceiro se, por eventualidade, vier a sofrer os efeitos de algum ato executivo.

O art. 779 do CPC/2015, ao indicar contra quem “a execução pode ser promovida”, está, na verdade, indicando quem deve ser, e não, necessariamente, quem é a parte passiva. Em outras palavras, o dispositivo refere-se à parte legítima e não à processual.

2. Legitimação passiva do devedor. Numa definição sintética, podemos afirmar que sujeito

passivo legítimo é aquele cujo patrimônio pode, por autorização da lei, ser submetido à execução. O Código, diferentemente do que fez ao tratar da legitimação ativa (art. 778, ao dividir entre caput e parágrafo), relaciona num mesmo artigo as várias situações de legitimação passiva primária e superveniente. O inc. I, ao indicar como sujeito passivo “o devedor”, presta obediência ao princípio geral da legitimação ordinária, segundo o qual as partes, na relação processual, devem em regra, ser as mesmas que figuram na relação de direito material. A referência a devedor “reconhecido como tal no título executivo” é para identificar aquele que, já nos primórdios da formação do título, detinha aquela condição. Distingue-se de outros que, também devedores, assumiram essa condição em decorrência de ato ou fato superveniente.

Enquadram-se no conceito de devedor, para os efeitos do inc. I, o avalista e o fiador convencional. É possível que alguém tenha sido avalista e fiador relativamente a um único negócio jurídico subjacente, caso em que a execução contra ele poderá fundar-se em mais de um título executivo. A hipótese está contemplada pela Súmula 27 do STJ: “Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio”. Assim, “o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato particular figurar como devedor solidário” (Súmula 27 do STJ).

É comum confundir-se fiança com aval, mas a jurisprudência tem sido tolerante com o erro: “resultando inequívoca a intenção das partes contratantes no sentido de que os rotulados ‘avalistas’ respondem solidariamente com o devedor principal pelos encargos assumidos no instrumento contratual, não se mostra admissível o excessivo apego ao formalismo para excluir a responsabilidade daquelas que, de forma iniludível e autonomamente, se obrigaram pelo pagamento da integralidade da dívida. A imprecisão técnica não pode servir de subterfúgio aos que desejam esquivar-se do cumprimento de compromissos livremente pactuados. Em casos tais, a expressão ‘avalista’, constante do título exequendo, deve ser tomada por coobrigado, codevedor ou garante solidário, a teor do que estabelece o art. 85 do Código Civil” (de 1916).³⁵

3. Espólio, herdeiros e sucessores. Assim como podem promover a execução, o espólio, os herdeiros e os sucessores do falecido estão igualmente sujeitos a suportá-la. Realmente, conforme observamos nos comentários ao artigo anterior, os herdeiros sub-rogam-se nas relações jurídicas patrimoniais do falecido, tanto na titularidade ativa (direitos subjetivos), quanto na passiva (obrigações), inclusive nas das fianças por ele prestadas, ainda que a obrigação afiançada tenha vencimento em data posterior à morte.³⁶

No interregno entre a morte e a ultimação da partilha, “o espólio responde pelas dívidas do falecido; mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção da parte que na herança lhe coube”. É o que estabelece o art. 796 do CPC/2015, dispositivo tipicamente de direito material, que repete o art. 1.997 do Código Civil (CC/1916, art. 1.796). Em compensação, é o Código Civil que dispõe sobre o ônus da prova quanto ao excesso, que caberá ao herdeiro, “salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados” (art. 1.792; CC/1916, art. 1.587).

Equiparam-se ao espólio a herança jacente e a herança vacante. E a pessoa de direito público a quem tocar os respectivos bens (CC, art. 1.822; CC/1916, art. 1.594) legitima-se passivamente na relação jurídica executiva de modo idêntico ao dos herdeiros, ou seja, com responsabilidade limitada ao valor do patrimônio recebido.

4. Extinção da pessoa jurídica. Várias são as causas determinantes da extinção das pessoas jurídicas, conforme anotamos nos comentários ao artigo anterior: por término de seu prazo, ou por deliberação de seus sócios, ou por ato de império, administrativo ou judicial. Em qualquer caso, e ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas – cuja morte acarreta a imediata transmissão de bens e obrigações aos herdeiros –, nas pessoas jurídicas a extinção da personalidade é antecedida por uma fase de liquidação, durante a qual o liquidante designado pelos sócios, ou, no caso de liquidação administrativa coativa, pela autoridade pública, tomará as providências necessárias a ultimar os negócios pendentes, apurar o ativo e promover a satisfação dos credores. Nessa fase, a sociedade ainda mantém sua personalidade jurídica, de modo que está legitimada a promover a execução ou a submeter-se à que lhe for proposta.³⁷

A liquidação tem finalidades semelhantes às do inventário por morte das pessoas físicas. Mas no inventário, há liquidação após a morte do primitivo titular dos bens e obrigações, os quais, conseqüentemente, já se acham transferidos à herança, enquanto, relativamente à pessoa jurídica, a fase liquidatória ocorre ainda em vida da sociedade. Enquanto pender obrigação, subsiste a personalidade jurídica.³⁸ Quando isso não ocorrer (ou seja, quando, por qualquer razão, for extinta a personalidade quando ainda pendente alguma obrigação), por ela responderão os sócios, ou acionistas, ou o liquidante, ou outros obrigados, inclusive, em certas situações, o denunciado à lide,³⁹ nos casos e nos termos previstos na lei civil (v.g., CC, art. 1.110; Lei 6.404, de 15.12.1976, art. 218).

Há casos em que a sociedade é extinta sem passar pela fase de liquidação. É o que ocorre quando há incorporação, fusão, ou cisão da sociedade com versão de todo o patrimônio da sociedade cindida (CC, arts. 1.116 a 1.122; Lei 6.404, de 15.12.1976, arts. 227 a 229). Sobre a sucessão nas dívidas e a correspondente legitimação passiva, trataremos a seguir.

5. Transmissão da dívida por ato entre vivos. A transmissão da dívida pode ocorrer também por ato entre vivos. Modalidade mais comum é a da assunção da dívida (CC, arts. 299.º a 303.º), que ocorre quando, por ato unilateral ou por contrato, alguém assume a dívida de outrem. A eficácia, perante o credor, dessa modalidade de novação subjetiva, depende de seu consentimento. Concordando o credor, é legítima e eficaz a substituição do devedor, mesmo que ele não consinta (CC, art. 362; CC/1916, art. 1.001).

Modalidade especial de transmissão de dívida ocorre nos casos de fusão, incorporação e de cisão de sociedades, já que não depende, necessariamente, de consulta ao credor. A matéria está regulada nos arts. 1.116 a 1.122 do CC e arts. 231 a 233 da Lei 6.404, de 15.12.1976. Em se tratando de credores por debêntures, o seu consentimento – que, em regra, dá-se por decisão colegiada, tomada em assembleia convocada com esse fim (art. 231) – poderá ser dispensado se lhes for assegurada a faculdade de resgatar suas debêntures no prazo de seis meses da data em que se tornar pública a ata em que se decidiu pela fusão, incorporação ou cisão da companhia (§ 1.º) Nessa hipótese, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem parcelas de seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate (§ 2.º).

Aos demais credores, não debenturistas, a lei dá tratamento diferenciado. A incorporação ou a fusão da sociedade, com a conseqüente extinção da primitiva devedora e a transmissão da dívida, dá-se independentemente de consentimento, reservada a eles, se prejudicados, a faculdade de “pleitear judicialmente a anulação da operação”, o que deverão fazer no prazo decadencial de 60 dias (art. 232). A consignação da importância devida “prejudicará a anulação pleiteada” (§ 1.º), e, sendo ilíquida a dívida, “a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação” (§ 2.º).

Dispensa-se igualmente o consentimento do credor na transmissão da dívida em decorrência da cisão da companhia. Se dela resultar a extinção da cindida, as sociedades que absorverem o seu patrimônio responderão solidariamente pelas respectivas obrigações. Se, com a cisão, subsistir a companhia cindida, tanto esta, quanto as que absorverem parcelas de seu patrimônio serão responsáveis solidárias pelas dívidas anteriores à cisão (art. 233). A solidariedade, nesses casos, ocorre mesmo em relação às obrigações que ficaram com a companhia cindida ou que foram assumidas por outra sociedade. À cláusula de limitação dessa garantia poderá opor-se qualquer credor relativamente ao seu crédito (parágrafo único).

6. O fiador judicial. Fiança é o ato ou o contrato pelo qual alguém, terceiro na relação obrigacional primitiva, obriga-se a atender a prestação do devedor, em caso de seu não cumprimento no prazo e no modo devidos. Trata-se, portanto, de garantia, necessariamente vinculada em caráter acessório a outra relação jurídica, da qual resulta a obrigação garantida. O Código de 1973 incluía como legitimado passivo da ação de execução o fiador judicial. No regime do novo código, o fiador legitimado passivamente é tão somente aquele que presta fiança convencional em negócio jurídico que sirva como título executivo extrajudicial.

7. Fiador convencional, fiador legal e abonador. No que se refere ao fiador convencional –

ou seja, ao que é fiador em virtude de contrato – há que se distinguir situações, segundo a natureza da obrigação afiançada. Com efeito, a fiança é espécie de caução, e quando prestada em garantia de obrigação líquida, certa e exigível, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, V,⁴⁰ qualificando-se o fiador como legitimado passivo primário, como devedor. Se, porém, a obrigação afiançada não estiver revestida dessas qualidades, ou seja, se a sua liquidez, certeza e exigibilidade depender de confirmação em processo de conhecimento, a legitimidade passiva do fiador no cumprimento de sentença terá por pressuposto sua participação na ação cognitiva em que se produzir o título executivo. Foi certamente a essa espécie de obrigação afiançada, e não à outra, que se referiu Pontes de Miranda quando afirmou que “o art. 568 exclui a execução da sentença contra o fiador que não seja judicial, pois só se refere ao fiador judicial. Afastou, na esteira das Ordenações Filipinas, Livro II, Título 92, pr. (fonte), e do Livro IV, Título 59, a litisconsorcialidade verdadeira do fiador na ação de execução se não foi litisconsorte na ação de condenação”.⁴¹ Idêntica doutrina constou em seu Tratado de Direito Privado,⁴² escrito na vigência do Código de Processo de 1939, e ali a distinção foi feita expressamente: “O credor tem contra o fiador a ação condenatória; ou, se a fiança é de dívida certa e líquida, ou de alguma dívida a que a lei conferiu executividade (CPC/1939, art. 298, que é exemplificativo), a ação executiva”.⁴³

Ao abonador, que nada mais é do que fiador do fiador,⁴⁴ são aplicáveis, de um modo geral, os princípios que regem a fiança convencional (CC/1916, art. 1.482), podendo, consequentemente, ser sujeito passivo da execução se sua garantia for de prestação líquida, certa e exigível. O mesmo vale para fiança prestada por imposição de lei (fiança legal), como, por exemplo, nos casos do art. 1.305, parágrafo único, do CC⁴⁵ e do art. 198 do CC⁴⁶.

8. Responsável titular do bem vinculado por garantia real. Aquele que oferece garantia real para assegurar a satisfação de obrigação de terceiro também é legitimado a responder à execução, se a atividade executiva puder interferir no bem dado em garantia. De modo a viabilizar o direito ao contraditório relativamente a eventual restrição em seu patrimônio, impõe-se a inclusão do garantidor no polo passivo da execução.

9. Responsável tributário. A execução judicial para cobrança de dívidas da Fazenda Pública tem disciplina específica na Lei 6.830, de 22.09.1980, que, em seu art. 4.º, aponta como um dos legitimados passivos “o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado” (inc. V), aplicando-se à dívida ativa, “as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial” (§ 2.º). Considera-se dívida ativa da Fazenda Pública qualquer valor cuja cobrança seja atribuída à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou às respectivas autarquias (art. 2.º, § 1.º). Pela lei especial, é sujeito passivo não apenas o responsável por obrigações de natureza tributária, mas também pelas de natureza não tributária.

No que se refere especificamente ao crédito tributário, o Código Tributário Nacional, que tem natureza de lei complementar, estabelece as condições a serem observadas pelo legislador ordinário na atribuição de responsabilidade. Fazendo distinção entre o contribuinte (definido como o sujeito passivo “quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” – art. 121, parágrafo único, I) e o responsável (“quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei” – inc. II), diz o Código Tributário Nacional que a responsabilidade pode ser atribuída “a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação” (art. 128).

Desde logo, o mesmo Código Tributário Nacional institui várias hipóteses de responsabilidade: a) a do adquirente, em relação a tributos incidentes sobre os bens adquiridos (arts. 130 e 131, I); b) a do espólio, do cônjuge meeiro e dos sucessores, relativamente aos tributos devidos pelo de cujus (art. 131, II e III); c) a do sucessor da pessoa jurídica, nos casos de fusão, transformação ou incorporação (art. 132), ou de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento (art. 133); d) a dos pais, tutores e curadores, relativamente aos tributos devidos pelos filhos menores, ou pelos tutelados e curatelados (art. 134, I e II); e) a dos administradores, do inventariante, do síndico e do

comissário, relativamente aos tributos devidos pelo administrado, pelo espólio ou pela massa falida ou pela concordatária (art. 134, III, IV e V); f) a dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício (art. 134, VI); g) a dos sócios, nos casos de liquidação da sociedade de pessoas (art. 134, VII) e a destes e dos administradores e dirigentes de pessoas jurídicas, nos casos de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei (art. 135).

Respondem solidariamente pelo pagamento da dívida ativa, tributária ou não, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados (Lei 6.830/1980, art. 4.º, § 1.º).⁴⁷

Os responsáveis pela dívida ativa, a exemplo do que ocorre com os fiadores (CPC/2015, art. 794), podem valer-se do benefício de ordem, nomeando à penhora bens livres e desembaraçados do devedor, ficando sujeitos à execução os seus próprios bens se aqueles forem insuficientes (Lei 6.830/1980, art. 4.º, § 3.º).

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

1. Cumulação de execuções. Cumular execuções significa promover, numa única relação processual, medidas executivas tendentes à satisfação coativa de duas ou mais prestações correspondentes a distintas obrigações. Tal cumulação – que é facultativa, e não obrigatória – tem em mira a economia processual e supõe a concorrência de três requisitos básicos: (a) serem as mesmas as partes, (b) ser o mesmo o juiz competente e (c) ser o mesmo o procedimento. A falta de qualquer destes requisitos impede que o credor exerça aquela faculdade, hipótese em que as execuções deverão ser promovidas em ações distintas, embora possivelmente simultâneas.

Não se confunde cumulação de execuções com litisconsórcio. Neste, há pluralidade de credores ou de devedores, mas unidade jurídica de obrigação; naquela, há pluralidade de obrigações e identidade de devedor. A cumulação de que trata o art. 780 é a objetiva, ou seja, a de dívidas diferentes de um mesmo devedor.

Também não se pode confundir cumulação de execução com pluralidade de títulos. É possível, com efeito, que a mesma dívida esteja representada por mais de um título, com um único ou mais de um devedor. É o caso, por exemplo, da obrigação de pagar quantia certa, decorrente de empréstimo bancário, representada por contrato de mútuo e por nota promissória. Segundo prevê a Súmula 27 do STJ, “pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio”. O que não se poderia, em tal caso, ainda segundo a jurisprudência daquela Corte, é incorrer em bis in idem, promovendo execuções distintas, que, embora fundadas em título próprio, objetivariam sempre a cobrança da mesma dívida.⁴⁸

2. Identidade de devedor e de credor. O primeiro requisito exigido pela lei para que a cumulação seja possível é ser o mesmo o devedor. Embora utilizando a palavra “devedor” no singular, certamente não há incompatibilidade entre cumulação e litisconsórcio passivo. Mesmo devedor não significa único devedor. Com efeito, pode ocorrer que haja várias dívidas, originadas de diferentes títulos, mas nos quais figuram como devedores as mesmas pessoas. Assim, por exemplo, quando os sócios da pessoa jurídica prestam aval ou fiança conjunta, para garantir mais de um contrato de financiamento. Há aqui mais de um devedor e mais de uma obrigação, mas nada impede que o credor promova a execução cumulada dos vários títulos. O que não se permite é a coligação de devedores, ou seja, que o credor cumule a execução de diferentes obrigações, cada qual com distintos devedores.

Não apenas o devedor há de ser o mesmo, como também o credor. Se o mesmo devedor é obrigado por títulos diversos, cada um deles com credor distinto, a cumulação é inviável. Haveria, na hipótese, litisconsórcio ativo caracterizado por coligação de credores, uma espécie de execução

coletiva assemelhada à execução contra devedor insolvente e que, fora do rito da insolvência civil, ensejaria balbúrdia no processo.

3. Mesmo juiz competente. A cumulação não é admitida se o juiz competente não for o mesmo. A regra vale tanto para o cumprimento de sentença quanto para a execução de título extrajudicial. Assim, em se tratando de títulos executivos judiciais oriundos de juízos diferentes não pode haver cumulação, salvo em hipóteses em que, havendo competências concorrentes (CPC, art. 516, parágrafo único), o credor optar por promover o cumprimento conjunto perante um mesmo juízo. É com essas reservas, portanto, que se há de compreender a doutrina que admite cumulação de execuções fundadas em diferentes títulos judiciais.

4. Mesma forma procedimental. Cada uma das diferentes configurações procedimentais estabelecidas pelo Código, ou, na linguagem do legislador, cada uma das “diversas espécies de execução” (Título II do Livro II da Parte Especial) e dos diversos procedimentos para o cumprimento das sentenças (Título II do Livro I da Parte Especial) está moldado à natureza peculiar da obrigação a ser executada coativamente. Os meios executivos são diferentes, adaptados à obtenção de um resultado específico. O princípio da adequação das formas, de observância compulsória na execução, impede que a parte possa dispor dos ritos estabelecidos. Essa a razão pela qual não é viável cumular execuções quando as obrigações a serem executadas, pela sua natureza díspar, exijam procedimentos diferentes, como, por exemplo, uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar quantia certa.

Essa limitação, aliás, se faz presente mesmo quando o título executivo seja formalmente um só. No exemplo mencionado, é possível que ambas as obrigações – a de fazer e a de pagar – estejam previstas no mesmo contrato. O princípio da indisponibilidade do rito impede a cumulação, cabendo ao credor, nesta situação, promover duas execuções ou dois requerimentos de cumprimento de sentença, que trilharão diferentes caminhos procedimentais. A circunstância de haver, formalmente, um único título, não é empecilho a que assim se proceda. Substancialmente, há, na mesma sentença ou no mesmo contrato, tantos títulos quantas forem as diferentes obrigações neles contidas.⁴⁹

5. Execução de prestações periódicas. No processo de conhecimento, as prestações periódicas que se vencerem no curso do processo consideram-se incluídas no pedido, de modo que, a respeito delas, deverá o juiz pronunciar-se na sentença (CPC/2015, art. 323). E na execução de título extrajudicial, será cabível procedimento assemelhado? Para Pontes de Miranda, sim. “Promovida a execução das prestações vencidas”, diz ele, “nada obsta a que, nos mesmos autos, se vá pedindo a execução das que se forem vencendo, mediante penhoras sucessivas. Somente cessa essa possibilidade com a terminação da relação processual”.⁵⁰ Dessa opinião não comunga Ulderico Pires dos Santos, ao fundamento de que o pressuposto da execução é a exigibilidade do título, de modo que não há “como admitir-se que nela possam ser incluídos títulos que ainda não estão vencidos e portanto não são exigíveis”.⁵¹

A razão maior da inviabilidade dessa cumulação, em nosso entender, está, não propriamente na inexigibilidade do título (cuja execução, afinal, seria superveniente, após o vencimento), mas na instabilidade a que estaria submetido o processo. A cada prestação que se vencesse, nova penhora haveria, e nova avaliação, e novos embargos. Ou seja, a economia processual, princípio norteador da cumulação de execuções, estaria, certamente, ferida de morte. O critério a ser seguido, portanto, há de ser o do art. 329 do Código: o pedido não pode ser modificado após a citação. As prestações periódicas posteriormente vencidas devem ser objeto de execução autônoma.

20

No regime do Código Civil de 1916 (art. 1.611), a condição de herdeiro somente era reconhecida ao cônjuge quando o falecido não tivesse deixado descendentes ou ascendentes.

38

Fran Martins. Curso de direito comercial. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 210.

39

Segundo o STJ, “a impossibilidade de ser executada sentença de procedência da ação de indenização contra a devedora, porque extinta a empresa, permite a execução diretamente contra a seguradora, que figurara no feito como denunciada à lide, onde assumira a posição de litisconsorte” (REsp 97.590, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, RSTJ 93/320).

40

Humberto Theodoro Júnior. Curso..., cit., vol. II, p. 762; Ovídio A. Baptista da Silva. Curso..., cit., vol. ii, p. 45; Araken de Assis. Manual..., cit., p. 222. Sérgio Shimura. Título executivo, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 324. Cândido Dinamarco, embora sustentando ser pacífico o entendimento de que “só o fiador judicial é parte legítima passiva à execução, não o convencional”, faz, todavia, a ressalva: “a menos, é claro, que este tenha sido parte vencida no processo condenatório ou haja prestado fiança em contrato que em si mesmo seja título executivo extrajudicial” (Execução civil, cit., p. 429, nota 158). Na jurisprudência do STJ, entende-se indispensável a presença do fiador no processo de conhecimento quando nele se constituiu o título executivo (judicial) (REsp 19.241, 3.^a Turma, Min. Dias Trindade, DJ de 01.09.1992, p. 8.046); todavia, considera-se “legítima a execução embasada em título consubstanciado em fiança, com liquidez demonstrada por perícia e validade decorrente da existência dos requisitos de que cuida o art. 585, II, do CPC” (REsp 46.404, 3.^a Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 29.08.1994, p. 22.197).

41

Pontes de Miranda. Comentários..., t. IX, p. 99.

42

Idem, t. XLIV, p. 167.

43

Idem, t. XLIV, p. 165.

44

10 Idem, t. XLIV, p. 157.

45

Silvio Rodrigues. Direito civil, cit., vol. III, p. 394.

46

Fran Martins. Contratos e obrigações comerciais. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 338.

47

A alienação de bens do falido, nestes casos, é ineficaz contra a Fazenda Pública, se desatendido o art. 31 da Lei 6.830/1980 (TRF, 4.^a Região, AC 91.04.01811, 2.^a Turma, Min. Juiz Teori Albino Zavascki, RTRF 4.^a Região 29/330).

48

Para evitar a nulidade da execução promovida em segundo lugar, admite-se a reunião das duas (REsp 34.195-8, 3.^a Turma, Min. Nilson Naves, RSTJ 66/301). Há, todavia, precedente em que se admitiu a curso paralelo de ambas, já que o perigo do bis in idem estava afastado porque na inicial o credor fizera “expressa ressalva no sentido de, em recebendo o débito num dos feitos, fará o anúncio no outro” (REsp 32.627-1, 4.^a Turma, Min. Barros Monteiro, RSTJ 56/274). No mesmo sentido: REsp 3.680, 4.^a Turma, Min. Athos Carneiro, DJ de 03.12.1990.

49

Amílcar de Castro. Comentários..., cit., p. 573.

50

Pontes de Miranda. Comentários..., cit., t. IX, p. 142.

51

Ulderico Pires dos Santos. O processo de execução na doutrina e na jurisprudência, cit., p. 35.

2

Cândido Dinamarco, Execução civil, cit., p. 431; Araken de Assis. Manual..., cit., p. 207; Alcides de Mendonça Lima, Comentários ao código de processo civil, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, vol. VI, p. 81; Humberto Theodoro Júnior, Curso..., cit., vol. II, p. 768.

3

Araken de Assis, Manual..., cit., p. 207; Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de processo civil comentado, São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 280.

4

Cândido Rangel Dinamarco, *Litisconsórcio*, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1994, p. 217.

5

Nesse sentido: Cândido Dinamarco, *Execução civil*, cit., p. 441; Araken de Assis, *Manual...*, cit., p. 229; Pontes de Miranda, *Comentários...*, cit., vol. II, p. 55; José da Silva Pacheco, *Tratado das execuções*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1976, vol. II, p. 369; Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, *Código de processo civil comentado*, cit., p. 808. Em sentido contrário, admitindo-a apenas se houver embargos à execução fundada em título extrajudicial: Alcides de Mendonça Lima, *Comentários...*, cit., p. 96; Vicente Greco Filho, *Direito processual civil brasileiro*, 9. ed., São Paulo: Saraiva, vol. 3, p. 19.

6

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, *Código de processo civil comentado*, cit., p. 808.

7

Araken de Assis, *Manual...*, cit., p. 208; Cândido Dinamarco, *Execução civil*, cit., p. 433; Humberto Theodoro Júnior, *Curso...*, cit., vol. II, p. 770.

8

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 1987, vol. IV, p. 81; José Alberto dos Reis, *Processo de execução*, 3. ed., Coimbra: coimbra editora, 1985, vol. I, p. 220; Alcides de Mendonça Lima, *Comentários...*, cit., p. 78; Dinamarco, *Execução civil*, cit., p. 360.

9

Donaldo Armelin, *Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro*, São Paulo: Ed. RT, 1979, p. 164. Na jurisprudência: STJ, REsp 36.293-8, 4. a Turma, Min. Barros Monteiro, RSTJ 63/385.

10

Na vigência da Lei 4.215, de 1966 (art. 99), o STJ tinha jurisprudência majoritária no sentido de reconhecer o direito autônomo do advogado (REsp 58.137-0, 3. a Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 09.12.1991, p. 18.025). Contra, entendendo que a execução, pelo advogado, dependia da existência de contrato escrito: REsp 2.165, 4. a Turma, Min. Bueno de Souza, DJ de 28.09.1992, p. 16.430.

11

Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, *Substituição processual*, São Paulo: Ed. RT, 1971, p. 93.

12

José Frederico Marques, *Manual...*, cit., vol. IV, p. 85; Moacyr Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, 9. ed., São Paulo: Saraiva, 1988, p. 238; Vicente Greco Filho, *Direito processual civil*

brasileiro, cit., vol. 3, p. 16.

13

Teori Albino Zavascki, O ministério público e a defesa de direitos individuais homogêneos, *Revista de Informação Legislativa*, 117/173; Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos, *Revista de Informação Legislativa*, 127/83. No mesmo sentido do texto: Cândido Dinamarco, *As três figuras da liquidação de sentença. Atualidades sobre liquidação de sentença*, obra coletiva, coordenadora Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 34.

14

Ada Pellegrini Grinover, *Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*, 2. ed., São Paulo: Forense Universitária, 1992, p. 553.

15

Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, *Substituição processual*, cit., p. 97.

16

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, cit., vol. XXV, p. 137.

17

Idem, p. 138.

18

Idem, p. 142.

19

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1993, vol. VI, p. 23.

21

Caio Mário Da Silva Pereira, *Instituições...*, cit., vol. VI, p. 98.

22

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários...*, cit., p. 106; Pontes de Miranda. *Comentários...*, cit., vol. IX, p. 90.

23

Amílcar de Castro, Comentários..., cit., p. 13.

24

Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 114.

25

Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 18.

26

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., vol. IX, p. 91.

27

Silvio Rodrigues, Direito civil, 19. ed., São Paulo: Saraiva, 1989, vol. II, p. 348.

28

Idem, p. 350.

29

“A cessão de crédito não inscrita no Registro de Títulos e Documentos, conquanto válida entre os contratantes, não é oponível a terceiros para excluir o crédito da constrição judicial” (STJ, REsp 19.661, 4. a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 08.06.1992, p. 8.623).

30

Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, cit., t. XXIII, p. 273.

31

Idem, ibidem.

32

Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, cit., t. XXIV, p. 283.

33

Nesse sentido: Dilson Dória, Curso de direito comercial, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 1991, vol. 2, p. 43 e 47 Na jurisprudência: STF, RE 92.674-7, 2. a Turma, Min. Décio Miranda, RT 567/246; RE 75.297-8, 2. a Turma, Min. Aldir Passarinho, RT 593/250.

34

Waldirio Bulgarelli, Manual das sociedades anônimas, 8. ed., São Paulo: Atlas, 1996, p. 325.

35

STJ, REsp 23.878, 4.ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 17.12.1992, p. 24.250.

36

STJ, REsp 19.113, 4.ª Turma, Min. Dias Trindade, DJ de 20.09.1993, p. 19.178.

37

Atento a isso, decidiu o STJ que “pendente de liquidação, a sociedade de economia mista segue titular dos direitos resultantes dos contratos de que participou, não podendo o Estado, que continua sendo apenas seu acionista, sub-rogar-se nas respectivas ações” (REsp 50.655, 2.ª Turma, Min. Ari Pargendler, DJ de 12.05.1997).

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO III. DA COMPETÊNCIA

Capítulo III. Da competência

Art. 781. A execução, fundada em título extrajudicial, será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I – a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ele sujeitos;

II – tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III – sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV – havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V – a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

1. Competência para a execução fundada em título extrajudicial. Na execução fundada em título executivo extrajudicial, a atividade jurisdicional executiva precede à cognitiva. A presunção da existência, liquidez e exigibilidade da prestação, que decorre da lei, permite ao credor o exercício imediato da pretensão à satisfação. A tutela de natureza cognitiva há de ser postulada pelo devedor, se for o caso, mediante embargos à execução. A conexidade sucessiva que pode ocorrer é, assim, de ordem inversa em relação à do art. 516, I e II: ela ocorrerá entre a ação de execução e a ação cognitiva de embargos.

É natural, portanto, que o legislador tenha estabelecido que a competência para a execução, nesses casos, obedecerá o regime comum previsto no Livro II da Parte Geral, como se de ação de conhecimento se tratasse, seja em relação à competência internacional (Título II), seja quanto à competência interna (Título III).

2. Competência internacional. Está sujeita à jurisdição brasileira e à competência dos órgãos estabelecida pela lei do País, a execução por título extrajudicial, nas seguintes hipóteses: (a) quando o executado, mesmo estrangeiro, tenha domicílio no Brasil, ou (b) quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. É o que dispõem os incs. I e II do art. 21 do CPC/2015. A hipótese do inc. III (quando “o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil”) diz respeito à ação de cognição, não tendo aplicação prática em relação a títulos extrajudiciais.¹ Estão, igualmente, sujeitas à jurisdição brasileira, (c) as execuções cuja prestação envolva ou cujos atos constitutivos incidam sobre bem imóvel situado no Brasil (art. 23, I).

Nas duas primeiras situações, (a) e (b), admite-se a jurisdição concorrente de país estrangeiro, muito embora isso não induza litispendência nem constitua obstáculo “a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhes são conexas” (art. 24 do CPC/2015). Na situação (c), todavia, a jurisdição brasileira não admite concorrência, estabelecida que é “com exclusão de qualquer outra” (CPC/2015, art. 23). É regra de preservação do princípio da soberania nacional sobre o seu território.

Em qualquer caso, os títulos executivos oriundos de país estrangeiro, somente terão eficácia executiva se satisfizerem aos requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicarem o Brasil como o lugar de pagamento da obrigação (CPC/2015, art. 784, § 3.º).

3. Competência funcional interna. No que se refere à competência interna, ressalta-se que a execução fundada em título extrajudicial será, sempre, da justiça comum de primeiro grau, federal ou estadual. Não se prevê hipótese de execução de tais títulos perante outros órgãos da justiça especializada da União (Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral), nem, originariamente, perante os tribunais.

Firma-se a competência da Justiça Federal nos casos previstos no art. 109 da CF/1988, sendo mais correntes as hipóteses do seu inc. I, ou seja, quando, na ação de execução, figurar como parte a União, suas autarquias ou empresa pública federal. A competência da Justiça dos Estados se dá por exclusão: não sendo da competência federal, a ação executiva deve ser proposta perante a justiça comum estadual.

A competência federal é funcional (“competência de jurisdição”) e, portanto, de natureza absoluta, improrrogável e sujeita a declaração de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (CF/1988, art. 64), que somente pode ser ampliada ou reduzida por emenda constitucional, contra ela não prevalecendo dispositivo legal hierarquicamente inferior. Assim, a ação anulatória do título, movida contra o credor e ente público federal, em curso na Justiça Federal, não importa competência desta para a ação de execução em que figurem como partes apenas pessoas de direito privado, já que “a competência prorrogável por conexão ou continência é somente a relativa”.² Igualmente, não poderá ser prorrogada por conexão a competência estadual para a ação de execução se, na Justiça Federal, correr ação indenizatória.³

É possível que, em decorrência de ato praticado em execução da competência da Justiça Estadual, haja embargos de terceiro promovidos pela União, ou por autarquia ou empresa pública federal. Considerando que a lei ordinária não pode reduzir ou ampliar competência prevista na Constituição, inaplicável será, ao caso, o art. 676 do CPC/2015, segundo o qual os embargos são da competência do juiz que ordenou a apreensão. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que compete à Justiça Federal processar e julgar não só os embargos de terceiro assim interpostos,⁴ como também a própria ação de execução.⁵ No Superior Tribunal de Justiça entende-se, igualmente, que, “tendo os embargos de terceiro natureza de ação, o interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, determina a competência *ratione personae*, que detém caráter absoluto e inderrogável, da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição”.⁶

4. Execução por carta, da Justiça Federal pela Justiça Estadual. É indelegável a competência da Justiça Federal para a Estadual, e vice-versa, salvo nos casos admitidos pela Constituição, como os do § 3.º do art. 109: o legislador ordinário pode atribuir competência federal a juiz estadual de comarca que não seja sede de vara federal. No que se refere ao processo de execução e ao cumprimento de sentença há delegação quando os atos executivos devam ser praticados em local que não seja sede de vara federal, permitindo-se a execução por carta precatória de juiz federal para juiz estadual. Nesse caso, investido o juiz estadual de jurisdição federal, seus atos estarão sujeitos a recurso para os Tribunais Regionais Federais, por força do que determina o § 4.º do art. 109 da CF/1988.⁷ Entendimento em sentido contrário (atribuindo aos tribunais estaduais a competência recursal nas mencionadas hipóteses), adotado em julgados do Superior Tribunal de Justiça,⁸ não se mostra compatível com o princípio da indelegabilidade da competência funcional, notadamente à de segundo grau. Não há, na Constituição, nem por exceção, hipótese de delegabilidade da função jurisdicional dos tribunais.

O mesmo princípio da indelegabilidade impõe, ainda, as seguintes consequências: na execução por carta expedida com base no art. 237, parágrafo único do CPC/2015 pela Justiça Federal para a Estadual, os embargos à execução serão sempre de competência do juízo deprecante, mesmo quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Inaplicável aqui, ante o comando constitucional superior, a regra de competência

estabelecida na parte final do art. 914, § 2.º do CPC/2015.⁹ Também serão da competência do juiz federal os embargos de terceiro, mesmo que a apreensão do bem tenha sido ordenada pelo juiz deprecado, não se aplicando ao caso, pela mesma razão acima apontada, a regra do art. 676 do CPC.¹⁰

5. Insolvência civil e concurso de credores. No que se refere à competência para a ação de execução contra devedor insolvente (art. 760 do CPC/1973, mantido no ponto) ela será sempre da Justiça Estadual, mesmo que figure como credor entidade federal. Justifica-se a afirmação não por se tratar de hipótese de execução coletiva universal, mas por ser causa decorrente da insolvência civil do devedor, que, para os efeitos do art. 109, I, da Constituição, é considerada “causa de falência”.¹¹

Da mesma forma, a intervenção de entidade federal em ação de execução em que não é parte, para, simplesmente, manifestar a preferência do seu crédito em concurso de credores (art. 908, caput, do CPC/2015) não compromete a competência da Justiça Estadual para decidir o incidente e prosseguir na causa. Era entendimento sedimentado, ainda à luz da Constituição de 1969, pelo Supremo Tribunal Federal¹² e pela Súmula 244 do Tribunal Federal de Recursos (“A intervenção da União, suas autarquias e empresas públicas em concurso de credores ou de preferência não desloca a competência para a Justiça Federal”), reafirmado, na vigência da atual Constituição, pelo Superior Tribunal de Justiça.¹³

6. Competência interna territorial. A enorme variedade de títulos executivos extrajudiciais dificulta o estabelecimento de uma diretriz que possa ser considerada universal sobre a competência de foro para a respectiva execução. É que, para a fixação da competência, há de se efetuar o cotejo do art. 781 com as regras previstas nos arts. 46.º a 56.º do CPC com as especificidades de cada um dos títulos executivos objeto da demanda. Com essa ressalva, pode-se afirmar que, no geral das vezes, determina-se a competência observando-se, em primeiro lugar, o foro de eleição, depois, o do lugar do pagamento (*forum destinatae solutionis*) e, finalmente, o do domicílio do devedor. Andava nesse sentido a doutrina predominante¹⁴ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,¹⁵ sob a égide do Código de 1973.

No que se refere especificamente a títulos de crédito, em que não há foro de eleição, a regra geral é que a competência para a execução é a do lugar do pagamento, foro esse competente também para as chamadas ações inversas, ou seja, as destinadas a anular o título (ações anulatórias) ou a liberar o devedor da obrigação (ações consignatórias).¹⁶ Não modifica a competência para a execução a circunstância de ter sido o título apontado para protesto em outra comarca, já que “o protesto traduz mera providência acauteladora de cunho administrativo, sem interferência nas questões a serem apresentadas ao juiz, para o fim da composição da lide”.¹⁷

Foge à regra, segundo entendimento predominante, a execução hipotecária, cuja competência é a do foro da situação da coisa (*forum rei sitae*). Sendo a hipoteca considerada direito real pelo inc. IX do art. 674 do CC, a competência para a execução submete-se ao preceituado no art. 47 do CPC/2015,¹⁸ podendo, no entanto, o credor, optar pelo foro de eleição.¹⁹ Importante anotar, todavia, a opinião contrária, sustentada em argumento de difícil contestação, por Cândido Dinamarco, que, embora reconhecendo que “sempre houve forte tendência doutrinária e jurisprudencial no sentido de considerar ‘ação real’ a do credor que vem a juízo pedir execução com fundamento em contrato hipotecário”, considera isso “resultado de um errado e tradicional desvio de perspectiva”.²⁰ Segundo ele, “a ação executiva hipotecária não é ação real sobre imóvel, porque ela não traz pedido destinado à obtenção do imóvel hipotecado, nem é real o direito do credor sobre o dinheiro que vem pedir”, de modo que, para efeito de competência, “prevalecerá, como nas execuções por título extrajudicial é corriqueiro, o foro do lugar para cumprir a obrigação (art. 53, III, d) ou, à falta de convenção a respeito, o foro pessoal (art. 46)”.²¹ Em abono dessa tese há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.²² Mesmo assim, é reconhecidamente majoritária a tese em outro sentido, que busca sustento na interpretação literal do art. 674, IX, do CC e do art. 47 do CPC/2015.

7. Competências concorrentes na execução de título extrajudicial. O Código de 2015 inova

ao instituir, para as execuções de títulos extrajudiciais, situações de competências concorrentes, autorizando a opção pelo foro que torne a execução mais econômica ou mais acessível para o exequente. Trata-se de competência relativa e, portanto, derogável por vontade das partes. Os incs. I a V do art. 781 arrolam hipóteses em que, por conveniência do exequente e com vistas a tornar a execução potencialmente mais frutífera, poderá haver a propositura da ação executiva no foro de domicílio do executado, no foro de eleição ou no da situação dos bens a ela sujeitos (inc. I), disposição similar àquela da competência para o cumprimento de sentença. Na existência de mais de um domicílio do executado, poderá o exequente escolher entre eles (inc. II), e na incerteza ou desconhecimento do domicílio do executado, poderá o exequente escolher entre o lugar em que aquele for encontrado ou o seu próprio domicílio (inc. III). Na pluralidade de executados (litisconsórcio passivo na ação de execução), cabe ao exequente escolher entre o foro de domicílio de um deles (inc. IV). Por fim, mesmo que ocorra mudança de domicílio do executado, poderá a execução ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem ao título, de modo a facilitar o acesso à justiça para o exequente (inc. V). Ressalte-se que a opção por um dos foros concorrentes insere-se no âmbito da discricionariedade do exequente, razão pela qual é ato que, neste aspecto, fica imune a controle jurisdicional. Todavia, há na doutrina quem sustente a possibilidade de controle desse tipo de escolha (a que se denominou, fora do Brasil, *forum shopping*) a partir de critérios de adequação (a doutrina do chamado *forum non conveniens*).²³

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 1.º – O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana;

§ 2.º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.

§ 3.º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4.º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5.º O disposto nos §§ 3.º e 4.º aplica-se à execução definitiva de título judicial.

1. Atos executivos. A execução forçada busca a atuação da vontade sancionatória da norma jurídica, o que faz mediante providências práticas destinadas a adequar a realidade fática ao enunciado endonormativo. Com efeito, a norma jurídica está estruturada à base de dois enunciados: o da endonorma, que dispõe sobre a conduta (prestação, dever jurídico) a ser observada; e o da perinorma, que estabelece a sanção (consequência jurídica) a ser aplicada pelo Estado em caso de inobservância daquela conduta. Sempre que esta sanção consistir em providências materiais, práticas, concretas, de modificação da realidade, sua imposição ocorre mediante processo de execução forçada. Ao conjunto dessas providências estatais dá-se o nome de atos executivos.

O caráter instrumental dos atos executivos faz com que eles sejam de conteúdo variado, adequado à natureza da sanção jurídica que se busca cumprir. Há situações em que o Estado promove diretamente as medidas práticas, independentemente da colaboração ou da vontade do executado. São atos executivos consistentes em invasão direta do patrimônio do executado, para de lá retirar o bem a ser entregue ao credor (a busca e apreensão, na execução de obrigação de dar), ou para lá arrecadar um bem a ser alienado a fim de satisfazer o pagamento devido (a penhora na execução de obrigação de pagar quantia certa), e assim por diante. A essa espécie de providências costuma-se denominar atos executivos de sub-rogação. Em todos esses casos, de invasão direta do patrimônio do devedor, verifica-se nitidamente o caráter substitutivo da função jurisdicional executiva: o Estado assume, de modo forçado, a atividade que deveria ser cumprida

espontaneamente pelo devedor, e o faz independentemente ou mesmo contra a vontade deste.

Há, por outro lado, atos executivos consistentes em medidas de pressão sobre a vontade do devedor, com o objetivo de forçá-lo a atender, ele próprio, a prestação devida e não cumprida espontaneamente. Pertence a esta espécie a imposição de multa (art. 814 do CPC/2015) e a prisão civil (art. 528 do CPC/2015). São os chamados meios executivos de coação.

Preocupado em buscar “a efetivação da tutela específica” ou “a obtenção do resultado prático equivalente”, o legislador ampliou os poderes do juiz no domínio dos atos executivos para cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, facultando-lhe uma espécie de poder executório genérico, que lhe permite determinar, além dos atos discriminados especificamente na regra de procedimento, qualquer outra medida, desde que legítima, necessária e adequada àquela finalidade, tais como “imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva” (CPC/2015, art. 536, § 1.º).

A essa gama de poderes, somam-se, ademais, os de que está investido o juiz investido por força do art. 139 do CPC/2015, que lhe faculta inclusive a utilização de diferentes meios para concretizar as suas ordens (inc. IV), mesmo em se tratando de tutela de prestações pecuniárias.

2. Princípio do monopólio estatal da execução forçada. Ao estabelecer que os atos executivos serão determinados por juiz e cumpridos por oficiais de justiça, o legislador deixa plasmado o princípio de que a execução forçada é ato de Estado, submetido ao poder de seu imperium monopolizado. Descarta-se a execução privada, seja por mão própria do credor, seja por obra de terceiro. Mesmo em casos, como os da execução de obrigação de fazer fungível, em que há designação de terceiro para realizar a prestação (CPC/2015, art. 817), esta é ato que se realiza sob estrito comando e controle estatal.

O cunho oficial dos atos executivos traz consequências práticas importantes. Por serem atos estatais, públicos, de imperium, eles têm caráter vinculativo não apenas em relação às partes, mas também em face de terceiros. A esse propósito, referindo-se à eficácia natural da sentença em face de terceiros, decorrente da circunstância de se tratar de ato emanado de agente público, escreveu Liebman: “a sentença, como ato autoritativo ditado por um órgão do Estado, reivindica naturalmente, perante todos, seu ofício de formular qual seja o comando concreto da lei ou, mais genericamente, a vontade do Estado para um caso determinado. As partes, como sujeitos da relação processual a que se refere a decisão, são certamente as primeiras que sofrem a sua eficácia, mas não há motivo que exima os terceiros de sofrê-la igualmente. Uma vez que o juiz é o órgão ao qual atribui o Estado o mister de fazer atuar a vontade da lei no caso concreto, apresenta-se a sua sentença como eficaz exercício dessa função perante todo o ordenamento jurídico e todos os sujeitos que nele operam. Certamente, muitos terceiros permanecem indiferentes em face da sentença que decidiu somente a relação jurídica que em caso concreto foi submetida a exame do juiz; mas todos, sem distinção, se encontram potencialmente em pé de igualdade de sujeição a respeito dos efeitos da sentença, efeitos que se produzirão efetivamente para todos aqueles cuja posição jurídica tenha qualquer conexão com o objeto do processo, porque para todos contém a decisão a atuação da vontade da lei no caso concreto. O juiz, que na plenitude de seus poderes e com todas as garantias outorgadas pela lei, cumpre sua função, declarando, resolvendo ou modificando uma relação jurídica, exerce essa atividade (e não é possível pensar diversamente) para um escopo que outra coisa não é senão a rigorosa e imparcial aplicação e atuação da lei; e não se compreenderia como esse resultado todo objetivo e de interesse geral pudesse ser válido e eficaz só para determinados destinatários e limitado a eles”.²⁴

Parafraseando Liebman, podemos afirmar que também os atos executivos, como a sentença, constituem atividade pública destinada a garantir e efetivar a observância da lei, “e já que a esta estão todos sujeitos indistintamente, devem todos, por igual, sujeitar-se ao ato que é pelo ordenamento jurídico destinado a valer como sua aplicação imparcial”;²⁵ e que, como a da sentença, a eficácia geral dos atos executivos “decorre tão singela e naturalmente do caráter público e universalmente reconhecido à administração da justiça, que não há necessidade de nenhuma norma especial que expressamente a sancione”.²⁶ Isso explica porque terceiros, alheios à relação processual e aos interesses em conflito, podem eventualmente ser submetidos a cumprir

atos de execução, como, por exemplo, nos casos de penhora de crédito, em que o devedor do executado fica obrigado a entregar ao juiz, e não ao seu credor, a prestação devida (CPC/2015, arts. 855, I, e 856, § 2.º), ou nos casos de execução de prestação alimentícia, em que o empregador do devedor fica obrigado a promover o desconto em folha de pagamento da quantia devida, entregando-a a quem determinar o juiz (CPC/2015, arts. 529 e 912). O caráter cogente destas imposições, cuja recusa de cumprimento pode inclusive acarretar sanções penais (CPC, art. 846, § 2.º e CP, arts. 329 e 330), tem sua matriz legitimadora no fundamento de que o poder de imperium é exercido para dar efetividade aos preceitos normativos, de modo a fazer cumprir a autoridade da lei, pressupostos indispensáveis à sobrevivência da sociedade organizada.

A oficialidade da execução explica também a natureza de certos atos executivos, que, como observou Cândido Dinamarco, não podem ser enquadrados “nos esquemas do direito privado”. Assim, “sendo pública a atividade do juiz no processo executivo (exercício do poder estatal), em decorrência disso seus atos são de direito público e derivam do próprio poder do Estado. Ele não vende o bem penhorado ao arrematante, nem representando o devedor, nem em nome do credor, nem ainda como titular (por expropriação) da faculdade de disposição. Como hoje quase pacificamente se entende, a alienação em hasta pública é ato tipicamente jurisdicional, de expropriação, realizado unilateralmente pelo Estado no exercício do seu jus imperii. É inadequada a denominação do instituto usufruto de imóvel ou empresa (conforme constava do CPC/1973, arts. 716 e ss.), destinada a uma forma de realização imperativa de recursos a serem expropriados para a satisfação do direito do exequente. Não se trata do instituto de direito privado, mas de mecanismo de direito público”.²⁷ Acerta, portanto, o legislador ao modificar para “penhora de frutos e rendimentos da coisa móvel ou imóvel” (art. 867 e ss.) o título da subseção correspondente no Código de 2015.

O agente estatal que, em regra, cumpre os atos executivos é o oficial de justiça. Há, todavia, participação eventual de outros agentes ou auxiliares da justiça, como o escrivão, o avaliador, o porteiro, o leiloeiro, o depositário, que, no exercício de munus público, concorrem, com atribuições específicas, para alcançar os fins a que se propõe a execução.

3. Natureza jurisdicional da execução. O art. 782 do CPC/2015, ao dispor que os atos executivos são determinados por um juiz, evidencia a natureza jurisdicional da função executiva. Foi-se o tempo em que se pensava que a função do juiz se resumia em proferir sentenças “dizendo o direito”, cabendo ao próprio interessado, ou a outros órgãos estatais, ou mesmo ao juiz, mas em função administrativa, promover-lhe a execução. Ninguém mais se aventura a negar, seriamente, que a execução tem natureza idêntica à da cognição, complementando-se uma à outra e formando ambas um conjunto único, que, não raro, são mesmo desenvolvidas em uma única relação processual. Como disse Carnelutti, revisando suas próprias convicções iniciais (segundo as quais a execução situava-se fora do campo da jurisdição),²⁸ “também o processo executivo serve para compor a lide, em sua forma mais grave (lide de pretensão não satisfeita)”.²⁹ Se o processo de execução representa um prosseguimento necessário do processo cognitivo, já que “a composição da lide exige a conversão do dever ser em ser”, o que se faz pela via da execução, como não haveriam de ter, ambos, “a mesma natureza?”, pergunta Carnelutti. Daí a conclusão, hoje incontestada, de que “também o processo executivo responde ao conceito de cumprimento da lei; confirma-se assim a fundamental unidade entre a cognição e a execução”.³⁰

4. Resistência à satisfação e resistência aos atos de execução. As funções jurisdicionais executivas são desencadeadas quando não há, por parte do devedor, o cumprimento espontâneo de obrigação de dar (entregar coisa), ou de fazer, ou de não fazer, ou de pagar quantia certa. O Estado-juiz, nestes casos, invade a esfera patrimonial do executado, substituindo-se a ele no atendimento ao direito subjetivo do credor. Cabe ao Estado-juiz, portanto, “efetivar a execução”.

Ora, há que se distinguir (a) a resistência do devedor em cumprir espontaneamente a obrigação que assumiu perante o credor e (b) a resistência que o devedor (ou o terceiro) opõe às ações do Estado destinadas a prestar a tutela executiva. No primeiro caso (a) a resistência configura atentado ao direito subjetivo particular do credor, não sendo cabível o emprego de coação pessoal de qualquer natureza (salvo nas excepcionais hipóteses do inadimplemento voluntário ou

inescusável de obrigação alimentícia, de que trata o art. 5.º, inc. LXVII da CF/1988)³¹ para obrigar o resistente a satisfazer a prestação. Isso comprometeria o princípio da patrimonialidade, segundo o qual a execução forçada recai sobre os bens e não sobre a pessoa.

Todavia, se é certo que o Estado não pode impor medidas de coação pessoal contra o devedor para forçá-lo a prestar o que deve, também é certo que, nem ao devedor e nem a terceiro, é lícito opor-se à função jurisdicional executiva, obstruindo ou impedindo que o Estado-juíz faça atuar a vontade sancionatória da lei. Essa espécie de resistência (b) é mais grave que a primeira (a), pois configura ato atentatório à própria dignidade da justiça (art. 600, III, do CPC/2015) e, eventualmente, crime contra a administração pública (arts. 329 e 330 do CP).

Havendo resistência da segunda espécie (b) e se assim for necessário para impor o cumprimento de suas decisões, ou, em outras palavras, para “efetivar a execução”, deve o juiz valer-se da força policial.

5. Requisição de força policial. O Poder Judiciário é um poder desarmado, de modo que, quando a autoridade de seus atos ou o cumprimento de sua missão constitucional estiverem ameaçados, deverá valer-se da força policial que atua subordinada ao Poder Executivo. A faculdade de requisitá-la para efetivar atos de execução está prevista, não só no art. 782, § 2.º, mas também no art. 846, § 2.º, que trata especificamente da efetivação da penhora, e no § 1.º do art. 536, referente aos meios executivos de que dispõe o juiz para fazer cumprir obrigação de fazer e de não fazer. O Código já a previra igualmente no art. 360, III, ao tratar do exercício do poder de polícia atribuído ao juiz.

Em todas estas situações, a lei prevê (a) uso de força policial, (b) mediante requisição, (c) por juiz, (d) quando necessário.

A expressão força policial deve ser entendida em sentido amplo, para abranger não apenas os órgãos policiais propriamente ditos (polícias estaduais e polícia federal) como também as Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). Qualquer delas pode ser requisitada quando sua intervenção for indispensável para garantir a autoridade do Poder Judiciário e o cumprimento de suas determinações, o que, em última análise, nada mais significa senão a garantia da ordem jurídica. Pense-se, por exemplo, na hipótese, que não é inédita em nosso país, da resistência da própria entidade policial a atos do Judiciário. A intervenção das Forças Armadas em casos dessa natureza está perfeitamente adequada à sua missão constitucional, destinada “à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem” (art. 142 da CF/1988).

A força pública será requisitada, diz a lei. Com efeito, os órgãos policiais e as forças armadas atuam sob o comando do Poder Executivo, a quem será dirigido o ofício requisitório. Requisitar não é sinônimo de requerer. O requerimento poderá ser atendido ou não, a juízo do órgão a quem é dirigido, que o avaliará. A requisição, ao contrário, deve ser atendida compulsoriamente. Ela é irrecusável por parte do órgão destinatário. O desatendimento de requisição de força pública necessária ao cumprimento de ordem judicial configura caso de intervenção da União no Estado-membro ou no Distrito Federal (art. 34, IV e VI, da CF/1988)³² e, em relação ao chefe do Poder Executivo, crime de responsabilidade (art. 85, VII, da CF/1988). Conforme anotou Cretella Júnior, referindo-se ao inc. IV do art. 36 da Constituição, “‘ordem judiciária’ é determinação dada pelo magistrado, nos autos, no decorrer da demanda. Não pode ser desobedecida. Nesse sentido, a autoridade competente do Estado-membro e, em último grau, o Governador, deve providenciar força militar estadual suficiente para traduzir, em fatos concretos, a ordem do juiz, o que, se não ocorrer, ensejará a intervenção federal no Estado por inércia do Executivo, no prover a ordem judiciária”.³³

A faculdade de requisitar força pública é do juiz, assim entendido o órgão do Poder Judiciário sob cujo comando se processa a execução (juiz de primeiro grau, estadual ou federal, juiz de tribunal ou ministro de tribunal superior) e independe de requerimento do exequente.³⁴

Em regra, os atos de execução ordenados pelo juiz são cumpridos por oficial de justiça (art. 782 do CPC/2015). A força pública somente será requisitada quando necessário, diz a lei. A avaliação da

necessidade ou não cabe ao juiz e não às autoridades policiais ou ao Poder Executivo. Caberá igualmente ao juiz decidir sobre o momento e a forma de atuação da força policial, bem assim, se for o caso, sobre a suspensão de seu uso. Moderação, prudência, sensibilidade para os problemas sociais, são virtudes que devem nortear as decisões do juiz em situações desta natureza, notadamente quando o cumprimento de suas decisões puder comprometer o sentimento das pessoas (por exemplo, busca e apreensão de menor, quando a sua guarda passou de um para outro dos seus pais) ou suas condições básicas de vida ou de saúde (por exemplo, em casos de despejo ou de desapossamento). É certo que o Estado de Direito impõe o cumprimento das normas legais, cumprindo ao juiz atuar, com firmeza, para que isso ocorra. Não é menos certo, todavia, que ao juiz cabe o papel de mediador dos conflitos sociais, papel esse cada vez mais importante no teatro da vida contemporânea.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Cândido Dinamarco. Execução civil, cit., p. 217.

2

STJ, CC 6.547, 2.^a Seção, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ 60/67; CC 14.460, 2.^a Seção, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.03.1996; CC 15.059, 2.^a Seção, Min. Barros Monteiro, DJ de 15.04.1996.

3

STJ CC 13.624, 2.^a Seção, Min. Nilson Naves, DJ de 18.09.1995.

4

RE 88.688, 2.^a Turma, Min. Moreira Alves, RTJ 98/217; RE 104.472, 2.^a Turma, Min. Djaci Falcão, RTJ 113/1.380. No mesmo sentido era a jurisprudência do TFR: AC 94.795, 6.^a Turma, Min. Américo Luz, RTFR 119/225.

5

STF, Conflito de Jurisdição 6.390, Pleno, Min. Néri da Silveira, RTJ 106/946.

6

STJ, CC 2363, 2.^a Seção, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 08.06.1992, p. 8.597. No mesmo sentido: CC 6609, 2.^a Seção, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 21.03.1994, p. 5.430; CC 751, 2.^a Seção, Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 04.12.1989, p. 17.877.

7

Nesse sentido: TRF, 4.^a Região, AI 96.04.07635, 5.^a Turma, Min. Juiz Teori Albino Zavascki, DJ de 26.06.1996, em cuja ementa constou que “o artigo 1.213, do CPC, atribui à Justiça Estadual o cumprimento de cartas

precatórias, expedidas pela Justiça Federal, que devam ser cumpridas ‘nas comarcas do interior’, ou seja, nas comarcas que não sejam sede de vara federal. Trata-se de hipótese de competência delegada, prevista no art. 109, § 3.º, da Constituição, de modo que, das decisões prolatadas pelo juízo deprecado, ‘o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau’ (§ 4.º do art. 109 da CF)”.

8

STJ, CC 12.466, 1.ª Seção, Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 05.06.1995, p. 16.609, em cuja ementa se lê que “o cumprimento de precatória expedida pela Justiça Federal, por si, não investe o Juiz Estadual de competência delegada (art. 109, I, CF) Os simples atos procedimentais e as decisões versando a fixação de honorários de perito, vícios ou defeitos de penhora e quanto à avaliação de bens, são decisões da competência do Juiz de Direito deprecado, com apreciação recursal pela Corte Estadual”.

9

Nesse sentido, ainda no regime da Constituição de 1969 (semelhante, no ponto, ao regime atual), a jurisprudência do STF segundo a qual “sendo a autora empresa pública federal e competente para o feito a justiça federal, nos termos do art, 125, I, da Constituição, é incabível a reserva de competência ao juízo deprecado, por carta, para julgar os embargos à penhora, perante ele opostos, quando não seja órgão da justiça federal” (RE 99258, 1.ª Turma, Min. Rafael Mayer, DJ de 17.06.1983, p. 8.963). No mesmo sentido, agora, a jurisprudência do STJ: “A competência para julgar os embargos de devedor opostos à execução promovida pela CEF, contra penhora efetivada através de carta precatória, é do juízo federal deprecante” (CC 10391, 2.ª Seção, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 27.03.1995, p. 7.116).

10

STJ, CC 6.609-3, 2.ª Seção, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 21.03.1994, p. 5.430; CC 17.713, 2.ª Seção, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 16.06.1997. No STF, na vigência da Constituição de 1969, a jurisprudência também afirmava: “Não pode a legislação ordinária (art. 1.049 do CPC) criar exceção a princípio constitucional – como o é o inc. I do art. 125 da Emenda Constitucional 1/69 –, que diz respeito à denominada competência de jurisdição (que é absoluta), e que só não se aplica aos casos nele expressamente excepcionados” (RE 88.688, 2.ª Turma, Min. Moreira Alves, RTJ 96/217).

11

Cândido Dinamarco. Execução civil, cit., p. 232.

12

Conflito de Jurisdição 6.078, Pleno, Min. Cunha Peixoto, RTJ 84/389; Conflito de Jurisdição 6.236, Pleno, Min. Cunha Peixoto, RTJ 101/102; Conflito de Jurisdição 6.484, Pleno, Min. Décio Miranda, DJ de 14.09.1984, p. 14.914; Conflito de Jurisdição 6.324, Pleno, Min. Cunha Peixoto, RTJ 104/513; CC 6.602, Pleno, Min. Aldir Passarinho, DJ de 05.09.1986, p. 15.831, RTJ 119/609.

13

CC 1246, 2.^a Seção, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 08.04.1991, p. 3.863; CC 2.295, 2.^a Seção, Min. Athos Carneiro, DJ de 24.02.1992, p. 1.851; CC 4.674, 2.^a Seção, Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 14.06.1993, p. 1.762; CC 4.722, 2.^a Seção, Min. Fontes de Alencar, DJ de 21.02.1994, p. 2.085; CC 15.543, 1.^a Seção, Min. Peçanha Martins, DJ de 20.05.1996, p. 59.455.

14

Humberto Theodoro Júnior. Curso..., cit., vol. II, p. 781; Cândido Dinamarco. Execução civil, cit., p. 219; Araken de Assis. Manual..., cit., p. 178.

15

STJ, CC 4.404-1/PR, 2.^a Seção, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20.09.1993, p. 19.132.

16

É o que também ficou decidido no CC 4.404, referido na nota anterior, em cuja ementa constou que “o foro do lugar do pagamento é também competente para as ações inversas à pretensão executiva do título (v.g. consignatória e anulatória)”. No mesmo sentido, TACSP, AI 506.740, Juiz Raphael Salvador, JTACSP-LEX 138/28.

17

TJESP, AI 5.853-0, Câmara Especial, Des. Rezende Junqueira, RJTJESP-LEX 103/267.

18

Araken de Assis. Manual..., cit., p. 178.

19

Humberto Theodoro Júnior. Curso..., cit., vol. II, p. 840; Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery. Código de processo civil comentado, cit., p. 406.

20

Cândido Dinamarco. Execução civil, cit., p. 224.

21

Idem, p. 227.

22

RE 77591, 1.^a Turma, Min. Rodrigues Alckmin, RTJ 69/877, cuja ementa é a seguinte: “Competência. Ação executiva hipotecária. Foro contratual. Pretendida competência do foro da situação do bem dado em

garantia. Improcedência. Ação para cobrança de dívida, ainda que garantida por hipoteca, não é ‘ação relativa a imóvel’. A res in iudicio deducta se refere ao pagamento exigido. O bem (ou os bens) dados em garantia não constituem matéria da lide – serão penhoráveis, se não paga a dívida, como qualquer imóvel de réus devedores situados em qualquer comarca, sem que isso desloque a competência de foro. Recurso extraordinário conhecido e não provido”.

23

Sobre o tema, ver Braga, Paula Sarno. Competência Adequada. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, vol. 38, n. 219, maio 2013, p. 13-42.

24

Enrico Tullio Liebman. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 123.

25

Idem, p. 125.

26

Idem, p. 126.

27

Cândido Dinamarco. Execução civil, cit., p. 195.

28

Francesco Carnelutti. Sistema de derecho procesal civil. Trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Uteha Argentina, vol. I, p. 156.

29

Francesco Carnelutti. Derecho y proceso, cit., vol. I, p. 328.

30

Idem, p. 329.

31

Nos termos da Súmula Vinculante 25 do STF, “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

STJ, Intervenção Federal 01, Corte Especial, Min. José Cândido de Carvalho Filho, RSTJ 37/119; Intervenção Federal 05, Corte Especial, Min. Torreão Braz, Lex-JSTJ 68/35; Intervenção Federal 09, Corte Especial, Min. Torreão Braz, DJ de 21.11.1994, p. 31.690; Intervenção Federal 12, Corte Especial, Min. Jesus Costa Lima, RSTJ 56/55; Intervenção Federal 15, Corte Especial, Min. Adhemar Maciel, DJ de 29.11.1993, p. 25.838; Intervenção Federal 26, Corte Especial, Min. Demócrito Reinaldo, RSTJ 74/65.

J. Cretella Júnior. Comentários à constituição de 1988. São Paulo: Forense Universitária, 1991, vol. IV, p. 2.079. No mesmo sentido: Pinto Ferreira. Comentários à constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990, vol. II, p. 315.

Pontes de Miranda. Comentários..., cit., t. IX, p. 178; Alcides de Mendonça Lima. Comentários..., cit., p. 204; Mario Aguiar Moura. O processo de execução, cit., p. 60; Ulderico Pires dos Santos. O processo de execução na doutrina e na jurisprudência, cit., p. 64.

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO IV. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO

Capítulo IV. Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução

Seção I

Do título executivo

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível.

1. Liquidez, certeza e exigibilidade. As características formais e substanciais dos títulos executivos não se esgotam nas disposições do art. 786 do CPC/2015. Devem ser buscadas, conforme sustentamos nos comentários ao art. 786, mediante exame sistemático do ordenamento processual, sendo particularmente significativo o disposto no art. 783: nenhum título executivo, seja ele judicial, seja extrajudicial, estará completo se não contiver representação documental de obrigação líquida, certa e exigível.

Liquidez é predicado intimamente relacionado com o de certeza, seu prerequisite necessário. A definição constante do art. 1.533 do CC/1916 (ainda válida, embora não reproduzida expressamente pelo Código de 2002) era precisa no particular: “considera-se líquida a obrigação certa, quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto”. Em outras palavras: para ser líquida, a obrigação deve (a) existir e (b) ter objeto determinado. No dizer de Pontes de Miranda, “o crédito diz-se líquido (ou diz-se líquida a dívida) quando, além de claro e manifesto (*efficere claram et manifestam probationem debiti*), dispensa qualquer elemento extrínseco para se lhe saber o importe (*non requiratur aliquot extrinsecus ad probandum*). Sabe-se que é e o que é”.¹ Em princípio, a liquidez não fica comprometida se o valor consignado originalmente no título como devido sofrer, supervenientemente, alteração para mais (como, por exemplo, pela incidência de encargos apuráveis à base de simples cálculo aritmético), ou para menos (como, por exemplo, quando há amortização da dívida).² Todavia, a obrigação originalmente líquida poderá se mostrar ilíquida se fato ou ato superveniente trazer incerteza sobre o exato conteúdo da prestação pendente.³

A exigibilidade tem, também ela, como prerequisite, a certeza do direito. Para ser exigível a prestação supõe-se: (a) que exista direito subjetivo a havê-la e (b) que o dever de prestá-la seja atual, e não futuro. Costuma-se afirmar, por isso mesmo, que obrigação exigível é a obrigação não sujeita (ou não mais sujeita) a termo ou a condição suspensiva. A rigor, a assertiva contém impropriedade. Se é correto sustentar que o advento do termo inicial (prazo) é pressuposto da exigibilidade, o mesmo não se pode dizer da condição suspensiva, que é pressuposto da própria existência da obrigação. É o que decorre do disposto no art. 121 do Código Civil (CC/1916, art. 114), conforme anotamos nos comentários ao art. 514.

Assim, é possível imaginar-se obrigação certa (existente), embora ilíquida (sem valor ou objeto determinado) ou inexigível (exigível apenas no futuro); mas não se pode, logicamente, conceber obrigação incerta, líquida ou exigível. A força executiva do título supõe, de qualquer modo e em qualquer caso, a conjunção dos três predicados: obrigação certa e líquida e exigível.

Certeza não é sinônimo de incontestabilidade. O título executivo atende ao requisito da certeza

quando for apto, por si mesmo, a representar, documentalmente, uma norma jurídica individualizada da qual decorra a obrigação de alguém de prestar a outrem uma coisa, uma quantia, um fato ou uma omissão. Embora contestáveis, em tese, os elementos subjetivos e objetivos dessa norma, ainda assim estará presente o requisito da certeza sempre que o título for, em si, intrinsecamente incontestável, ou seja, sempre que a eventual contestabilidade não decorrer de insuficiência ou de contradição (dicção contra) interna ao título, mas depender de elementos extrínsecos. A certeza, tal como a liquidez e a exigibilidade, já dizia Carnelutti, são qualidades que devem ser avaliadas segundo o que estiver representado no título.

Afirmar que um direito subjetivo, ou uma obrigação, existe, é dizer que alguém tem a faculdade de, no presente ou no futuro, exigir de outrem uma determinada conduta. A identificação dos sujeitos da relação jurídica constitui, por isso mesmo, elemento indispensável ao predicado da certeza. Não se poderá tomar como título executivo certo o que não identificar o credor e o devedor da prestação nele representada. Conforme Frederico Marques, “o título executivo tem, na prestação, seu elemento nuclear”, mas “na prestação, há um sujeito ativo que pode exigir-lhe o cumprimento, e um sujeito passivo a quem a exigência se destina, os quais devem ser indicados no título, para a individualização subjetiva deste”.⁴

O que se contém no art. 783, em suma, é o princípio básico do processo de execução, segundo o qual o título executivo deve representar de modo completo a norma jurídica individualizada, “de tal sorte que o juiz, ao receber a inicial, conheça quem deve, o que deve e quando deve” cumprir a obrigação.⁵

2. Execução forçada e título executivo. Para que se compreenda a importância que tem, na fenomenologia do direito, o princípio consagrado no art. 783 (da *nulla executio sine titulo*), é indispensável que se considere a dinâmica da concretização do ordenamento jurídico. O fenômeno da atuação das normas no plano social comporta três momentos bem distintos: primeiro, o da formulação abstrata dos preceitos normativos; segundo, o da definição da norma para o caso concreto; e terceiro, o da execução da norma individualizada. A formulação abstrata dos preceitos normativos, ou seja, a criação das normas (momento um) é atividade pública monopolizada pelo Estado-legislador. Já a definição da norma concreta, é dizer, a identificação da norma individualizada que se formou, concretamente, pela incidência da norma abstrata (momento dois), bem como a sua execução, ou seja, a sua transformação efetiva em fatos ou comportamentos (momento três), são atividades que não demandam, necessariamente, o concurso ou a intervenção estatal.

As atividades dos momentos dois e três desenvolvem-se, em geral, de modo espontâneo, voluntário, e sem formalidades, a ponto tal que, como observou Latorre, na maioria das vezes sequer há consciência de que se trata de uma atividade jurídica: “entrar num autocarro, comprar bilhetes para uma sessão de cinema, comprar jornal, são atos que têm uma transcendência jurídica, embora quase nunca reparemos nisso: podemos exigir que o autocarro nos transporte a um local determinado ou que nos seja permitido entrar no cinema para ver o espetáculo; adquirimos a propriedade do jornal, perdemos a do dinheiro que pagamos”.⁶ Nessas condutas do dia a dia, espontâneas e informais, há incidência de normas abstratas em suportes fáticos, nascem normas jurídicas concretas, os seus destinatários identificam o seu conteúdo e os elementos das relações jurídicas que a partir delas são estabelecidas (sujeitos ativos, sujeitos passivos, prestações) e, finalmente, há cumprimento dos seus enunciados, mediante condutas e comportamentos com eles compatíveis.

Em certos casos, o momento dois, embora ocorra voluntariamente (isto é, sem intervenção estatal), se dá de modo formal. É assim, por exemplo, quando se ajusta contrato em forma escrita, na presença de testemunhas ou perante um tabelião, ou quando se emite um título de crédito. O que se faz, nessas situações, é formalizar documentalmente o conteúdo de determinada norma jurídica concreta, identificando os elementos da relação de direito exsurgente, o sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação, com o seu objeto, seu prazo e suas condições. Quando a formalização documental tiver natureza constitutiva da obrigação – que é o que geralmente ocorre nos casos acima enfocados – haverá contemporaneidade entre incidência (da norma abstrata) e identificação (da norma concreta que daí nasce). Casos há em que os interessados delegam a terceiro, também

particular, o encargo de identificar os contornos da norma concreta. É o que ocorre quando determinada controvérsia é submetida a juízo arbitral.

Também nessas hipóteses o momento três é, em regra, espontâneo: os destinatários da norma concretizada (formalizada no contrato ou no título de crédito ou na sentença arbitral), dão-lhe o devido cumprimento, adotando a conduta adequada à satisfação da prestação devida.

No entanto, a identificação da norma concreta ou a sua execução, ou ambas, quando não desenvolvidas voluntariamente, demandam concurso estatal, o que se dá pela atuação do Estado-juiz, mediante exercício da sua função jurisdicional. Tomemos um exemplo. O choque entre dois automóveis, com danos recíprocos, é suporte fático para a incidência da norma estabelecida no arts. 186 e 927 do CC (CC/1916, art. 159), a saber: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”; “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Ocorrido o fato, a incidência do preceito normativo abstrato é automática, de modo que, independentemente da vontade dos envolvidos, surge norma jurídica concreta, estabelecendo relação obrigacional de reparação dos prejuízos. A identificação de tal norma supõe imputação da culpa, com consequente posicionamento dos envolvidos nos polos ativo e passivo da relação obrigacional, e apuração dos danos e do seu montante, que é a prestação devida. Nem sempre haverá entre os interessados consenso a respeito de todos esses pontos. Nem sempre haverá, portanto, espontaneidade de identificação da norma individualizada. Estabelecendo-se controvérsia a respeito de qualquer dos aspectos assinalados, estará instalada crise de identificação da norma, a demandar, para a sua solução, intervenção estatal. Mediante atividade cognitiva, o Poder Judiciário definirá, por sentença, o conteúdo da norma concretizada, indicando os elementos da relação jurídica dela decorrente, seus sujeitos e sua prestação.

Definida a norma concreta, a atividade jurisdicional poderá ser mais uma vez convocada se o seu cumprimento sofrer percalço, seja pela inércia do obrigado, seja por sua resistência, seja pelo atendimento insatisfatório da prestação. Nasce, aí, a pretensão à execução forçada.

O certo é que, para alcançar o momento três, o da execução, pressupõe-se superado o momento dois: executa-se a norma concreta já definida em seus contornos. Isso vale tanto para a execução espontânea, quanto para a forçada. Há, porém, um importante pressuposto a distinguir uma da outra. Aquela, a execução espontânea, pode ocorrer independentemente de qualquer formalidade no processo de identificação da norma; mas esta, a execução forçada, pressupõe que a norma concreta esteja formalmente identificada, de modo que o seu conteúdo possa ser demonstrado ao juiz da execução com razoável grau de certeza. É o legislador que estabelece as características formais que deve assumir a norma individualizada para ensejar a outorga da tutela jurisdicional executiva. Surge, assim, o título executivo, que pode ser judicial, quando a identificação da norma concretizada tiver participação do Estado-juiz, ou extrajudicial, nos demais casos.

Sumariando o exposto nessa abordagem preliminar, podemos dizer que a execução forçada é efetivação de norma jurídica concreta cuja existência e conteúdo se exterioriza mediante forma prevista em lei. O título executivo é, portanto, sob o aspecto substancial, uma norma jurídica individualizada, e, sob o aspecto formal, o conjunto dos documentos que a representam. Essas afirmações serão melhor detalhadas a seguir.

3. Natureza do título executivo. Muito se debateu e ainda se debate na doutrina a respeito da natureza do título executivo. O tema foi objeto de célebre polêmica entre Carnelutti e Liebman, um dando ênfase ao aspecto documental do título e o outro acentuando seu aspecto substancial. Para Carnelutti, o título executivo é um documento e sua função é essencialmente probatória. Para Liebman, o título é um ato, com eficácia constitutiva da sanção. Segundo Carnelutti, o título é o documento que o credor deve apresentar ao órgão judicial para obter a execução, semelhante ao bilhete de passagem que o viajante apresenta na estação do trem. “Tal documento está provisto de uma particular eficácia en el sentido de que atribuye a la situación jurídica que en el está representada, la certeza necesaria para que se la actúe mediante la ejecución forzada; basta ello para concluir que es un documento que hace prueba legal, o en otra forma, que es una prueba

legal”.⁷ Liebman via a questão de modo diferente. Para ele, a execução consiste na atuação prática da vontade da lei, sendo que “os atos destinados a isso podem e devem realizar-se quando o Estado manifestou análoga vontade ou, o que é o mesmo, quando a sanção se concretizar. O ato expressivo de tal vontade é o título executório, que se pode, pois, considerar portador da sanção, e é uma decisão do juiz que aplica a sanção, ou um ato diverso que tem, por disposição de lei, idêntico efeito”.⁸ O título executivo seria, em síntese, “o ato que torna concreta e atual a vontade do Estado de que se exerça uma atividade executória de determinado conteúdo e medida, a favor de uma pessoa e a cargo de outra pessoa”.⁹

Há dificuldades na adoção de qualquer das duas orientações, com o radicalismo com que foram defendidas inicialmente. Liebman, ao considerar o título como o ato pelo qual foi constituída a vontade sancionatória do Estado, não dá resposta adequada à executividade dos títulos extrajudiciais, os quais, criados que são sem a participação estatal, certamente não têm aptidão para fazer nascer a referida “vontade sancionatória”. A força sancionatória, na verdade, não é constituída por ato especial, mas deriva, isto sim, do próprio ordenamento jurídico. Com efeito, a norma jurídica, no enunciado da perinorma, já contém, em si, o comando dirigido ao Estado, para que, não havendo cumprimento espontâneo, lhe dê execução forçada, fazendo atuar a sanção. Desse modo, a atividade jurisdicional executiva independente de outro (prévio) comando ou autorização estatal (jurisdicional), e isso explica a possibilidade de execução sem prévia condenação, bem assim a aptidão executiva de títulos extrajudiciais.

Por outro lado, ao considerar o título executivo como prova legal do crédito, Carnelutti subestimou-lhe os aspectos substanciais. Esse exagero foi por ele mesmo revisto em seus últimos escritos. Fazendo balanço da “disputa forte e fecunda” que travou com Liebman, e na tentativa de superá-la, Carnelutti voltou a acentuar, com razão, ser inegável que algum documento deve ser apresentado ao juiz para obter a tutela executiva: “si un individuo le contase al oficial judicial que es el acreedor de otro y le pidiese que embargase sus muebles, oiria que le contestaba: donde es el trozo de papel? Papeles cantan y villarinos duermen (canten cartas e callen barbas)”.¹⁰ Acentuou também que a negação do caráter documental do título decorreu de uma desatenta conceituação de documento, “que no es una cosa cualquiera sino una cosa representativa; para hacernos entender, no un vaso vacio, sino lleno y sin aquello que contiene no seria documento; el documento, en suma, no vale solamente por si sino por aquello que contiene o, prescindiendo de la metáfora, por aquello que representa”, de modo que “cuando el título es definido como un documento, es claro que su eficacia depende no solo del continente, sino además del contenido, esto es, no solo de algo que representa sino de lo que está representado”.¹¹

Todavia, reconhece Carnelutti que a expressão prova legal não é a mais adequada para o conceito de título executivo, e nesse ponto revê suas posições. É que a prova serve para a verificação da existência histórica de um fato, não da sua eficácia jurídica, ou seja, da existência de uma relação jurídica. Ora, “el título ejecutivo es necesario y suficiente a fin de que el oficio considere no solo la existencia de los hechos de los cuales deriva la relación, sino la existencia de la relación misma”, e daí a necessária conclusão de que “el título es algo más que una prueba legal; este algo más está ya expresado, por una feliz intuición, por la palabra título, que sirve precisamente para significar un documento provisto de una eficacia más intensa que la de medio de prueba, en cuanto vale para establecer la existencia de una relación jurídica, o, en otros términos, la eficacia jurídica de un hecho”.¹² À luz destas considerações arrematou Carnelutti ser preferível a definição de título executivo como documento à de ato: “el documento, en efecto, implica el contenido, mientras que el acto no implica el continente”.¹³

A formulação do conceito de título executivo com utilização conjunta de seus elementos formais e substanciais é, na verdade, a que acabou predominando. Em Chiovenda, aliás, já se lia que “em todo o título executório deve, pois, ter-se presente e distinto um duplo significado e elemento, substancial e formal: a) o título em sentido substancial é o ato jurídico de que resulta a vontade concreta da lei; b) o título em sentido formal é o documento em que o ato se contém”.¹⁴ É esta, também, em essência, a linha de orientação adotada por outros autores estrangeiros¹⁵ e, de um modo geral, pela doutrina brasileira, que, inobstante as variações conceituais a respeito da função do título no processo de execução, convergem, todavia, na opinião de que, para definir tal

função, é indispensável considerar tanto os elementos extrínsecos como os intrínsecos que formam o título. Assim, por exemplo, na definição de Pontes de Miranda, “o título executivo é documento que contém a relação jurídica, de que se irradia a obrigação”;¹⁶ para Moacyr Amaral Santos, “título executivo consiste no documento que, ao mesmo tempo em que qualifica a pessoa do credor, o legitima a promover a execução. Nele está a representação de um ato jurídico, em que figuram credor e devedor, bem como a eficácia, que a lei confere, de atribuir àquele o direito de promover a execução contra este”.¹⁷ Conformes também nesta orientação: José Frederico Marques (“ele é ato jurídico e documento a um só tempo”),¹⁸ Alcides de Mendonça Lima (“o título deve ser concretizado em um documento, no qual se contenha relação jurídica bilateral entre as partes”),¹⁹ Amílcar de Castro (“o título executivo, em sua forma externa, abriga o direito que tem o exequente contra o Estado de recorrer às vias judiciais; e em seu elemento intrínseco é que deve conter a decisão judicial ou a obrigação a ser executada”),²⁰ Vicente Greco Filho (“documento ou ato documentado que consagra obrigação certa e que permite a utilização direta da via executiva”),²¹ Marcelo Lima Guerra (“representação documental típica de um direito líquido, certo e exigível”),²² Sérgio Shimura (“documento ou ato documentado, tipificados em lei, que contêm uma obrigação líquida e certa e que viabilizam o uso da ação executiva”).²³

4. Forma, conteúdo e função do título executivo. A forma e o conteúdo do título executivo estão diretamente relacionados com a sua função no sistema processual. Segundo o art. 783 do CPC/2015, o título executivo é a base da execução. Base é tudo quanto serve de fundamento ou apoio. É o alicerce das edificações. Não se pode construir uma execução forçada senão sobre o alicerce delimitado pelo título executivo. A imagem de Carnelutti tem significado semelhante: o título é como o projeto de que se utiliza o mestre de obras para executar a construção do edifício.²⁴ Seja alicerce, seja projeto, o certo é que no título executivo “encontra-se o resultado a que deve tender a execução”.²⁵

Ora, a execução forçada, conforme já asseverado, tende a dar cumprimento a uma norma jurídica concreta. Conforme Barbosa Moreira, o que se busca com a execução é fazer “atuar a norma concreta já enunciada em prévio processo de conhecimento ou expressa em documento à que a lei confere semelhante eficácia”.²⁶ Quanto a esse ponto específico, aliás, concordavam Liebman e Carnelutti, aquele ao sustentar que a execução forçada “é, (...) na realidade, execução de regra jurídica sancionatória”,²⁷ e este ao identificá-la como “esfuerzo de adecuar (...) el derecho al hecho, esto es, de hacer que aquello que debe ser, sea”.²⁸ Pois bem, nesse pressuposto de que a execução forçada busca dar efetividade a uma norma jurídica concreta, há de se concluir que o título executivo – base, alicerce, fundamento, projeto, guia, que é da execução – deve ter por conteúdo precisamente a referida norma.

Ao sustentarmos que o conteúdo do título executivo é uma norma jurídica concreta, individualizada, estamos afirmando que ele: (a) não só espelha a relação jurídica exsurgente da incidência da norma abstrata sobre o suporte fático, mas, mais que isso, que ele (b) é portador de uma eficácia típica: a de autorizar a outorga de tutela jurisdicional executiva. Essa eficácia não decorre de ato de vontade, nem de sentença. Decorre, sim, da própria norma jurídica, da qual é parte essencial. “A norma jurídica permite que o lesado pela violação dela exija o cumprimento dela”, escreveu Goffredo Telles Júnior, acrescentando: “em virtude do autorizamento, o lesado pode, com fundamento jurídico, completar sua interação com quem o prejudicou. Após a ação violadora da norma jurídica, a própria norma violada autoriza e permite a reação competente”.²⁹ Esse é, aliás, o elemento distintivo por excelência entre a norma jurídica e as demais normas de conduta: a aptidão para atribuir ao lesado a faculdade de exigir o seu cumprimento forçado. Segundo a lição clássica de Luis Recasens Siches, “en el Derecho, cabalmente la posibilidad predeterminada de esa ejecución forzada, de la imposición inexorable de lo determinado en el precepto jurídico, incluso por medio de poder físico, constituye un ingrediente esencial de éste. La sanción jurídica, como ejecución forzada de la conducta mandada en el precepto (...), o como ejecución forzada de una conducta sucedánea de reparación o compensación, o como retribución de una infracción consumada ya irremediable – pena – constituye un elemento esencial de la norma jurídica”.³⁰ Assinale-se que tal atributo está presente não apenas na norma jurídica abstratamente considerada, mas também na norma individualizada. As duas são estruturalmente

assemelhadas, sendo que “a essência da norma individualizada (...) é idêntica à da norma genérica. Há, entre ambas, diferença de grau, que não afeta a substância”.³¹ O conteúdo do título executivo é, portanto, uma norma individualizada, e não um simples ato jurídico. Com efeito, para sustentar a afirmação de que o título é, substancialmente, um ato apenas, ter-se-ia que admitir, como alguns admitem, que o título extrajudicial é “ato onde se acerta também a sanção”.³² Ora, essa doutrina compromete o monopólio estatal no domínio da perinorma (estabelecimento da sanção jurídica), e, por isso mesmo, não se compadece com nosso sistema de direito.³³ É a norma que impõe as consequências sancionatórias às condutas lesivas. Ao puro e simples ato de vontade não se confere aptidão alguma para criar, atribuir ou acertar a sanção.

Toda a norma jurídica, inclusive a norma individualizada, compõe-se de dois enunciados: o da endonorma, ou norma primária, que dispõe sobre a conduta devida, a prestação, o dever jurídico e que relaciona o sujeito ativo e o sujeito passivo; e o da perinorma, ou norma secundária, que estabelece a sanção, a consequência jurídica, em caso de não cumprimento do preceito endonormativo, e que é dirigido contra o Estado, trazendo embutida autorização para que o interessado possa vindicar a tutela jurisdicional. O que caracteriza o título executivo é a peculiaridade de representar norma individualizada que contém, no enunciado da sua perinorma, autorização para outorga, ao interessado, de uma específica forma de tutela: a tutela jurisdicional executiva. Essa eficácia é reservada a certas normas individualizadas, revestidas de características especiais, estabelecidas em lei.

O Código de Processo Civil enuncia, no seu art. 784, um rol de títulos executivos extrajudiciais, que, como se verá, não é exaustivo, nem no que diz respeito ao número deles e muito menos no que se refere às suas características. Para identificá-las, é indispensável exame sistemático do ordenamento processual. Assim, a eficácia executiva supõe que o título se refira à obrigação cujo objeto seja prestação de entrega de coisa (Livro II, Título II, Capítulo II) ou prestação de fazer (Capítulo III, Seção II) ou de não fazer (Seção III), ou de pagar quantia certa (Capítulos IV e V), o que constitui elemento identificador do procedimento executório a ser observado. Supõe, outrossim, que a obrigação seja certa e que a prestação seja líquida e exigível (arts. 783 e 803, I), vale dizer, que a norma jurídica concreta esteja com seus elementos essenciais adequadamente determinados. Assim, é também pressuposto para ter força executiva que o título identifique os sujeitos ativo e passivo da relação jurídica obrigacional,³⁴ exigência decorrente da “importante função de legitimação”³⁵ por ele desempenhada no processo. É identificação que se impõe inclusive quando o sujeito, ativo ou passivo, já não é mais o originário, mas derivado, e cujos documentos comprobatórios “comporão a representação documental do crédito líquido, certo e exigível em que consiste o título executivo”.³⁶ É desta forma que se compatibiliza a função do título com o “ser dinâmico da obrigação”³⁷ nele contida.

Em suma, a eficácia executiva supõe que o título seja completo “tanto objetiva como subjetivamente”.³⁸ Somente se contiver essas características é que ele realmente poderá servir de base para a execução, dado que habilitará o juiz, condutor do processo executivo, a “saber quem seja o credor, quem seja o devedor, qual o bem devido, e quando seja devido”,³⁹ bem assim qual o regime procedimental a ser adotado. E, se esse é o conteúdo que a lei impõe ao título para dar-lhe eficácia, designá-lo simplesmente de ato é dizer pouco. Ato tem significado jurídico limitado. O título, não raro, é composto de uma pluralidade de atos, ou de particulares, ou de órgão jurisdicional, ou de ambos, como se verá. Na verdade, o título executivo é, substancialmente, uma norma jurídica individualizada, já que contém (a) uma relação jurídica (ato jurídico lato sensu + obrigação certa + prestação líquida e exigível + partes) e (b) uma eficácia típica de autorizar a propositura da ação executiva.

Sob o aspecto de sua exteriorização formal, o título executivo deve estar consubstanciado em documentação escrita, que servirá para “instruir a petição inicial” (CPC/2015, art. 798, I). É o modo como se demonstra ao juiz a existência da norma individualizada. Os elementos substanciais do título podem vir exteriorizados num único documento (por exemplo, numa nota promissória) ou em mais de um documento (exemplos: duplicata sem aceite + comprovante de entrega da mercadoria + certidão de protesto; contrato de mútuo + contrato de cessão de crédito). As exigências formais não são uniformes para todos os títulos. Há particularidades específicas para

cada uma de suas espécies, indicadas em lei (nomeadamente no art. 784 do Código e em dispositivos especiais que disciplinam a formação dos títulos ali arrolados).

Apresentada a documentação representativa do título, com as formalidades extrínsecas adequadas, estará o juiz habilitado a dar seguimento ao processo de execução. Não se descarta, todavia, a hipótese de falta de correspondência ontológica entre forma e conteúdo. A norma jurídica individualizada, representada na documentação juntada à inicial, pode não existir efetivamente, ou porque nunca existiu, ou porque deixou de existir; ou pode existir, mas com outra configuração, com outra prestação ou com outro sujeito, diferentes daqueles que os documentos aparentam. Isso evidencia que a forma de exteriorização do título traduz certeza apenas relativa quanto à sua substância,⁴⁰ abrindo caminho para controle jurisdicional, por via cognitiva, da relação jurídica em que se insere a prestação. Em outras palavras: a falta de correspondência entre o que o título formal aparenta ser e o que efetivamente ele é em substância, constitui matéria a ser invocada pelo executado, mediante embargos, que, se recebidos, estancarão, até seu julgamento, os atos executivos. O âmbito dessa cognição é variado, dependendo da natureza do título. Será bem amplo, em se tratando, por exemplo, de escrito particular assinado por duas testemunhas (CPC/2015, 784, III). Será mais limitado se o título executivo for título de crédito (nota promissória, letra de câmbio – CPC/2015, 784, I), porque sua natureza abstrata impede o exame do negócio jurídico subjacente. E será ainda mais restrito em se tratando de título executivo judicial, caso em que o âmbito de cognição da impugnação abrange, em regra, apenas as incidências jurídicas ocorridas após a sua formação original.

O certo é que o título executivo não é prova absoluta da existência da obrigação e, sendo assim, ele autoriza a ação executiva, mas não legitima, necessariamente, os atos de execução. Anotou, a propósito, Ovídio A. Baptista da Silva, invocando Liebman, que, “oportunizando a lei, através dos embargos, a destruição do título executivo – quando o direito não exista – acaba condicionando o ato final executivo (que é propriamente a execução), à existência efetiva do direito substancial; e confirmando o entendimento de que o título executivo permite apenas que o credor inicie e desenvolva a atividade executória (que é a ‘ação’ processual executiva), mas não possa atingir o resultado executivo, se o executado lograr demonstrar, nos embargos, a inexistência do crédito, configurado no título”.⁴¹

À luz destas considerações, é possível formular conceito mais completo de título executivo: é a representação documental de norma jurídica individualizada, contendo obrigação líquida, certa e exigível, de entregar coisa, ou de fazer, ou de não fazer, ou de pagar quantia em dinheiro, entre sujeitos determinados, e que tem a eficácia específica de viabilizar a tutela jurisdicional executiva.

5. Classificação dos títulos executivos: judiciais, extrajudiciais e mistos. A moderna concepção do título executivo representa solução de compromisso entre dois antigos sistemas jurídicos, fundados em valores antagônicos: o sistema romano, segundo o qual “mesmo depois de obtida uma sentença de condenação, o credor não podia usar de meios executivos e tinha de propor nova ação, a *actio judicati*, a fim de se verificar se o seu direito ainda subsistia”, e o germânico, segundo o qual “o credor pode começar por um ato executivo, a penhora, e depois é que pode surgir, por iniciativa do devedor, uma espécie de juízo de apreciação e de conhecimento”.⁴² Um, o direito romano, “observou com grande rigor o princípio segundo o qual deviam conhecer-se as razões das partes antes de fazer-se a execução”, enquanto o outro considerava “toda a falta de cumprimento da obrigação como ofensa à pessoa do credor”, autorizando-o “a reagir e a reparar o seu direito lesado pelo emprego da força, sem necessidade de dirigir-se a qualquer terceiro, autoridade ou particular, para o exame imparcial de suas afirmações”.⁴³ A execução aparelhada (*executio parata*), atribuindo à sentença condenatória a eficácia, antes desconhecida, de viabilizar a execução, sem necessidade de nova ação, e, mais tarde, a outorga dessa mesma eficácia a certos “instrumentos de dívida lavrados perante o tabelião (*instrumenta guarentigiata*)”, foram as novidades introduzidas pelos juristas da Idade Média, inaugurando “compromisso entre essas duas correntes contrárias”.⁴⁴

Na raiz daqueles antigos sistemas de pensamento subjazia, como se vê, um conflito de valores ainda hoje presente: de um lado, a necessidade de preservar a segurança jurídica como forma de

alcançar maior justiça na solução dos conflitos (o que demanda tempo), e, de outro, a necessidade de emprestar ao direito o mais efetivo e pronto atendimento (o que requer do Estado resposta imediata às demandas contra o descumprimento). Esse “conflito executivo”, como vem sendo denominado modernamente,⁴⁵ tem recebido, no correr dos anos, no direito comparado, soluções legislativas que ora pendem para a valorização da segurança jurídica, ora para a efetividade, do que resulta ou a ampliação ou a limitação das espécies de títulos executivos, notadamente os extrajudiciais. O sistema normativo brasileiro, que na vigência do Código de 1973, em sua versão original, já elencava número bem significativo de títulos executivos extrajudiciais, passou a apresentar, após a Lei 8.953, de 13.12.1994, um elenco ainda mais representativo, seja pelo acréscimo de novas espécies, seja pela qualificação substantiva outorgada às já existentes. O Código de 2015, por sua vez, inova ainda mais, ampliando o rol de títulos executivos extrajudiciais, conforme se verá no devido tempo.

A eficácia executiva, que era idêntica para todos os títulos,⁴⁶ hoje depende da espécie a que pertencem. Muito embora todos eles tenham aptidão para autorizar o credor a requerer a satisfação do crédito e a sujeitar o devedor às consequências daí decorrentes, alguns permitem a instauração de uma fase de cumprimento nos autos do mesmo processo, outros demandam a propositura de uma ação de execução. Além da questão procedimental, o que distingue uma e outra das espécies, na verdade, é a “carga de cognição com que se começa”.⁴⁷ Os chamados “títulos executivos judiciais” são formados com a participação de órgão do Poder Judiciário, de modo que, em relação a eles, a atividade de identificação da norma concreta já foi objeto de cognição. Quanto aos títulos extrajudiciais, em que a identificação da norma individualizada ocorreu sem qualquer certificação jurisdicional típica, o processo de cognição, se for o caso, será instalado posteriormente. Disso resulta também que, em se tratando de título extrajudicial, os embargos do devedor podem trazer a juízo tanto matéria posterior à formação do título, quanto matéria anterior a ela; contrariamente, em se tratando de título judicial, a impugnação só poderá versar sobre matéria superveniente dado que os atos de formação do título já foram objeto de prévia certificação jurisdicional. As raras exceções que autorizam a rediscussão de questões relacionadas à fase cognitiva são: (a) as do art. 525, § 1.º, I, do Código, referente à falta ou nulidade da citação do réu no processo de conhecimento em que foi revel; e (b) a do § 12 do mesmo artigo, bem como a do § 5.º do art. 535, quando o título executivo judicial esteja revestido de inconstitucionalidade qualificada, assim considerado o que tenha sido formado de modo incompatível com anterior decisão do Supremo Tribunal Federal que, em controle de constitucionalidade, incidental ou por ação, reconheceu a legitimidade de preceito normativo, ou declarara a sua ilegitimidade, total ou parcial, inclusive mediante técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ou por interpretação conforme.⁴⁸

Nas palavras de Vaccarella, caracteriza-se título executivo extrajudicial “quando la legge abilita il debitore ad utilizzare, nel corso della procedura esecutiva, il medesimo strumento per dedurre sia fatti anteriori che fatti posteriori alla formazione del titolo”.⁴⁹ Há, aqui, segundo Pontes de Miranda, “execução adiantada”, o que importa a outorga, ao autor, de “pretensão à tutela jurídica por adiantamento”.⁵⁰ Não se trata, contudo, de forma de antecipação da tutela ou de tutela cautelar, como às vezes se insinua.⁵¹ A execução forçada de título extrajudicial é forma de tutela definitiva e autônoma (e não provisória), sem qualquer relação necessária de dependência ou de referência a outra espécie de tutela ou a outro processo (como ocorre com a tutela antecipatória e a cautelar).⁵²

Os títulos executivos extrajudiciais acarretam, portanto, a inversão da ordem das atividades jurisdicionais (em que, por princípio, a cognição antecede a execução). Trata-se de inversão apenas parcial, pois o desencadeamento da atividade cognitiva, por embargos de devedor, quando ocorre, se dá em momento em que a ação de execução encontra-se ainda na sua fase inicial (CPC, art. 915), podendo ser suspensa (CPC/2015, art. 919, § 1.º) até o julgamento dos referidos embargos, quando então serão levados a cabo os atos executivos propriamente ditos. A outorga de executividade a títulos extrajudiciais opera outros efeitos, ainda mais significativos, a saber: (a) torna eventual, e não necessária e nem obrigatória, a atividade cognitiva e (b) impõe inversão da iniciativa na busca da tutela cognitiva, com importantes consequências práticas, notadamente no que diz respeito ao ônus da prova. O título extrajudicial contém presunção iuris tantum de certeza do direito nele

representado, cabendo ao executado não apenas a iniciativa de promover a ação desconstitutiva, como também o ônus probatório apto a desfazer aquela presunção.

Pertence ao domínio discricionário da política legislativa a criação ou não de títulos extrajudiciais, mas essa discricionariedade tem limites. Ela está condicionada pelo princípio da proporcionalidade, que sempre há de presidir a solução legislativa de conflitos entre segurança e efetividade dos direitos.⁵³ Assim, ao legislador certamente não seria dado negar executividade à norma jurídica concreta certificada por sentença transitada em julgado, se nela estiverem presentes todos os elementos identificadores da obrigação (sujeitos, prestação, liquidez, exigibilidade), pois isso representaria atentado ao direito constitucional à tutela jurisdicional executiva, inerente ao direito de ação (art. 5.º, XXXV). Por outro lado, também não seria compatível com a Constituição, notadamente com o direito fundamental à segurança jurídica previsto no seu art. 5.º, LIV, a situação oposta, ou seja, a outorga de eficácia executiva a situações em que a norma jurídica concreta, desprovida de qualquer elemento probatório documentado, resultasse apenas da afirmação do próprio interessado. Em outras palavras: a legitimidade constitucional dos títulos executivos extrajudiciais supõe que a norma jurídica concreta esteja representada por documentos que possam induzir, com razoável grau de certeza, a sua efetiva existência, de modo que se possa ter como pouco provável a contestação do devedor. Certeza com tal grau de razoabilidade é que justifica, em nome da efetividade e da economia processual, a outorga desde logo ao credor a pretensão à tutela jurisdicional executiva.⁵⁴

Por outro lado, o exame sistemático do Código impõe seja adicionada, à classificação nele expressa, uma terceira espécie de títulos. São os títulos mistos, aqueles em que a norma jurídica individualizada tem seus elementos integrativos representados por documentação em parte de origem extrajudicial e em parte já com certificado judicial. São exemplos dessa terceira espécie os títulos que embasam a execução de obrigação sujeita a condição ou termo (CPC/2015, art. 514), que são compostos: (a) por uma sentença a respeito da relação obrigacional e (b) por prova (de origem extrajudicial) da ocorrência do termo ou da condição. Igualmente, na execução de crédito certificado por sentença condenatória cujos direitos tenham sido objeto de posterior cessão, o título executivo do credor cessionário terá dupla origem: (a) judicial, no que diz respeito à obrigação e (b) contratual, no que se refere ao titular do crédito (observe-se que, conforme já sustentamos, a identificação das partes é elemento integrativo do título). Outro exemplo: a execução por quantia certa nos casos em que o credor preferir o valor e as perdas e danos em substituição à coisa (CPC/2015, art. 809) ou aos serviços (CPC/2015, art. 816) não entregues ou não prestados pelo devedor. Como a execução específica primitivamente intentada tem por base título extrajudicial, a execução substitutiva (por quantia certa) virá sustentada em título de origem mista: (a) extrajudicial, quanto à existência da obrigação (an debeatur) e (b) judicial, no que se refere ao valor (quantum debeatur), eis que a sua liquidação já terá o certificado judicial (CPC/2015, art. 809, § 2.º e art. 816, parágrafo único).

Não é meramente acadêmica a preocupação com esta terceira espécie de título, dadas as importantes consequências que têm em relação ao âmbito cognitivo da ação de embargos. Com efeito, fundada a execução em título executivo misto, a matéria suscetível de invocação nos embargos será ampla (CPC/2015, art. 917) relativamente aos elementos da norma jurídica individualizada ainda não submetidos ao crivo jurisdicional; e será restrita (CPC/2015, art. 525, § 1.º) em relação aos demais, já certificados judicialmente.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II – a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III – o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas;

IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V – os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI – o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII – o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII – o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X – o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

XI – a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas;

XII – todos os demais títulos, a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

§ 1.º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

§ 2.º Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados.

§ 3.º O título estrangeiro, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação.

1. Títulos executivos extrajudiciais. Como todo o título executivo, também os extrajudiciais devem representar, documentalmente, norma jurídica individualizada, contendo obrigação líquida, certa e exigível de entregar coisa, de fazer ou de não fazer ou de pagar quantia. Nos títulos executivos judiciais, a norma jurídica individualizada tem, na sua formação, a chancela do poder jurisdicional do Estado (exceto, como se viu, a sentença arbitral), o que lhe confere grau de certeza tal que impede a reapreciação, em impugnação, da legitimidade dos atos da sua criação (salvo em caso de nulidade ou falta de citação do réu revel no processo de conhecimento, hipótese prevista no art. 525, § 1.º, I, do CPC/2015, ou em caso de incompatibilidade com superveniente decisão do STF em controle de constitucionalidade, hipótese dos §§ 12 e ss. do mesmo artigo). Nos títulos executivos extrajudiciais, ao contrário, a norma jurídica individualizada é formada sem a participação do Estado-juiz. Sendo assim, e considerando que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5.º, XXXV, da CF/1988), sempre será cabível a reapreciação, na via jurisdicional, da legitimidade dos atos formativos dos títulos extrajudiciais, sendo ampla, consequentemente, a matéria de defesa dos embargos do executado (CPC/2015, art. 917).

Os títulos executivos extrajudiciais elencados nos incs. I a XI do art. 784 são normas jurídicas individualizadas produzidas por atos dos particulares no exercício da autonomia da vontade. Esse poder normativo (“poder negocial”) encontra seu sustento legitimador na observância das normas gerais, das quais decorre por derivação⁵⁵ e com as quais deverá, consequentemente, manter estrita relação de correspondência.⁵⁶

A certidão de dívida ativa (inc. IX) e a certidão expedida por serventia notarial (inc. XI) constituem representação de norma jurídica individualizada formada por ato de agente estatal (porém não no exercício de função jurisdicional típica) para tanto autorizado por norma geral. Sujeitam-se, assim, à revisão pelo Estado-juiz, que poderá anulá-la quando não guardar adequada

conformidade com as normas gerais, não apenas no que se refere ao seu conteúdo, mas igualmente no que diz com o processo de sua formação e à competência do órgão autorizado a produzi-la.

A nota característica dos títulos extrajudiciais, sejam eles produzidos pelo poder negocial dos particulares, sejam eles originários de ato de autoridade, consiste, portanto, na sujeição dos seus atos constitutivos ao controle de validade (= relação de conformidade entre norma individual e norma geral) pelo poder jurisdicional do Estado. Essa mesma característica está presente na sentença arbitral, e daí por que sustentamos ter sido imprópria sua inclusão entre os títulos executivos judiciais.

Pertence ao domínio do direito material a disciplina dos requisitos formais e substanciais dos atos jurídicos que a lei processual arrola como títulos executivos extrajudiciais. Mas o direito processual, instrumento que é para realização do direito material, não fica imune ao contágio deste, de modo que, em muitas circunstâncias, não se poderá compreender adequadamente um sem conhecer o outro.

2. Inciso I. O inciso I outorga eficácia executiva a cinco títulos de crédito: letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. A letra de câmbio, que é uma ordem de pagamento do sacador contra o sacado, e a nota promissória, que é promessa de pagamento assumida pelo emitente, estão disciplinadas pelo Dec. 2.044, de 31.12.1908, com as modificações decorrentes da Lei Uniforme de Genebra a que o Brasil aderiu nos termos do Dec. 57.663, de 24.01.1996. A duplicata representa crédito decorrente da venda de mercadoria ou da prestação de serviços e tem sua disciplina básica na Lei 5.474, de 18.07.1968 e na Lei 6.458, de 01.11.1977. Título típico do direito brasileiro, guarda semelhança com a letra de câmbio, notadamente porque também caracterizada pelo saque do credor (o vendedor-credor saca pela importância faturada ao comprador); a ela se aplicam, subsidiariamente, “no que couber, os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das Letras de Câmbio” (art. 25 da Lei 5.474, de 1968). A debênture, disciplinada pela Lei 6.404, de 15.12.1976, título emitido por sociedades por ações, representativo de fração de mútuo por ela tomado, confere aos seus titulares direito de crédito (art. 52), ao qual se agrega ou garantia real sobre determinado bem, ou garantia flutuante (que assegura privilégio geral sobre todo o ativo da devedora), ou ambas (art. 58). Além de ser título executivo e título de crédito, a debênture é, também, título mobiliário apto a ser negociado em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão, nos termos da legislação específica (Lei 6.385, de 07.12.1976, art. 2.º), o que potencializa sobremodo sua aptidão como instrumento destinado a captar recursos pelas companhias emitentes. O cheque, que é ordem de pagamento à vista contra um banco e cuja função mais importante é a de servir como meio de pagamento, está regulado pela Lei 7.357, de 02.09.1985 e pela Lei Uniforme de Genebra sobre cheques, integrada ao direito brasileiro pelo Decreto 57.595, de 07.01.1966.

Os títulos de crédito são instrumentos criados e moldados para facilitar e agilizar a circulação de riquezas. Para o adequado desempenho desta função econômica são dotados de características próprias, que os distinguem dos demais títulos de direito, notadamente as da cartularidade, literalidade e autonomia. São importantes os impactos de tais características no processo de execução forçada.

A cartularidade ou incorporação “consiste, em última análise, na materialização do direito no documento”, o que acarreta, como consequência prática, a de que “o documento torna-se essencial à existência do direito nele mencionado, e necessário para a sua exigência, tornando-se legítima a cobrança pelo titular que o adquiriu regularmente”.⁵⁷ Isso faz com que a obrigação nele contida seja “quérable, perseguível, de ida ao obrigado, e a reclamação só se realiza mediante apresentação do título”.⁵⁸

A cartularidade tem como reflexo processual direto o de que a petição inicial da ação executiva deve vir instruída com a via original do documento.⁵⁹ A juntada de fotocópia só é admitida excepcionalmente em casos justificáveis, como, por exemplo, quando a apresentação do original foi feita em outro processo.⁶⁰

Por literalidade do título entende-se a sua aptidão para representar formalmente o exato conteúdo do direito e da obrigação. “A literalidade”, diz Bulgarelli, “é a medida do direito contido no título. Vale, assim, o documento pelo que nele se contém, exprimindo, portanto, a sua existência, o seu conteúdo, a sua extensão, e a modalidade do direito nele mencionado”.⁶¹ Observa Pontes de Miranda, a propósito, que “o título cambiário é título formal, porque a lei, acentuando a literalidade exigida, só admite vontade cambiária que se expresse e se declare no título, de modo que créditos e dívidas resultem imediatamente do texto cambiário”.⁶²

A literalidade produz consequências importantes no âmbito processual. Uma delas, a da função legitimadora do exequente: somente o credor designado no título é que está legitimado a promover a execução, e poderá fazê-lo apenas em face dos que se obrigaram no próprio título (como emitentes, ou sacados, ou avalistas, ou endossantes). Se, pela literalidade do título, ficar configurado que seu titular é o portador, há de se ter como legitimado aquele que o apresentar, já que a posse, nesses casos, é presunção juris tantum de propriedade.

A regra da legitimação pela literalidade não é absoluta. Falecendo qualquer dos figurantes do título, a legitimação ativa ou passiva transfere-se, independentemente de qualquer anotação cartular, ao espólio ou aos herdeiros e sucessores designados no formal ou na certidão de partilha. Igualmente, se o figurante do título é pessoa jurídica que se extingue, por incorporação, por fusão ou por cisão (Lei 6.404/1976, arts. 223, 227, 228 e 229), a sucessora se investe na posição da sociedade extinta, independentemente de qualquer ato cambiário específico. A titularidade do direito e, portanto, a legitimação processual, são demonstradas com a apresentação dos instrumentos pelos quais se efetivou a operação societária de que resultou a extinção da primitiva credora ou devedora.

Relativamente ao cheque pós-datado, a literalidade da data não é levada em consideração para efeito de exigibilidade, que continua sendo à vista. Pode-se considerar pacífica a orientação da jurisprudência segundo a qual “a circunstância de haver sido aposta no cheque data futura, embora possua relevância na área penal, no âmbito dos direitos civil e comercial traz como única consequência prática a ampliação real do prazo de apresentação”,⁶³ sem qualquer comprometimento de sua executividade.⁶⁴

Outra importante consequência decorrente da literalidade do título é a de que o credor não pode exigir do obrigado mais do que a quantia pela qual se obrigou. Se o negócio subjacente é um contrato de mútuo, de que a cambial é garantia, o executado que apenas se obrigou cambiariamente não responde por obrigações contratuais extracartulares.⁶⁵ Pode ocorrer que o devedor seja, simultaneamente, obrigado pela cártula e pelo contrato. A Súmula 26 do Superior Tribunal de Justiça figura a situação: “O avalista de título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário”. Nestes casos, o credor dispõe da ação cambial e da ação causal (esta com fundamento no contrato de mútuo firmado por duas testemunhas), cabendo observar que “não poderá o credor exercer a ação derivada do negócio subjacente sem exhibir a cambial e isso em razão de que os títulos de crédito se destinam a circular. Ora, se a nota promissória tiver sido transferida, por endosso, a terceiro, de boa-fé, não poderá o devedor (emitente) opor àquele o pagamento que tenha efetuado ao credor primitivo sem o resgate do título”.⁶⁶ Nada impede, porém, que o credor promova uma única execução pelos dois títulos,⁶⁷ sendo que, na autorizada palavra do STJ, “instrumentalizada a execução com mais de um título, a eventual imprestabilidade de um não induz, necessariamente, a invalidade dos demais. Havendo apenas um válido dentre eles, idônea se afigura a execução, ressalvada a posição dos avalistas se imprestável o título cambial”.⁶⁸ Não se pode exigir, no entanto, que um obrigado cambiário responda por obrigações nascidas da conduta processual de outro coobrigado, seu litisconsorte passivo.⁶⁹

Terceira característica dos títulos de crédito é a sua autonomia, prevista no art. 43 do Dec. 2.044/1908, nos seguintes termos: “As obrigações cambiais são autônomas e independentes umas das outras. O signatário da declaração cambial fica, por ela, vinculado e solidariamente responsável pelo aceite e pelo pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da falsificação ou da nulidade de qualquer outra assinatura”. O atributo da autonomia, diz Pedro Barbosa Pereira,

“significa que cada um dos signatários do título originário ou de qualquer declaração posterior nele acrescentada se obriga pelo que subscreve e fica vinculado desde o momento da assinatura. Mais ainda: cada uma destas obrigações tem existência jurídica própria; de cada uma das assinaturas resulta obrigação autônoma e completa”.⁷⁰ A autonomia é requisito fundamental para que o título possa circular com segurança e assim desenvolver plenamente sua função econômica, o que explica a preocupação da lei de fazê-lo “livre do contágio de quaisquer causas das relações jurídicas em que estiveram os possuidores precedentes”.⁷¹

Bem se vê que a autonomia dos títulos de crédito limita significativamente o âmbito material dos embargos do devedor.⁷² Mas não se deve perder de vista que ela busca, primordialmente, a salvaguarda dos interesses do terceiro de boa-fé. Nessa perspectiva, a autonomia não pode ser considerada um dogma, e, por isso mesmo, a doutrina mais moderna e, especialmente, a jurisprudência, inclinam-se nitidamente por orientação relativizadora dos seus efeitos, evitando, destarte, que em seu nome se consagrem situações de prejuízo. Um formalismo cego, nesse domínio, poderia redundar na intolerável consequência de fazer com que o órgão acabe por danificar sua própria função.⁷³ Mesmo em relação aos títulos abstratos, ou seja, aqueles que não trazem menção ao negócio jurídico subjacente que lhe serviu de causa (de que a nota promissória e a letra de câmbio são exemplos),⁷⁴ a autonomia (abstração), em princípio, não é invocável entre devedor e credor originários.⁷⁵ Mais ainda, se o título não circulou, admite a jurisprudência que o próprio avalista possa opor certas exceções relacionadas com a existência do débito, como ocorre “se a dívida, pertinente à relação que deu causa à criação do título desapareceu ou não chegou a existir, ao menos no montante nele consignado”.⁷⁶ Pode também ocorrer que, no momento da emissão da cambial, decidam os interessados apor nela anotação expressa vinculando-a ao negócio jurídico subjacente, caso em que, segundo a jurisprudência, o título “perde a característica de abstração, podendo ao endossatário ser oposta a defesa que o devedor teria em razão do contrato”.⁷⁷

Os títulos de crédito, em geral, especialmente os abstratos, bastam-se a si mesmos, não dependendo de qualquer outro documento para completá-los. Tal independência, todavia, não é essencial à sua natureza, notadamente em se tratando de títulos causais. Assim ocorre com a duplicata, que, por ser título causal, (a) é nula se derivar de negócio que não autoriza sua emissão,⁷⁸ e que (b) se aceita pelo sacado, autoriza ação de execução independentemente da apresentação de qualquer outra prova,⁷⁹ mas que (c), não tendo sido aceita, somente constitui título executivo se vier acompanhada do instrumento de protesto e da prova da entrega da mercadoria⁸⁰ ou, em se tratando de duplicata de serviços, do instrumento comprobatório do vínculo.⁸¹

3. Inciso II. O inc. II do art. 784 elenca os seguintes títulos executivos: (a) documento público (gênero) assinado pelo devedor, de que é espécie (b) a escritura pública. Ao contrário dos demais títulos executivos extrajudiciais relacionados no Código, que se referem exclusivamente à obrigação de pagar quantia, os do inc. II podem ter como prestação também a entrega de coisa, ou as de fazer e de não fazer. Corrente doutrinária sustenta, em nome do requisito da liquidez – reconhecidamente indispensável a qualquer título executivo (CPC/2015, art. 783) –, que, no que se refere à entrega de coisa, restringe-se a executividade aos títulos cuja prestação seja de coisa certa.⁸² Há de se observar, todavia, que, nas obrigações alternativas e nas obrigações para entrega de coisas determinadas pelo gênero e quantidade (fungíveis), a incerteza é apenas aparente. O legislador, nos arts. 800 e 811 do CPC/2015, estabeleceu procedimentos adequados – aplicáveis aos títulos executivos extrajudiciais – para a individualização do seu objeto. Assim, a interpretação sistemática do Código impõe concluir que, nas situações focadas (obrigações alternativas e entrega de coisa fungível), o requisito da liquidez não está comprometido, inexistindo, conseqüentemente, empecilho à executividade do título extrajudicial.⁸³

A escritura pública, lavrada por tabelião, é espécie do gênero documento público,⁸⁴ este caracterizado pela circunstância de ser produzido por qualquer agente público cuja autoridade incute a seus atos fé pública. “Para que o instrumento seja documento público”, diz Pontes de Miranda, “é preciso que seja pública – no sentido de fé pública – a documentalidade. Supõe-se a autoridade para a função, seja judiciária ou não. O que é preciso é que, conforme a lei, o oficial

público possa funcionar na feitura do documento”.⁸⁵

4. Inciso III. Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O documento particular há de ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Não se reclama reconhecimento das firmas. Assinatura a rogo não é assinatura do devedor. É de terceiro. Quem não sabe assinar (analfabeto) ou não pode, por qualquer razão, fazê-lo, deve ser representado no título por mandatário constituído por instrumento público.⁸⁶ Testemunhar significa confirmar que o fato existiu. A fidelidade do testemunho de que o instrumento assinado espelha a realidade do que se passou, supõe a presença da testemunha ao ato de assinatura. Embora a lei não refira expressamente, é intuitivo, portanto, que o testemunho referido no inc. III seja de quem presenciou o ato, não de quem dele tomou conhecimento por terceiro.⁸⁷ Havendo dúvida razoável, é legítima a exigência de identificação das testemunhas do contrato.⁸⁸

Questiona-se a executividade dos contratos de abertura de crédito, que se caracterizam, essencialmente, pela obrigação assumida pelo banqueiro (creditor) de colocar à disposição do cliente (creditado) determinada quantia, a ser por ele utilizada de uma única ou em mais de uma vez.⁸⁹ Os que a negam, sustentam que neles o devedor não assume obrigação de pagar quantia determinada, de modo que o valor devido é incerto e depende de posterior comprovação da utilização do crédito aberto e do quanto ainda pendente de restituição. Ora, sustenta-se, há “impossibilidade de o título completar-se com extratos fornecidos pelo próprio credor, que são documentos unilaterais”.⁹⁰ Corrente mais liberal reconhece, todavia, a força executiva de tais contratos, quando o extrato da movimentação bancária tiver sido “elaborado de forma discriminada, com emprego de rubricas adequadas (especificadas), e de molde a abranger todo o período transcorrido entre a data da celebração do ajuste e a do ajuizamento da execução, possibilitando, assim, a aferição de sua exata correspondência com o que pactuado e permitindo a impugnação, em sede de embargos do devedor, dos lançamentos efetuados de modo abusivo, em descompasso com as estipulações contratuais”.⁹¹ A doutrina, em geral, endossa esse modo de pensar, notadamente quando há estipulação contratual reconhecendo como prova da utilização do crédito os cheques, saques, ordens e recibos emitidos pelo devedor.⁹² O STJ resolveu a questão na linha da primeira corrente, conforme se verifica da sua Súmula 233: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”. A súmula 247 complementa: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Pode ocorrer, todavia, que, utilizado o crédito, o devedor venha a reconhecer formalmente o valor devido. É comum na prática bancária, com efeito, a assinatura, nesses casos, de instrumentos de confissão de dívida. Ora, em tal ocorrendo, embora o primitivo contrato de abertura de crédito não seja considerado título executivo, certamente o será o documento superveniente, desde que formalizado por um dos modos previstos no inc. III do art. 784 (v.g., quando, sendo documento particular, for assinado pelo devedor e duas testemunhas).

Os contratos eletrônicos têm sido, modernamente, objeto de controvérsia sobre se constituem título executivo ou não. Embora a jurisprudência do STJ seja no sentido da interpretação restritiva do dispositivo, há precedente incluindo no rol do inciso III o contrato eletrônico de mútuo assinado digitalmente.⁹³

5. Inciso IV. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por Tribunal. Transação é forma de autocomposição do litígio mediante concessões mútuas entre os litigantes. Supõe poder de disposição do direito material, poder que o Ministério Público e a Defensoria Pública não têm.⁹⁴ Mesmo os advogados dos transatores, para transigir em nome de seus constituintes, hão de estar munidos de poderes específicos, que não se incluem na “procuração geral para o foro” (CPC/2015, art. 105). Disso resulta que o referendo a que se refere o inc. IV nada mais é do que um testemunho qualificado do ato, que, todavia, não dispensa a assinatura dos transatores ou de representantes com poderes para transigir.

O inc. IV do art. 784 inova ao incluir no rol de títulos executivos extrajudiciais também os

instrumentos de transação referendados por mediador ou conciliador. Trata-se de decorrência natural do sistema de conciliação, desde a muito incorporada ao sistema processual, e de mediação, implantada pela Lei 13.140, de 26.06.2015. Apesar de inexplicável resistência cultural à sua efetiva adoção no Brasil, conciliação e mediação constituem importantes modalidades de solução de controvérsias, razão pela qual, segundo o próprio Código de Processo, devem ser estimuladas “por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3.º, § 2.º). O êxito desses métodos resulta em acordo, que, quando celebrado fora do processo, constitui título executivo extrajudicial, na forma prevista no inc. IV do art. 784 e, quando homologado judicialmente, passa a ser título judicial, nos termos do art. 515, II e III do CPC/2015.

Realmente, a transação apta a produzir título executivo extrajudicial é a que não foi levada à homologação do juiz, ou porque o processo judicial não foi instaurado, ou porque as partes, por conveniência, preferiram dele desistir, fazendo vigorar sem a chancela do juiz o que acordaram particularmente. Todavia, qualquer que seja a modalidade de autocomposição extrajudicial, o correspondente instrumento pode ser levado a homologação judicial, hipótese em que a sentença homologatória passa a se revestir da qualidade de título executivo judicial (CPC/2015, art. 515, III), semelhante à sentença homologatória de autocomposição alcançada no curso do processo (CPC/2015, art. 515, II). Em qualquer dos casos, a sentença homologatória revestir-se-á da qualidade de decisão de mérito e, portanto, se não atacada por recurso, formará coisa julgada material, somente passível de desfazimento por ação rescisória.

Essa faculdade de levar a homologação judicial acordos celebrados extrajudicialmente foi introduzida no Código de Processo, ainda no regime de 1973, pela Lei 10.232/2006, que incluiu no rol dos títulos executivos judiciais “o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente” (CPC/1973 art. 475-N, V, cujo correspondente atual é o inc. III do art. 515: “decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”). Trata-se, bem se percebe, de título distinto do previsto no inc. III do mesmo art. 465-N do CPC/1973, ou seja, da “sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo”, cujo correspondente atual é o inc. II do art. 515, a saber: “a decisão homologatória de autocomposição judicial”.

Algumas observações, todavia, são importantes para distinguir essas espécies de título. Transação é forma de autocomposição do litígio, mediante concessões mútuas entre as partes (CC, art. 1.025). É, segundo Pontes de Miranda, “o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada ou determinadas relações jurídicas, seu conteúdo, extensão, validade, ou eficácia”.⁹⁵ O ato negocial de transação pode ser celebrado antes ou durante a pendência de processo. Em qualquer caso, sendo “negócio jurídico de direito material, tem de existir, ser válida e ser eficaz segundo os princípios de direito material, que a regem”.⁹⁶ Definindo norma jurídica individualizada da qual exsurja obrigação de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia, a transação celebrada antes do ajuizamento da ação pode constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III e IV do CPC/2015. Na pendência do processo, homologada pelo juiz, será título executivo judicial para desencadear a atividade executiva de cumprimento. Sendo título extrajudicial, a eventual oposição do devedor relativamente à validade e eficácia do ato poderá ser deduzida em embargos à execução (art. 914). O mesmo não ocorre quando há homologação judicial. Com efeito, é condição para a homologação do ato o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos pelo direito material. Ao homologá-lo, portanto, o juiz atesta a higidez do negócio, afirmando, “explícita ou implicitamente, que existiu a transação, que é válida e eficaz”.⁹⁷ É por isso que, passada em julgado a sentença (que é de mérito – CPC/2015, art. 487, III, b), a transação somente poderá ser desfeita por ação rescisória. Ao contrário do que ocorre com a transação extrajudicial, a judicial, como qualquer sentença transitada em julgado, não pode, na fase de cumprimento, ser atacada por impugnação. Nisso, aliás, reside o seu caráter de título executivo judicial: inviabiliza impugnação que deduza alegações relativas à formação do título, matéria que, implícita ou explicitamente, já foi acertada na sentença homologatória, e, por isso mesmo, está acobertada pela eficácia da coisa julgada.

Sob o ponto de vista do seu conteúdo, não há diferença entre a transação homologada judicialmente e a não homologada. É difícil compreender, destarte, como se possa sustentar que a executividade da transação supõe conteúdo condenatório,⁹⁸ a menos que se admita que as partes possam autocondenar-se extrajudicialmente e que a sentença homologatória é condenatória. Na verdade, o que dá condições de executividade à transação é a circunstância de representar a definição de norma jurídica individualizada da qual exsurge obrigação certa, com prestação líquida e exigível de entregar coisa, fazer, não fazer ou pagar quantia. A homologação judicial não modifica o conteúdo da transação, mas apenas certifica, com marca oficial, sua validade jurídica.

Pois bem, a característica do título judicial criado com a introdução do inc. V do art. 475-N do CPC/1973, agora reproduzido no inc. III do art. 515 do CPC/2015, é justamente a de ser um acordo celebrado extrajudicialmente e que é trazido a juízo, não para resolver controvérsia objeto de processo em curso, mas apenas para ser homologado. O que lhe confere a natureza de título judicial é, pois, a homologação. Sem ela, o ato seria simplesmente um título executivo extrajudicial, nos termos dos incs. III ou IV do art. 784 do CPC/2015.

A distinção entre os títulos dos incs. II e III do art. 515 reside, portanto, nisso: na hipótese do inc. II, as partes celebram acordo para resolver controvérsia objeto de uma demanda judicial em curso; e na hipótese do inc. III, o acordo não tem qualquer relação com demanda judicial estabelecida. Aqui, o Judiciário é chamado e o processo é instaurado apenas para a homologação.

É estranha à natureza típica da função jurisdicional a atividade judicial destinada a, simplesmente, homologar autocomposição extrajudicial. É, na verdade, atividade qualificada como jurisdição voluntária (CPC/2015, art. 725, III). Realmente, a função jurisdicional existe para dirimir conflitos e não para atuar em situações em que o conflito já está superado. Se as partes já chegaram a um acordo extrajudicial, o conflito (= a lide) já não existe e a função jurisdicional poderia ser dispensada. Todavia, a homologação judicial confere ao acordo, que já têm a eficácia executiva de título extrajudicial, uma importante eficácia adicional, a da ampliação do seu âmbito de proteção e de segurança jurídica, reduzindo, conseqüentemente, os limites da sua impugnabilidade. A exemplo do que ocorre nas hipóteses de conciliação e de transação destinadas a extinguir controvérsia em curso (art. 515, II), cumpre ao juiz, como pressuposto da homologação de autocomposição extrajudicial, verificar se o ato celebrado pelas partes atendeu os requisitos de validade estabelecidos pelo direito material. A homologação, portanto, é o reconhecimento oficial de que o negócio existiu, é válido e eficaz. Da sentença que assim atestar caberá apelação (CPC/2015, art. 724) e uma vez transitada em julgado, faz coisa julgada material.

Ao contrário dos do inc. I (que incorporam em si mesmos o direito material, e que, por isso mesmo, reclamam sua apresentação no original), os documentos do inc. IV do art. 784 podem ser apresentados ao juízo da execução por cópia autenticada, sejam eles documentos públicos, sejam particulares.⁹⁹

6. Incisos V e VI. Os contratos a que aludem os incs. V e VI são classificáveis em dois grupos, cada um com natureza própria: no primeiro, incluem-se os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução, que são contratos acessórios, destinados a garantir a obrigação contraída em outro contrato (denominado principal), podendo os dois constar de um único ou de mais de um instrumento; no segundo grupo estão os contratos de seguro, em que um dos contratantes (segurador) obriga-se, mediante paga (prêmio), a indenizá-lo em certa quantia caso ocorra determinado evento (risco) nele previsto, no caso, a morte.

Os contratos de garantia, por serem acessórios, submetem-se ao “princípio geral de que o acessório segue o principal”, que tem como uma das consequências a de que “a extinção do contrato principal acarreta a do contrato acessório, pois, logicamente, não lhe pode sobreviver, por faltar razão de ser”.¹⁰⁰ O crédito que dá ensejo à execução, nesses casos, é, conseqüentemente, o crédito garantido, e não propriamente o contrato que o garante.¹⁰¹ Daquele, portanto, se reclama certeza, liquidez e exigibilidade como condição para execução da garantia. Assim, nos contratos de abertura de crédito com garantia hipotecária, será indispensável que a execução seja acompanhada do adequado demonstrativo contábil dos valores devidos.¹⁰²

Os contratos do primeiro grupo enquadram-se no conceito lato de caução. A caução, lato sensu considerada, pode ser (a) real, quando a garantia consiste na vinculação de um bem (que pode ser do devedor principal ou de terceiro), ou (b) fidejussória, nos demais casos. São contratos de caução real a hipoteca, o penhor e a anticrese; são de caução fidejussória os de fiança¹⁰³ e os em que alguém, sem se dizer fiador, ou qualificando-se, equivocadamente, como “avalista”, assume, no contrato, como garante solidário, a dívida de terceiro.¹⁰⁴ É a esses últimos que se refere o Código, quando mencionou o contrato de caução, no inc. V.¹⁰⁵

Nos contratos de hipoteca (que tem como garantia um imóvel – Código Civil, art. 1.473; CC/16, art. 810), de penhor (em que se dá em garantia, mediante efetiva entrega ao credor, um objeto móvel – Código Civil, art. 1.431; CC/1916, art. 768) e de anticrese (em que se entrega ao credor um imóvel, cedendo-lhe “o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos” – Código Civil, art. 1.506; CC/1916, art. 805), é indispensável que o bem (que fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação – Código Civil, art. 1.419; CC/1916, art. 755) esteja devidamente especificado no contrato, bem como o total ou o valor estimado da dívida garantida, o prazo para o pagamento e os encargos sobre ela incidentes (Código Civil, art. 1.424; CC/1916, art. 761). Importa salientar, todavia, que a vinculação do bem não vai ao ponto de autorizar o credor a ficar com ele, se a dívida não for paga. A lei proíbe expressamente que tal ocorra, mesmo que as partes assim acordem, vedada que é a cláusula de pacto comissório (Código Civil, art. 1.428; CC/1916, art. 765). O que o credor pode obter, em qualquer dos casos, é a quantia devida, não o bem vinculado, de modo que, a rigor, como anotou Dinamarco, é impróprio denominar de ação real a execução hipotecária.¹⁰⁶ Saliente-se, por oportuno, que o pagamento da dívida poderá se efetivar, se assim acordarem as partes, por superveniente dação em pagamento do próprio bem objeto da garantia, como admite expressamente o parágrafo único do art. 1.428 do CC, mas essa faculdade não elimina a proibição de pacto comissório.

A anticrese tem como particularidade a de ser “direito real pelo qual se garante a adimplimento da percepção dos frutos do bem imóvel e imputação ao pagamento devido. Não se garante para o caso de adimplir; garante-se, com a percepção, a solução, por imputação”.¹⁰⁷

A mais comum garantia de caução fidejussória é a fiança. O contrato de fiança, pelo qual “uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso esse não a cumpra” (Código Civil, art. 818; CC/1916, art. 1.481), é contrato acessório, que tem seu destino intimamente relacionado com a dívida garantida. Pode referir-se a dívida presente ou a dívida futura (Código Civil, art. 821; CC/1916, art. 1.485); pode garantir quantia já determinada ou ainda indeterminada; e pode ser pelo valor total da obrigação principal ou por valor inferior (Código Civil, art. 823; CC/1916, art. 1.487). Tudo isso deve ser levado em consideração para apurar sua aptidão executiva. Será título executivo, nos limites da quantia garantida, quando a obrigação principal for líquida, certa e exigível,¹⁰⁸ ou seja, quando o credor tiver título executivo também em relação ao afiançado. Do contrário, não,¹⁰⁹ como é o caso do contrato de fiança para garantir dívida futura, de valor indeterminado.¹¹⁰

Os contratos de seguro que dão ensejo à execução forçada são, unicamente, os de seguro de vida. A prestação que se executa é a da indenização, cujo direito nasce, não com o nascimento da relação contratual, mas sim com a ocorrência do risco (morte). O risco, para este específico efeito, por ser “acontecimento incerto, independente da vontade das partes”,¹¹¹ é espécie de condição suspensiva, cuja ocorrência deve ser demonstrada pelo exequente no ato da propositura da ação. O título executivo, ou seja, a representação documental de uma norma jurídica individualizada contendo a obrigação do segurador de pagar ao segurado determinada quantia, será formado, nestes casos, pela apólice de seguro e pela prova da morte.¹¹² Os demais contratos de seguro dependem das formalidades do inc. III para assumirem a natureza de título executivo.

7. Incisos VII, VIII e X. Os créditos decorrentes de “foro” e “laudêmio” de bem imóvel relacionam-se a uma espécie de direito real sobre coisa alheia, a enfiteuse, prevista no Código Civil de 1916 (arts. 678 a 694) e abolida pelo Código de 2002, que expressamente proibiu “a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei 3.071, de 01.01.1916, e leis posteriores” (art. 2.038). São títulos executivos,

consequentemente, apenas os créditos de foro e laudêmio decorrentes de enfiteuses constituídas sob a égide do Código Civil de 1916. Segundo dispunha o art. 678 daquele Código, “dá-se a enfiteuse, aforamento, ou empraçamento, quando por ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui a outrem o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro anual, certo e invariável”. “Sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por venda ou dação em pagamento”, acrescentava o art. 686, “o senhorio direto, que não usar da opção [de adquiri-lo pelo mesmo preço e nas mesmas condições – art. 683], terá direito de receber do alienante o laudêmio, que será de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o preço da alienação, se outro não tiver sido fixado no título de aforamento”. A enfiteuse ajustada em contrato escrito é título executivo para cobrança da pensão anual (foro). Quanto ao laudêmio, o título para sua cobrança é mais complexo: compõe-se, não apenas do contrato de enfiteuse, mas também do instrumento de alienação do domínio útil pelo enfiteuta, onde conste o respectivo preço, base de cálculo do valor devido ao senhorio direto, documento indispensável para demonstrar a certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação.

Aluguel é a retribuição devida pelo uso e gozo da coisa objeto de contrato de locação. Tanto o aluguel, quanto outras rendas imobiliárias, podem ser exigidas por via de ação de execução sempre que forem ajustadas em contrato escrito, independentemente de assinatura de testemunhas. Se o contrato, originalmente com prazo determinado, tiver sido prorrogado sem fixação de vencimento, ainda assim não perde sua eficácia executiva.¹¹³ Se houver sublocação, o contrato será título executivo se observar as mesmas condições da locação, nomeadamente a de ser ajustado por escrito.¹¹⁴

O inc. VIII do Código atribui executividade a contratos de locação de bens imóveis, não se compreendendo nele o aluguel de coisas móveis. É o que sustenta a doutrina, de um modo geral.¹¹⁵ Será, contudo, título executivo o contrato de coisa móvel enquadrável no inc. II, III ou no inc. IV do art. 784, vale dizer, quando estiver assinado também por duas testemunhas, ou constar de escritura pública ou decorrer de transação referendada. Se a locação for mista – ou seja, do bem imóvel e de bens móveis – há que se distinguir a situação (a) em que os móveis são os que guarnecem o imóvel e se destinam ao fim econômico da locação (mesa, cadeiras, camas e fogão, na locação de fim residencial; escrivaninhas, telefone e computador, na locação comercial para escritório), daquela (b) em que nenhuma relação existe entre um e outro (locação do apartamento e do automóvel; da casa e do barco). Na situação (a), a “relação de pertencibilidade”¹¹⁶ dos móveis em relação ao imóvel, impõe que se considere aqueles integrantes deste para fins de definição da eficácia executiva do contrato. Na situação (b), ao contrário, o tratamento há de ser distinto e autônomo para cada espécie de coisa locada.

O encargo de condomínio também pode ser cobrado por via executiva quando “documentalmente comprovado”, seja ele referente aos encargos – ordinários ou extraordinários – devidos pelo locatário (inc. VIII), seja ele referente ao próprio condômino proprietário diante do condomínio (inc. X). Nos demais casos, sua cobrança há de seguir o procedimento comum. Por contrato “documentalmente comprovado” há de se entender o conjunto das deliberações dos condôminos (convenção de condomínio e a ata de assembleia) que estabeleceu o valor da cota devida pelos condôminos e o prazo para ser recolhida ao condomínio.¹¹⁷ Se não houver prévia definição do valor ou do prazo, a cobrança supõe ação de conhecimento pelo rito sumário.

8. Inciso IX. Considera-se dívida ativa da Fazenda Pública qualquer valor cuja cobrança seja atribuída, por lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou às suas autarquias, independentemente de se tratar de dívida tributária ou não. É a definição dada pelo art. 2.º da Lei 6.830, de 22.09.1980, que estabelece procedimento próprio para a respectiva execução forçada. O título executivo é a certidão de dívida ativa, extraída dos registros da respectiva inscrição efetuada pelo órgão da entidade pública. A inscrição é o ato pelo qual se define, no âmbito administrativo, a liquidez e certeza do crédito (art. 2.º, § 3.º), devendo constar do respectivo termo o nome do devedor e dos demais responsáveis, o respectivo endereço (se conhecido), o valor originário da dívida, sua origem e natureza, o termo inicial e a forma de calcular os encargos legais ou contratuais sobre ela incidentes (juros, correção monetária, multas), o número do processo administrativo ou do auto de infração (se houver) e a data da inscrição (art. 2.º, § 5.º). “A Certidão

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente” (§ 6.º), podendo, ambos, “ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico” (§ 7.º).

Inscrição em dívida ativa não se confunde com o lançamento tributário, nem com a constituição do crédito não tributário da Fazenda Pública. “A inscrição, como Dívida Ativa, só ocorre após o lançamento definitivo do crédito tributário ou a apuração dos demais créditos e depois de transcorrido, na esfera administrativa, o prazo fixado para o respectivo pagamento”.¹¹⁸ Só há inscrição em dívida ativa quando a obrigação consistir em pagamento de quantia certa.¹¹⁹ As demais obrigações – de entrega de coisa, de fazer ou de não fazer – para com as pessoas de direito público, submetem-se ao regime comum dos títulos executivos.¹²⁰

Diferentemente dos demais títulos executivos, a certidão de dívida ativa poderá ser “emendada ou substituída” pelo exequente enquanto não for proferida “a decisão de primeira instância” (§ 8.º do art. 2.º da Lei 6.830/1980), assim entendida a sentença que julga os embargos do executado ou a que extingue o processo de execução (por exemplo, quando o juiz conhece, de ofício ou provocado por exceção de pré-executividade, matéria relacionada com pressupostos processuais ou condições da ação ou mesmo com a nulidade do título).¹²¹

9. Inciso XI. O valor dos emolumentos e despesas devidas por atos de serventuário judicial ou de registro, certificado pela própria serventia, constitui título executivo extrajudicial. Trata-se de espécie nova, não prevista no Código revogado. A força executiva da certidão se justifica pela presunção de legitimidade do débito, decorrente não só do controle oficial a que estão sujeitos os atos dos serventuários da justiça, como também da subordinação ao estrito princípio da legalidade do valor dos emolumentos e demais despesas deles decorrentes.

10. Inciso XII. A criação de novos títulos executivos extrajudiciais supõe observância do princípio da legalidade em sentido estrito. Explica-se a exigência pela enorme repercussão que o fenômeno acarreta em relação à posição das partes no processo. A outorga de executividade ao título não apenas permite a imediata busca da tutela de execução, como também (a) atribui presunção juris tantum de certeza da obrigação nele representada, (b) torna eventual e não necessário o processo de cognição e (c) impõe inversão da iniciativa na busca da tutela cognitiva, com a consequente atribuição do ônus da prova ao devedor. Somente a lei pode produzir legitimamente tão graves consequências. A norma do inc. XII é cogente, não sendo disponível à autonomia de vontade. Não se admite pacto executivo negocial, a criação de título executivo por contrato ou por renúncia extrajudicial aos meios de tutela oferecidas ao devedor. “A pretensão de execução, como toda pretensão à tutela jurídica, é criada pelo Estado, e não pelas pessoas contratantes ou declarantes unilaterais”.¹²²

Mesmo ao legislador se impõe limites à criação de títulos extrajudiciais. Cada novo título extrajudicial, com efeito, representa um passo em direção à efetividade da tutela dos direitos, mas, em contrapartida, significa também um risco à segurança jurídica. Há de atentar o legislador, por isso mesmo, para o princípio da proporcionalidade, de modo a evitar que, em nome de um valor jurídico, se venha a comprometer irremediavelmente a outro, igualmente importante.

São vários e de diversa natureza os títulos executivos extrajudiciais criados por lei especial. Há os que representam criação de norma jurídica individualizada fundada no poder negocial (títulos de crédito rural, criados pelo Dec.-lei 167, de 14.02.1967; títulos de crédito industrial, criados pelo Dec.-lei 413, de 09.01.1969; títulos de crédito comercial, criados pela Lei 6.840, de 03.11.1980; Cédula de Produto Rural, criada pela Lei 8.929, de 22.08.1994, referente a obrigação de “entrega de coisa incerta” – art. 15; contrato escrito de honorários advocatícios – art. 24 da Lei 8.906, de 04.07.1994; compromisso arbitral fixando os honorários dos árbitros – art. 11, parágrafo único da Lei 9.307, de 23.09.1996, entre outros). E há os que representam norma jurídica individualizada identificada por ato de autoridade administrativa (decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou de multa – art. 71, § 3.º, da Constituição; decisões da Comissão de Valores Mobiliários, impondo multas – art. 32 da Lei 6.385, de 07.12.1976; decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, cominando multa ou impondo obrigação de fazer ou não fazer – art. 60 da Lei 8.884, de 11.06.1994, entre outros). O que todos têm em comum, inclusive

as decisões do Tribunal de Contas,¹²³ é a submissão ao controle jurisdicional no que se refere aos requisitos de legalidade. Provocado por embargos ou por ação anulatória, poderá o Judiciário examinar a legitimidade do procedimento administrativo e dos atos de que resultou a criação do título, podendo negar validade e eficácia executiva aos que não apresentam os indispensáveis requisitos exigidos pela respectiva lei autorizadora.

11. Ação de execução e ação cognitiva do devedor. A demanda, proposta pelo devedor, para ver anulado o título executivo ou ver declarada a inexistência da relação jurídica de débito e crédito, ou para consignar a quantia ou a coisa, não guarda identidade com a ação de execução. São ações diferentes na causa de pedir e no pedido. Não há como estabelecer-se entre elas relação de litispendência. Uma não prejudica o ajuizamento da outra.

Entre ação de execução do título e outra ação a ele relacionada, há laço de conexão (CPC/2015, art. 55, § 2.º, I), a determinar, em princípio, em nome da segurança jurídica e da economia processual,¹²⁴ a reunião dos processos, prorrogando-se a competência do juiz do caso cujo registro ou distribuição se deu antes (CPC/2015, art. 59). Tal prorrogação não ocorre, todavia, se importar comprometimento da competência absoluta (como, por exemplo, se a execução é da competência estadual e a ação anulatória do título, por ter sido proposta também contra ente público federal, seja da competência da justiça federal).¹²⁵

O disposto no § 1.º, do art. 784, representa concretização normativa do direito constitucional de ação e de acesso à justiça.¹²⁶ Por isso mesmo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele medidas liminares que, limitando a eficácia do dispositivo – e, conseqüentemente, do direito constitucional que ele representa – impedem o exercício da pretensão à tutela jurisdicional executiva.¹²⁷ Se a ação de execução depende do protesto do título (como, por exemplo, em caso de duplicata não aceita) e este tiver sido sustado por medida judicial, ainda assim há de se privilegiar o direito constitucional de acesso à justiça: “mantém-se a vedação do protesto, ressalvando-se, expressamente, seja aquela (a ação de execução) instaurada”.¹²⁸

Nas execuções da dívida ativa de natureza fiscal, há a peculiaridade decorrente do art. 151 do Código Tributário Nacional, que prevê situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais “o depósito do seu valor integral” (inc. II). Se a obrigação é inexigível, a execução não pode ser instaurada (CPC/2015, art. 783 e art. 803, I), o que significa que o dispositivo limita o acesso do Fisco ao Judiciário, merecendo, por isso mesmo, interpretação restritiva. O depósito, em garantia, do valor integral do crédito reclamado, tem função e natureza semelhante à da penhora de dinheiro, por nomeação do contribuinte, para ajuizamento de embargos de devedor, com o conseqüente efeito suspensivo dos atos da execução.¹²⁹ Essa semelhança explica e justifica a suspensão da exigibilidade do crédito: com o depósito, o Fisco obtém, na prática, a mesma garantia que obteria se ajuizasse a ação e penhorasse dinheiro. Mas, para operar essa eficácia de inibir o acesso do Fisco ao Judiciário, o depósito (a) há de ser integral e em dinheiro (Súmula 112 do STJ) e (b) será convertido em renda pública ao final do processo se o contribuinte não obtiver, no mérito, sentença favorável.¹³⁰

O inc. IV do art. 151 do CTN, por sua vez, estabelece como causa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário “a concessão de medida liminar em mandado de segurança”. Também esse inciso mereceu interpretação limitadora, o que fazia concluir que somente a liminar concedida especificamente em ação de mandado de segurança (em que se supõe presente relevância do direito líquido e certo do contribuinte) é que podia gerar a suspensão e assim impedir a ação de execução fiscal. Entendia-se que não era cabível, por exemplo, outorgar semelhante força à medida cautelar que, “ajuizada quando há necessidade de produção de provas, não evidencia de plano as razões suscetíveis de abalar a presunção de legitimidade do crédito tributário”.¹³¹ Sobreveio, todavia, a LC 104, de 11.01.2001, acrescentando o inc. V ao art. 151 do CTN, segundo o qual também suspende a exigibilidade do crédito tributário “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. A inovação, que atualiza o CTN às novas formas de tutela jurisdicional de urgência, não existentes à época da sua entrada em vigor, elimina a discussão sobre os limites de aplicação do inc. IV.¹³²

Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução, o inverso também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação. O meio típico de que dispõe para isso é a ação de embargos de devedor (CPC/2015, art. 914), que, proposta na devida oportunidade (art. 915) e, se for o caso, com garantia do juízo (CPC/2015, art. 919, § 1.º), tem a eficácia especial de suspender os atos executivos até seu julgamento (CPC/2015, art. 914). Todavia, referido prazo não é decadencial, a não ser no que se refere ao direito de suspender a execução. Assim, não tendo sido proposta a ação de embargos ou tendo o respectivo processo sido extinto sem julgamento de mérito, nada impede que o devedor intente outra ação cognitiva com aquele mesmo propósito,¹³³ embora sem a eficácia de suspender a ação executiva, cujos atos podem ser paralelamente praticados.¹³⁴ Não tem sentido, por exemplo, que se iniba o acesso ao Judiciário do executado que, tendo interesse em desconstituir o título executivo, não dispõe de bens para oferecer em penhora e assim ajuizar embargos suspensivos. Seu direito de ação, nesse caso, poderá ser exercido independentemente de garantia do juízo, pelo rito comum, sendo que o efeito suspensivo da execução, nas circunstâncias, opera-se por outra causa: pela falta de bens penhoráveis (CPC/2015, art. 921, III).

Os embargos do devedor têm natureza de ação de conhecimento, razão pela qual não podem reproduzir o pedido ou a causa de pedir de outra ação cognitiva eventualmente já proposta. Isso configuraria litispendência.¹³⁵ A solução, nestas circunstâncias, é a de dar à ação anterior o tratamento que se daria à ação de embargos, inclusive com suspensão da execução, o que somente poderá ser negado se o devedor não promover a garantia do juízo, com o depósito ou a penhora, nos casos que a lei assim o exigir.¹³⁶

12. Título executivo extrajudicial estrangeiro. Título oriundo de país estrangeiro é o produzido em outro país, ainda que seus figurantes sejam brasileiros. É o “título assinado e datado no estrangeiro”.¹³⁷ Ao contrário das sentenças judiciais e arbitrais estrangeiras (que dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal e que são executadas perante a Justiça Federal), os títulos extrajudiciais oriundos do estrangeiro podem ser executados no Brasil independentemente daquela formalidade, regendo-se a competência interna pelas normas gerais (CPC/2015, art. 781).

Todavia, para ter eficácia executiva em nosso País, o título estrangeiro (a) “há de satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração” e (b) há de “indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação”. Decorrencia de (a) é que, “se o título extrajudicial não é tido, na lei estrangeira que o rege, como título executivo, isso obsta a que o seja no Brasil, mesmo se a lei brasileira o faz tal”.¹³⁸ Além dos citados requisitos, a execução supõe que (c) a obrigação seja líquida, certa e exigível, (d) o título seja traduzido para o vernáculo e (e) o seu valor seja convertido em moeda nacional.¹³⁹

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

1. Processo de execução como procedimento especial. Em dispositivo inovador, sem correspondente na legislação anterior, o novo Código de Processo Civil faculta ao credor de título executivo extrajudicial optar pelo processo de conhecimento e, desse modo, obter a certificação do seu crédito antes de promover qualquer ato executivo. Assim, a atividade cognitiva, que seria eventual e por iniciativa do executado na fase de embargos, é antecipada por provocação do próprio credor.

De alguma forma, esse dispositivo revela a compreensão do legislador sobre a natureza de procedimento especial da execução de títulos executivos extrajudiciais. Diferentemente do que ocorria no passado, hoje já não há separação absoluta entre processo de conhecimento e processo de execução. Seguindo uma tendência que veio se acentuando a partir dos anos noventa, o Código aprofundou o chamado sincretismo processual, concentrando em procedimento único, sempre que possível, atividades jurisdicionais cognitivas e executivas. Daí porque não faz sentido cogitar-se de um processo com funções diversas, mas tão somente de um procedimento voltado à tutela de

situações diferenciadas. O que se leva em consideração, em tais circunstâncias, não é propriamente a natureza do direito material objeto da demanda (como ocorre ordinariamente em procedimentos especiais), mas a preocupação de formatar procedimento apto a propiciar a tutela jurisdicional por modo mais adequado e eficaz. Assim, relativamente a títulos executivos extrajudiciais, a instituição da especialidade do procedimento advém da presunção de legitimidade da obrigação e da correspondente força executiva outorgada pelo ordenamento ao título que a representa, o que permite superar, sem grandes riscos de abusos contra o devedor, a prévia certificação judicial da efetiva existência do crédito.

A propósito, quando da apresentação do anteprojeto do Código, vozes importantes da doutrina propugnavam a inclusão dos processos voltados à execução de títulos executivos extrajudiciais dentro de um grupo maior de procedimentos voltados à tutela jurisdicional diferenciada.¹⁴⁰ O fato de as execuções fundadas em título executivo extrajudicial estarem previstas em livro próprio (“Processo de Execução”) não significa que estejam submetidas a um processo autônomo e puro. Ao contrário, as previsões especiais ligadas à sua tramitação, bem como os espaços de atividade cognitiva que oferecem em sua tramitação (como, por exemplo, os relativos à cognição na arrematação), dão conta de que se trata de um instrumento de tutela jurisdicional diferenciada.

2. Possibilidade de utilização do procedimento comum a despeito da existência de título executivo extrajudicial. O art. 785 prevê a possibilidade de escolha pelo credor do procedimento que entender mais adequado, ainda que detenha título executivo extrajudicial. Na esteira do que a própria doutrina propugnava a algum tempo¹⁴¹ com acolhida da jurisprudência,¹⁴² passa a execução a ser uma verdadeira faculdade de quem se afirma titular do direito. A existência de técnicas executivas (e mesmo da técnica antecipatória) diferenciadas no âmbito do procedimento comum em relação ao procedimento especial de execução de título executivo extrajudicial permite vislumbrar alguma utilidade nessa opção.¹⁴³ Além disso, por não dispensar, mas apenas inverter a iniciativa de promoção do contraditório, a execução do título pode, em certas circunstâncias, acarretar maior demora na entrega da prestação devida, notadamente se houver embargos, cujo domínio cognitivo é, como se sabe, o mais amplo possível.

Seção II

Da Exigibilidade da Obrigação

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título.

1. Requisitos específicos da execução. Deve-se à influência de Liebman a qualificação, pelo Código, do inadimplemento do devedor e do título executivo como “requisitos necessários para realizar qualquer execução”. Segundo a doutrina liebmaniana, toda a execução tem um pressuposto prático, o inadimplemento, e um pressuposto legal, o título executivo. “A situação de fato que pode dar lugar à execução”, escreveu ele, “consiste sempre na falta de cumprimento de uma obrigação por parte do obrigado. Só quando se verifica uma situação dessa espécie é que surge a razão de ser, o interesse prático concreto para fazer-se a execução”.¹⁴⁴ E acrescentou: “a existência de um crédito insatisfeito não é porém suficiente para que possa pedir-se a execução. É ainda necessária a existência de uma sentença legalmente pronunciada, verificando esse fato e condenando o devedor. Tal ato tem eficácia de título executório e funciona como condição necessária e suficiente da execução, segundo o princípio tradicional: nulla executio sine titulo”.¹⁴⁵

A marca dessas lições ficou plasmada no Capítulo IV do Título I do Livro II da Parte Especial do Código, cuja Seção I trata “do título executivo” e cuja Seção II trata “da exigibilidade da obrigação”.

2. Inadimplemento, interesse de agir e mérito. No que se refere especificamente ao pressuposto do inadimplemento, a doutrina, de um modo geral, enquadra-o como condição da ação de execução relacionada ao interesse de agir.¹⁴⁶ O próprio Liebman, conforme se viu, sugeria

esse caminho ao referir-se ao inadimplemento como “razão de ser” da execução: se houve adimplemento, ou se ainda não houve o inadimplemento, não há por que buscar tutela jurisdicional, totalmente desnecessária nas mencionadas circunstâncias.

Todavia, essa orientação não se mostra correta, notadamente quando contrastada com a formulação clássica da teoria das condições da ação. Segundo os padrões clássicos, as condições da ação têm integral independência em relação ao mérito da causa, de tal modo que, ausentes aquelas, nada impediria que a pretensão de mérito pudesse vir repetida em outra ação posterior (CPC/2015, art. 485, VI, combinado com o seu § 2.º). Pode-se imaginar, com efeito, hipótese de execução de título de crédito ainda não vencido, caso em que, extinto o processo, poderia o credor, no futuro, vencido o prazo e não pago o valor do débito, repetir a ação. É situação em que o inadimplemento não havia ocorrido, mas poderia vir a ocorrer. No entanto, outra é a situação jurídica quando se promove a execução de um título de crédito já pago. Nessa hipótese não há inadimplemento porque houve adimplemento, de modo que, muito mais que a falta de interesse de agir, há, no caso, improcedência da ação executiva, que certamente não poderá ser repetida. Idêntica seria a solução para eventual demanda, em ação de conhecimento, em que se formulasse pedido condenatório de dívida já paga. Em casos tais, ninguém se aventuraria a contestar que o inadimplemento é tema relacionado com a própria existência do direito, ou seja, é questão de mérito, e não de processo. Mesmo no primeiro exemplo, a eventual ação executiva posterior não seria simples repetição da primeira. Ela somente se viabilizaria se e quando sobreviesse modificação no estado de fato, ou seja, a superveniência do vencimento e o não cumprimento da obrigação.

Essas considerações abonam a doutrina que considera imprópria a inclusão do inadimplemento como requisito da execução.¹⁴⁷ “Não é só interesse processual o que falta ao credor que promove a execução sem ter ocorrido o inadimplemento (...). Falta-lhe a ação (de direito material)”, escreveu Pontes de Miranda.¹⁴⁸ O inadimplemento, na verdade, é instituto jurídico do domínio do direito material e o questionamento a seu respeito integra o objeto litigioso da ação executiva, ou seja, o seu próprio mérito.¹⁴⁹ Inadimplemento não é condição da ação de execução, mas condição para realizar legitimamente os atos executivos, ou, em outras palavras, condição para uma ação executiva procedente.¹⁵⁰

3. Conceito de inadimplemento. O Código revogado, no parágrafo único do art. 580, conceituava o inadimplemento como a não satisfação espontânea do “direito reconhecido pela sentença” ou da “obrigação, a que a lei atribuir a eficácia de título executivo”. Referia-se, o dispositivo, ao inadimplemento culposo, ou seja, àquele em que “a obrigação não é cumprida por fato imputável ao devedor”.¹⁵¹ Distingue-se dele, com efeito, o inadimplemento fortuito, involuntário, decorrente de acontecimento estranho à vontade do obrigado e que torna impossível o cumprimento da obrigação. Do inadimplemento culposo resulta a responsabilidade do devedor. Do fortuito, não, já que em nosso direito está consagrado o princípio da exoneração pela inimputabilidade.¹⁵² Ressalva-se, no último caso, as situações em que o devedor assumiu a responsabilidade pelo caso fortuito ou a força maior, ou em que estes ocorreram quando o devedor já se encontrava em mora (art. 1.058 do CC/1916). Esses são conceitos típicos do direito material, que, portanto, apesar do silêncio do novo Código, ainda devem ser considerados.

O inadimplemento pode ser relativo ou absoluto. A mora é inadimplemento relativo. É o inadimplemento em que o devedor não entregou a prestação devida, mas ainda subsiste a possibilidade de entrega. Diferencia-se do inadimplemento absoluto porque neste, o não cumprimento vem associado à impossibilidade de futuro atendimento da prestação específica, de forma que o credor, além de não ter recebido a coisa, o fato ou a abstenção devida, já não pode mais alimentar expectativa de vir a recebê-los. “O descumprimento da obrigação”, ensina Silvio Rodrigues, “pode ser relativo ou absoluto. No primeiro caso, isto é, quando a obrigação não foi cumprida em tempo, lugar e forma devidos, mas poderá sê-lo, proveitosamente para o credor, dá-se a mora. Quando a obrigação não foi cumprida, nem poderá sê-lo, proveitosamente para o credor, dá-se o inadimplemento absoluto”.¹⁵³ Há mora do devedor, como pode haver também do credor. “Mora do devedor (mora debitoris)”, nas palavras de Pontes de Miranda, “é o retardo, a demora, contrária ao direito, da prestação, por alguma causa imputável a ele. Mora do credor

(mora creditoris, mora accipiendi) é o retardo no adimplemento pelo credor, porque o credor omite a cooperação indispensável. Não há mora sem demora; por isso mesmo, se a prestação não mais pode ser feita, não há mora: há impossibilidade da prestação”.¹⁵⁴

O inadimplemento a que se refere o art. 786 do CPC/2015 é tanto o relativo, quanto o absoluto,¹⁵⁵ desde que se trate de obrigação prevista em título executivo. No primeiro caso, a execução será pela prestação específica. No segundo, a execução será a genérica, por equivalente em dinheiro (antecedida, se for o caso, de ação de liquidação), ou, em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer e sendo isso viável, por “providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”, na forma prevista no art. 497 do CPC/2015. Configura-se inadimplemento absoluto, a permitir a execução genérica, independentemente de prévia sentença condenatória, quando há deterioração da coisa (CPC/2015, art. 809) ou a superveniente impossibilidade da prestação do fato, como nos casos em que a prestação só poderia ter ocorrido em dia certo ou sob circunstâncias que já não mais se reproduzirão, hipóteses em que as perdas e danos serão apurados em liquidação (CPC/2015, art. 816, parágrafo único).

Se o inadimplemento absoluto de obrigação de fazer ou de entregar coisa ficar evidenciado antes do início da execução, inviabilizando desde logo a própria propositura da execução específica, oferece-se ao credor a via da execução genérica ou por providência de resultado prático equivalente (no caso de obrigação de fazer) ou pelo valor das perdas e danos, hipótese em que deverá ser antecedida de liquidação.¹⁵⁶

4. Controle do requisito do inadimplemento. Em regra, a ausência do requisito do inadimplemento deve ser alegada pela via de embargos (art. 910, § 2.º, e art. 917, do CPC/2015). Porém, em certas circunstâncias, sendo notório o adimplemento ou a inexigibilidade (e por notório há de se entender o fato cuja comprovação independe de dilação probatória), nada impede que o juiz conheça a matéria de ofício. E sendo conhecível de ofício, nada impede que o próprio executado a suscite, independentemente de penhora ou de embargos, por simples petição, mediante via que se convencionou denominar exceção de pré-executividade.¹⁵⁷

5. Mero cálculo aritmético. O que já estava implícito no Código revogado está agora expresso no parágrafo único do art. 786: não é considerada ilíquida, para fins de execução, a obrigação cujo valor possa ser apurado por “simples operações aritméticas”. A exemplo do que ocorre também com títulos executivos judiciais, dispensa-se procedimento específico de liquidação quando o valor for apurável por mero cálculo. Em casos tais, cumpre ao exequente, aos instaurar a execução, apresentar com a petição inicial “o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação” (art. 798, I, b), o que permitira ao devedor, se for o caso, exercer o controle sobre o acerto da dívida, impugnando eventuais excessos.

Art. 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.

Parágrafo único. O devedor poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa; caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba, sem cumprir a contraprestação, que lhe tocar.

1. Prova da contraprestação. A matéria do caput tem relação íntima com a do art. 476 do Código Civil (art. 1.092 do CC/1916): “nos contratos bilaterais”, diz-se nele, “nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. O credor que promover a execução forçada, conseqüentemente, terá o encargo de provar que cumpriu a contraprestação que lhe corresponde. Se não o fizer, incidirá o parágrafo único: não se procederá à execução se o devedor se propõe satisfazer a prestação, com meios considerados idôneos pelo juiz, mediante execução da contraprestação pelo credor, e este, sem justo motivo, recusar a oferta.

A prova do inadimplemento da prestação a cargo do exequente é exigência que diz respeito às hipóteses de obrigações recíprocas e interdependentes, decorrentes da mesma relação jurídica, do mesmo negócio. Prestação e contraprestação devem estar interligadas organicamente. O caput tem

o mesmo pressuposto do parágrafo único: a exigibilidade da contraprestação devida pelo executado somente ocorrerá se e quando houver a entrega da prestação que cabe ao exequente. Não sendo ainda exigível a contraprestação do devedor, não há falar-se em inadimplemento. E, sem inadimplemento, não se pode realizar a execução (CPC/2015, art. 786).

Se, todavia, as prestações têm de ser atendidas sucessivamente e à do exequente for a última, não incidirá a exigência do caput. Nesse caso, o executado é obrigado a satisfazer a prestação que lhe cabe, independentemente da do credor exequente, que será devida em segundo lugar e não em primeiro e nem simultaneamente.

Verificando o juiz que não foi juntada, com a petição inicial, a prova a que se refere o caput, determinará ao exequente que supra a omissão no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 801). Se a falha escapar ao controle espontâneo do juiz, faculta-se ao devedor suscitar o tema, por simples petição na própria ação de execução. Em se tratando de requisito que o juiz pode – e até deve – controlar de ofício, nada impede que o executado provoque o tema mesmo sem embargar. Mas, não havendo meios adequados para, prontamente, demonstrar o inadimplemento do credor, que não cumpriu a prestação que lhe cabia, ou quando tal demonstração depender de dilação probatória, a objeção deve ser suscitada pelo executado em ação de embargos, configurada que está hipótese de excesso de execução, a teor do art. 917 § 2.º, IV, do CPC/2015.

2. Exoneração do devedor executado. Pode ocorrer que o executado tenha interesse não apenas em afastar a execução, mas também em, desde já, exonerar-se da obrigação. Para isso, a teor do parágrafo único, é indispensável que vá além de, simplesmente, se dispor a implementar a sua prestação. É mister que a deposite em juízo. O procedimento constitui, sem dúvida, peculiar espécie de consignação.¹⁵⁸ Aqui também, a exemplo do que se passa, *mutatis mutandis*, na ação consignatória, o depósito somente terá eficácia (= força de pagamento) quando “concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento” (CC, art. 336; CC/1916, art. 974).

Efetuada o depósito, o exequente só poderá levantar a prestação depositada quando cumprir a contraprestação que deve.

Se algum ato executivo (penhora, por exemplo) já tiver sido praticado, como proceder? O Código não responde explicitamente à questão. No entanto, interpretação sistemática leva à conclusão de que tais atos não podem subsistir. Com efeito, se o depósito exonera o executado da obrigação, já não haverá razão de ser para a execução forçada ou para manutenção de qualquer ato já praticado com essa finalidade. Sendo assim, cabe ao juiz não apenas impedir a prática de novos atos executivos, suspendendo o processo, como também determinar as providências necessárias à desconstituição, jurídica e fática, dos atos executivos já levados a cabo.

E se o credor-exequente permanecer omissa relativamente à contraprestação que lhe cabe? O depósito, que foi em consignação, e que, portanto, tem força de pagamento, já não poderá, é certo, retornar às mãos do executado. A alternativa que a este se oferece é a de promover, ele próprio, demanda judicial (ação de conhecimento ou de execução, conforme o caso) contra o exequente para haver a prestação a que tem direito.

3. Controle do adimplemento do credor. Bem se vê, do exposto, que, em casos de obrigações bilaterais a execução, para ser realizada, supõe (a) o inadimplemento do executado e, também, (b) o adimplemento do exequente. Segundo dispõe o caput do art. 787, cabe a este, já com a petição inicial, “provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do credor”. Verificando o juiz que não foi atendido esse requisito, determinará ao exequente que supra a omissão no prazo de quinze dias sob pena de indeferimento da inicial (CPC/2015, art. 801).

Se a falha escapar ao controle inicial do juiz, caberá ao devedor a iniciativa de apontá-la, o que fará por petição nos autos ou mediante embargos.¹⁵⁹ Em se tratando de requisito que o juiz pode –

e até deve – controlar de ofício, nada impede que o executado suscite a matéria mediante simples petição.¹⁶⁰ Porém, este meio será inadequado se, nas circunstâncias do caso, não ficar demonstrado, prontamente, o inadimplemento do credor ou quando tal demonstração depender de dilação probatória. Nesses casos, cumpre ao executado opor embargos, enquadrando a situação como excesso de execução, a teor do art. 917 § 2.º, IV, do CPC.

Art. 788. O credor não poderá iniciar a execução, ou nela prosseguir, se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.

1. Situações disciplinadas no dispositivo. O art. 778 disciplina, basicamente, três situações, a saber: (a) oferta e recebimento da prestação devida antes de iniciar a execução; (b) oferta e recebimento da prestação depois de iniciada a execução; e (c) oferta e recusa da prestação antes do início da execução. A solução para todas elas foi construída à base de dois princípios, um complementar do outro, ainda que, circunstancialmente, servindo a interesses contrapostos: o de que o devedor tem direito de forrar-se à responsabilidade cumprindo a obrigação e o de que o credor não está obrigado a receber prestação diversa da que tem direito.

Uma quarta situação poderá ocorrer: a (d) oferta e recusa da prestação depois da propositura da ação executiva. A solução há de ser buscada por analogia, também sob o enfoque dos mesmos princípios.

2. Adimplemento (a) antes ou (b) no curso da execução. Toda execução tem por único fim “obter para o exequente precisamente aquele benefício que lhe traria o cumprimento da obrigação por parte do devedor ou, se isto não é possível, ao menos um benefício equivalente”.¹⁶¹ Ora, se a obrigação é cumprida na devida forma, já não subsistirá razão alguma para dar início ou prosseguimento aos atos executivos. Na situação (a), em que o adimplemento ocorreu antes da propositura da ação, a execução carece de um dos seus “requisitos necessários”, o inadimplemento, de modo que o art. 778 reproduz o que já dispusera o dispositivo antecedente. O mesmo fenômeno acontece na situação (b), em que o cumprimento da obrigação se dá depois da propositura da ação executiva: o requisito necessário do inadimplemento deixa de existir por fato superveniente.

São diferentes, em cada caso, as consequências relacionadas com os ônus processuais. Na situação (a), a ação foi proposta desnecessariamente, de modo que, com a extinção do processo, deverá haver condenação do exequente nas custas e honorários. Já na situação (b), havendo inadimplemento quando da sua propositura, a ação executiva se mostrava necessária e a superveniente satisfação da prestação pelo devedor não o exime dos encargos processuais.

Na situação (a), poderá o exequente sofrer outras consequências: a da condenação por litigância de má-fé por deduzir pretensão contra texto expresso de lei (art. 80, I, do CPC/2015) e, ressalvada hipótese de ter agido de boa-fé (Súmula 159 do STF), a do pagamento de que trata o art. 940 do CC (que praticamente reproduz o art. 1.531 do CC/1916). Segundo esse artigo, “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

3. Recusa da prestação. Se o devedor oferece a prestação e o credor a recusa, estabelece-se conflito de interesses que poderá ser submetido ao Judiciário ou por iniciativa do devedor, mediante ação de consignação, ou do credor, por ação de execução. É desta última hipótese que cuida o art. 778, em sua segunda parte.

A recusa será justa se a prestação oferecida “não corresponder ao direito ou à obrigação”, diz o Código de Processo, reiterando preceito semelhante ao do art. 313 do CC, relativo ao objeto do pagamento: “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. O mesmo princípio podia ser vislumbrado no Código Civil de 1916, em seu art. 863 (obrigação de dar coisa certa) e art. 878 (obrigação de fazer). Em casos tais, proposta a ação,

poderá o devedor, em embargos, demonstrar que houve mora accipiendi.

4. Oferta da prestação após a propositura da ação. Pode ocorrer que a oferta se dê quando a ação executiva já foi proposta, e, nesse caso, há peculiaridades a serem levadas em consideração. Em se tratando de execução por quantia certa contra devedor solvente, a hipótese configura remição da execução, de que trata o art. 826 do CPC/2015. Pago o valor devido, com os acréscimos e encargos, extingue-se o processo.

Em se tratando de obrigação de entrega de coisa, a oferta deve ser acompanhada da efetiva entrega, procedendo-se, neste caso, na forma prevista no art. 807. Porém, se o credor já tiver exercido a faculdade de que trata o art. 809 – de haver perdas e danos pela não entrega oportuna da coisa – não poderá ser obrigado a voltar atrás. Aceitará ou não a prestação in natura, conforme lhe convier.

Quando se trata de obrigação de fazer ou de desfazer, a oferta do adimplemento e o efetivo atendimento da prestação, após a propositura da ação, mas fora do prazo estabelecido no título executivo e assinado pelo juiz (arts. 815 e 822), acarreta a extinção do processo, com base no art. 924, III, do CPC/2015. Todavia, se no momento da oferta o credor já tiver exercido a opção por haver perdas e danos (art. 816), a iniciativa do devedor será, em princípio, ineficaz, pois já não mais se estará diante de execução de prestação de fazer ou de desfazer e sim de prestação de pagar. Não será cabível, a esta altura, impor ao credor a renúncia à prestação cujo direito foi legitimamente alcançado. A solução mais conforme com o sistema será a de assegurar ao exequente a faculdade de optar para trás, escolhendo, entre a primitiva prestação in natura e a indenização em dinheiro, a que lhe for mais conveniente.

5. Adimplemento imperfeito. “O adimplemento ruim não basta para que o credor fique sem a pretensão e a ação”, escreveu Pontes de Miranda.¹⁶² É que o adimplemento que extingue a obrigação é somente aquele em que a prestação corresponder ao direito ou à obrigação. Se o devedor oferece prestação diferente ou insuficiente, o adimplemento é imperfeito, ruim, o que enseja ao credor o exercício da ação executiva para haver a prestação efetivamente devida.

Em se tratando de prestação divisível, o credor não está obrigado a aceitá-la em parte quando a obrigação consistia em satisfazê-la por inteiro (CC, art. 314; CC/1916, art. 889). Se aceitou prestação parcial, poderá demandar executivamente pela diferença. Há de ter o cuidado, nesses casos, de ressaltar o que já recebeu, para não incorrer nas sanções do art. 940 do CC (CC/1916, art. 1.531), acima referido. A oposição do executado, também nesses casos, deve ser manifestada, em princípio, pela via da ação de embargos, como prevê a parte final do art. 788. Não se descarta, porém, em casos de manifesto e notório adimplemento, a possibilidade de promover defesa por via de exceção de pré-executividade, a que se fez referência nos comentários ao art. 786.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Pontes de Miranda. Comentários..., cit., t. IX, p. 385.

2

STJ, REsp 4.486, 3.^a Turma, Min. Cláudio Santos, DJ de 22.10.1990, p. 11.665; REsp 32.176, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 15.08.1994, p. 20.337; REsp 46.137, 3.^a Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 14.10.1996, p. 38.999.

3

Decidiu o STJ que, no negócio de alienação fiduciária, “a venda extrajudicial do bem, independentemente de prévia avaliação ou da anuência do devedor, retira do contrato a característica de título executivo, pela perda da liquidez inerente e indispensável a tais títulos” (REsp 2.432, 4.^a Turma, Min. Athos Carneiro, DJ de 17.12.1990, p. 15.380). Decidiu, também, que, havendo “duplicatas caucionadas pelo devedor junto ao estabelecimento bancário credor, para efeito de cobrança e compensação nos valores devidos”, não haverá “liquidez e certeza da obrigação que motive a ação de execução” enquanto não houver “essa compensação e apuração do saldo de débito” (REsp 2.282, 3.^a Turma, Min. Gueiros Leite, DJ de 20.08.1990, p. 7.963).

4

José Frederico Marques. Manual..., cit., vol. IV, p. 19.

5

TAMG, Apelação 21.710, Juiz Cunha Campos, apud Alexandre de Paula, Código de processo civil anotado. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 1988, vol. III, p. 2.182.

6

Angel Latorre. Introdução ao direito. Trad. de Manuel de Alarcão. Coimbra: Livraria Almedina, 1978, p. 15.

7

Francesco Carnelutti. Instituciones..., cit., vol. I, p. 266, n. 173.

8

Enrico Tullio Liebman. Embargos do executado, cit., p. 136, n. 82.

9

Idem, p. 138.

10

Francesco Carnelutti. Derecho y proceso, cit., p. 346, n. 188.

11

Idem, p. 347, n. 188.

12

Idem, p. 348, n. 188. Em nota de rodapé, observou Carnelutti que em sua Teoria Generale del Diritto, 1. ed.,

p. 454, e a partir da 3. ed. de suas Istituzioni del Nuovo Processo Civile, ao definir título executivo, substituiu o conceito de prova legal pelo de título legal.

13

Idem, p. 347, n. 188.

14

Giuseppe Chiovenda. Instituições..., cit., vol. I, p. 310, n. 90.

15

Sobre o tema: Gian Antonio Micheli. Proceso de ejecución. Trad. de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1970, p. 3 et seq.; Crisanto Mandrioli. L'azione esecutiva. Milano: Giuffrè, 1955, p. 327 et seq.; Italo Andolina. Contributo alla dottrina del titolo esecutivo. Milano: Giuffrè, 1982 e 'Cognizione' ed 'esecuzione forzata' nel sistema della tutela giurisdizionale. Milano: Giuffrè, 1983; José Alberto Dos Reis. Processo de execução, cit., vol. I, p. 68 et seq.; J. Ramiro Podetti. Tratado de las ejecuciones. 3. ed. Buenos Aires: Ediar, 1997, p. 109 et seq.; Eduardo j. Couture. Fundamentos del derecho procesal civil. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1990, p. 448 et seq.

16

Pontes de Miranda. Comentários..., cit., t. IX, p. 222.

17

Moacyr Amaral Santos. Primeiras linhas..., cit., vol. 3, p. 217.

18

José Frederico Marques. Manual..., cit., vol. 4, p. 16.

19

Alcides de Mendonça Lima. Comentários..., cit., p. 237.

20

Amílcar de Castro, Comentários..., cit., p. 47.

21

Vicente Greco Filho. Direito processual civil brasileiro, cit., vol. 3, p. 23.

22

Marcelo Lima Guerra. Execução forçada – controle de admissibilidade, cit., p. 116.

23

Sérgio Shimura. Título executivo. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 112.

24

Francesco Carnelutti. Derecho y proceso, cit., p. 346, n. 188.

25

Amílcar de Castro. Comentários..., cit., p. 46.

26

José Carlos Barbosa Moreira. O novo processo civil brasileiro, cit., p. 342. A mesma afirmação encontra-se em outras passagens da mesma obra: a execução consiste “em dar efetividade prática à regra jurídica concreta que deve disciplinar a situação” (p. 288), e “representa a efetivação da norma jurídica concreta aplicável à situação” (p. 297).

27

Enrico Tullio Liebman. Manual..., cit., p. 208.

28

Francesco Carnelutti. Derecho y proceso, cit., p. 328.

29

Goffredo Telles Júnior. Direito quântico, cit., p. 263.

30

Luis Recasens Siches. Estudios de filosofía del derecho. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1936, p. 128. No mesmo sentido: Maria Helena Diniz. Compêndio..., cit., p. 341.

31

Antonio Carlos de Campos Pedroso. Normas jurídicas individualizadas: teoria e aplicação. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 123.

32

33

O próprio autor da referida tese, Ronaldo Cunha Campos, em outra passagem de sua obra, reconhece que a “fixação e atuação da sanção (é) território (...) reservado ao monopólio estatal” (p. 15). Inobstante, sustenta que “o título extrajudicial implica exceção. A lei comunica a determinados atos dos interessados a eficácia de acertar a sanção. Esta a nosso sentir o significado do ato denominado título extrajudicial” (p. 15).

34

Araken de Assis. Manual..., cit., p. 121; José Frederico Marques. Manual..., cit., vol. 4, p. 19; Moacyr Amaral Santos. Primeiras linhas..., cit., vol. 3, p. 217. Em sentido contrário, entendendo que “a identificação dos titulares do direito e da obrigação (...) é estranha à teoria do título executivo”, Cândido Dinamarco. Execução civil, cit., p. 490.

35

Liebman, Embargos do executado, cit., p. 126. No mesmo sentido: Gian Antonio Micheli. Proceso de ejecución, cit., p. 13.

36

Marcelo Lima Guerra. Execução forçada, cit., p. 115.

37

Clóvis V. do Couto e Silva. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1976, p. 10.

38

Humberto Theodoro Júnior. Curso..., cit., vol. II, p. 741.

39

Amílcar de Castro. Comentários..., cit., p. 57.

40

José Maria Gonçalves Sampaio. A acção executiva e a problemática das execuções injustas. Lisboa: Cosmos, 1992, p. 326.

41

Ovídio A. Baptista da Silva. Curso..., cit., vol. II, p. 33.

42

José Alberto dos Reis. Processo de execução, cit., vol. 1, p. 73.

43

Enrico Tullio Liebman. Processo de execução, cit., p. 9-10.

44

Idem, p. 10.

45

Italo Andolina. “Cognizione” ed “esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale, cit., p. 14.

46

Enrico Tullio Liebman. Manual..., cit., p. 212.

47

Pontes de Miranda. Comentários..., cit., t. IX, p. 30.

48

A constitucionalidade destes dispositivos do CPC foi reconhecida pelo STF na ADI 2418, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 04.05.2016, com a seguinte ementa: “constitucional. (...) Legitimidade da norma processual que institui hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (Art. 741, parágrafo único e art. 475-L, § 1.º do CPC/1973; Art. 525, § 1.º, III E §§ 12 e 14 E Art. 535, III, § 5.º do CPC/2015). (...) 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1.º do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1.º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5.º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Ação julgada improcedente”.

49

Romano Vaccarella. Titolo esecutivo, precetto, opposizioni. 2. ed. Torino: Utet, 1993, p. 100.

50

Pontes de Miranda. Comentários..., cit., t. IX, p. 63 e 69.

51

Andrea Proto Pisani. Appunti sulla tutela cautelare. Rivista di Diritto Civile 1/113, 1987.

52

Teori Albino Zavascki. Antecipação da tutela, cit., p. 31.

53

Abordamos o tema em Antecipação da tutela, cit., p. 61.

54

Sobre o tema: Romano Vaccarella. Titolo esecutivo, precetto, oppsizioni, cit., p. 101-103.

55

Antonio Carlos De Campos Pedroso, Normas jurídicas individualizadas, cit., p. 124.

56

Hans Kelsen, Teoria geral das normas, Trad. de José Florentino Duarte, Porto Alegre: Fabris, 1986, p. 337.

57

Waldirio Bulgarelli, Títulos de crédito, 12. ed., São Paulo: Atlas, 1996, p. 58.

58

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 270.

59

Nesse sentido a doutrina: Alcides Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 287; Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 111; Sérgio Shimura, Título executivo, cit., p. 263. Na jurisprudência do STJ, REsp 33.530, 3ª Turma, Min. Dias Trindade, DJ 24.05.1993, p. 10.008; REsp 62.290, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 29.04.1996, p. 13.414; REsp 73.544, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 29.10.1996, p. 41.642.

60

Nesse sentido: STJ, REsp 16.153, 3ª Turma, Min. Nilson Naves, DJ 04.05.1992, p. 5.886.

61

Waldirio Bulgarelli, Títulos de crédito, cit., p. 59.

62

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 267.

63

STJ, REsp 16.855, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 07.06.1993, p. 11.261.

64

STJ, REsp 67.206, 4ª Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 23.10.1995, p. 35.681.

65

STJ, REsp 2.598, 3ª Turma, Min. Athos Carneiro, Revista Jurídica 161/78.

66

Norberto Da Costa Caruso Mac'donald, Ação cambiária, Revista de Estudos Jurídicos (Centro de Ciências Jurídicas da Unisinos) 17/112.

67

Súmula 27 do STJ: “Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio”.

68

STJ, REsp 3.238, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 19.11.1990, p. 13.262. No mesmo sentido: REsp 19.774, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 01.06.1992, p. 8.053; REsp 16.853, 4ª Turma, Min. Athos Carneiro, DJ 22.03.1993, p. 4.547; REsp 34.719, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 02.08.1993, p. 14.257.

69

Nesse sentido, STJ, REsp 4.685, 3ª Turma, Min. Nilson Naves, em cuja ementa se lê: “Avalista. Litigância de má-fé do avalizado. Responde o avalista, do mesmo modo que o avalizado, pelo que emerja do título. Não pode ser responsabilizado, entretanto, pela conduta processual do avalizado. Assim, não é possível exigir-lhe o pagamento, devido em decorrência da litigância de má-fé daquele” (DJ 25.02.1991, p. 1.468).

70

Pedro Barbosa Pereira, Curso de direito comercial, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1969, vol. II, p. 136.

71

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 268.

72

Sobre o regime das defesas e exceções oponíveis nas ações cambiárias, consultar Norberto da Costa Caruso Mac'donald, Ação cambiária, cit., p. 113 et seq.

73

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 267.

74

Waldirio Bulgarelli, Títulos de crédito, cit., p. 60.

75

Darcy Arruda Miranda Júnior, Curso de direito comercial, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 3., p. 3. Na jurisprudência do STJ: REsp 3.593, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 19.11.1990, p. 13.259.

76

STJ, REsp 43.119, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, Revista Jurídica 243/61.

77

STJ, REsp 11.961, 4ª Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, RSTJ 99/285. No mesmo sentido o precedente citado naquele acórdão: REsp 14.012, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo.

78

STJ, REsp 6.004, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 05.08.1991, p. 9.996.

79

STJ, REsp 19.718, 4ª Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 16.11.1992, p. 21.146.

80

STJ, REsp 30.700, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ 05.04.1993, p. 5.838; REsp 35.433, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ 18.10.1993, p. 21.875.

81

STJ, REsp 2.340, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 14.03.1994, p. 4.519.

82

Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do código de processo civil, cit., p. 228; J. J. Calmon De Passos, Inovações no código de processo civil, cit., p. 133.

83

Admitem a executividade de título extrajudicial com obrigação de entrega de coisa fungível: Edson Ribas Malachini, Os títulos executivos e a nova lei 8.953, de 1994, Reforma do código de processo civil, obra coletiva, coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 785; Ernane Fidélis Dos Santos, Títulos executivos, Reforma do código de processo civil, obra coletiva, cit., p. 739; Araken De Assis, Manual..., cit., p. 138; Sérgio Bermudes, A reforma do código de processo civil, cit., p. 132; Nelson Nery Junior, Atualidades sobre o processo civil, cit., p. 110; Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução, cit., p. 159.

84

Alcides De Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 298.

85

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 290.

86

Idem, t. IX, p. 293; Ulderico Pires Dos Santos, O processo de execução..., cit., p. 122; Sérgio Shimura, Título executivo, cit., p. 288; Humberto Theodoro Júnior, processo de execução, cit., p. 159. Em sentido contrário, admitindo assinatura a rogo em certos casos: José Da Silva Pacheco, Tratado das execuções, cit., p. 271.

87

Há precedente do STJ em outro sentido, sustentando que o Código não reclama a presença das testemunhas ao ato (REsp 1.127, 3ª Turma, Min. Cláudio Santos, DJ 04.12.1989, p. 17.882).

88

STJ, REsp 154.397, 4ª Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 30.03.1998, p. 82.

89

Orlando Gomes, Contratos, cit., p. 327; Nelson Abrão, Curso de direito bancário, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1988, p. 90.

90

STJ, REsp 122.347, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ 98/263. Outros precedentes da mesma Turma nesse sentido: REsp 29.597, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 13.09.1993, p. 18.559; REsp 36.391, Min. Costa Leite, DJ 23.05.1994; REsp 57.171, Min. Waldemar Zveiter, DJ 15.05.1995, p. 13.400; REsp 31.735, Min. Cláudio Santos, DJ 22.04.1996, p. 12.566; REsp 142.781, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 10.11.1997, p. 57.760; REsp 115.462, Min. Costa Leite, DJ 13.04.1998, p. 116; REsp 164.167, Min. Costa Leite, DJ 18.05.1998, p. 98.

91

STJ, REsp 85.775, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 24.03.1997. Outros precedentes da mesma Turma: REsp 11.037, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 08.06.1992, p. 8.620; REsp 71.217, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 18.12.1995, p. 44.585; REsp 120.280, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 10.11.1997, p. 57.772; REsp 64.426, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 27.04.1998, p. 169.

92

Carlos Alberto De Oliveira, Exequibilidade dos contratos de abertura de crédito, Revista Jurídica 242/133; Humberto Theodoro Júnior, Execução – contrato de abertura de crédito como título executivo, Revista Jurídica 236/132.

93

STJ, REsp 1.495.920/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018.

94

Ao celebrar os chamados “Termos de Ajustamento de Conduta – TAC”, o Ministério Público não está investido de poderes de disposição do direito material ou de dispensar o cumprimento de deveres ou obrigações impostos por lei. O que o sistema normativo lhe confere são poderes para ajustar, com o obrigado, o melhor modo de satisfazer a prestação devida ou de cumprir os seus deveres legais.

95

Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, t. XXV, p. 117.

96

Idem, p. 138.

97

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 1974, t. IX, p. 241.

98

Idem, t. IX, p. 237; Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução, 18. ed., São Paulo: LEUD, 1997, p. 141; Sérgio Shimura, Título executivo, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 231.

99

STJ, REsp 11.725, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.03.1992; STJ, REsp 57.365, 3ª Turma, Min. Cláudio Santos, DJ 11.09.1995, p. 28.826.

100

Orlando Gomes, Contratos..., cit., p. 78.

101

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 294.

102

STJ, REsp 6.949, 4ª Turma, Min. Athos Carneiro, DJ 01.04.1991, p. 3.425.

103

Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 325; Humberto Theodoro Júnior, Execução..., cit., p. 160; Araken De Assis, Manual..., cit., p. 139.

104

É a hipótese de que trata a Súmula 26 do STJ, cujos precedentes admitem a figura do devedor ou garante solidário, distinta da do fiador (RSTJ 33/109-142).

105

Paulo Furtado, Execução..., 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1991, p. 43.

106

Cândido Dinamarco, Execução civil, cit., p. 225.

107

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 324.

108

STJ, REsp 5.825, 4ª Turma, Min. Athos Carneiro, DJ 30.09.1991, p. 13.487.

109

STJ, REsp 2.375, 3ª Turma, Min. Cláudio Santos, DJ 04.06.1990, p. 5.060; STJ, Agravo Regimental no Agravo

de Instrumento 105.805, 3ª Turma, Min. Nilson Naves, DJ 11.11.1996, p. 43.711.

110

STJ, REsp 2.069, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 11.06.1990, p. 5.360.

111

Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil, cit., vol. III, p. 329.

112

“A apólice de seguro acompanhada do documento médico indicando o grau de incapacidade da vítima, é título executivo extrajudicial” (Súmula 26 do 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo).

113

STJ, REsp 23.700, 3ª Turma, Min. Nilson Naves, DJ 19.10.1992, p. 18.246; REsp 31.565, 5ª Turma, Min. Assis Toledo, DJ 05.04.1993, p. 5.854; REsp 46.089, 5ª Turma, Min. José Dantas, DJ 16.05.1994, p. 11.779.

114

Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução, cit., p. 167; Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 340.

115

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 341; Araken de Assis, Manual..., cit., p. 140; Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 125.

116

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 342.

117

Ao julgar o REsp 43.318, 3ª Turma, Min. Cláudio Santos, decidiu o STJ que “o procedimento sumário – art. 275, II, do CPC, não se aplica à cobrança de despesas condominiais cujos valores tenham sido estabelecidos e aprovados em convenção, pois, nesta hipótese, o caso é de ação de execução, ex vi do art. 585, IV, do CPC e art. 12, § 2.º, da Lei 4.591/1964” (DJ 26.02.1996, p. 4.008).

118

Leon Frejda Szklarowsky, Apuração e inscrição da dívida ativa da fazenda pública; natureza jurídica, Conteúdo do ato de controle administrativo da legalidade (Lei 6.830/80, art. 2.º, § 3.º), RePro 23/168.

119

Está sujeito à inscrição em Dívida Ativa inclusive o crédito União por custas judiciais (art. 16 da Lei 9.289, de 04.07.1996). Os embargos do devedor, em eventual execução, não podem, todavia, alterar o resultado da sentença condenatória que impôs ao vencido os ônus sucumbenciais. A coisa julgada, neste caso, tem eficácia, porque opera em favor (e não contra) do terceiro (Fazenda Pública) que não foi parte no processo.

120

Donaldo Armelin, Cobrança da dívida ativa não tributária da fazenda pública, RePro 45/8.

121

Maria Helena Rau De Souza, Execução fiscal – doutrina e jurisprudência, Coordenador Vladimir Passos de Freitas, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 32.

122

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., p. 265. No mesmo sentido, Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 282. Com base nessa orientação, a jurisprudência do STJ negou eficácia executiva à convenção entre produtores e revendedores de veículos, de que trata o art. 17, da Lei 6.729/79 (REsp 23.424, 3ª Turma, Min. Dias Trindade, DJ 31.08.1992, p. 13.649; REsp 5689, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 18.02.1991, p. 1.036; REsp 14.989, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ 24.02.1992, p. 1.869).

123

Rodolfo de Camargo Mancuso, Sobre a execução das decisões proferidas pelos tribunais de contas, especialmente e legitimação, Revista dos Tribunais, 743/94.

124

STJ, REsp 100.435, 2ª Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ 01.12.1997, p. 62.704.

125

STJ, Conflito de Competência 6.547, 2ª Seção, Min. Barros Monteiro, DJ 21.03.1994, p. 5.430; Conflito de Competência 14.460, 2ª Seção, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 18.03.1996, p. 7.501.

126

Cândido Dinamarco, A reforma do código de processo civil, cit., p. 232.

127

STJ, REsp 2.793, 4ª Turma, Min. Athos Carneiro, DJ 03.12.1990, p. 14.322; REsp 5.052, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 03.12.1990, p. 14.325; REsp 2.794, 4ª Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 06.08.1990, p. 7.342; ROMS 830, 4ª Turma, Min. Bueno de Souza, DJ 09.12.1991, p. 18.082; REsp 13.891, 4ª Turma, Min.

Barros Monteiro, DJ 23.03.1992, p. 3.489; ROMS 5.258, 4ª Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 05.02.1996, p. 1.398; REsp 34.211, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 16.09.1996, p. 33.743.

128

STJ, REsp 27.020, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 07.02.1994, p. 1.171.

129

TRF, 4ª Região, AI 90.04.17169, 2ª Turma, rel. Juiz Teori Albino Zavascki, RTRF 4ª Região 8/207.

130

TRF, 4ª Região, Embargos Infringentes 95.04.36954, 1ª Seção, Juiz Teori Albino Zavascki, RTRF 4ª Região 28/300, com a seguinte ementa: “Tributário. Processo Civil. Depósito judicial do tributo questionado. Destino, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito. 1. O autor tem o direito – ou a faculdade – de efetuar ou não o depósito do valor do tributo questionado; porém, não tem nem o direito, nem a faculdade, de, a seu critério, retirar a garantia dada, notadamente porque, suspendendo a exigibilidade do crédito, ela operou, contra o réu, os efeitos próprios de impedi-lo de tomar qualquer providência no sentido de cobrar o tributo ou mesmo de, por outra forma, garanti-lo. 2. As causas de extinção do processo sem julgamento de mérito são invariavelmente imputáveis ao autor da ação, nunca ao réu. Admitir que, em tais casos, o autor é que deve levantar o depósito judicial, significaria dar-lhe o comando sobre o destino da garantia que ofereceu, ou seja, significaria retirar da garantia toda a sua substância. 3. Assim, ressalvadas as óbvias situações em que a extinção do processo decorrer de reconhecimento de que a pessoa de direito público não é parte na relação de direito material questionada – e que, portanto, não é parte legítima para figurar no processo – o depósito judicial somente poderá ser levantado pelo contribuinte que, no mérito, se consagrar vencedor”.

131

STJ, ROMS 5.026, 2ª Turma, Min. Ari Pargendler, DJ 26.02.1996, p. 3.978. No mesmo sentido, STJ, REsp 30.610, 1ª Turma, Min. Milton Luiz Pereira, DJ 15.03.1993, p. 3.789; ROMS 1.269, 1ª Turma, Min. Demócrito Reinaldo, DJ 08.11.1993, p. 23.513; REsp 9.390, 1ª Turma, Min. Milton Luiz Pereira, DJ 22.08.1994, p. 21.211; REsp 52.971, 1ª Turma, Min. Demócrito Reinaldo, DJ 06.05.1996, p. 14.373; REsp 94.513, 1ª Turma, Min. Demócrito Reinaldo, DJ 11.11.1996, p. 43.662.

132

Leandro Paulsen, Direito Tributário: Constituição, Código Tributário e Lei de Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, 4. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002, p. 732.

133

STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 8.089, 4ª Turma, Min. Athos Carneiro, DJ 20.05.1991, p. 6.537; REsp 9.401, 2ª Turma, Min. Peçanha Martins, DJ 25.10.1993.

134

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 148; Gil Trota Telles, Propositura de ação declaratória negativa depois de ajuizada execução de título extrajudicial, *Ajuris* 55/104; Sérgio Shimura, Título executivo, cit., p. 351.

135

Cândido Dinamarco, A reforma do código de processo civil, cit., p. 232, nota 3.

136

Araken de Assis, Reforma do processo executivo, Inovações do código de processo civil, coordenador José Carlos Teixeira Giorgis, cit., p. 148; Carlos Alberto Carmona, O processo de execução depois da reforma, Reforma do código de processo civil, coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira, cit., p. 752. Na jurisprudência: STJ, REsp 33.000, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 26.09.1994, p. 25.646; REsp 34.166, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 07.11.1994, p. 30.019; REsp 57.624, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 03.06.1996, p. 19.247.

137

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 375.

138

Idem, p. 376.

139

STJ, REsp 4.819, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, RSTJ 27/313.

140

Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, O projeto do novo CPC: críticas e propostas, São Paulo: Ed. RT, 2010, em especial p. 68. A partir de bases diferentes, mas com a mesma proposta, ver Albuquerque Jr., Roberto Paulino; Araújo, Gabriela Exposito; Gouveia Filho, Roberto Campos. Da noção de direito ao remédio jurídico processual à especialidade dos procedimentos das execuções fundadas em título extrajudicial: ensaio a partir do pensamento de Pontes de Miranda. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Antonio Adonias (coord.), Execução e cautelar: estudos em homenagem a José de Moura Rocha, Salvador: JusPodivm, 2012, p. 501-524.

141

Humberto Theodoro Jr., Tutela diferenciada: Opção do credor entre a ação executiva e a ação ordinária de cobrança, Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza (Org.), Studi di Diritto Processuale Civile in Onore di Giuseppe Tarzia, Milano: Giuffrè, 2005, vol. 3, p. 2527-2548.

142

STJ, 3ª Turma, REsp 207.173/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJ 05.08.2002, p. 325.

143

Nesse sentido José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1061.

144

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, cit., p. 6. No mesmo sentido, Manual de direito processual civil, cit., p. 205.

145

Idem, p. 8.

146

José Frederico Marques, Manual..., cit., vol. 4, p. 39; Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas..., cit., p. 212; Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 209; Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, cit., vol. 3, p. 21; Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de processo civil comentado, cit., p. 814.

147

Cândido Dinamarco, Execução civil, cit., p. 414. No mesmo sentido: Marcelo Lima Guerra, Execução forçada – Controle de admissibilidade, São Paulo: Ed. RT, 1995, p. 84; Willis Santiago Guerra, Aspectos da execução forçada no direito processual brasileiro, RePro 83/60.

148

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., vol. IX, p. 186.

149

Araken de Assis, Manual..., cit., p. 145.

150

Ovídio A. Baptista da Silva, Curso..., cit., vol. II, p. 35.

151

Orlando Gomes, Obrigações..., cit., 11. ed., revista e atualizada por Humberto Theodoro Júnior, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 143.

152

Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., vol. II, p. 244; Orlando Gomes, Obrigações..., cit., p. 151.

153

Silvio Rodrigues, Direito civil, cit., vol. II, p. 294.

154

Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, cit., t. XXIII, § 2.798, p. 117.

155

Em outro sentido, Araken de Assis, para quem o parágrafo único do art. 580 cogita apenas do inadimplemento relativo (Manual..., cit., p. 148). “Em todas as situações de inadimplemento absoluto”, sustenta, “o credor deverá pleitear indenização, condenando o inadimplente (...). Da condenação resultará outra espécie de crédito, que, uma vez liquidado (...), e não acudindo o devedor com espontâneo cumprimento (art. 580, parágrafo único), propiciará, então sim, o ajuizamento da demanda executória” (Manual..., cit., p. 147).

156

Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 218; Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 194.

157

Nesse sentido: Ovídio A. Baptista da Silva. Curso..., cit., vol. II, p. 36; Araken de Assis, Manual..., cit., p. 155. Em sentido contrário, entendendo que a matéria somente pode ser conhecida e decidida na ação de embargos: Marcelo Lima Guerra, Execução forçada, cit., p. 85; Cândido Dinamarco, Execução civil, cit., p. 414.

158

Mario Aguiar Moura, O processo de execução, cit., p. 92.

159

Pontes de Miranda, Comentários..., cit., t. IX, p. 201.

160

Nesse sentido, além de Pontes de Miranda, Alcides de Mendonça Lima, Comentários..., cit., p. 223 e 225; Amílcar de Castro, Comentários..., cit., p. 44. Em outro sentido, entendendo que “essa exceção deve ser oposta pelo devedor através de embargos”: Ulderico Pires dos Santos, O processo de execução na doutrina e na jurisprudência, cit., p. 67.

161

José Alberto dos Reis, *Processo de execução cit.*, vol. 1, p. 23.

162

Pontes de Miranda, *Comentários... cit.*, t. IX, p. 190.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XII - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO II - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO V. DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL

Capítulo V. Da responsabilidade patrimonial

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

1. Responsabilidade patrimonial. Na estrutura de uma norma jurídica individualizada de natureza creditícia pode-se identificar: (a) no enunciado da endonorma, um sujeito (devedor) obrigado a entregar a outro (credor) uma determinada prestação; e (b) no enunciado da perinorma, o Estado-juiz com o poder-dever de fazer atuar coativamente sobre determinados bens a sanção prevista para o não atendimento do preceito endonormativo. Da relação que existe entre os figurantes da endonorma (credor e devedor) nasce o débito, ou seja, o dever de prestar; e, da relação que se estabelece entre o Estado e o sujeito sobre cujo patrimônio recai a sanção jurídica, nasce a responsabilidade, ou seja, a sujeição dos bens ao atendimento coativo da prestação.¹ O débito está relacionado com o preceito que define a conduta do devedor e o seu atendimento espontâneo; a responsabilidade, diferentemente, só ganha sentido e função com o inadimplemento do preceito e com a execução forçada da prestação.

Acertada, portanto, ao contrário do que afirma certa corrente doutrinária,² a preocupação do legislador em disciplinar, em capítulo do Código de Processo, o tema da responsabilidade patrimonial. Trata-se, com efeito, de instituto de natureza processual,³ cuja invocação e atuação é desencadeada em decorrência da crise que se estabelece pelo não cumprimento espontâneo da obrigação e pela consequente necessidade do recurso à tutela coativa do Estado.

2. Bens “presentes e futuros” do devedor. Ficam sujeitos à execução, como regra primeira em matéria de responsabilidade patrimonial, os bens do patrimônio do próprio devedor. “Bens presentes e futuros”, é o que diz o art. 789, em redação criticável, que não pode ser interpretada literalmente, sob pena de se estabelecer um regime de geral indisponibilidade contra o devedor desde o momento em que assume a obrigação. Aparentemente, o legislador, ao formular o preceito, fixou-se, não no marco temporal da constituição da obrigação, e sim no estabelecido pelo início do processo executivo, para dizer: respondem pela dívida os bens constantes do patrimônio do devedor neste momento (em que se pede a tutela do Estado) bem como os que, daqui em diante, forem a ele incorporados. É a inteligência que melhor conforma o dispositivo com o princípio geral, realçado na doutrina, segundo o qual “o devedor responde por suas obrigações com os bens que se encontram em seu patrimônio no momento da execução”.⁴

A submissão do patrimônio do devedor à responsabilidade executória não é absoluta. A lei, estabelecendo a regra geral, já anuncia ressalvas (“salvo as restrições estabelecidas em lei”), a significar que há bens do devedor que escapam à força coativa estatal. Os absolutamente impenhoráveis (CPC/2015, art. 833) não se submetem à execução em nenhuma hipótese. Há bens que somente podem ser penhorados à falta de outros (art. 834). É o que se denomina, doutrinariamente, de impenhorabilidade relativa. “Além disso”, mostra Dinamarco, “manifesta-se diversas vezes no ordenamento jurídico o princípio de que a execução deve onerar o devedor tão pouco quanto possível; ele busca a justa medida e peso da responsabilidade objetiva, evitando excessos – e o faz por meio do instituto do benefício da excussão (CPC/2015, art. 794), da faculdade de nomear bens à penhora em primeiro lugar (CPC/2015, art. 829, § 2.º), de postular redução ou substituição da penhora (art. 850)”.⁵

O Código Civil de 2002 tratou da responsabilidade patrimonial do seguinte modo: “Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”. O Código Civil, na verdade, limita-se a enunciar o princípio geral da responsabilidade primária, no que, aliás, agiu apropriadamente, já que a habitat natural dessa matéria é, como antes se demonstrou, o processo, e não o direito civil. Quanto ao princípio enunciado, são harmônicos os dois Códigos. Já as exceções e limitações decorrem de leis de natureza processual que regulamentam mais detalhadamente a matéria, e que persistem porque sua relação com o Código Civil é a de norma especial em face de norma geral. A esta exceção, de que nem todos os bens do devedor respondem pelas dívidas, há de se acrescentar outra: nem só os bens do devedor dão suporte à responsabilidade patrimonial. Há bens, como os alienados em fraude à execução, que já estão no patrimônio de terceiro e que, mesmo assim, podem ser apreendidos para serem entregues ao exequente, ou penhorados e alienados para satisfazer as dívidas do executado.

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

I – do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II – do sócio, nos termos da lei;

III – do devedor, ainda que em poder de terceiros;

IV – do cônjuge ou companheiro nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

V – alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;

VI – cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

VII – do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

1. Responsabilidade patrimonial secundária. Débito e responsabilidade estão, quase sempre, concentrados em uma única pessoa: o próprio devedor (titular do dever de prestar espontaneamente) suporta, em regra, com o seu patrimônio, os atos da execução forçada. É o que se chama de responsabilidade executória primária, cuja sede normativa está localizada no art. 789 do CPC/2015. Há situações, todavia, de responsabilidade executória secundária, em que “a responsabilidade se separa da obrigação e vai alcançar terceiro não devedor”,⁶ como no caso do sócio, quando o seu patrimônio se submete ao jugo da execução promovida contra a sociedade, ou do cônjuge, quando seus bens suportam a carga executiva de dívida contraída por seu marido ou por sua mulher.

A doutrina predominante, na esteira do pensamento de Liebman, considera o responsável secundário como terceiro, e não como parte, na relação processual.⁷ Essa orientação, que tem como consequência prática mais importante a de definir como sendo os embargos de terceiro (e não os embargos do devedor) o instrumento de defesa do responsável secundário, deve ser tomada com reservas. Com efeito, o exame das várias situações elencadas no art. 790 evidencia que, a rigor, apenas três, as dos exemplos acima citados (do sócio, do cônjuge e do responsável apurado mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previstas nos seus incs. II, IV e VII, respectivamente), constituem hipóteses típicas de responsabilidade executória secundária. O inc. III, ao estabelecer que se submetem a execução os bens do devedor “ainda que em poder de terceiro” é caso manifesto de responsabilidade executória primária. O inc. I (de sujeição, à execução, dos bens objeto de “ação fundada em direito real ou obrigação reipersecutória” transferidos “a sucessor a título singular”) trata de transmissão mortis causa, de modo que o sucessor, e não o de cujus, figurará como parte executada. O inc. V (bens alienados ou gravados em fraude à execução) figura situações em que a responsabilidade se dirige, não à universalidade de um patrimônio, mas apenas a um ou a alguns bens específicos, que (a) foram transferidos a terceiro quando já em curso uma demanda judicial que poderia afetá-los, razão pela qual (b), para

efeito de responsabilidade executória, nunca se incorporaram eficazmente no patrimônio de terceiro. Do ponto de vista do Estado-juiz – a quem está referenciado, como antes se viu, o instituto da responsabilidade patrimonial –, é como se jamais tivessem deixado de pertencer ao devedor, a evidenciar que, a rigor, está-se a tratar de verdadeira responsabilidade patrimonial primária. Nesses casos, sem dúvida, o terceiro que pretender salvar da execução os referidos bens, há de fazê-lo como terceiro na relação processual. A ressalva a ser anotada é a da execução para entrega de coisa que, já litigiosa, foi alienada e está, no momento da execução, na posse do novo adquirente, caso em que, por força do art. 808, a execução será contra ele direcionada.

Muito diferente é a situação do sócio (inc. II) e a do cônjuge ou companheiro (inc. IV), cuja responsabilidade patrimonial tem, no fundo, natureza fiduciária, em face da posição de proveito que, real ou presumidamente, obtiveram em decorrência do débito assumido pela sociedade ou pelo outro cônjuge. É o que se verá mais adiante.

2. Sucessor a título singular. Os bens objeto de sentença proferida em ação real (ou, como diz o inc. I, “fundada em direito real”) e aqueles relativos a obrigações reipersecutórias ficam sujeitos à respectiva execução, ainda quando transferidos a terceiro (“sucessor a título singular”). Ocorre que, em nosso sistema, sentenças dessa natureza não reclamam ação autônoma para serem executadas. São sentenças executivas lato sensu, cujo cumprimento se dá no âmbito da mesma relação processual em que foram proferidas. Assim, a rigor, a matéria do inc. I, do art. 790, não pertence ao domínio do processo autônomo de execução, como observou acertadamente Ovídio A. Baptista da Silva,⁸ especialmente após a vigência do art. 461-A, introduzido no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei 10.444, de 07.05.2002 (análogo aos arts. 498, 536, § 2.º, e 538, caput e § 3.º).

Preceito normativo assemelhado consta do inc. I do art. 792, segundo o qual considera-se em fraude à execução (e, portanto, ineficaz perante ela) a alienação de bens “quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória”. O esforço da doutrina buscando traçar os limites materiais de incidência de cada um (inc. I do art. 790 e inc. I do art. 792) não logrou, até agora, resultado uniforme. Há uma linha de pensamento sustentando que “ambos tutelam o direito de sequela que integra todos os direitos reais. A diferença é que o art. 790, I, cuida da ineficácia da alienação ocorrida após a sentença proferida na ação real, ao passo que o art. 792, I, antecipa a proteção à sequela fazendo a ineficácia atingir mesmo as alienações verificadas antes do julgamento definitivo da causa”.⁹ Considerada sob outro ângulo, esta orientação leva a uma conclusão inaceitável do ponto de vista sistemático: a de que a lei teria considerado em fraude à execução a alienação do bem litigioso que se realizasse no curso do processo de conhecimento, mácula que não existiria se a mesma alienação tivesse ocorrido no intervalo entre a sentença e a sua execução. Esse calcanhar de Aquiles fica ainda mais exposto quando se tem presente que a ação em causa é executiva lato sensu, não havendo intervalo algum entre a sentença e a execução, realizadas que são, ambas, na pendência de uma única relação processual.

Mais adequado ao sistema é o entendimento segundo o qual a aquisição do bem litigioso, a que se refere o inc. I do art. 790, é a resultante do falecimento, ou seja, “sucessor a título singular é a pessoa a quem foi transferida, por causa de morte, determinada porção de bens”.¹⁰ É situação que escapa do âmbito de abrangência do inc. I do art. 792, pois seria absurdo catalogá-la como hipótese de fraude à execução, notadamente porque a sucessão causa mortis se dá, não por concurso de vontade, mas por força de lei (CC, art. 1.784; CC/1916, art. 1.572). O dispositivo, ademais, “resolve, no plano do processo, a situação do legatário que recebe bem que é ou vem a ser objeto de processo fundado em direito real”, fazendo operar o direito de sequela “sem embargo da irresponsabilidade do sucessor singular por dívidas do testador em outros casos”.¹¹

Qualquer que seja a linha de entendimento que se adote, o resultado prático da conjugação dos dois dispositivos acaba sendo o mesmo: a transferência, mortis causa ou por ato entre vivos, de bem objeto de ação real, não inibe a atividade executiva em favor de credor.

3. Responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade. Independentemente da forma como se constituem ou da finalidade a que se destinam, as sociedades têm personalidade jurídica própria, distinta e independente em relação às pessoas (físicas ou jurídicas) dos respectivos sócios

ou acionistas (CC/1916, art. 20). É o seu patrimônio por conseguinte, e não o dos seus sócios, o que, em regra, fica sujeito aos atos de execução forçada pelas obrigações assumidas pela sociedade. Desde logo importa destacar duas situações especiais. Primeira: a da chamada sociedade irregular ou de fato, que, constituída sem observância das formalidades ou dos registros exigidos por lei, não chegou a adquirir status jurídico e aptidão para ser, ela própria, sujeito de direitos e obrigações. Seus integrantes, em consequência, respondem, pessoalmente, pelos atos que em nome dela praticarem e pelas obrigações em nome dela assumidas.¹² Enquadra-se nessa situação a chamada “sociedade em comum”, ou seja, aquela cujos atos constitutivos estão pendentes de inscrição, de que tratam os arts. 986 a 990 do CC, por cujas obrigações “todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente (...) excluído do benefício de ordem (...) aquele que contratou pela sociedade” (CC, art. 990).

E a segunda situação especial é a das sociedades que, embora regularmente constituídas, utilizam abusiva ou fraudulentamente a condição de autonomia da sua personalidade e do seu patrimônio, para acobertar interesses ou vantagens particulares de seus sócios. A utilização, pelos sócios, da personalidade jurídica da sociedade para, em fraude à lei, obter benefícios à custa de terceiros, dá ensejo a que se “desconsidere” a independência dessa personalidade, permitindo ao juiz “erguer o véu” que a encobre a fim de “verificar o jogo de interesses que se estabeleceu em seu interior”,¹³ atribuindo, se for o caso, responsabilidade pessoal aos que dela se beneficiaram ilicitamente. É o que decorre da teoria da desconsideração da pessoa jurídica (disregard theory). O Código Civil de 2002 tratou expressamente do tema em seu art. 50: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. A esse segundo caso trata o inc. VII, de que trataremos adiante.

Há casos em que, por força de lei, o patrimônio pessoal dos sócios constitui uma espécie de garantia dos credores da sociedade, e nessa condição está sujeito a ser chamado para, subsidiariamente, responder pelas obrigações sociais. Isso pode ocorrer de vários modos e em diferentes graus, desde a responsabilidade extremamente limitada, como nas sociedades por ações (em que o acionista é responsável apenas pelo valor correspondente ao preço de emissão das ações que adquirir ou subscrever – Lei 6.404, de 15.12.1976, art. 106), até a inteiramente ilimitada, como nas sociedades em nome coletivo (em que o patrimônio pessoal dos sócios responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade – CC, art. 1.039; CCo, art. 316). Em outros casos, a lei prevê a responsabilidade perante terceiros, solidária e ilimitadamente, dos que, na condição de administradores da sociedade, agirem com culpa no desempenho das suas funções. É o que estabelece o art. 1.016 do CC em relação à sociedade simples, dispositivo aplicável também à sociedade limitada (CC, art. 1.053) à semelhança do que dispunha, para a sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o art. 10 do Dec. 3.708, de 10.01.1919. Relativamente às obrigações tributárias da pessoa jurídica, há preceito análogo, estabelecendo a responsabilidade pessoal do administrador, no art. 135 do CTN.

Em qualquer dos casos de responsabilidade subsidiária, proposta a execução contra a pessoa jurídica e não tendo ela força patrimonial suficiente para suportar a obrigação, poderão os atos executivos ser “redirecionados” contra o patrimônio do sócio responsável, “hipótese em que este deve ser preliminarmente citado em nome próprio para se defender da responsabilidade imputada, cuja causa o credor deve traduzir em petição clara e precisa”.¹⁴ Essa orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, calcada em entendimento semelhante do Supremo Tribunal Federal,¹⁵ evidencia a opção pela corrente doutrinária segundo a qual o responsável é parte, e não terceiro, no processo de execução, razão pela qual há de se defender por embargos de devedor, e não por embargos de terceiro.¹⁶ Em se tratando de obrigações de natureza fiscal, a responsabilização do sócio independe de prévia inscrição da dívida em seu nome, podendo ser citado e ter seus bens penhorados mesmo que não figure expressamente da certidão de dívida ativa.¹⁷

4. Bens do devedor em poder de terceiros. Para efeito de responsabilidade patrimonial, é

irrelevante a situação possessória dos bens do devedor. Sem prejuízo da preservação de eventuais vínculos contratuais legitimamente estabelecidos entre o proprietário e terceiros de boa-fé,¹⁸ os bens objeto de execução específica, e os penhoráveis, na execução por quantia certa, podem ser perseguidos seja em que mãos estiverem. Desapossado por força de apreensão, arresto ou penhora, reserva-se ao prejudicado a faculdade de assestar contra o exequente a ação de embargos de terceiro (CPC/2015, art. 674). A hipótese do inc. III do art. 792, bem se vê, não inova em matéria de responsabilidade patrimonial, constituindo mero esclarecimento da regra geral do art. 789.

5. Responsabilidade patrimonial do cônjuge ou companheiro. Os casos em que os bens próprios ou reservados ou da meação do cônjuge respondem pelas obrigações assumidas por seu consorte, são definidos pelo direito material. Segundo a Lei 4.131, de 27.08.1962, em seu art. 3.º, “pelos títulos de qualquer natureza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que casados pelo regime de comunhão universal, somente responderão os bens particulares do signatário e os comuns até o limite de sua meação”. Já o art. 246 do CC/1916 atribuía à “mulher que exercer profissão lucrativa, distinta da do marido” a livre disponibilidade do produto do seu trabalho e dos bens com ele adquiridos (bens reservados), mas do seu parágrafo único, interpretado a contrario sensu, decorria um importante preceito: os bens de ambos os dois cônjuges respondem pelas dívidas assumidas por qualquer deles em benefício da família. O Código Civil de 2002 mantém a orientação: respondem, solidariamente, ambos os cônjuges pelas dívidas assumidas por qualquer um deles quando contraídas (a) para comprar as coisas necessárias à economia doméstica (art. 1.644), ou (b) no exercício da administração dos bens comuns (art. 1.663) ou, em geral, (c) “para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal” (art. 1.664).

A aplicação do conjunto dos preceitos normativos sobre responsabilidade patrimonial dos cônjuges desperta, no domínio processual, alguns problemas que ainda desafiam a argúcia dos doutrinadores e, especialmente, dos juízes. O primeiro deles é o que diz respeito ao ônus da prova de ter, a dívida, beneficiado ou não a família. A orientação firmada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a de que, na constância da sociedade conjugal, há de se presumir, como regra, que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges o são em benefício comum do casal, de modo que cabe ao cônjuge que pretende salvar a meação o ônus de provar o contrário.¹⁹ Persiste a mesma presunção quando a dívida decorrer de aval prestado pelo cônjuge à sociedade de que fizer parte como sócio.²⁰ Todavia, (a) se o aval for prestado a sociedade estranha,²¹ ou (b) se a dívida decorrer de ato ilícito praticado por um dos cônjuges,²² ou, ainda, (c) em se tratando de obrigação fiscal de sociedade, se a execução do cônjuge resultar da sua responsabilidade como sócio,²³ inverte-se a situação: presume-se que a família não foi beneficiada, cabendo ao credor, que pretender responsabilizar a meação do outro cônjuge, demonstrar o contrário. A propósito, segundo a Súmula 251 do STJ, “a meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal”.

Questiona-se, outrossim, sobre o modo de excluir a meação do cônjuge. Predomina o entendimento segundo o qual “a exclusão da meação deve ser considerada em cada bem, e não na indiscriminada totalidade do patrimônio”, sendo que, em se tratando de bem indivisível, penhora-se e aliena-se o todo, entregando-se ao cônjuge titular da meação a metade do preço obtido.²⁴ A posição contrária, segundo a qual “o direito do meeiro sobre os bens não pode ser substituído pelo depósito da metade dos valores obtidos com a hasta pública”, sendo, consequentemente, “inadmissível a alienação do bem por inteiro, ainda que seja indivisível”,²⁵ produz como resultado prático a penhora e a venda de fração ideal do bem e, consequentemente, o estabelecimento de regime condominial entre o cônjuge meeiro e o terceiro adquirente. Ora, se essa situação é naturalmente compatível com bens imóveis, certamente não o é em relação a bens móveis. A hasta pública da fração ideal de um imóvel, por exemplo, dificilmente encontraria licitantes, ou os encontraria, mas com ofertas de lances em valores certamente abaixo do real. Sem licitantes, criar-se-ia, na prática, a inalienabilidade de todo o bem, em prejuízo dos interesses do credor, que acabaria não podendo tornar efetiva a responsabilidade patrimonial do devedor, como lhe assegura o art. 789 do CPC/2015. A alienação da fração ideal por valor abaixo de um padrão razoável acarretaria, se não a nulidade do ato (preço vil), pelo menos um sério prejuízo econômico

ao devedor, a quem a lei assegura o direito de ser executado pela via menos gravosa possível. Como se percebe, nenhuma solução é perfeita, pois nenhuma consegue harmonizar plenamente os diversos interesses conflitantes. Todas elas acabam comprometendo, em alguma medida, ou o direito do cônjuge meeiro, de salvar in natura a sua meação (CPC/2015, 674, § 2.º, I), ou o do credor, de efetivar a responsabilidade patrimonial do devedor (CPC/2015, art. 789), ou o do devedor, de não sofrer execução desnecessariamente mais gravosa (CPC/2015, art. 805). Ora, a orientação predominante, ao início referida, que propõe a alienação do bem em seu todo e a posterior destinação da metade do preço ao meeiro, é a que melhor acomoda os interesses em conflito, nascendo daí a sua legitimidade.

Reconhece-se ao cônjuge meeiro dupla posição em face do processo onde seu marido ou sua mulher figura como executado: a de terceiro, quando pretende defender a sua meação, o que o legitima a propor embargos de terceiro; e a de parte, quando, em face da responsabilidade patrimonial dos seus bens, pretende impugnar o título executivo ou os atos de execução, o que fará, conseqüentemente, por ação de embargos à execução.²⁶ A dupla legitimação persiste mesmo quando o cônjuge meeiro for intimado da penhora que incidiu sobre imóvel do casal,²⁷ mas a instrumentalidade das formas e a economia do processo recomendam tolerância quando a defesa da meação vier por embargos à execução.²⁸ Em nome desses princípios, poder-se-á acolher como embargos à execução eventuais embargos de terceiro que impugnem o título ou os atos executivos, com a condição, nessa hipótese, de ter sido observado o prazo próprio (CPC/2015, art. 915).

Ressalte-se que o regime relativo ao companheiro (em união estável) em regra será idêntico ao que ocorre no regime de comunhão parcial de bens. Excepcionam-se eventuais regimes estipulados de forma diferente em contrato escrito, como previsto no Código Civil (CC, art. 1.725).

6. Fraude à execução e fraude contra credores. Considerada a regra do art. 789 do Código, segundo a qual a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recai, em regra, sobre o patrimônio do próprio devedor, é pertinente anotar, como o fez Liebman, que “toda a alienação dos bens do devedor é, pois, potencialmente um prejuízo para o credor, que corre o perigo de não poder realizar a execução frutífera por falta de objeto”.²⁹ Advertido dessa realidade, o legislador impôs limites à faculdade de disposição dos bens por parte de quem tenha assumido obrigações, ainda pendentes de cumprimento: o ato de disposição do patrimônio não pode ser feito com o intuito de eximi-lo da responsabilidade executiva, em prejuízo dos credores. Ato dessa natureza é considerado fraudulento, cuidando o legislador de inibir seus efeitos danosos.

São de duas espécies as fraudes atentatórias ao princípio da responsabilidade patrimonial: a fraude contra credores, de que cuidam os arts. 200 a 205 do CC (CC/1916, arts. 106 a 113), e a fraude à execução, referida no Código de Processo Civil, no inc. V do art. 790 e no art. 792. Distingue-se uma da outra não apenas pelas circunstâncias fáticas que as tipificam, mas especialmente pelas consequências jurídicas que delas resultam. “Constitui fraude contra credores”, ensina Caio Mário da Silva Pereira, “toda a diminuição maliciosa levada a efeito pelo devedor, com o propósito de desfalcocar aquela garantia, em detrimento dos direitos creditórios alheios. Não constitui fraude, portanto, o fato em si de reduzir o devedor o seu ativo patrimonial, seja pela alienação de um bem, seja pela constituição de garantia em benefício de certo credor, seja pela solução de débito preexistente. O devedor, pelo fato de o ser, não perde a disposição de seus bens. O que se caracteriza como defeito, e sofre a repressão da ordem legal, é a diminuição maliciosa do patrimônio, empreendida pelo devedor, com o ânimo de prejudicar os demais credores, ou com a consciência de causar dano”.³⁰ A fraude à execução pode ser considerada uma especialização da fraude contra credores³¹ e se caracteriza pela maior gravidade, já que o ato fraudulento de alienação ou oneração de bens se dá quando já em curso uma demanda judicial contra o proprietário.

Fraudada a execução, há ineficácia do negócio em face do processo executivo, ou seja, os bens alienados ou gravados com ônus real continuam sujeitos ao cumprimento coativo da obrigação independentemente de prévia sentença declaratória de nulidade ou de prévia desconstituição judicial do negócio. Trata-se, portanto, de hipótese de ineficácia primária, cuja consequência imediata é a de que o bem continua sujeito aos atos executivos como se jamais tivesse ocorrido a

alienação ou o gravame. Já na fraude contra credores, a ineficácia do negócio é sucessiva, ou seja, “o negócio jurídico fraudulento nasce plenamente eficaz”, inclusive perante a execução, de modo que “a responsabilidade do bem alienado só se configura mediante o exercício bem sucedido da ação pauliana”.³² Na fraude à execução, a intenção fraudulenta (*consilium fraudis*) dispensa prova, pois está *in re ipsa*,³³ presumindo-se configurada (presunção *iuris et de iure*)³⁴ pela simples realização do ato tipificado na lei como fraudulento. Em se tratando da fraude contra credores, diversamente, compete ao autor da ação pauliana alegar e provar esse elemento subjetivo do ato. A diversidade de tratamento é justificada doutrinariamente pelo nível de gravidade do atentado: na fraude a credores, que ocorre quando ainda não existe litispendência, atenta-se apenas contra interesses privados, enquanto na fraude à execução, perpetrada quando já em curso a atividade jurisdicional, afronta-se a própria autoridade estatal, inibindo-lhe o regular desenvolvimento da atividade executória.³⁵

O Código de Processo, ao tratar da responsabilidade patrimonial, reporta-se à fraude à execução (inc. V), trazendo referência à fraude contra credores no inc. VI. Procedente a ação pauliana, o bem alienado ou gravado, é, como na fraude à execução, submetido ao processo executivo. Variam, portanto, os meios processuais, mas nos dois casos chega-se ao mesmo resultado: “na ‘fraude à execução’ a atividade do credor é mais simples, amparada em presunção absoluta, tornando-se mais difícil, quase fatal, a posição do devedor e do terceiro; na ‘fraude contra credores’ ocorre o inverso: a atividade do credor é mais difícil, pela prova da malícia que lhe cumpre fazer, tornando-se, assim, mais simples a posição do devedor e do terceiro”.³⁶

Embora o Código Civil, a exemplo do anterior, induza, repetidas vezes, a conclusão de que a fraude contra credores gera a anulabilidade do negócio (arts. 158, 159, 165, 171, II, que correspondem aos arts. 106, 107, 113 e 147, II, do CC/1916), o que se tem aí é hipótese de ineficácia relativa, ou seja, de inoponibilidade do negócio em relação a certos credores apenas. Com efeito, o fenômeno da anulação do negócio jurídico importaria o retorno, puro e simples, do status quo ante, do que resultaria a reincorporação do bem ao patrimônio do devedor alienante, podendo, com isso, beneficiar qualquer outro dos seus credores, inclusive os supervenientes à alienação.³⁷ Ora, não é para isso que se coíbe a fraude nem é essa a finalidade da ação pauliana. Tem inteira razão Cândido Dinamarco ao salientar que não teria “significado racional ou ético beneficiar também os credores sucessivos à alienação, quando eles não foram vítimas de fraude alguma e, quanto a eles, o negócio fraudulento não frustrou qualquer expectativa, que legitimamente pudessem alimentar, de se satisfazerem à custa do bem alienado ou gravado”.³⁸ Aliás, o próprio alienante poderia ser beneficiado com a reposição dos fatos aos status quo ante: tendo como única obrigação a devolução do preço, poderá, dependendo das circunstâncias, obter substancial vantagem patrimonial em prejuízo do terceiro, o que seria absurdo.³⁹ Portanto, a ação pauliana, que, segundo o próprio Código Civil, só pode ser intentada pelos credores que já o eram ao tempo em que se deu a fraude (art. 158, § 2.º; CC/1916, art. 106, parágrafo único), não conduz a uma sentença anulatória do negócio, mas sim à de retirada parcial de sua eficácia. Ela, na verdade, conforme anotou Liebman, “elimina apenas as consequências deste ato que sejam prejudiciais para os credores, permitindo-lhes executar os bens que foram alienados nas condições mencionadas. Em outras palavras, restabelece sobre os bens alienados não a propriedade do alienante, mas a responsabilidade por suas dívidas, de maneira que possam ser abrangidas pela execução a ser feita”.⁴⁰

Ao contrário da fraude à execução, que pode ser alegada como matéria de defesa em embargos de terceiro, a fraude contra credores supõe, como condição para submeter o bem à responsabilidade executiva, prévia sentença de procedência em ação pauliana, que desconstitua a eficácia operada pelo negócio. Importante corrente jurisprudencial e doutrinária se formou em outro sentido, para reconhecer que também a fraude a credores poderia ser reconhecida judicialmente quando alegada pelo credor, em eventual ação de embargos de terceiro. Fundam-se, seus adeptos, essencialmente no argumento de que “demonstrada a fraude ao credor, a sentença não irá anular a alienação, mas simplesmente, como nos casos de fraude à execução, conduzirá à ineficácia do ato fraudatório perante o credor embargado, permanecendo o negócio válido entre os contratantes, o executado-alienante e o embargante-adquirente. A sentença terá, destarte, caráter predominantemente declaratório, pois declarará a validade e eficácia do ato de constrição e a

possibilidade de o bem fraudulentamente alienado responder pela dívida, embora mantido no patrimônio do adquirente”.⁴¹ A matéria, objeto de antiga e profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência, inclusive no Supremo Tribunal Federal,⁴² refletida também no Superior Tribunal de Justiça,⁴³ acabou sendo sumulada, nessa Corte, nos seguintes termos: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores”.⁴⁴ O enunciado presta adesão à tese da anulabilidade (e não da ineficácia) do negócio em fraude a credores, devendo a anulação ser objeto de ação própria. Mas, conforme salientou o Min. Eduardo Ribeiro, “admitindo-se a hipótese como de ineficácia, essa, ao contrário do que sucede com a fraude à execução, não é originária, demandando ação constitutiva que lhe retire a eficácia”.⁴⁵ Seja caso de anulabilidade, seja caso de ineficácia (que não é originária, mas sucessiva), haverá necessidade de sentença desconstitutiva (e não simplesmente declaratória), que não pode ser emitida contra o autor da ação de embargos. “Não é admissível a discussão da fraude a credores na sede de embargos de terceiro”, escreveu Dinamarco, “porque sem desconstituir a eficácia secundária do negócio, ele é (ao menos provisoriamente) eficaz apesar da fraude”.⁴⁶

Em se tratando de fraude à execução, o bem fica desde logo passível de constrição judicial, independentemente de sentença ou de decisão declarativa ou desconstitutiva, já que o negócio que o alienou ou gravou não opera qualquer efeito perante a execução. É ineficácia originária, que pode ser reconhecida, se for o caso, de ofício ou por provocação do credor, na execução ou em embargos. As situações que configuram fraude tão severamente combatida pelo sistema jurídico são as descritas nos incs. I e IV do art. 792 do Código (quando sobre o bem alienado ou gravado pender ação fundada em direito real, ou quando a alienação ou oneração foi ajustada ao tempo em que já corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência) e as previstas em leis especiais (inc. V).

7. Desconsideração da personalidade jurídica. O inc. VII do art. 790 inova ao prever, expressamente, a possibilidade de sujeição dos bens daquele que é declarado responsável por força de desconsideração da personalidade jurídica (direta ou inversa). Essa desconsideração da personalidade pode ser provocada por incidente processual próprio, disciplinado nos arts. 133 a 137. É incidente incluído em Título que trata da intervenção de terceiros (Título III, do Livro III da Parte Geral). Trata-se, com efeito, de mecanismo para coactar a presença de terceiro no processo, a fim de fazer valer as disposições de direito material que permitem a desconsideração do manto da pessoa jurídica. O Código, portanto, apenas prevê um procedimento específico de promover o contraditório da pessoa natural ou jurídica que potencialmente virá a responder pela obrigação objeto da demanda. A instauração e decisão do incidente constitui pressuposto necessário à sujeição dos bens ao processo executivo.

Art. 791. Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o superficiário, responderá pela dívida, exclusivamente, o direito real do qual é titular o executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação, no segundo caso.

§ 1.º Os atos de constrição a que se refere o *caput* serão averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas.

§ 2.º Aplica-se, no que couber, o disposto neste artigo à enfiteuse, à concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso.

1. Direito de superfície e execução. Consagrado pelo Código Civil como direito real autônomo (art. 1.255, II), o direito de superfície decorre da concessão feita pelo proprietário do imóvel a outrem (superficiário) “de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório do Registro de Imóveis” (CC, art. 1.369). É contrato gratuito ou oneroso (CC, art. 1.370), e o direito pode ser transferido a terceiro, por ato inter vivos ou causa mortis (CC, art. 1.372). Esse peculiar direito real pode,

portanto, ensejar a necessidade de execução forçada das obrigações que dele decorrem, seja das do proprietário, seja das do superficiário. Daí a razão porque o Código de Processo, adaptando-se ao sistema do Código Civil, disciplina de maneira específica os limites da sujeição dos bens ao processo executivo, amoldando o sistema processual à natureza do direito de superfície.

Cada um dos direitos reais (o do direito de superfície e o do direito de propriedade) responderá autonomamente pelas dívidas de seus titulares, uma vez que constituem dois patrimônios autônomos (o direito de propriedade e o direito que envolve as edificações e plantações erguidas na superfície). Dessa separação deriva a necessidade de que também eventuais restrições ou averbações em matrícula sejam registradas em separado, com a identificação relativamente ao direito real sobre a qual incidem. Garante-se ao titular do direito real autônomo a manutenção de sua posição mesmo em caso de transferência do outro direito real autônomo ao credor, uma vez que se trata de posições jurídicas distintas.⁴⁷

2. Regime processual idêntico ao do direito de superfície aplica-se à enfiteuse, à concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso. A enfiteuse, disciplinada como direito real sobre coisa alheia pelo Código Civil de 1916 (arts. 678 a 694), já não é mais permitida pelo Código Civil atual, que, todavia, resguardou as já constituídas “subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores” (art. 2.038). “Dá-se enfiteuse, aforamento ou aprazamento”, dizia o art. 678 do CC/1916, “quando por ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui a outrem o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio uma pensão, ou foro, anual, certo e invariável”. A “concessão de uso especial para fins de moradia” e a “concessão de direito real de uso”, por sua vez, são direitos reais previstos no Código Civil atual (art. 1.225, XI e XII, redação da Lei 11.481, de 31.05.2007), sem correspondentes no Código anterior. À semelhança do que ocorre com o direito de superfície, são institutos jurídicos que atribuem direitos reais distintos a diferentes titulares, mas sobre o mesmo bem imóvel. Daí a semelhança de regime processual a que estão submetidos no âmbito do processo executivo.

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I – quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II – quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III – quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V – nos demais casos expressos em lei.

§ 1.º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2.º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3.º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4.º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

1. Situações configuradoras de fraude à execução. Quatro são as situações descritas no

art. 792 como caracterizadoras de fraude à execução: (a) a alienação ou oneração de bens quando sobre eles pender ação fundada em direito real ou obrigação reipersecutória, desde que a existência da demanda tenha sido averbada no registro; (b) a alienação ou oneração de bens nos quais tenha sido averbada a existência de execução (averbação premonitória prevista no art. 828; (c) a alienação ou oneração de bens no registro dos quais tenha sido averbada hipoteca judiciária (art. 495) ou outro ato de constrição judicial originário do processo em que arguida a fraude; e (d) quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Todas têm em comum a circunstância fática consistente na alienação ou oneração de bem do patrimônio do demandado quando já em curso uma demanda judicial. Diferem, todavia, substancialmente, pelos valores jurídicos que lhe dão suporte e razão de ser.

Na primeira (a), o que se busca assegurar é o direito de seqüela, inerente ao direito real ou obrigacional de cunho reipersecutório vindicado na ação, e daí por que a configuração da fraude independe do estado de insolvência do executado; no segundo (b) e no terceiro (c) busca-se tutelar os interesses de terceiros que possam vir a adquirir o bem gravado, razão pela qual é indispensável, para o reconhecimento da fraude à execução, a inexistência de outros bens que possam satisfazer a obrigação. Já na última (d), o princípio resguardado é o da responsabilidade patrimonial, o que explica o pressuposto da insolvência, aqui indispensável para que se tenha o ato como fraudatório.

Mas há uma quinta situação (e), de ocorrência frequente, que é geralmente tratada como de fraude à execução, embora não se afeioe a nenhuma das modalidades descritas no Código: a alienação ou oneração de bens objeto de constrição judicial (penhora, arresto, sequestro, apreensão). Aqui também, como nas situações (a) a (d), há alienação ou oneração de bem quando em curso demanda judicial, mas o valor jurídico atingido é outro, o da própria autoridade estatal. A atividade jurisdicional não pode ser afrontada nem prejudicada pela subtração dos bens que o juiz, no exercício da sua autoridade e no desempenho de sua função pública, separou do patrimônio do demandado para dar-lhes uma destinação específica, de servir de meio para a execução forçada (função executiva), ou de instrumento para garanti-la (função cautelar). Impõe-se, portanto, não confundir essa situação com as de fraude à execução de que tratam os incs. I e IV, inobstante as semelhanças que guardam umas com as outras. Já anotara Liebman, em observação de inteira atualidade, que “é frequente nos escritores e julgados a afirmação de que as alienações de bens penhorados não valeriam porque feitas em fraude à execução. Mas, como se explica no texto, neste caso as alienações são ineficazes em face da execução por efeito do vínculo imposto sobre os bens pela penhora, sem depender da fraude nem de seus requisitos”.⁴⁸ A explicação, segundo ele, está em que “a penhora impõe (...) sobre a coisa um vínculo de caráter processual que, sem afetar os direitos do executado, sujeita a mesma ao poder sancionatório do Estado para servir à satisfação do exequente; vínculo que permanece invariado quaisquer que sejam as modificações que possam ocorrer na condição jurídica da coisa. O direito do executado sobre ela coexiste, intacto em sua essência, com o vínculo público processual que o ato de penhora impôs sobre a mesma; qualquer forma de exercício daquele direito é permitido, enquanto praticamente possível, mas não altera este vínculo. Se a execução por qualquer motivo for desfeita, o terceiro que adquiriu eventualmente algum direito sobre os bens penhorados poderá pretender satisfazê-lo; mas enquanto a execução continuar, nada poderá fazer que prejudique o exequente ou outros credores concorrentes”.⁴⁹

Examinem-se os pressupostos comuns e os especiais de cada uma dessas situações.

2. Alienação ou oneração de bens. O conceito de alienação ou oneração de bens, para os efeitos do art. 792 do Código, deve ser formatado à luz de uma compreensão teleológica do dispositivo. A alienação que pode dar ensejo à fraude é qualquer ato entre vivos, com a participação voluntária do devedor, de que resulte a transferência da propriedade a terceiro, seja a título oneroso, seja a título gratuito (venda, doação, permuta, dação em pagamento). Não se compreende como tal a transmissão do domínio por força de desapropriação, ainda que o preço seja ajustado por acordo de vontades, já que nessa hipótese a alienação é imposta por ato de Estado, cuja efetivação independe do concurso de vontade do proprietário. Mas, há de se entender como alienação o ato de renúncia a direito material (renúncia a herança, por exemplo), pois

importa diminuição voluntária do patrimônio do devedor, com reflexos em interesses do credor.⁵⁰ Questiona-se a respeito da dação em pagamento de dívida vencida. Sustenta uma corrente que o ato não pode ser considerado em fraude à execução, “pois o devedor que paga cumpre um dever civil, e por isso mesmo está o adquirente isento de fraude ainda sabendo existir outros credores, que poderão não ser pagos por inteiro”.⁵¹ Rebate a tese Pontes de Miranda, ao fundamento de que, à base dela, “pretende-se atribuir à precedência da dívida consequência acima do conteúdo do princípio legal: no art. 593, I, do CPC/1973 porque o vício litigioso é o mesmo; no art. 593, II, do CPC/1973 porque se caracterizou a insolvência, e nada justificaria que se não subordinassem as dívidas a tratamento mais equidoso; no art. 593, III, do CPC/1973 pela especialidade da regra jurídica”.⁵² O que dá respaldo a esse acertado modo de pensar é, sobretudo, o princípio da igualdade, adotado pelo sistema processual em caso de insolvência do devedor (par conditio creditorum).⁵³

Oneração é qualquer ato que, sem importar a transmissão da propriedade do bem, limita as faculdades do domínio, mediante criação, em favor de terceiro, de direito real. São direitos reais dessa espécie os do art. 1.225 do CC (CC/1916, art. 674), divididos entre direitos de gozo e fruição (superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, rendas sobre imóveis), e direitos de garantia (penhor, anticrese e hipoteca). A promessa de compra e venda, agora expressamente arrolada como direito real (CC, art. 1.225, VII), já era considerada, no regime anterior, como apta a gerar, preenchidos certos requisitos,⁵⁴ direito real oponível erga omnes. É direito real sui generis, que limita as faculdades do domínio relativamente ao bem comprometido, atribuindo ao promitente comprador o poder de reivindicar a propriedade.⁵⁵ Nessas condições, é negócio jurídico enquadrável no caput do art. 792 do CPC/2015.

3. Litispendência. O segundo pressuposto comum às várias espécies de fraude é a litispendência. A fraude do inc. I estará configurada quando, relativamente ao bem alienado ou onerado, “pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória”; a do inc. II, quando tiver sido averbada “a pendência do processo”; a do inc. III, quando tiver sido averbada “hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo em que foi arguida fraude”; a do inc. IV, “quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”. A questão está em saber qual o momento em que, para aquele efeito, se considera “pendente” ou “em curso” a demanda: é a data da distribuição ou a da citação do réu?

Os defensores da primeira alternativa sustentam-se no disposto na parte inicial do art. 312 do Código: “considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada”.⁵⁶ A corrente contrária baseia-se na segunda parte do mesmo dispositivo: “todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado”, sustentando, com razão, que a fraude do inc. I supõe litigiosidade sobre o bem alienado ou onerado, e que a do inc. IV requer litispendência, efeitos esses que decorrem, não da distribuição da ação, mas da citação válida (CPC/2015, art. 240).⁵⁷ Essa orientação é a adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.⁵⁸

4. Inc. I – pressupostos específicos. Para a configuração da fraude de que trata o inc. I, é necessário que o bem alienado ou onerado seja a coisa litigiosa de ação fundada em direito real. Não é estranha ao direito a possibilidade da venda da coisa litigiosa. O próprio Código a admite, em seu art. 109, com o alerta de que sua ocorrência “não altera a legitimidade das partes”, e de que os efeitos da sentença “estendem-se ao adquirente e ao cessionário” (§ 3.º). Em outras palavras, a alienação da coisa litigiosa é válida, mas inteiramente ineficaz perante o autor em caso de procedência da ação. Assim é que, quando da execução (que se dará, no caso do art. 498, independentemente de ação autônoma), se “alienada a coisa quando já litigiosa, expedir-se-á mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido depois de depositá-la” (CPC, art. 808).

É nesse contexto sistemático que se deve interpretar o inc. I do art. 792. Se a causa da ineficácia da alienação ou oneração é a circunstância de o negócio ter por objeto coisa litigiosa, a caracterização da fraude independe da situação patrimonial do devedor.⁵⁹

Na hipótese do inc. I, há de se ter como relativa, e não absoluta, a presunção de que o terceiro, participante do negócio, conhecia a litigiosidade instalada sobre o bem.⁶⁰ Em se tratando, porém, de bem imóvel, o registro da citação no ofício imobiliário, previsto no art. 167, I, 21, da Lei 6.015, de 31.12.1973, é “prova presumida, irrefragável, de conhecimento das condições legais de fraude por parte de terceiro”.⁶¹ Se o registro não tiver sido lavrado, nem por isso se descarta a fraude, e a questão se resume então em definir a quem cabe o ônus de provar a ciência, pelo terceiro, da pendência da ação. Predomina o entendimento de que “não tendo a citação sido levada àquele Registro, conquanto ainda aí exista a fraude, cumpre ao exequente prová-la, o que vale dizer que insta a este provar que o terceiro adquirente ou beneficiário com a oneração tinha conhecimento da ação pendente contra o alienante ou o instituidor do ônus real”.⁶² A mesma orientação há de ser adotada em relação aos bens móveis: sem registro da publicidade da citação, o ônus da prova de que o terceiro tinha ciência da ação fundada em direito real é do credor. Havendo sucessivas transferências do bem, há de se proteger os terceiros de boa-fé. Se a citação não foi registrada, a boa-fé do terceiro se presume, cabendo ao credor o ônus de provar o contrário. Todavia, os negócios posteriores ao registro, mesmo quando realizados sucessivamente, são ineficazes perante o autor da ação, porque a nenhum dos novos adquirentes beneficia a alegação de desconhecimento do fato da litigiosidade do bem.

5. Inc. II – pressupostos específicos. O inc. II do art. 792 prevê como situação de fraude à execução a alienação ou oneração de bem que tenha sido gravado por averbação no registro correspondente. Prevista no Código de 1973 reformado no art. 615-A, a chamada averbação premonitória recebeu tratamento pelo novo Código no seu art. 828. Permite-se ao exequente a obtenção de certidão, com a informação de que há execução admitida por juiz, pendente contra o proprietário do bem. Ela deve conter, além da identificação do processo, a indicação das partes e do valor da causa, de modo a permitir a averbação no registro de imóveis ou outros bens sujeitos a registro. Tanto o §. 4.º do art. 828 quanto o art. 792, II, consideram em fraude à execução a alienação ou oneração ocorridas após a averbação. Ressalte-se que a mesma certidão pode ser obtida após a apresentação do requerimento de cumprimento de sentença (relativamente aos títulos executivos judiciais). Além de conferir garantia para o exequente, a averbação constitui instrumento de tutela da confiança de terceiros adquirentes.

6. Inc. III – pressupostos específicos. Em situação análoga à prevista no art. 792, II, o inc. III igualmente considera em fraude à execução a alienação ou oneração de bem gravado com hipoteca judiciária (art. 495, CPC) ou constrição judicial, desde que devidamente registrada na matrícula.

7. Inc. IV – pressupostos específicos. A fraude à execução de que trata o inc. IV do art. 792 pressupõe, como nos demais casos, (a) negócio de alienação ou oneração de bens e (b) quando já corria contra o devedor uma demanda. Com algumas particularidades, porém. O bem objeto do negócio não é o que constitui a “coisa litigiosa”. É bem do patrimônio do devedor que esteja apto a suportar a responsabilidade patrimonial disciplinada no art. 789. É, em suma, qualquer bem penhorável. Por demanda em curso entende-se aquela que possa produzir título executivo de obrigação de pagar. Se ela for precedida de tutela provisória cautelar antecedente, em cuja petição inicial fiquem indicados, como devem ser (CPC, art. 305), os termos e fundamentos da futura lide principal de natureza condenatória, conta-se de lá o período da fraude à execução.⁶³ O simples protesto do título, porém, não desencadeia o período suspeito, razão pela qual a alienação ou oneração posterior a ele e anterior à litispendência pode configurar fraude contra credores, não fraude à execução.⁶⁴

A sentença proferida em ação penal condenatória somente produz eficácia na jurisdição civil quando transita em julgado. É a partir desse momento, portanto, que a alienação ou oneração de bens penhoráveis do réu condenado podem configurar ato em fraude à execução.⁶⁵ Há quem pense ser necessária também a instauração do procedimento de liquidação,⁶⁶ mas uma interpretação analógica do sistema a dispensa. Com efeito, a sentença condenatória penal passa a ter eficácia civil de título executivo judicial no momento do seu trânsito em julgado. Ora, a alienação ou oneração de bens é considerada em fraude à execução tão logo constituído o título executivo judicial, mesmo extinto o processo de conhecimento em que foi formado e ainda não

instaurada a liquidação correspondente.

A instalação do juízo arbitral não pode ser considerada para efeito de fraude à execução, porque é procedimento sem natureza jurisdicional. O título executivo que dele resulta, embora arrolado como título judicial, tem, na verdade, natureza de título extrajudicial. Os negócios de disposição dos bens penhoráveis, celebrados antes da citação do devedor no cumprimento da sentença arbitral, não configuram, portanto, fraude à execução e sim, se for o caso, fraude contra credores.

Para que haja a fraude à execução de que trata o inc. IV é indispensável, também, que a redução do patrimônio, decorrente da alienação ou oneração de bens penhoráveis, resulte em insolvência do devedor, isto é, em incapacidade patrimonial para suportar a obrigação executada. Requer-se, portanto, não só a litispendência, mas também o dano ao credor.⁶⁷ A penhora faz presumir a insolvência,⁶⁸ cabendo ao devedor, se for o caso, demonstrar o contrário.⁶⁹ O inciso “se contenta com a insolvência de fato”,⁷⁰ dispensada sua declaração formal por sentença, como a que enseja a execução por concurso universal (Título IV, do Livro II do CPC/1973, mantido no ponto – art. 1.052 do CPC/2015). Insolvente o devedor, a fraude se configura mesmo que solventes sejam seus fiadores⁷¹ ou os seus sócios.⁷²

Se, no curso da “demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”, o devedor alienou ou onerou vários bens em diferentes momentos, a ineficácia não atingirá, necessariamente, a todas as operações, mas tão somente aquelas a partir das quais resultou comprometida a força patrimonial do executado. A constrição judicial, conseqüentemente, há de se dar na ordem inversa das alienações ou onerações, começando pelos últimos bens comprometidos e regredindo progressivamente até alcançar o montante necessário para o atendimento integral da prestação devida e dos seus acessórios.⁷³

8. Distinção entre fraude à execução (inc. IV) e alienação de bens penhorados. Presentes os requisitos objetivos da litispendência e da insolvência, a alienação ou oneração de bens penhoráveis é ineficaz perante a execução, nos termos do inc. IV do art. 792, sendo despidendo qualquer exame sobre as condições subjetivas de culpa ou má-fé.⁷⁴ Não se exige, tampouco, prévia constrição judicial do bem por penhora, arresto, sequestro ou qualquer medida semelhante, e nem, portanto, qualquer registro.⁷⁵ Convém evitar a confusão – frequente na doutrina e na jurisprudência – entre (a) a fraude à execução prevista no inc. IV do art. 792, cuja configuração supõe litispendência e insolvência, e (b) a alienação de bem penhorado (ou arrestado, ou sequestrado), que é ineficaz perante a execução independentemente de ser o devedor insolvente ou não. Ressalte-se que a alienação de bem objeto de constrição devidamente registrada (art. 792, III) tem sistemática diferente, inclusive pela aplicação do Enunciado da Súmula 375, STJ. Da distinção entre as duas resultam importantes conseqüências: se o devedor for solvente, a alienação de seus bens é válida e eficaz a não ser que (a) se trate de bem já penhorado ou, por qualquer outra forma, submetido a constrição judicial, e (b) que o terceiro adquirente tenha ciência – pelo registro ou por outro meio – da existência daquela constrição; mas, se o devedor for insolvente, a alienação será ineficaz em face da execução, independentemente de constrição judicial do bem ou da cientificação formal da litispendência e da insolvência ao terceiro adquirente.⁷⁶ Emerge daí a providência elementar e indispensável, quando da celebração de negócios com bens de maior valor, de atender ao “dever social (...) de se verificar a situação patrimonial daquele que irá transferir ou gravar um bem, examinando, se for o caso de bem imóvel, o seu histórico cartorário, procedendo, mais ainda, em relação ao atual e anteriores proprietários, a um crivo generalizado junto ao foro cível, por meio da coleta de negativas forenses”.⁷⁷

O problema surge quando o bem adquirido do devedor insolvente é objeto de nova alienação. Há quem entende que, “ineficaz, em relação ao credor, a alienação de bem, pendente lide que possa levar à insolvência do devedor, a fraude à execução contamina as posteriores alienações, independentemente de registro da penhora que sobre o mesmo bem foi efetivada”,⁷⁸ ressaltando-se aos adquirentes “ação de perdas e danos”.⁷⁹ Contudo, em prestígio ao princípio da boa-fé,⁸⁰ há de se resguardar a situação dos terceiros que não tinham nem meios e nem razão para suspeitar da origem irregular do bem adquirido.⁸¹ A sujeição de tais bens ao processo executivo supõe, aqui

sim, demonstração, a cargo do credor, do consilium fraudis nas sucessivas operações.

Se o devedor for solvente, isto é, se, apesar da alienação ou oneração de bens, mantiver força patrimonial para suportar a dívida executada, fraude à execução não houve no negócio. Todavia, conforme acima dito, se o bem onerado ou alienado tiver sido objeto de anterior constrição judicial, a ineficácia perante a execução se configurará, não por força do inc. IV, mas por representar atentado à função jurisdicional. Mesmo assim, impõe-se resguardar a situação do adquirente de boa-fé. Para tanto, é importante considerar que a penhora, o sequestro e o arresto são medidas que importam, em regra, a retirada do bem da posse de seu proprietário. Assim, é lícito que se presuma, em se tratando de bem móvel, a boa-fé do terceiro que o adquire de quem detenha a posse, sinal evidente da ausência de constrição judicial. A mesma presunção milita em favor de quem adquire bem imóvel, de proprietário solvente, se nenhum ônus ou constrição judicial estiver anotado no registro imobiliário,⁸² presunção que, com maior razão, se estende aos posteriores adquirentes, se houver alienações sucessivas.⁸³ É presunção juris tantum, cabendo ao credor o ônus de desfazê-la. O registro, porém, faz publicidade erga omnes da constrição judicial, de modo que, a partir dele, serão ineficazes, perante a execução, todas as posteriores onerações ou alienações do imóvel, inclusive as sucessivas, inclusive por expressa menção do art. 792, III.

9. Inc. V: outras situações de fraude à execução. Além das situações de fraude alinhadas nos incs. I e IV, há outras, previstas no próprio Código (como a do § 3.º do art. 856) e na legislação especial. Destaca-se, pela sua relevância, a do art. 185 do CTN: “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução”. Trata-se de presunção juris et de jure,⁸⁴ e tem os seguintes pressupostos necessários: a) a existência de um crédito fiscal devidamente inscrito em dívida ativa e “em fase de execução”; b) a insolvência do devedor, ou seja, a falta de outros “bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida” (parágrafo único). Nesse caso, não se aplica o Enunciado 375 da Súmula do STJ.

O que se deve entender por crédito tributário “em fase de execução” é matéria doutrinariamente controvertida. O crédito tributário encontra-se em tal fase desde o momento em que foi inscrito em dívida ativa, dizem uns.⁸⁵ Indispensável a efetiva propositura da ação de execução fiscal, sustentam outros.⁸⁶ Este último é o entendimento que predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a particularidade de que “basta a existência de pedido executivo despachado pelo juiz”, mesmo sem a citação.⁸⁷ Sem razão a primeira corrente. Com efeito, antes da distribuição da demanda executiva, a situação fiscal do alienante não tem publicidade alguma, não sendo razoável, por isso mesmo, estabelecer, contra os que com ele negociam, a presunção juris et de jure de serem partícipes de fraude à execução.

Adotada essa orientação, resta evidenciado que a hipótese do art. 185 do CTN é semelhante à do inc. IV do art. 792 do CPC/2015. O traço que as distingue é apenas um: “enquanto na fraude à execução do direito comum se reclama a existência de ‘demanda em curso contra o devedor’, como condição proveitosa, induzindo daí a necessidade de citação”, na fraude à execução fiscal “o legislador se satisfaz com o simples ajuizamento da execução”.⁸⁸

10. Ônus da prova na ausência de registro. Nos casos em que não há registro do bem, impõe-se ao terceiro adquirente demonstrar que tomou as cautelas necessárias, obtendo as certidões pertinentes, relativamente ao bem e ao vendedor. Incumbe ao terceiro adquirente, portanto, o ônus da prova de que desconhecia a situação patrimonial do vendedor de potencial insolvência.

11. Marco temporal da fraude nos casos de desconconsideração da personalidade jurídica. O Código, ao prever um expediente específico para a desconconsideração da personalidade jurídica, é coerente ao situar como marco temporal em que pode verificar-se a fraude à execução como o da citação da parte cuja personalidade se pretende desconconsiderar. Esse ato de chamamento do terceiro a participar do contraditório é o que delimita o momento a partir do qual poderá ser reconhecida a fraude à execução.

12. Direito ao contraditório e embargos de terceiro. Em se tratando de possível afetação do patrimônio jurídico do terceiro, deve preceder ao reconhecimento da fraude a possibilidade de

esse terceiro adquirente exercer contraditório efetivo. O Código, portanto, na esteira do quanto previsto nos arts. 7.º, 9.º e 10, prevê o dever de intimação do terceiro adquirente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, oponha embargos de terceiro, se assim quiser.

Art. 793. O exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder.

1. Beneficium excussionis realis. A responsabilidade patrimonial de que trata o art. 789, sujeita-se, na sua efetivação, a uma disciplina normativa que estabelece a ordem pela qual os bens serão excutados. A regra geral é a do art. 835, que ordena os bens penhoráveis começando por dinheiro e seguindo graduação decrescente, baseada, em essência, na presumida liquidez (aptidão para se transformar em dinheiro) de cada um deles. Essa regra, criada para agilizar a execução – em benefício do credor, portanto – sofre algumas exceções. Assim, o § 3.º do próprio art. 835 dispõe que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia”. O art. 793 é outra dessas exceções. Ele cria, em favor do devedor, o *beneficium excussionis realis*, ao impedir que o credor promova a execução sobre outros bens enquanto não excutados os que tem em seu poder, por direito de retenção.

São várias as situações enquadráveis no dispositivo. O penhor (hipótese abarcada pelo § 3.º do art. 835 do CPC/2015) é o exemplo clássico, pois é da sua essência a posse e o direito de retenção pelo credor (CC, arts. 1.431 e 1.433, II; CC/1916, arts. 768 e 772). Também têm direito de retenção: a) o possuidor de boa-fé, pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (CC, art. 1.219; CC/1916, art. 516); b) o depositário, pelo valor das despesas e prejuízos devidos pelo depositante (CC, art. 644; CC/1916, art. 1.279); c) o mandatário, pelo valor do reembolso do que lhe for devido em consequência do desempenho de cargo (CC, arts. 664 e 681; CC/1916, art. 1.315); o comissário, pelas despesas feitas e pelas comissões devidas pelo exercício da comissão (CC, art. 708; CCo, art. 156).

2. Pressupostos da exceção. A incidência do art. 793 supõe (a) que o exequente esteja na posse de bem de propriedade do executado, (b) que tenha, relativamente a ele, direito de retenção e (c) que haja relação de pertinência entre o bem possuído e a obrigação executada. Se o credor possui o bem, mas não tem direito de retê-lo para haver a dívida, ou se tinha direito de retenção do bem, mas já não é mais seu possuidor, o dispositivo não incide, e a ordem de excussão será a da regra geral do art. 835 e seus parágrafos. Também não incide se não há relação alguma entre a dívida executada e o direito de retenção. Impõe-se, para a invocação do art. 793, observância do princípio da conexidade, ínsito ao direito de retenção. “A causa do direito de retenção há de ser ligada à dívida”, diz Pontes de Miranda, e acrescenta: “se há dois ou mais negócios jurídicos no mesmo instrumento, a pretensão ligada a um não permite reter-se o que concerne a outro. É preciso haver ligação econômica, a conexidade”.⁸⁹

3. Invocação da exceptio excussionis realis. O benefício de ordem de excussão poderá ser invocado pelo executado por simples petição, no prazo que tem para nomear bens à penhora (CPC, art. 829, § 2.º), hipótese em que a matéria será decidida no juízo da execução (CPC, art. 853, parágrafo único).⁹⁰ Se não o fizer, nem por isso fica o exequente liberado de atendê-lo, e a infringência, nesse caso, poderá ser alegada em embargos.⁹¹

Tratando-se de benefício criado em seu favor,⁹² nada impede que o devedor dele abra mão, nomeando à penhora outro bem, melhor situado no rol do art. 835. Passado o prazo da nomeação, a renúncia poderá ser recusada se não convier ao credor, o que não impede, todavia, a substituição a qualquer tempo do bem penhorado por dinheiro (CPC, art. 847). Se o bem retido desaparecer por culpa do credor, pode o devedor pleitear a compensação entre o seu valor de mercado e a dívida objeto da execução forçada.⁹³

A prioridade de excussão do art. 793 não inibe ampliação da penhora (CPC, art. 850), mas, para preservar o princípio, o bem objeto do direito de retenção há de ser o primeiro a ir a hasta pública.

Art. 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os

pormenorizadamente.

§ 1.º Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor.

§ 2.º O fiador, que pagar a dívida, poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo.

§ 3.º O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem.

1. *Beneficium excussionis personalis*. Pelas obrigações garantidas por fiança respondem dois patrimônios: o do devedor (afiançado) e o do fiador. Assiste ao fiador executado, todavia, a faculdade de nomear à penhora bens livres e desembargados do devedor, indicando-os pormenorizadamente. É o denominado benefício de ordem (*beneficium excussionis personalis*), que tem como fundamentos (a) a natureza subsidiária da fiança⁹⁴ (“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra” – CC, art. 818; CC/1916, art. 1.481), e (b) o princípio da economia processual,⁹⁵ evitando, por esse meio, uma segunda execução, a ação de regresso do fiador sub-rogado contra o seu afiançado.

O benefício de ordem assiste tanto ao fiador judicial como ao convencional;⁹⁶ tanto à fiança civil, quanto à comercial,⁹⁷ hoje tratadas indistintamente, no particular, pelo art. 827 do CC. Antes do Código Civil de 2002 havia quem negava, à fiança comercial, a aplicação do art. 794 do Código, porque a consideravam fiança solidária por natureza.⁹⁸ Mas o próprio Código Comercial, matriz da solidariedade do fiador mercantil (art. 291), deixava claro que “se o fiador for executado com preferência ao devedor originário, poderá oferecer à penhora os bens deste, se os tiver desembargado”. Atualmente, com a revogação da Parte Primeira do Código Comercial (CC, art. 2.045), a matéria está unificada e uniformizada pelo Código Civil.

O fiador não pode invocar o benefício de ordem se dele renunciou (art. 794, § 3.º), ou se prestou a fiança obrigando-se como principal pagador ou devedor solidário ou, ainda, se o afiançado for insolvente. É o que dispõe o art. 828, do CC (CC/1916, art. 1.492).

2. Invocação do benefício de ordem. É condição para o exercício eficaz do benefício de ordem que o fiador indique à penhora bens do devedor livres e desembaraçados de ônus, sitos na mesma comarca. Esta última exigência (de outro modo, bens “sitos no mesmo município”) é análoga ao disposto no art. 827, parágrafo único, do CC. No Código de Processo Civil de 1973 não havia previsão de análogo requisito. Aliás, na vigência do Código Civil de 1916, que também exigia que os bens estivessem situados “no mesmo município” (art. 1.491, parágrafo único), entendia-se que tal dispositivo não persistia e com a superveniência do Código de Processo Civil de 1973, omissos no ponto.⁹⁹ O argumento da eficácia revocatória da lei superveniente operava a partir de 2002 em sentido oposto, ou seja, em favor do Código Civil. O Código de Processo de 2015 passou a estabelecer a exigência para bens na mesma Comarca.

Se os bens do afiançado forem insuficientes, deverão, mesmo assim, ser executados em primeiro lugar, caso os tenha indicado o fiador, respondendo os bens desse, se for o caso, apenas pela diferença. É o que dispõe a segunda parte do § 1.º do art. 794.

O momento próprio para a indicação é o do art. 829 do Código: no prazo de três dias a contar da citação. Esgotado o prazo, preclui a faculdade de indicar, só podendo ser renovada se houver necessidade de proceder segunda penhora (CPC/2015, art. 851) ou de ampliar a penhora feita (art. 850). Não se pode confundir preclusão, instituto de direito processual, com renúncia, instituto de direito material. O não exercício tempestivo da faculdade de indicar bens do devedor importa preclusão, e não renúncia tácita ao benefício, que não se admite em tais casos (CC, art. 828, I; CC/1916, art. 1.492, I). Sustentar que a invocação do benefício de ordem pode ser feita a qualquer tempo porque em relação a ele não há renúncia tácita¹⁰⁰ significa isentar o fiador do ônus da preclusão, franqueando-lhe oportunidade para tumultuar o processo.

3. Benefício de ordem e fraude à execução. O regime da fraude à execução de que trata o inc.

IV do art. 792 aplica-se, em princípio, a qualquer obrigado, inclusive ao fiador. Mas seu pressuposto essencial é a litispendência, de modo que não se configura a fraude se o fiador aliena ou onera seus bens antes da propositura da ação de execução, ainda que contra o afiançado já corra demanda apta a levar ambos à insolvência.¹⁰¹ Uma vez citado, todavia, sujeita-se ao regime geral da responsabilidade patrimonial, a significar que, não sendo exitosa a eventual invocação do benefício de ordem, poderá o exequente, se necessário, penhorar os bens que o fiador tiver alienado ou onerado no curso da demanda.

Sustentamos, ao comentar o art. 792, que a insolvência do devedor, caracterizadora da fraude à execução, independe da solvência do seu fiador. A alienação ou oneração de bens do afiançado nas circunstâncias descritas no inc. IV daquele artigo são, pois, ineficazes em face à execução, nada impedindo que o fiador, ao invocar o benefício de ordem, os indique à penhora.

4. Execução pelo fiador sub-rogado. O fiador que pagar a dívida, sub-roga-se nos direitos do credor (CC, art. 831; CC/1916, art. 1.495), legitimando-se a promover execução contra o devedor (CPC/2015, 778, § 1.º, IV). Se o pagamento ocorreu por execução forçada, os direitos de sub-rogado poderão ser exercidos no mesmo processo, ainda que não tenha sido exercido ou tenha havido renúncia ao benefício de ordem.

O princípio da economia processual, que inspira o § 2.º do art. 794, recomenda sua aplicação, por analogia, a outros casos de sub-rogação, nomeadamente as de que trata o direito cambiário (avalistas em relação ao avalizado e outros coobrigados, endossante em relação aos endossantes anteriores e ao emitente, e assim por diante).¹⁰²

Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei.

§ 1.º O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que sejam primeiro executados os bens da sociedade.

§ 2.º Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1.º nomear quantos bens da sociedade, situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.

§ 3.º O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo.

§ 4.º Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.

1. Responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade. A autonomia da personalidade do sócio em relação à da sociedade tem, no campo da responsabilidade patrimonial, os seguintes reflexos: (a) os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, a não ser quando a lei o determinar; e (b) quando responde, o sócio “tem direito a exigir que sejam primeiro executados os bens da sociedade”. Consagra-se, assim, a natureza subsidiária dessa responsabilidade, que tem como contrapartida o ônus do credor de acionar primeiro a sociedade, depois, se for o caso, o sócio.¹⁰³ O Código Civil reafirma o princípio da responsabilidade subsidiária (“Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”), mas excepciona a situação do sócio que, na “sociedade em comum”, (espécie de sociedade não personificada, cujos atos constitutivos não estão devidamente inscritos – CC, art. 986), “contratou pela sociedade”. A esse não assiste o benefício de ordem (CC, art. 990).

A primeira parte do art. 795 reproduz, de certo modo, o que já constou no inc. II do art. 790. Ao comentá-lo, referimos duas situações em que a responsabilidade do sócio não é secundária, nem subsidiária, mas primária: a das sociedades irregulares e a da utilização abusiva da personalidade social. No primeiro caso, os sócios de fato respondem pelas obrigações assumidas em nome da pretensa sociedade (que juridicamente não existe); e, na segunda situação, enseja-se a possibilidade de invocar a teoria da desconsideração da pessoa jurídica (disregard theory). Em qualquer dos casos, não há falar-se em responsabilidade subsidiária, nem em benefício de ordem.

2. Invocação do benefício de ordem. Citado o sócio, em face do qual foi redirecionada a execução primitivamente proposta contra a sociedade (tema que foi abordado nos comentários ao art. 790, II), tem ele a faculdade de invocar o *beneficium excussionis personalis*, nomeando à constrição “bens da sociedade, sitos na mesma comarca, livres e desembargados, quantos bastem para pagar o débito”. O regime é semelhante ao do fiador em relação ao afiançado, conforme do disposto no art. 794, já que se exige que os bens indicados estejam localizados na comarca da execução e que sejam suficientes para cobrir a dívida. Reproduz-se, quase literalmente, a regra prevista no parágrafo único do art. 827 do CC. Em outras palavras, o regime é o seguinte: quando invocado pelo sócio, o benefício de ordem supõe indicação de bens da sociedade sitos na mesma comarca.

Interpretação a contrario sensu do disposto na parte final do § 1.º do art. 795 poderia levar à conclusão de que ao sócio somente é facultado invocar o benefício de ordem se os bens da sociedade forem suficientes para cobrir toda a dívida. Não parece ser esta a compreensão mais adequada. A natureza subsidiária da responsabilidade do sócio, adotada como regra, conduz a resultado interpretativo menos rígido, a permitir a nomeação de bens penhoráveis da sociedade, sitos na comarca, independentemente do seu valor, sem prejuízo da ampliação da penhora em bens do próprio sócio, se necessário. É interpretação que atende aos interesses do credor, de ver penhorados bens suficientes para cobrir toda a dívida, sem sacrificar o direito do sócio, de ver executados, em primeiro lugar, os bens da sociedade.

Relativamente ao momento em que o benefício de ordem deve ser invocado, a lei foi omissa, a exemplo do que ocorreu quando tratou de idêntico benefício concedido ao fiador (CPC, art. 794). Conforme anotamos ao comentar aquele dispositivo, tanto lá quanto aqui a nomeação dos bens há de ser feita no prazo de três dias previsto no art. 829, sob pena de preclusão. Passada esta oportunidade, o benefício de ordem poderá ser eficazmente invocado somente se houver necessidade de ampliação da penhora (CPC, art. 850) ou de segunda penhora (CPC, art. 851).

Se a sociedade praticou atos em fraude à execução, ao sócio, chamado a pagar a dívida, assistirá a faculdade de invocar o benefício de ordem nomeando à penhora os bens alienados ou onerados fraudulentamente. O que sustentamos, neste particular, em relação ao fiador, aplica-se ao sócio.

3. Execução regressiva do sócio. O sócio, forçado a pagar judicialmente a dívida da sociedade, sub-rogando-se no crédito, poderá promover execução regressiva no mesmo processo. É o que estabelece o § 3.º do art. 795. Terá, assim, oportunidade de indicar à constrição outros bens do patrimônio social, como os situados em comarca diversa e mesmo os embargados (objeto de direito real em favor de terceiro, ou já penhorados).

4. Desconsideração da personalidade jurídica. Para que possa haver a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o sócio não responde, como regra, pelas dívidas da sociedade, impõe o § 4.º do art. 795 que a questão seja submetida ao incidente processual próprio, disciplinado nos arts. 133 a 137. Trata-se do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em cujo procedimento está assegurado o exercício de defesa e de produção de prova (art. 135), após o que o pedido será decidido, por decisão interlocutória ou, se for o caso, pelo relator (art. 136).

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

1. Responsabilidade patrimonial do espólio. Nos comentários ao caput do art. 778 e ao inc. II do art. 779 anotamos que, com a morte, opera-se mutação subjetiva na titularidade do patrimônio do falecido, sub-rogando-se os herdeiros nas relações jurídicas em que ele figurava, seja como credor, seja como devedor, seja como responsável. Enquanto não ultimada a partilha, os bens e obrigações do de cujus constituirão um todo indiviso, o espólio, que, embora sem personalidade jurídica, figura, com autorização da lei, como sujeito ativo ou passivo também nas relações processuais.

Ao estabelecer que o espólio e, depois da partilha, os herdeiros, respondem pelas dívidas do

falecido, o art. 796 reproduz o disposto na lei civil (CC, art. 1.997; CC/1916, art. 1.796). É norma que projeta para além da morte do devedor o princípio geral da responsabilidade patrimonial consagrado no art. 796. Consideram-se como sendo dos herdeiros, para esse efeito, “as dívidas e obrigações do decujo que se não hajam extinguido, inclusive as obrigações que advierem, após o falecimento do decujo, se oriundas de causas anteriores”.¹⁰⁴ Respondem a herança e os herdeiros também por fiança prestada pelo falecido ainda que a obrigação afiançada, com prazo prefixado, se vença após a sua morte.¹⁰⁵

Os bens do espólio continuam respondendo pelas obrigações do de cujus na mesma extensão como respondiam ao tempo em que o devedor era vivo. Em certas situações, a morte até amplia a base material da garantia do credor. Há bens, com efeito, cuja impenhorabilidade é estabelecida para assegurar ao devedor o regular exercício da sua profissão e um padrão de vida digno. Com sua morte, cessada a causa justificadora da proteção, eles se tornam penhoráveis. Assim ocorre com os vencimentos ou salários não pagos em vida, com os bens utilizados no exercício da sua profissão, com o imóvel que servia de moradia do falecido. Tornam-se penhoráveis, também, os imóveis gravados com cláusula de inalienabilidade, que se extingue com a morte do proprietário.

2. Responsabilidade patrimonial dos herdeiros. Feita a partilha dos bens do espólio, cada herdeiro passará a responder pelas dívidas do de cujus na proporção da parte que na herança lhe coube. O formal de partilha será o documento básico para aquilatar a extensão dessa responsabilidade, eis que nele estarão descritos os bens herdados e o que eles representam, em valor relativo, em face do patrimônio partilhado.

Para sustentar a responsabilidade assim definida sujeitam-se à execução os bens do herdeiro, e não os bens que o herdeiro recebeu na partilha. Essa distinção tem consequências significativas no plano jurídico. Subsiste a responsabilidade patrimonial mesmo que os bens herdados tenham perecido em mãos do herdeiro, ou tenham sido por ele alienados. Se os alienou, não obrou em fraude à execução, a não ser que, já citado quando da alienação, não tenha reservado outros bens suficientes para suportar a parte que lhe tocou na dívida executada.

Pode ocorrer que o herdeiro tenha recebido, na partilha, apenas bens impenhoráveis, como, por exemplo, móveis destinados a guarnecer a residência. Mesmo nesse caso, e ainda que persista a impenhorabilidade, o herdeiro não se exime de responder, com os demais bens penhoráveis do seu patrimônio, pelas dívidas do falecido, proporcionalmente ao valor do que herdou. Amplia-se, aqui também, a garantia do credor com a morte do primitivo devedor. A situação, se inconveniente para o herdeiro, pode ser evitada com renúncia à herança.

Em outros casos ocorre o contrário: reduz-se, com a partilha, a base patrimonial de segurança do credor (embora permaneça a mesma, juridicamente, a extensão da responsabilidade), quando o herdeiro adquire, com o produto da herança, bens impenhoráveis, ou dá, aos bens recebidos em partilha, destinação que os torna impenhoráveis. É o caso de quem, vivendo antes em casa alugada, adquire com os bens da herança sua moradia própria, que é impenhorável (Lei 8.009, de 29.03.1990). O mesmo se dá na situação em que o taxista de profissão passou a utilizar o automóvel herdado em sua atividade profissional (CPC, art. 833, V). Nos dois casos, os bens recebidos, antes penhoráveis, já não mais poderão sofrer ato executivo, nem mesmo pelos credores do falecido. Se outros bens penhoráveis não tiver o herdeiro, sua responsabilidade patrimonial subsistirá, mas sem base material para ser concretizada.

Não tem eficácia perante os credores do de cujus a cláusula de inalienabilidade (e, portanto, de impenhorabilidade) imposta aos bens deixados com o seu falecimento. Se o herdeiro recebe bens assim clausulados “o gravame será apenas para as dívidas pessoais dele – passadas ou futuras – e não para as relativas ao espólio”.¹⁰⁶

3. Responsabilidade patrimonial da herança jacente, dos legatários e do cônjuge supérstite. Se o falecido não deixar testamento e nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, ou se estes renunciarem (CC, arts. 1.819 e 1.823; art. 1.591 do CC/1916) a responsabilidade patrimonial pelas dívidas será suportada pela herança jacente e pela vacante (CPC, art. 741, § 4.º), bem como, se for o caso, pelo órgão do Poder Público que assumir o domínio dos bens deixados

pelo de cujus (CC, art. 1.822; CC/1916, art. 1.594), aplicando-se-lhes o regime do art. 796 do CPC.

A responsabilidade patrimonial prevista no art. 795 do Código é a dos herdeiros, não a dos legatários. Estes, em princípio, não respondem pelas dívidas do falecido. Só responderão se as dívidas não se comportarem no patrimônio deixado aos herdeiros. “Se as dívidas reduzem a herança, a ponto de não caberem na porção disponível as liberalidades, o legado é diminuído, ou são diminuídos os legados, posto que possa o legatário ou possam os legatários depositar a diferença para haver o legado. (...) Assim, em princípio, o legatário não responde pelas dívidas da herança. Se responde, a responsabilidade é limitada ao valor do legado, ao tempo em que tem de ser entregue e o é, e não ao tempo da abertura da sucessão”.¹⁰⁷

Relativamente ao cônjuge ou companheiro supérstite, sua responsabilidade patrimonial pelas dívidas assumidas por seu consorte é a definida no art. 790, IV, do CPC, e não se altera com o falecimento dele.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Salvatore Satta, *L'esecuzione forzata*, 4. ed., Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1963, p. 36; Alfredo Buzaid, *Do concurso de credores no processo de execução*, São Paulo: Saraiva, 1952, p. 16.

2

Entre os processualistas brasileiros, por exemplo, Alcides de Mendonça Lima entende que a responsabilidade patrimonial é instituto de direito material e que, portanto, sua disciplina, “é estranha tecnicamente ao Código de Processo Civil” (*Comentários... cit.*, p. 408). José Frederico Marques distingue a responsabilidade patrimonial (“imane a toda obligatio”) da responsabilidade processual, que “transforma a abstrata vinculação dos bens do devedor à obligatio assumida, na vinculação prática e concreta que se traduz nos atos coativos e expropriatórios da execução forçada” (*Manual... cit.*, vol. 4, p. 42).

3

É a orientação inaugurada por Carnelutti (*Sistema... cit.*, vol. I, p. 61), defendida por Liebman (*Processo de execução cit.*, p. 32; *Manual... cit.*, p. 209) e acolhida, no Brasil, entre outros, por Cândido Dinamarco (*Execução civil cit.*, p. 249), Humberto Theodoro Júnior (*Execução... cit.*, p. 198) e Amílcar de Castro (*Comentários... cit.*, p. 68).

4

Cândido Dinamarco. *Execução civil cit.*, p. 245.

5

Cândido Dinamarco, *Execução civil cit.*, p. 246.

6

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução cit., p. 74.

7

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução cit., p. 75. Em sentido contrário, na doutrina brasileira, Araken de Assis, Manual... cit., p. 304.

8

Ovídio A. Baptista da Silva, Curso... cit., vol. II, p. 73.

9

Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução cit., p. 208. No mesmo sentido: Araken de Assis, Manual... cit., p. 332.

10

Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 69.

11

Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 170.

12

Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 71; Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 427; Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução cit., p. 202.

13

Silvio Rodrigues. Direito civil cit., vol. I, p. 77. Também na jurisprudência do STJ entende-se que “é possível desconsiderar a pessoa jurídica usada para fraudar credores” (REsp 86.502, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 26.08.1996, p. 29693).

14

STJ, REsp 7.397, 2.^a Turma, Min. Ari Pargendler, RSTJ 81/159. No mesmo sentido: REsp 598, 1.^a Turma, Min. José Delgado, DJ 19.08.1996, p. 28433; REsp 45.453, 2.^a Turma, Min. Ari Pargendler, DJ 17.03.1997, p. 7461. Manifestamos o mesmo entendimento, no sentido da necessidade de citação do sócio responsável, como relator da Remessa de Ofício 91.04.1033725, TRF, 4.^a, 2.^a T., DJ 11.08.1993, p. 31118. “Se a sociedade tiver sido dissolvida irregularmente, sem que se encontre bens de sua propriedade” admite-se a execução direta contra o sócio (REsp 21.586, 2.^a Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.10.1994, p. 28734).

STF, RE 101.067, 2.^a Turma, Min. Aldir Passarinho, RTJ 116/1.086.

STJ, REsp 4.412, 1.^a Turma, Min. Pedro Aciole, DJ 04.03.1991, p. 1968. Todavia, se o sócio, sem ainda ter sido citado, ajuíza embargos de terceiro, nada impede que estes sejam acolhidos, para, “sob a salvaguarda da instrumentalidade das formas”, serem apreciadas e julgadas as questões nele postas (STJ, REsp 75.337, 1.^a Turma, Min. Milton Luiz Pereira, DJ 04.03.1996, p. 5379. No mesmo sentido, no TRF da 4.^a Região: AI 92.04.0091, 2.^a Turma, Juiz Teori Albino Zavascki, DJ 15.06.1994, p. 31452).

STJ, REsp 7.378, 1.^a Turma, Min. Garcia Vieira, DJ 14.12.1992, p. 23895; REsp 41.836, 2.^a Turma, Min. Hélio Mosimann, DJ 09.12.1996, p. 49238. No mesmo sentido, a jurisprudência do STF e do extinto TFR, conforme demonstramos ao relatar o acórdão AC 89.04.09854, TRF 4.^a Região, 2.^a Turma, DJ 28.08.1991, p. 20284; RTRF 4.^a Região 7/164.

Ovídio A. Baptista da Silva, Curso... cit., vol. II, p. 74; Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução cit., p. 203.

STJ, REsp 38.800, 3.^a Turma, Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ 50/354; REsp 21.817, 3.^a Turma, Min. Cláudio Santos, DJ 30.11.1992, p. 22609.

STJ, REsp 84.009, 3.^a Turma, Min. Costa Leite, DJ 01.07.1996, p. 24052; REsp 56.198, 3.^a Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 16.12.1996, p. 50863; REsp 45.741, 4.^a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 21.11.1994, p. 31773; REsp 87.710, 3.^a Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.02.1997, p. 723; REsp 64.132, 3.^a Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 24.03.1997, p. 9012; REsp 137.069, 3.^a Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 13.10.1997.

STJ, REsp 1.930, 4.^a Turma, Min. Athos Carneiro, DJ 07.05.1990, p. 3832.

STJ, REsp 44.399, 1.^a Turma, Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ 76/214; REsp 46.497, 2.^a Turma, Min. Ari Pargendler, RSTJ 94/118; REsp 50.443, 2.^a Turma, Min. Ari Pargendler, DJ 12.05.1997, p. 18778.

STJ, REsp 44.399, 1.^a Turma, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 19.12.1994, p. 35269; REsp 38.056, 2.^a Turma, Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 02.09.1992, p. 31054. No mesmo sentido, a Súmula 112 do extinto TFR: “Em execução fiscal, a responsabilidade pessoal do sócio-gerente de sociedade por quotas, decorrente de violação de lei ou excesso de mandato, não atinge a meação da sua mulher”.

24

REsp 16.950, 4.^a Turma (maioria), Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 05.04.1993, p. 5840 (RSTJ 50/235); REsp 1.164, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, RSTJ 8/385; REsp 31.234, 4.^a Turma (maioria), Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 29.11.1993, p. 25885.

25

REsp 89.167, 4.^a Turma (maioria), Min. Barros Monteiro, RSTJ 94/249.

26

STJ, REsp 19.335, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 05.10.1992, p. 17107; REsp 83.051, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27.05.1996, p. 17876. É também a orientação doutrinária (Araken de Assis, Manual... cit., p. 1030), amparada em lição de Hamilton de Moraes e Barros, segundo a qual “a mesma pessoa física ou jurídica pode ser simultaneamente parte e terceiro no processo, se são diferentes os títulos jurídicos que justificam esse duplo papel” (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. IX, p. 294).

27

STJ, Súmula 134: “Embora intimada da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação”.

28

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Código de Processo Civil anotado, 6. ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 668; STJ, REsp 31.956, 4.^a Turma, Min. Fontes de Alencar, RSTJ 57/330.

29

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução cit., p. 83.

30

Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil cit., vol. I, p. 372.

31

Yussef Said Cahali, Fraudes contra credores, São Paulo: Ed. RT, 1989, p. 68.

32

Cândido Dinamarco, Execução civil cit., p. 263.

33

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução cit., p. 85.

34

Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 440; Yussef Said Cahali, Fraudes contra credores cit., p. 83.

35

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução cit., p. 85; Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 80; Yussef Said Cahali, Fraudes contra credores cit., p. 79.

36

Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 440.

37

Pontes de Miranda, defensor da tese de que o efeito da fraude contra credores é a anulabilidade do negócio (e não a ineficácia relativa), admite: “O que é certo é que, para nascer a ação de anulação, é preciso ter havido diminuição do patrimônio, tal, que prejudique credores anteriores; mas a eficácia sentencial aproveita a todos, anteriores ou não, que se admitem ao concurso de credores” (Tratado de direito privado cit., t. IV, p. 486, § 503.2).

38

Cândido Dinamarco, Execução civil cit., p. 273.

39

Foi o que observou o Min. Eduardo Ribeiro em voto no REsp 13.322, reproduzido no acórdão do REsp 40.805, 3.^a Turma, DJ 08.05.1995, p. 12386.

40

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, p. 84. Nesse mesmo sentido: Cândido Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, p. 1987, p. 426; Ovídio A. Baptista da Silva, Curso... cit., vol. II, p. 77; Yussef Said Cahali, Fraudes contra credores cit., p. 313; P. R. Tavares Paes, Fraude contra credores, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1993, p. 32. Em sentido contrário, sustentando que a hipótese é de anulabilidade e não de ineficácia do ato fraudulento: Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas... cit., vol. 3, p. 251; José Frederico Marques, Manual... cit., vol. 4, p. 47; Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 439; Silvio Rodrigues, Direito civil cit., vol. 1, p. 244.

41

Voto do Min. Athos Gusmão Carneiro, no julgamento do REsp 5.307, reproduzido, para a ele aderir, pelo Min. Sálvio de Figueiredo, no REsp 20.166, 4.^a Turma, RSTJ 53/148.

42

Sobre o tema, com vasta fonte doutrinária e jurisprudencial ilustrando as duas correntes, consultar: Yussef Said Cahali, *Fraudes contra credores cit.*, p. 356.

43

Ilustrativos da divergência jurisprudencial a respeito do tema, no STJ, são os seguintes precedentes: REsp 20.166, 4.^a Turma, Min. Fontes de Alencar, RSTJ, 53/143; Embargos de Divergência em Recurso Especial 46.192, CE, Min. Nilson Naves, RSTJ 101/351; Embargos de Divergência no REsp 24.311, 2.^a Seção, Min. Barros Monteiro, j. 30.05.1994.

44

STJ, Súmula 195, cujos precedentes estão na RSTJ 101/341.

45

STJ, REsp 40.805, 3.^a Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 08.05.1995, p. 12386.

46

Cândido Dinamarco, *Execução civil cit.*, p. 265. Yussef Said Cahali sustenta tratar-se não de sentença de desconstituição de eficácia, mas de “declaração de ineficácia jurídica do negócio fraudulento”, de modo que não tem natureza constitutiva, e sim declaratória (*Fraudes contra credores cit.*, p. 324).

47

Sobre o tema, ver Rodrigo Mazzei, *Observações sobre a penhora envolvendo o direito de superfície (e outros direitos reais imobiliários) no Projeto do Código de Processo Civil*, RePro, ano 39, n. 228, 2014, p. 163-206.

48

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução cit.*, p. 98, nota 9. No mesmo sentido: Sálvio de Figueiredo Teixeira, *Fraude à execução*, Ajuris, 37/229; Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, *Fraude à execução*, Digesto de processo, Rio de Janeiro: Forense, 1985, vol. 3, p. 7.

49

Enrico Tullio Liebman, *Processo de execução cit.*, p. 97. No mesmo sentido: Humberto Theodoro Júnior,

Processo de execução cit., p. 313. Sobre os efeitos processuais e materiais da penhora, inclusive esse de “tornar ineficazes em relação ao credor (não nulos, nem anuláveis) os atos de disposição que porventura venha o devedor a praticar”, conferir José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro cit., p. 278.

50

Pontes de Miranda, Comentários... cit., t. IX, p. 467; Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 198; Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, Fraude à execução cit., p. 8; Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 81.

51

Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 81.

52

Pontes de Miranda, Comentários... cit., t. IX, p. 466.

53

Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 197.

54

Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil cit., vol. IV, p. 315.

55

Orlando Gomes, Contratos..., 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 246.

56

Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 452; Yussef Said Cahali, Fraudes contra credores cit., p. 465; Belmiro Pedro Welter, Fraude de execução... Porto Alegre: Síntese, 1997, p. 37; Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, Fraude à execução, cit., p. 6; Maria Berenice Dias, Fraude à execução, Ajuris 50/75.

57

Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 195; Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fraude de execução cit., p. 233; Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de processo civil comentado cit., p. 829; Pontes de Miranda, Comentários... cit., p. 462; Ernane Fidélis dos Santos, Manual... cit., vol. 2, p. 75.

58

STJ, REsp repetitivo 956.943/PR, Corte Especial, Min. João Otávio Noronha, DJe 01.12.2014; STJ, REsp 37.011, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, RSTJ 53/310; REsp 34.860, 3.^a Turma, Min. Nilson Naves, RSTJ 59/298; REsp 53.756, 3.^a Turma, Min. Nilson Naves, RSTJ 77/177; REsp 55.871, 3.^a Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 01.04.1996, p. 9909; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 65.271, 2.^a Turma, Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 19.05.1997, p. 7908; REsp 60.519, 2.^a Turma, Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 26.05.1997, p. 6245; REsp 97.646, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 18.11.1996, p. 44901; REsp 35.342, 4.^a Turma, Min. César Asfor Rocha, DJ 16.12.1996, p. 50873; REsp 31.321, 2.^a Turma, Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 21.10.1996, p. 40225; REsp 37.931, 4.^a Turma, Min. Fontes de Alencar, DJ 16.09.1996, p. 33744; REsp 76.063, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 24.06.1996, p. 22767; REsp 63.003, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 02.10.1995, p. 32380; REsp 61.114, 3.^a Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ 18.12.1995, p. 44560.

59

Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 192; Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fraude de execução, cit., p. 228.

60

Pontes de Miranda, Comentários... cit., t. IX, p. 460.

61

Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 87.

62

Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas... cit., vol. 3, p. 252. No mesmo sentido: Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução cit., p. 209; Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 87; Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fraude de execução cit., p. 231; Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 193; Pontes de Miranda, Comentários... cit., p. 461. Alcides de Mendonça Lima sustenta que “é indispensável a formalidade da inscrição da citação do réu em tais ações no Registro de Imóveis”, mas admite que sua falta apenas inverte o ônus da prova (Comentários... cit., p. 447-448). Yussef Said Cahali endossa o entendimento (Fraudes contra credores cit., p. 433). Na jurisprudência: STJ, REsp 135.228, 3.^a Turma, Min. Nilson Naves, DJ 13.04.1998, p. 117.

63

STJ, REsp 77.326, 3.^a Turma, Min. Waldemar Zveiter, RSTJ 89/230. Na doutrina: Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 194; Ernane Fidélis dos Santos, Manual... cit., vol. 2, p. 76; Ovídio A. B. da Silva, Curso... cit., vol. II, p. 77. Contra, entendendo que as medidas preventivas não servem para a configuração da fraude: Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 452.

64

Pontes de Miranda, Comentários... cit., t. IX, p. 463; Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 195.

65

Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 453; Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, Fraude à execução cit., p. 8.

66

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fraude de execução cit., p. 228.

67

STJ, REsp 34.498, 3.^a Turma, Min. Waldemar Zveiter, RSTJ 53/268; REsp 20.778, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 31.10.1994, p. 29550; REsp 61.448, 3.^a Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ 27.11.1995, p. 9159. Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 451.

68

STJ, REsp 29.808, 3.^a Turma, Min. Nilson Naves, DJ 03.05.1993, p. 7796.

69

STJ, REsp 13.988, 3.^a Turma, Min. Cláudio Santos, DJ 28.06.1993, p. 12886; REsp 1.436, 3.^a Turma, Min. Bueno de Souza, DJ 21.08.1995, p. 25367.

70

STJ, REsp 101.472, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 28.04.1997, p. 15876.

71

STJ, REsp 47.106, 3.^a Turma, Min. Costa Leite, DJ 20.02.1995, p. 3180.

72

TRF, 4.^a Região, AC 34.032, 2.^a Turma, Juiz Teori Albino Zavascki, DJ 08.09.1994, p. 49412.

73

Pontes de Miranda, Comentários... cit., p. 466; Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 452; Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 88; Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 202; Ernane Fidélis dos Santos, Manual... cit., vol. 2, p. 76; Humberto Theodoro Júnior, Processo de execução cit., p. 212; Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fraude de execução cit., p. 228.

74

STF, RE 108.911, Min. Carlos Madeira, DJ 22.08.1986, p. 14524. Na doutrina: Pontes de Miranda.

75

STJ, REsp 89.657, 3.^a Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 18.05.1998, p. 82.

76

A jurisprudência do STJ ainda vacila quanto ao ponto. Há precedentes no sentido de que “tratando-se de aquisição efetuada diretamente do devedor, e sendo este insolvente, desnecessário demonstrar que o adquirente tinha conhecimento da pendência da demanda” (REsp 38.239, 3.^a Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ 10.10.1994, p. 27167); há precedentes entendendo que “na ausência de registro, ao credor cabe o ônus de provar que o terceiro tinha ciência da demanda em curso” (REsp 4.132, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 07.10.1991, p. 13910; REsp 40.854, 4.^a Turma, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 13.10.1997, p. 51594); e, finalmente, há julgados sustentando que a fraude, nestes casos, depende da prova, a ser feita pelo credor, “de que o adquirente tinha motivo para saber da existência da ação” (REsp 114.415, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 26.05.1997, p. 22546).

77

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, Fraude à execução cit., p. 8.

78

STJ, REsp 34.189, 3.^a Turma, maioria, Min. Dias Trindade, RSTJ 58/353.

79

REsp 27.555, 3.^a Turma, Min. Dias Trindade, DJ 16.11.1992, p. 21141.

80

STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 9.500, 3.^a Turma, Min. Nilson Naves, DJ 17.06.1991, p. 4164; REsp 54.150, 2.^a Turma, Min. Ari Pargendler, DJ 17.03.1997, p. 7461; REsp 68.212, 3.^a Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ 15.04.1996, p. 11525.

81

REsp 45.453, 2.^a Turma, Min. Ari Pargendler, DJ 16.12.1992, p. 50826; REsp 32.890, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 11.12.1994, p. 34350.

82

STJ, REsp 92.507, 1.^a Turma, Min. José de Jesus Filho, RSTJ 93/105; RMS 7.229, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, RSTJ 93/265; REsp 113.666, 3.^a Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 30.06.1997, p. 31031; REsp 56.056, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 17.03.1997, p. 7505; REsp 76.063, 4.^a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 24.06.1996, p. 22767.

83

STJ, REsp 43.738, 2.^a Turma, Min. Américo Luz, DJ 14.08.1995, p. 24012; REsp 68.212, 3.^a Turma, Min. Waldemar Zveiter, DJ 15.04.1996, p. 30437.

84

STJ, REsp 2.250, 1.^a Turma, Min. Cesar Asfor Rocha, RSTJ 57/175; REsp 81.297, 1.^a Turma, Min. Demócrito Reinaldo, DJ 16.12.1996, p. 63712. Na doutrina: Aliomar Baleeiro, *Direito tributário brasileiro*, 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 604.

85

Paulo de Barros Carvalho, *Curso de direito tributário*, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 1991, p. 356.

86

Milton Flaks, *Comentários à lei da execução fiscal cit.*, p. 294; Celso Ribeiro Bastos, *Curso de direito financeiro e de direito tributário*, São Paulo: Saraiva, 1991, p. 226.

87

REsp 33.993, 1.^a Turma, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 27.06.1994, p. 16902; REsp 74.021, 1.^a Turma, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 04.03.1996, p. 5375; REsp 119.979, 1.^a Turma, Min. José Delgado, DJ 17.11.1997, p. 59435.

88

Yussef Said Cahali, *Fraudes contra credores cit.*, p. 726.

89

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado cit.*, t. XXII, § 2.735, p. 257.

90

Mario Aguiar Moura, *O processo de execução cit.*, p. 205.

91

Pontes de Miranda, *Comentários... cit.*, t. IX, p. 472; Amílcar de Castro, *Comentários... cit.*, p. 96.

92

Alcides de Mendonça Lima, *Comentários... cit.*, p. 457.

93

STJ, REsp 8.453, 4.^a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 03.08.1992, apud Sálvio de Figueiredo Teixeira, Código de Processo Civil anotado cit., p. 421.

94

Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 97.

95

Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 465.

96

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Código de Processo Civil comentado, cit., p. 421; Araken de Assis, Manual... cit., p. 223.

97

Pontes de Miranda, Comentários... cit., p. 473; Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 99; Fran Martins, Contratos e obrigações comerciais, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 341.

98

Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 206.

99

Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 208; Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 98; Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 465.

100

Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 463.

101

Em sentido contrário: Mario Aguiar Moura, O processo de execução p. 210.

102

Humberto Theodoro Júnior, Curso... cit., vol. II, p. 829.

103

Pontes de Miranda, Comentários... cit., t. IX, p. 478; Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit.,

p. 211; Amílcar de Castro, Comentários... cit., p. 100; Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 467.

104

Pontes de Miranda, Tratado de direito privado cit., vol. 60, § 6.008, p. 300.

105

STJ, REsp 19.113, 4.ª Turma, Min. Dias Trindade, DJ 20.09.1993, p. 19178.

106

Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 472; Mario Aguiar Moura, O processo de execução cit., p. 213.

107

Pontes de Miranda, Tratado de direito privado cit., vol. 60, § 6.007, p. 298. No mesmo sentido: Alcides de Mendonça Lima, Comentários... cit., p. 472.

© desta edição [2018]

Referências Bibliográficas

- ABRÃO, Nelson. *Curso de direito bancário*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1988.
- ALEX, Robert. *Teoría de los derechos fundamentales*. Trad. de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.
- ALVIM, Arruda. *Código de processo civil comentado*. São Paulo: Ed. RT, 1976.
- _____. Interpretação da sentença líquidanda – Fidelidade ao seu sentido original – Multa convencional e ‘astreintes’ – Diferenças e limites. *Revista de Processo* 77:182.
- _____. *Manual de direito processual civil*. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- ALVIM, J. E. Carreira. *Ação monitória e temas polêmicos da reforma processual*. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.
- _____. *Código de processo civil reformado*. Belo Horizonte: Del Rey, 1995.
- ANDOLINA, Italo. ‘Cognizione’ ed ‘esecuzione forzata’ nel sistema della tutela giurisdizionale. Milano: Giuffrè, 1983.
- _____. *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo*. Milano: Giuffrè, 1982.
- ANDRIGHI, Fátima Nancy. O registro da penhora e a reforma do CPC. *Revista Jurídica* 215:51.
- ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Notas sobre a liquidação de sentença. *Revista de Processo* 44:21.
- ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Cabe citação com hora certa na execução? Ed. RT 584:284.
- ARMELIN, Donaldo. Cobrança da Dívida Ativa não tributária da Fazenda Pública. *Revista de Processo* 45:8.
- _____. O processo de execução e a reforma do código de processo civil. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do código de processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- _____. *Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 1979.
- ARRUDA, Antonio Carlos Matteis de. *Liquidação de sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1981.
- ASSIS, Araken de. *Eficácia civil da sentença penal*. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- _____. *Manual do processo de execução*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1995.
- _____. Reforma do processo executivo. In GIORGIS, José Carlos Teixeira (coord.). *Inovações do código de processo civil*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.
- BALEIRO, Aliomar. *Direito tributário brasileiro*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983.

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Ação para cumprimento das obrigações de fazer e não fazer. In GIORGIS, José Carlos Teixeira (coord.). *Inovações do código de processo civil*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.

_____. *Comentários ao código de processo civil*. 2. ed. Porto Alegre: Lejur, 1986.

_____. *Curso de processo civil*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1998.

_____. *Do processo cautelar*. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

_____. *Jurisdição e execução na tradição romano-canônica*. São Paulo: Ed. RT, 1996.

_____. *Sentença e coisa julgada*. 2. ed. Porto Alegre: Fabris, 1988.

BARBI FILHO, Celso. Efeitos da reforma do código de processo civil na execução específica do acordo de acionistas. *Gênesis – Revista de Direito Processual Civil* 3:601.

BARCELOS, Pedro dos Santos. Possibilidade de admissão de embargos de devedor sem estar seguro o juízo da execução, Ed. RT 652:227.

BARROS, Humberto Gomes de. Execução contra a fazenda pública. *Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva*, vol. 9, n. 2, 1997, p. 100.

BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de direito financeiro e de direito tributário*. São Paulo: Saraiva, 1991.

BENETI, Sidnei Agostinho. A penhora de bem imóvel diante da lei n. 8.953/94. *Reforma do código de processo civil*. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). São Paulo: Saraiva, 1996.

BERMUDES, Sérgio. *A reforma do código de processo civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

BETANHO, Luiz Carlos. *Código penal e sua interpretação jurisprudencial*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 1993.

BEVILÁQUA, Clóvis. *Teoria geral do direito civil*. 6. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1953.

BOBBIO, Norberto. *Teoría general del derecho*. Trad. Jorge Guerrero R. 2. ed. Santa Fe de Bogota, Colombia: Temis, 1992.

_____. *Teoria do ordenamento jurídico*. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 7. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1996.

BUENO, Cássio Scarpinella. O artigo 604 do código de processo civil comporta objeção de pré-executividade? In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Atualidades sobre liquidação de sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1997.

BULGARELLI, Waldirio. *Manual das sociedades anônimas*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

_____. *Títulos de crédito*. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

BUZAID, Alfredo. *Do concurso de credores no processo de execução*. São Paulo: Saraiva, 1952.

_____. Da liquidação por artigos em ação de ressarcimento de perdas e danos. *Revista de Processo* 43:12.

CAHALI, Yussef Said. *Honorários advocatícios*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1990.

_____. *Fraudes contra credores*. São Paulo: Ed. RT, 1989.

CALAMANDREI, Piero. *Instituciones de derecho procesal civil*. Trad. Santiago Sentis Melendo.

Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1986.

_____. La condana. *Opere giuridiche*. Napoli : Morano, 1972, 5.º v., p. 493.

_____. La condena 'genérica' a los daños. *Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares*. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945.

CAMPOS, Ronaldo Cunha. *Execução fiscal e embargos do devedor*. Rio de Janeiro: Forense, 1978.

CARMONA, Carlos Alberto. O processo de execução depois da reforma. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do código de processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.

_____. Das boas relações entre os juízes e os árbitros. *Revista do Advogado*, Associação dos Advogados de São Paulo, 51:19.

_____. O processo de liquidação de sentença. *Revista de Processo* 60:44.

CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição – Noções fundamentais. *Ajuris* 20:33.

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Aspectos processuais da nova lei de arbitragem. *Revista Forense* 339:135.

CARNELUTTI, Francesco. *Sistema de derecho procesal civil*. Trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Uteha Argentina.

_____. *Instituciones del proceso civil*. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.

_____. *Derecho y proceso*. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971.

CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de direito tributário*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.

CASTRO, Amílcar de. *Comentários ao código de processo civil*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1983.

CASTRO, José Antônio de. *Execução no código de processo civil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1983.

CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de direito processual civil*. 3. ed. Trad. J. Guimarães Menegale, São Paulo: Saraiva, 1969

COSSIO, Carlos. *La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad*. 2. ed. Buenos Aires: Abelardo-Perrot, 1964.

_____. Teoria egológica e teoria pura do direito. *Revista Forense*, maio 1950, p. 47.

COSTA, José Rubens da. Alterações no processo de conhecimento. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do código de processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.

COUTO E SILVA, Clóvis V. do. *A obrigação como processo*. São Paulo: José Bushatsky, 1976.

COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del derecho procesal civil*. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1990.

CRETELLA JÚNIOR, José. *Comentários à constituição de 1988*. São Paulo: Forense Universitária, 1991.

DALL'AGNOL JÚNIOR, Antonio Janyr. Da desistência no processo de execução. *Ajuris* 19:86.

_____. Concurso particular de preferência, *Ajuris* 7:54.

DIAS, Maria Berenice. Fraude à Execução, *Ajuris* 50:75.

- DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. *Fraude à execução. Digesto de processo*. Rio de Janeiro: Forense, 1985, vol. 3.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *A instrumentalidade do processo*. São Paulo: Ed. RT, 1987.
- _____. *A reforma do código de processo civil*. São Paulo: Malheiros, 1995.
- _____. As três figuras da liquidação de sentença. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Atualidades sobre liquidação de sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- _____. *Execução civil*. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
- _____. *Fundamentos do processo civil moderno*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1987.
- _____. *Litisconsórcio*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1994.
- DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de introdução à ciência do direito*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
- _____. *Curso de direito civil brasileiro*. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
- DORIA, Dilson. *Curso de direito comercial*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.
- ENGISCH, Karl. *Introdução ao pensamento jurídico*. Trad. J. Baptista Machado. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. *Comentários ao código de processo civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.
- FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo; MILARÉ, Édís e NERY JUNIOR, Nelson. *A ação civil pública e a tutela jurisdicional dos interesses difusos*. São Paulo: Saraiva, 1984.
- FERREIRA, Carlos Renato de Azevedo. *Exceção de pré-executividade*. Ed. RT 657:243.
- FERREIRA, Pinto. *Comentários à constituição brasileira*. São Paulo: Saraiva, 1990.
- FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. *Manual da arbitragem*. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- _____. *Arbitragem – Jurisdição e Execução*. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- FLAKS, Milton. *Comentários à lei da execução fiscal*. São Paulo: Forense, 1981.
- FORNACIARI JÚNIOR, Clito. *A reforma processual civil (artigo por artigo)*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- FREITAS, Juarez. *A interpretação sistemática do direito*. São Paulo: Malheiros, 1995.
- FURNO, Carlo. *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*. Florença: Casa Editrice del Dott. Carlo Cya, 1942.
- FURTADO, Paulo. *Execução*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.
- FUX, Luiz. *Tutela antecipada e locações*. Rio de Janeiro: Destaque, 1995.
- GOMES, Orlando. *Obrigações*. 11. ed. revista e atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- _____. *Contratos*. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- GRECO FILHO, Vicente. *Direito processual civil brasileiro*. 9. ed. São Paulo: Saraiva.

- GRINOVER, Ada Pellegrini. *Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. 2. ed. São Paulo: Forense Universitária, 1992.
- _____. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer. *Revista de Processo* 79:76.
- GUERRA, Marcelo Lima. *Execução forçada – Controle de admissibilidade*. São Paulo: Ed. RT, 1995.
- _____. *Execução indireta*. São Paulo: Ed. RT, 1998.
- GUERRA, Willis Santiago. Aspectos da execução forçada no direito processual brasileiro. *Revista de Processo* 83:60.
- HEGEDUS, Margarita de. Cooperación judicial internacional en materia cautelar. Apud LANDOSI SOSA, Angel (Coord.). *Curso de derecho procesal internacional y comunitario del Mercosur*. Montevideo: Fundacion de Cultura Universitaria, 1997.
- JESUS, Damásio de. *Direito penal*. 13. ed. São Paulo: Saraiva.
- KELSEN, Hans. *Teoria geral das normas*. Tradução de José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1986.
- LACERDA, Galeno. Ação civil pública. *Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul*, 19:32.
- _____. *Comentários ao código de processo civil*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- _____. Execução de título extrajudicial e segurança do “juízo”. *Ajuris* 23:11.
- _____. O Código e o formalismo processual. *Ajuris* 28:7.
- LATORRE, Angel. *Introdução ao direito*. Trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: Livraria Almedina, 1978.
- LIEBMAN, Enrico Tullio. *Eficácia e autoridade da sentença*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
- _____. *Embargos do executado*. Trad. J. Guimarães Menegale. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1968.
- _____. *Manual de direito processual civil*. Trad. Cândido Rangel Dinamarco. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
- _____. *Processo de execução*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1968.
- LIMA, Alcides de Mendonça. “Astreintes”. In FRANÇA, R. Limongi (coord.). *Enciclopédia Saraiva do direito*. 8. vol., p. 350.
- _____. *Comentários ao código de processo civil*. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense.
- MACHADO, Hugo de Brito. In MARTINS, Ives Gandra da Silva e MENDES, Gilmar Ferreira (coord.). *Ação declaratória de constitucionalidade*. São Paulo: Saraiva, 1994.
- MACHADO, J. Baptista. *Introdução ao direito e ao discurso legitimador*. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.
- MACHADO, Luiz Melíbio Uiraçaba. Juízo arbitral – Comentários sobre a lei n. 9.307/96, *Ajuris*, 69:345.
- MAC'DONALD, Norberto da Costa Caruso. Ação cambiária. *Revista de Estudos Jurídicos* (Centro de Ciências Jurídicas da Unisinos), 17:112.
- MALACHINI, Edson Ribas. Os títulos executivos e a nova lei n. 8.953, de 1994. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. *Reforma do código de processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.

- _____. *Questões sobre a execução e os embargos de devedor*. São Paulo: Ed. RT, 1980.
- MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, especialmente e legitimação. *RT* 743:94.
- MANDRIOLI, Crisanto. *L'azione esecutiva*. Milano: Giuffrè, 1955.
- _____. *L' esecuzione forzata in forma specifica*. Milano: Giuffrè, 1953.
- MARINHO, José Domingos da Silva. A necessidade de uma constituição concisa. *Justitia* 135:24.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *A antecipação da tutela na reforma do processo civil*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
- _____. *Tutela inibitória*. São Paulo: Saraiva, 1998.
- MARQUES, José Frederico. *Manual de direito processual civil*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1987.
- MARTINS, Fran. *Contratos e obrigações comerciais*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972.
- _____. *Curso de direito comercial*. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- MEDINA, Llewellyn. Execução de obrigação alternativa quando a escolha pertence ao credor. *Revista Brasileira de Direito Processual* 40:98.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 14. ed. São Paulo: Ed. RT, 1989.
- _____. *Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, "habeas data"*. 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 1989.
- MENDES, Gilmar Ferreira. *Controle de constitucionalidade – Aspectos jurídicos e políticos*. São Paulo: Saraiva, 1990.
- _____. *Jurisdição constitucional*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- MICHELI, Gian Antonio. *Proceso de ejecución*. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1970.
- MIRANDA JÚNIOR, Darcy Arruda. *Curso de direito comercial*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.
- MORAES, Voltaire de Lima. A ação civil pública e a tutela do meio ambiente. *Ajuris* 37:220.
- MOREIRA, José Carlos Barbosa. A antecipação da tutela jurisdicional na reforma do código de processo civil. *Revista de Processo* 81:210.
- _____. A tutela específica do credor nas obrigações negativas. *Temas de direito processual – Segunda série*. São Paulo: Saraiva, 1980.
- _____. Antecedentes da reforma processual e sistemática geral do novo código de processo civil. *Estudos sobre o novo código de processo civil*. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1974.
- _____. *O novo processo civil brasileiro*. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- _____. Reflexões críticas sobre uma teoria da condenação civil. Apud *Temas de direito processual civil – 1.ª Série*. São Paulo: Saraiva, 1977.
- _____. Sobre a participação do juiz no processo civil. In GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel e WATANABE, Kazuo (coord.). *Participação e processo*. São Paulo: Ed. RT, 1988.
- MOURA, Mario Aguiar. *O processo de execução*. Porto Alegre: Emma, 1975.

- NERY JUNIOR, Nelson. *Atualidades sobre o processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 1995.
- NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. *Código de processo civil comentado*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- NEVES, Celso. *Estrutura fundamental do processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- NOGUEIRA, Antônio de Pádua Ferraz. Problemática e implicações da revogação do ato expropriatório. Ed. RT 566:23.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto de. Exeqüibilidade dos contratos de abertura de crédito. *Revista Jurídica* 242:133.
- _____. *Comentários ao código de processo civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- _____. OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. Dano moral. *RDR* n. 7, jan./abr. 1997.
- OLIVEIRA JÚNIOR, Waldemar Mariz de. *Substituição processual*. São Paulo: Ed. RT, 1971.
- PACHECO, José da Silva. *Tratado das execuções*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1976.
- PAES, P. R. Tavares. *Fraude contra credores*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- PASSOS, J. J. Calmon de. A crise do processo de execução. *Ciência Jurídica* 37:21.
- _____. A transferência da propriedade para o domínio do expropriante no curso da ação de desapropriação. *Ajuris* 26:189.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1984.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- _____. *Inovações no Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- PAULA, Alexandre de. *Código de processo civil anotado*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 1988.
- PAULSEN, Leandro. *Direito Tributário: Constituição, Código Tributário e Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da Jurisprudência*. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002.
- PEDROSO, Antonio Carlos de Campos. *Normas jurídicas individualizadas: Teoria e aplicação*. São Paulo: Saraiva, 1993.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
- _____. *Responsabilidade civil*. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- PEREIRA, Pedro Barbosa. *Curso de direito comercial*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1969.
- PISANI, Andrea Proto. Appunti sulla tutela cautelare. *Rivista di Diritto Civile*, I, 1987.
- PODETTI, J. Ramiro. *Tratado de las Ejecuciones*. 3. ed. Buenos Aires: Ediar, 1997.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1974.
- _____. *Dez anos de pareceres*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
- _____. *Tratado das ações*. São Paulo: Ed. RT, 1978.
- _____. *Tratado de direito privado*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT.

- PRATA, Edson. *As astreintes no direito brasileiro*. *Revista Brasileira de Direito Processual* 22:15.
- REIS, José Alberto dos. *Processo de execução*. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1985.
- RODRIGUES, Silvio. *Direito civil*. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.
- SAMPAIO, José Maria Gonçalves. *A ação executiva e a problemática das execuções injustas*. Lisboa: Cosmos, 1992.
- SANCHES, Sydney. *Execução específica (das obrigações de contratar e de prestar declaração de vontade)*. São Paulo: Ed. RT, 1978.
- SANTOS, Ernane Fidélis dos. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1988.
- _____. *Títulos executivos*. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do código de processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- SANTOS, Moacyr Amaral. *Primeiras linhas de direito processual civil*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, vol. 3.
- SANTOS, Ulderico Pires dos. *O processo de execução na doutrina e na jurisprudência*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
- SATTA, Salvatore. *L'esecuzione forzata*. 4. ed. Torino: Utet, 1963.
- SHIMURA, Sérgio Seiji. *Execução para entrega de coisa*, *Justitia* 57(172):106.
- _____. *Título executivo*. São Paulo: Saraiva, 1997.
- SICHES, Luis Recasens. *Estudios de filosofia del derecho*. Barcelona: Bosch, 1936.
- SOUZA, Maria Helena Rau de. *Execução fiscal – Doutrina e jurisprudência*. Vladimir Passos de Freitas (coord.). São Paulo: Saraiva, 1998.
- SZKLAROWSKY, Leon Frejda. *Apuração e inscrição da dívida ativa da fazenda pública; natureza jurídica. Conteúdo do ato de controle administrativo da legalidade (Lei 6.830/80, art. 2.º, § 3.º)*. *Revista de Processo* 23:168.
- TÁCITO, Caio. *Desapropriação – Desistência*. *RDP* 68:93.
- TALAMINI, Eduardo. *A determinação do valor do crédito por simples cálculo*. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Atualidades sobre liquidação de sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- _____. *Tutelas mandamental e executiva lato sensu e a antecipação de tutela ex vi do art. 461, § 3.º, do CPC*. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Aspectos polêmicos da antecipação da tutela*. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. *Código de processo civil anotado*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
- _____. *Fraude à execução*. *Ajuris* 37:229.
- TELLES, Gil Trota. *Propositura de ação declaratória negativa depois de ajuizada execução de título extrajudicial*. *Ajuris* 55:104.
- TELLES JÚNIOR, Goffredo. *Direito quântico*. São Paulo: Max Limonad.
- THEODORO JÚNIOR, Humberto. *As inovações no código de processo civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- _____. *Curso de direito processual civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

_____. Execução – Contrato de abertura de crédito como título executivo. *Revista Jurídica* 236:132.

_____. *Processo de execução*. 18. ed. São Paulo: Livraria Editora Universitária de Direito, 1997.

TESHEINER, José Maria Rosa. Do concurso especial de credores no código de processo civil de 1973. *Ajuris* 3:105.

VACCARELLA, Romano. *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*. 2. ed. Torino: Utet, 1993.

VARELA, Antunes. *Direito das obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 1977.

VASCONCELOS, Antonio Vital Ramos de. Inexistência de execução no processo de desapropriação. *Ciência Jurídica*, n. 68, março/abril/96.

WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Liquidação de sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1997.

_____. Anotações sobre a liquidação de sentença depois da reforma do CPC. Apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Atualidades sobre liquidação de sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1997.

WATANABE, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do código de processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.

WELTER, Belmiro Pedro. *Fraude de execução*. Porto Alegre: Síntese, 1997.

YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação de tutela específica nas obrigações de declaração de vontade. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Aspectos polêmicos da antecipação da tutela*. São Paulo: Ed. RT, 1997.

_____. *Tutela jurisdicional específica nas obrigações de declaração de vontade*. São Paulo: Malheiros, 1993.

ZAVASCKI, Teori Albino. *Antecipação da tutela*. São Paulo: Saraiva, 1997.

_____. Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos. *Revista de Informação Legislativa*, 127:83 e *Forense* 329:156.

_____. Ministério Público e ação civil pública. *Revista de Informação Legislativa*, 114:156.

_____. O Ministério Público e a defesa de direitos individuais homogêneos. *Revista de Informação Legislativa* 117:173.

Índice Alfabético-remissivo

Ação anulatória

–Do título executivo: Art. 781, 6 e art. 784, 9

Ação cautelar

–Desistência da Execução: art. 775, 8

Ação de execução

–Aplicação Subsidiária do Processo de Conhecimento: art. 771, 1 e 2

–Cumulação de Execuções: art. 780, 1, 2, 3, 4 e 5

–Desistência: art. 775, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

–Prestações Periódicas: art. 780, 5

–Requisitos: art. 786, 1 e 2

Ação Executiva *Lato Sensu*

–Autonomia: Introdução 6

Ação Pauliana

–Fraude Contra Credores: art. 790, 6

Adimplemento

–Antes ou no Curso da Execução: art. 788, 2

–Imperfeito: art. 788, 5

–Recusa da Prestação: Art. 788, 3

–v. Inadimplemento

Aluguel

–Título Executivo: art. 784, 7

Antecipação de Tutela

–Execução: Introdução 7

Anticrese

–Título Executivo: art. 784, 6

Assistência

–Processo de Execução: art. 778, 2

Astreintes

–Desistência da Execução: art. 775, 7

Atos executivos

–Atos Executivos: art. 782, 1 e 4

Benefício de ordem

–Fiador, em relação ao Afiançado: art. 794, 1 e 2

–Fraude à Execução: art. 794 3

–Sócio, em relação à Sociedade: art. 795, 2

Boa-fé

–Na Fraude à Execução: art. 790, 6 e art. 792, 10

–Na Fraude Contra Credores: art. 790, 6

Caução

–Título de Crédito: art. 784, 6

Cessão

–de Crédito: art. 778, 10 e 11

–v. contrato

Cessionário

–Legitimação Ativa: art. 778, 10

Cheque

–Título Executivo: art. 784, 2

Coisa julgada

–Sentença declarando inexistente a obrigação: art. 776, 4

Competência

–execução fundada em título extrajudicial: art. 781, 1

–funcional: art. 781, 3

–internacional: art. 781, 2

–territorial: art. 781, 6

Concurso

–de credores: art. 781, 5

Cônjuge

–legitimação ativa: art. 778, 9

–responsabilidade patrimonial: art. 790, 5

Contrato

–cessão de crédito: art. 778, 10 e 11

–de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução: art. 784, 6

–de seguro: art. 784, 6

–títulos executivos: art. 784, 2 e 3

Credor

–legitimação ativa: art. 778, 4

Cumprimento Provisório

–Desistência: art. 775, 9

Cumulação de execuções

–v. Ação de execução

Debênture

–título executivo: art. 784, 2

Desistência

–da execução: art. 775, 1, 2, 4, 7, 9 e 10

Devedor

–exoneração nas obrigações bilaterais: art. 787, 2

–legitimação passiva: art. 779, 2

–v. Responsabilidade patrimonial

Dignidade da justiça

–atos atentatórios: art. 774, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

–comportamento processual: art. 772, 2

Direito de retenção

–execução sobre bens retidos: art. 793, 1, 2 e 3

Direitos individuais homogêneos

–legitimidade para a execução: art. 778, 5

Dívida

–transmissão: art. 779, 3, 4 e 5

Dívida ativa

–certidão de dívida ativa: art. 784, 8

Documento

–particular: art. 784, 4

–público: art. 784, 3

Duplicata

–título executivo: art. 784, 2

Embargos

–da retenção: art. 775, 6

Embargos de terceiro

–cônjuge: art. 790, 5

–desistência da execução: art. 775, 8

–fraude contra credores: art. 790, 6

Embargos do devedor

–desistência da execução: art. 775, 4, 5, 10

–excesso de execução: art. 775, 5

Encargo de condomínio

–título executivo: art. 784, 7

Entrega de coisa

–v. Execução para entrega de coisa

Espólio

–Legitimação ativa: art. 778, 8

–Legitimação passiva: art. 779, 3

–Responsabilidade patrimonial: art. 796, 1

Exceção de pré-executividade

–Conceito: art. 771, 1

Excesso de execução

–Embargos: art. 775, 5

Execução

–Autonomia da execução forçada: Introdução 5, 6 e 7

–Distinção entre cognição e execução: Introdução 3

–Injusta: art. 776, 6

–Natureza Jurisdicional: art. 782, 3

–Requisitos: art. 786, 1 e 4

–v. Desistência

–v. Meios Executivos

Execução fiscal

–depósito do valor: art. 784, 11

Execução por carta

–Justiça Federal pela Justiça Estadual: art. 781, 4

Fiador

–benefício de ordem: art. 794, 1, 2 e 3

–convencional, legal e abonador: art. 779, 7

–judicial: art. 779, 6

–sub-rogado: art. 794, 4

Força Policial

–Requisição: art. 782, 5

Foro

–Título Executivo: art. 784, 7

Fraude à Execução

–Distinção da Alienação de Bens Penhorados: art. 792, 8

–Distinção de Fraude a Credores: art. 790, 6

–Pressupostos: art. 792, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

–Situações configuradoras: art. 792, 1 e 9

Fraude Contra Credores

–Distinção da Fraude à Execução: art. 790, 6

–v. Ação Pauliana

Herança

–Responsabilidade Patrimonial: art. 796, 2 e 3

Herdeiro

–Legitimação: art. 778, 8 e art. 779, 3

–Responsabilidade Patrimonial: art. 790, 2

Hipoteca

–Contrato de Hipoteca: art. 784, 6;

Inadimplemento

–Adimplemento Imperfeito: art. 788, 5

–Conceito: art. 786, 3

–Controle: art. 786, 4

–Cumprimento da Obrigação pelo Devedor: art. 788, 1, 2 e 4

–Recusa da Prestação: art. 788, 3

–Requisito da Execução: art. 786, 1

Insolvência

–Insolvência Civil e Concurso de Credores: art. 781, 5

Intervenção de Terceiros

–Na execução: art. 778, 2

–v. Processo de Execução

Juiz

–Poderes: art. 772, 1

Jurisdição

–Conceito: Introdução, 2

–Natureza Jurisdicional da Execução: Introdução 3 e art. 782, 3

Justiça Federal

–Execução por Carta: art. 781, 4

Laudêmio

–Título Executivo: art. 784, 7

Legatários

–Responsabilidade Patrimonial: art. 796, 3

Legitimação (no processo de execução)

–Ativa: art. 778, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13

–Cessionário: art. 778, 10

–Cônjuge Sobrevivente: art. 778, 9

–Espólio, Herdeiros e Sucessores: art. 778, 8

–Fiador: art. 779, 6 e 7

–Litisconsórcio, Assistência e Intervenção de Terceiros: art. 778, 2

–Passiva: art. 779, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9

–Pessoa Jurídica: art. 778, 13

–Responsável Tributário: art. 799, 9

–Sub-rogado: art. 778, 12

–Substituto Processual: art. 778, 7

–Sucessor na Dívida: art. 779, 3, 4, 5

Letra de Câmbio

–Título Executivo: art. 784, 2

Liquidez

–Conceito: art. 783, 1

Litisconsórcio

–Processo de execução: art. 778, 2

Meação do Cônjuge

–Medo de excluir: art. 790, 5

Ministério Público

–Legitimação: art. 778, 5

–Título Executivo: art. 784, 5

Multa

–Ato Atentatório à Dignidade da Justiça: art. 774, 7, 8, 9

–v. *Astreintes*

Nota Promissória

–Título Executivo: art. 784, 2

Novação

–Novação: art. 779, 5

Obrigação

–Bilateral: art. 787, 1

Obrigações Bilaterais

–Adimplemento: art. 787, 3

Partes

–Processo de Execução: art. 778, 1 e 779, 1

–v. Legitimação

Penhor

–Título Executivo: art. 784, 6

Penhora

–Alienação de Bens Penhorados: art. 792, 8

Perdas e Danos

–Inexistência da Obrigação Executada: art. 776, 1, 4 e 6

Pessoa Jurídica

–Extinção: art. 779, 6

Poderes do Juiz

–Direção do Processo: art. 772, 1

Preferência

–v. Direito de Preferência

Princípios

–da Disponibilidade: art. 775, 1 e 3

–da Iniciativa: art. 778, 3

–do Monopólio estatal da Execução Forçada: art. 782, 2

Processo de Conhecimento

–Aplicação Subsidiária à Execução: art. 771, 1 e 2

Processo de Execução

–Aplicação subsidiária do processo de conhecimento: art. 771, 1 e 2

–Autonomia: Introdução 5, 6 e 7

–Natureza: Introdução 3 e 4

Responsabilidade

–Do Exequente: art. 776, 1 e 3

Responsabilidade Patrimonial

–Bens do devedor em poder de terceiros: art. 790, 4

–Conceito: art. 789, 1

–Da Herança Jacente, dos Legatários, do Cônjuge, Supérstite: art. 796, 3

–Do Cônjuge: art. 790, 5

- Do Devedor: art. 789, 2
- Do Espólio: art. 796, 1
- Do Sócio: art. 790, 3, art. 795, 1
- Do Sucessor a título Singular: art. 790, 2
- Responsável tributário: art. 779, 9
- Secundária: art. 790, 1

Sanção

- Classificação: Introdução 4
- Conceito: Introdução 4

Seguro

- Título Executivo: art. 784, 6

Sócio

- v. Responsabilidade Patrimonial
- v. Benefício de Ordem

Sub-rogação

- Fiador: art. 794, 4
- Legitimação: art. 778, 12

Substituição Processual

- Ação de Execução: art. 778, 7

Sucessor

- Responsabilidade Patrimonial: art. 790, 2
- v. Legitimação
- v. Partes

Terceiro

- Posse de Bens do Devedor: art. 790, 4

Termo

- v. Obrigação Condicional ou a termo

Título de Crédito

- Título executivo: art. 784, 2

Título Executivo

- Liquidez, certeza e Exigibilidade: art. 783, 1

Títulos Executivos Estrangeiros

–Extrajudicial: art. 784, 12

Títulos Executivos Extrajudiciais

–Certidão de Dívida Ativa: art. 784, 8

–Cheque: art. 784, 2

–Competência para a Execução: art. 781, 1

–Conceito: art. 784, 1

–Contrato de Seguro de Vida: art. 784, 6

–Contratos de Hipoteca, de Penhor, de Anticrese, e de Caução: art. 784, 6

–Crédito decorrente de Foro Laudêmio, Aluguel ou Renda de Imóvel: art. 784, 7

–Debenture: art. 784, 2

–Documento particular: art. 784, 4

–Documento Público: art. 784, 3

–Duplicata: art. 784, 2

–Encargo de Condomínio: art. 784, 7

–Estrangeiro: art. 784, 12

–Instrumento de Transação Referendado pela Defensoria Pública: art. 784, 5

–Instrumento de Transação Referendado pelo Ministério Público: art. 784, 5

–Instrumento de Transação Referendado pelo Advogado: art. 784, 5

–Letra de Câmbio: art. 784, 2

–Nota Promissória: art. 784, 2

–Outros: art. 784, 10

Transação

–Instrumento referendado pela Defensoria Pública: art. 784, 5

–Instrumento Referendado pelo Ministério Público: art. 784, 5

–Instrumento Referendado Pelos Advogados: art. 784, 5